



Arturo Yrarrázaval

DERECHO ECONÓMICO II

Yael Schwartzstein

1º Semestre 2019



6 de marzo

- Algunos hablan de que el Dº económico es Dº regulatorio (normas que rigen el comportamiento económico) + Libre Competencia. El comportamiento económico incluye millones de decisiones económicas tomadas diariamente por agentes económicos.

1. Dº regulatorio

- ley de bancos
- de valores (es un tema de dº comercial)
- seguros
- sociedades anónimas (SA)
- comisión para el mercado financiero (CMF)
- *tiene más pero no ciñen a dº económico (energía, telecomunicaciones, etc.).
- *no existe superintendencia de mercados y seguros y este año no va a existir de bancos
- *La línea divisora entre dº económico y dº comercial es: **OPE VS AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. → IMPORTANTE**
- *La ley de bancos es de OPE (y dº económico), ya que los bancos NO pueden realizar ninguna facultad que no esté tipificada en la Ley de General de Bancos (LGB), es decir, solo pueden realizar las operaciones que están dentro de este marco regulador (son treinta y algo). Los bancos se constituyen en virtud de una autorización de la CMF, la ley determina la formación de los bancos (ej: cuántos directores deben haber), la CMF es la que determina la liquidación (NO quiebre) de un banco. Por lo tanto, la LGB, aunque tenga relación con particulares, pertenece al OPE ya que, desde el nacimiento hasta su muerte, son regulados por la CMF

2. Libre Competencia (LC)

Una típica defensa de la LC es que a esa empresa no se le aplica el Dº a la Competencia. A las empresas estatales si se le aplica el dº a la competencia. Esto fue ampliamente discutido en Chile y sigue siendo discutido principalmente en países que tienen una gran cantidad de empresas estatales, por ejemplo, China.

¿La Asociación Nacional de Fútbol puede ser sancionado por dº de competencia?
¿Los clubes de fútbol? La respuesta es que mientras Asociación Nacional de Fútbol o lo que fuese, realicen actividades económicas SI pueden ser sancionados por dº de competencia.

Hay 3 cuerpos legales. Todos tienen relación con el funcionamiento de los mercados, pero desde distintas aristas:

-Ley de la Competencia (LDLC): rige las prácticas restrictivas (PR) de la competencia NO los monopolios. **El bien jurídico protegido es la COMPETENCIA** (otros piensan que es la protección de los consumidores y otros la eficiencia de los mercados). La competencia NUNCA es perfecta, pero esta ley trata de que sea lo más perfecta posible. El Tribunal de la Competencia (TDLC) debe seleccionar las prácticas restrictivas más importantes. La más preocupante de hoy en día son las colusiones,

ya que las empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio y esto afecta gravemente a los consumidores. Existen colusiones:

- a) con delación compensada
- b) sin delación compensada

Con la delación compensada, cambia la LDLC. Uno de los miembros de la colusión, se confiesa ante la fiscalía nacional económica (FNE) para eximirse de responsabilidad. El confesor debe dar todos los detalles de cómo opera la colusión, de otra forma, no se le acepta la delación.

-Ley de Protección al Consumidor (LPC): **El bien jurídico protegido es el mismo consumidor en su relación con los proveedores de miles de bienes distintos.** Pero protege ciertos aspectos de esta relación, no completamente ya que sería lo más ineficiente del mundo. La ley va tipificando y analizando distintas conductas entre proveedores y consumidores y cuáles sanciona. Estas conductas están muy desarrolladas, casi en exceso. Se llega a ese nivel de detalle por el **principio de reserva legal** (todo lo fundamental DEBE estar en la LEY), el cual se ve permanentemente porque de acuerdo con el art 19 N°21 de la CPR: *“respetando las normas legales que la regulan”*, vale decir, el único que puede regular distintos aspectos de la economía es el **legislador**.

En la última modificación a esta ley, el tema fue que el TC declaró que había atribuciones del SERNAC que no le corresponderían, y, por lo tanto, había partes de la ley creada en el congreso que son inconstitucionales → solo el legislador puede regular en ámbitos económicos.

*Para que las leyes no sean tan extensas, se agregan circulares que son bastante libres, pero dentro del marco de la ley (principio de reserva legal).

-Ley de la Competencia Desleal (LCD): la ley debe tipificar cuáles son las competencias desleales entre **EMPRESAS**, acá NO entra el consumidor. Ej: publicidad desleal (ej: se miente sobre el producto, habla pésimo de otros productos (debe mencionar directamente a los otros competidores hablando mal de ellos, salvo que esta comparación sea verdadera → pero tiene que tener autorización de la otra marca ya que, si no, infringe los dº de autor (caso Mercedes VS Toyota)), etc.).

- También trataremos sobre dº económico internacional:

1. Comercio internacional (CI)

- Las importaciones en Chile están al orden de **80.000 millones** de dólares, al igual que las exportaciones.
- Hace 30 años, era de 4.000 millones de dólares. Aumentó tanto por la libertad cambiaria.
- Se puede exportar prácticamente todo, salvo 2-3 bienes que tienen limitaciones.
- Las exportaciones tienen muy pocas limitaciones. Ya ni se debe ir al BC (hasta el año 2000 se tenía que pedir autorización al BC para poder exportar). Antes, las exportaciones eran muy reguladas desde el punto de vista cambiario.

- La razón del control anterior a las exportaciones era por los cambios internacionales, había escasez de divisas, y, por lo tanto, se debía controlar a los exportadores para garantizarle a los importadores las divisas y que éstas no se fueran del país.
- Este fatal mito desapareció porque en el año 89` la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del BC dispuso la regla general de la **LIBERTAD CAMBIARIA**, puedo comprar y vender divisas cuándo quiera y en la forma que quiera, salvo que el BC termine la libertad cambiaria cuando quiera y sin dar razón de por medio. En Argentina pasó esto.
- Hoy en día, las normas del mercado cambiario están muy simplificadas (esto es muy bueno). En un país donde no existe escasez de divisas, no debiese existir restricción cambiaria.

2. Inversión extranjera:

- Lo que importa es la residencia o domicilio del inversionista, NO su nacionalidad.
- La inversión extranjera en Chile tiene normas legales que los protejan, en cambio la inversión interna NO tiene normas legales que los protejan. La ley ayuda, especialmente, desde el punto de vista cambiario.
- El inversionista extranjero, por definición, trae y saca divisas, y lo que necesita es una garantía de que cuando quiera sacar esas divisas –pagando los impuestos que correspondan- lo pueda hacer.
- Esta garantía no existió con el Corralito en Argentina (termina *Menem* y hay muchos presidentes, y ahí ocurre el Corralito). Con esta situación, ningún inversionista pudo sacar divisas de Argentina, y, por lo tanto, miles de inversionistas demandan al Estado Argentino, además de todos los que compraron bonos emitidos por el Estado en monedas extranjeras. El Estado Argentino pierde prácticamente todos los juicios, y, por lo tanto, no puede ni salir el avión presidencial ya que se lo embargarían. De hecho, un buque fue embargado en África por un año.

3. Financiamiento internacional:

- Prácticamente no tiene normas internas, entonces todo tipo de financiamiento puede entrar al país cuando quiera y en la forma que quiera, salvo que el BC ponga alguna restricción, que vendría a ser, por ejemplo, el encaje (el BC retiene un % del préstamo, y devuelve el mismo monto, por lo que en países con mucha inflación no conviene para nada, ya que se desvaloriza completamente).

4. Procesos de integración económica:

- No tenemos que estudiarlo mucho, ya que no estamos integrados en ninguno.
- Si lo vamos a ver respecto al CI, ya que éste no es tan libre cuando países se empiezan a enemistar (ejemplo: China VS USA → se empiezan a cobrar aranceles altos) y quiebran el principio de la OMC: “mayor libertad económica posible”. Chile se adhiere en la década del 80`, siendo uno de los primeros países latinoamericanos en adherirse.

- Este principio, implica que, si hay *dumping* en el precio de algún bien, se le pueden aplicar **dº compensatorios** que pueden ser de hasta un 35%.
- El dº económico analiza las legislaciones económicas de cada país. Esta normativa es cada vez más sencilla afortunadamente.
- Chile es de los países más endeudados del mundo, pero es un endeudamiento privado, por lo que el Eº no se preocupa.
 - La deuda externa pública es pequeña, la alta es la deuda externa privada.
 - ¿Por qué no se preocupan de la deuda externa privada? Porque el Eº en Chile no asume (y no debiese) ninguna responsabilidad por la deuda privada, esos son problemas entre un acreedor extranjero y un deudor dentro del país, pero son privados.
 - El problema se da cuando no hay divisas para pagar deuda externa pública que sale de las reservas internacionales.

7 de marzo

EVOLUCIÓN DEL Dº REGULATORIO

- El dº regulatorio va cambiando y actualizándose. Ha habido una evolución impresionante en Chile. El actual es desarrollado y va enfrentando nuevos desafíos. Por ejemplo: Uber. En algunos países, se regula en ciertos aspectos los Uber, por ejemplo, en materia tributaria.
- Existe dº regulatorio en Chile desde la década del 20`
- El impulso de dº regulatorio se da en 1920 por la **Misión Kemmerer** → comisión extranjera que sugirió a la autoridad la creación de diversos organismos:
 - ✓ Ley General de Bancos (LGB):
 - Ahora vamos en la versión 7º de esta Ley.
 - Con esta, los bancos deben someterse a una regulación.
 - ✓ Superintendencia de Bancos (SBIF):
 - Este año pasa a ser parte de la Comisión de Mercados Financieros (CMF).
 - ✓ Contraloría General de la República (CGR):
 - Tiene 2 funciones fundamentales:
 1. Controla la legalidad de normas inferiores a la ley (decretos supremos, reglamentos, decisiones administrativas, etc) para que estén de acuerdo a la ley.
 2. Controla todo el gasto público.
 - En 1943, la Contraloría pasa a ser un organismo **autónomo**. Esto es muy importante, ya que, de esta manera, puede controlar efectivamente el gasto público a cargo del poder ejecutivo. Esto le da seriedad al control del gasto público.
 - Banco Central (BC):
 - Este cumple 3 funciones: monetaria, crediticia y cambiaria.
 - Sus funciones las realiza a través de decisiones del Consejo del BC.
 - El Ministro de Hacienda puede suspender acuerdos del BC (hasta ahora nunca se ha hecho), pero si hay unanimidad en los miembros del Consejo después de este veto, se va a aplicar de todas maneras.

- El BC emite acuerdos, y de esta manera, regula. Estos acuerdos son obligatorios, y si una institución financiera no cumple con el acuerdo, va a ser sancionada.
- Hay acuerdos en materia crediticia y cambiaria (compilados en compendios), pero NO en acuerdos en materia monetaria. Esto se debe a que el BC, tiene una **facultad omnímoda** sobre la materia monetaria, es decir, nadie los puede cuestionar. La facultad omnímoda, solo la tiene en materia monetaria, NO en crediticia ni cambiaria. Esta facultad omnímoda en materia monetaria se da en casi todos los países, aun cuando los BC NO sean autónomos, como es el caso de Argentina.
- La **autonomía** del BC en Chile se da en 1989.
- El BC es un gran regulador en materia crediticia. En materia monetaria, no es regulador ya que tiene una facultad omnímoda sobre esta materia.
- El objetivo del BC en Chile es la **estabilidad de la moneda** (es discutido el % de inflación que permite estabilidad, algunos dicen que es de un dígito, otros de menos de 4%, etc.). Antes, se decía que era para el desarrollo económico del país.
- La mayoría de los BC del mundo, comparten este objetivo: estabilidad de la moneda.
- Superintendencia de Sociedades Anónimas (SA):
 - En aquel entonces, las SA no eran muy importantes en Chile.
 - Se hicieron importantes durante s.XX y s.XXI.
 - Las que eran importantes, eran sociedades de personas o de responsabilidad limitada (es un tipo de sociedad de personas), NO anónimas.
 - ¿Por qué sugiere una superintendencia de sociedades que no eran tan importantes? Porque prevén que éstas serán importantes en un futuro por 3 razones:
 1. **regla de mayoría.** En una sociedad de responsabilidad limitada, si un socio no está de acuerdo, no se hace. Por lo tanto, es muy difícil a veces tomar decisiones, vender acciones, echar a alguien, etc.
 - Todos los bancos deben formarse como SA porque el legislador quiere que haya la menor cantidad de conflictos entre accionistas, y, por tanto, hace que gane la mayoría al tomar decisiones.
 - Si la minoría no desea ceder ante alguna decisión, vende sus acciones.
 2. **regla de los traspasos.**
 - El traspaso de acciones de SA requiere: comprador, vendedor y acuerdo respecto del precio. En cambio, el traspaso de acciones en sociedades de responsabilidad limitada debe ser aprobado por todos los miembros de la sociedad.
 3. se puede **aumentar/disminuir el capital** de una SA, con el acuerdo de la junta de accionistas (mayoría), en cambio, en una sociedad de personas debe haber un acuerdo de todos los socios.
 - La Superintendencia de Sociedades Anónimas (SA), pasa a ser la Superintendencia de Mercados y Valores (SVS) en el s.XX (en el 80') y actualmente es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

- Con la SVS, se deja de lado las SA cerradas (no se regulan) y las abiertas si se regulan.
 1. **Cerradas:**
 - menos de 500 accionistas
 - emiten instrumentos limitadamente al público
 2. **Abiertas:**

Hay 3 requisitos para que sea abierta. Con cualquiera de estos requisitos, pasa a ser abierta.

 - 500 accionistas o más
 - emiten instrumentos de deuda o de capital libremente al público
 - 100 accionistas controlen más del 10%

*En algunos países, se les denomina públicas a este tipo de sociedades. Este tipo de sociedades, pasan a estar bajo el control de la CMF.
- Hay otras actividades económicas, que también están reguladas: **Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)**, que NO son reguladas por la CMF, ya que son regulados por la **Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones**. Esta surge en la década del 80`, ya que surge el modelo de capitalización de las pensiones, por lo tanto, surgen administradoras **privadas**.
- Otra que también está regulada, son las **ISAPRES**, que tienen su propia **Superintendencia de ISAPRES**.
- En un minuto, existieron estas 4 superintendencias (bancos, SA, AFP e ISAPRES) y el profesor las considera necesarias, ya que se necesitaba regulación en Chile.
- Si nos vamos por importancia de actividades económicas (en dinero que mueven), debería haber superintendencias de otras actividades, tales como, minería, agricultura, etc. Entonces, ¿por qué éstas no son reguladas y las otras 4 sí? Porque **afectan a millones de personas** si es que éstas llegan a ser liquidadas/cerradas. Ej: pensiones, salud, etc. Las crisis bancarias, afectan al OPE, pero una crisis en la agricultura NO afecta a todo el OPE, sino solo a ciertas familias.

Así, se regula para que el sistema funcione lo mejor posible → de esta manera **previene**. Las superintendencias tienen esta función preventiva, y la utilizan con la información que tienen las superintendencias de cada uno de los bancos, AFP, ISAPRES, etc. Hoy en día, todo este papeleo es digital. La información entregada por las AFP es más o menos y las de las ISAPRES pésima, la de los bancos funciona bien.
- Se pasa de la Superintendencia de SA a la SVS en 1980, y se pasa a la CMF en 2017, que es un órgano colegiado. Se llega a la conclusión de que los superintendentes siendo una sola persona, era muy fácil de que se equivocaran en la regulación, por lo tanto, se plantea que debiese existir órganos colegiados, especialmente para 2 funciones:
 - a) Regulatoria → hoy en día, las normas las dicta una comisión conformada por 5 personas (que en Chile, actualmente, soy muy calificadas).
 - b) Sancionadora → unos de los grandes problemas de la superintendencia, es que ésta era juez y parte en la parte sancionadora, y con la ley 21.000 (Ley de la CMF), se separa. De esta manera, se logra ser imparcial.

- ¿En qué países no es necesario el dº regulatorio? En países con sistemas centralmente planificados. Pero, en la medida que los países tengan economía libre, deben estar regulados. Ahora, el campo de regulación de la economía es discutible (ej: Uber), al igual que la calidad de la regulación. La **calidad/eficiencia** de la regulación tiene diversos factores que la determinan:
 - Debe haber un análisis económico detrás de la regulación para poder determinar su calidad.
 - Cuántos organismos regulan.
 - Remuneraciones de los controladores, ya que si son muy malas van a surgir conflictos de intereses.
 - Etc.

12 de marzo

- Las superintendencias o CMF tienen 3 funciones fundamentales:
 1. **Fiscalizar**
 2. **Regular**
 - A través de **circulares** emitidas por los superintendentes. Es muy importante el ámbito de esta regulación.
 - Las circulares son dictadas por el presidente de la CMF o superintendentes cuándo quieran y cómo quieran y NO son reguladas por la Contraloría, por tanto, convierte a los superintendentes en verdaderos legisladores dentro de sus ámbitos exclusivamente.
 - Son dº regulatorios imprescindibles, pero peligrosos ya que no están regulados/revisados por nadie.
 - ¿Cómo se pueden cuestionar estas circulares cuando exceden en el ámbito respectivo? No se pueden cuestionar directamente las circulares ya que habría miles de reclamos, la única manera de que quede inválida es no cumpliéndola, y, luego reclamando las sanciones de éstas ante la CMF.
 - Las sanciones de las circulares SI son reclamables ante la CMF, y si la superintendencia pierde, generalmente se cambian las circulares para que no se sigan reclamando sanciones similares.
 3. **Sancionar**
 - Fundamentalmente a través de multas/sanciones pecuniarias que recaen en las empresas y NO a los directores, ejecutivos ni dueños.
 - ¿Por qué no se sanciona a las personas naturales que tomaron estas decisiones, si así, les dolería más el bolsillo y se evitaría la repetición de estas acciones? Porque la sanción a una persona jurídica es mucho más fácil que la sanción a una persona natural por el mismo caso. En una sanción personal, hay que tener muy buenos fundamentos para decir que esa persona es responsable, mientras que con una sanción a una persona jurídica no, es decir, solo basta con tener evidencia que la empresa es responsable, sin tener que indicar específicamente a alguien responsable.
 - Para sancionar a una persona natural, hay que demostrar su culpabilidad, su dolo, etc., y, por tanto, en el dº regulatorio económico, se prefiere sancionar a la empresa y NO a la persona natural responsable dentro de la empresa.

- Está la alternativa de sancionar también a las personas naturales responsables, pero esto queda a criterio del regulador en cuánto va a sancionar a la empresa y en cuánto a las personas específicas.
- La empresa siempre es sancionada.
- Si el dº regulatorio llegase a sancionar delitos, pasa a ser un tema más complicado. Hay casos en donde les dan cargos penales a personas de altos cargos, y ellos alegan al TC porque la sanción era desproporcionada ante el delito, y el TC acepta la desproporción, tomando jurisdicción sobre un tema que no tienen competencia (sobre dº de competencia).
- En ninguna parte de la constitución sale algo sobre la desproporción, pero el TC lo hace mezclando el art 19 N° 26, N° 24, N° 19, etc.).
- Las **personas jurídicas no son responsables penalmente** (hay excepciones, como el lavado de dinero o tráfico de drogas, en que se manda a la cárcel a los ejecutivos). Esto, teniendo en cuenta que la LDLC contempla a través de sus últimas modificaciones la sanción de cárcel, pero, para personas naturales dentro de la empresa y no la empresa misma.
- Los legisladores eligen qué superintendencias deben ser creadas o no, qué actividades serán reguladas y en qué forma. El criterio con el que escogen, es si **afecta o no a millones de personas, y así, al OPE**. Por eso, hay actividades con grandes masas de dinero pero que no tienen superintendencias ya que no afectan a tanta gente ni al OPE.
- Hay regulaciones parciales y totales (ISAPRES, AFP, etc.). Parciales serían, por ejemplo: agua potable, gas, concesiones de obras públicas, electricidad, etc. ya que son **monopolios naturales**. Aquí se entremezcla dº regulatorio con dº de competencia. El concepto de monopolio natural va evolucionando a través del tiempo, por ejemplo, con las telecomunicaciones (antes solo existía Entel y ellos alegaban que eran un monopolio natural, pero las otras empresas alegan que esto es falso a partir de la década del 80').
- ¿Qué consecuencia tiene para el dº regulatorio los monopolios naturales?
El **precio debe ser regulado**, ya que como no hay otra alternativa, no se puede dejar que la empresa "cobre lo que quiera". En realidad, no puede cobrar lo que quiera, ya que tiene una curva de demanda, y de ella no se puede salir, pero puede cobrar excesivamente.
 - Las empresas viven de los ingresos (PxQ), y si se sale de la curva de demanda, pierde ingresos.
 - Los precios de los monopolios naturales se fijan con un algoritmo que se adapta a muchísimos factores y variables. Estos algoritmos fueron copiados a países europeos u otros, y se le hicieron algunos cambios para adaptarlos a la realidad chilena.

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen superintendencia ya que afectan a millones de personas, así, afectan al OPE.
- El Eº debe proteger los recursos de las pensiones, para así garantizar la pensión mínima de una persona al jubilarse, poniendo la diferencia para alcanzar el mínimo. Así, el Eº gasta muchísimo para alcanzar el mínimo de pensión de las personas (miles de

millones). El sistema antiguo duró hasta la década del 80` y había muchas personas en él, por lo que se tuvo que reconocer todos los pagos para jubilaciones hechos antes del nuevo sistema, esto se llama Bono de Reconocimiento.

- Si quiero la mayor rentabilidad me voy al fondo A, si quiero la mayor seguridad me voy al fondo E. La rentabilidad y seguridad van en direcciones opuestas.
- El sistema previsional ha tenido una rentabilidad anual ajustada del 8%, y esto lo ve cada afiliado en su cuenta.

ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional)

- Más del 80% de las personas en Chile, están en FONASA NO en ISAPRES.
- FONASA NO está regulado por la superintendencia de ISAPRES.
- ISAPRES es un sistema de seguro optativo, y cada persona escoge cuánto pagar por su seguro.
- Uno paga un 7% de la remuneración para FONASA, mientras que en las ISAPRES si uno tiene cargas puede llegar a pagar un 15-20% de la remuneración. La tarifa del seguro se ve con la remuneración anual del afiliado, y las cargas que contiene consigo. El monto se va regulando anualmente por la remuneración del afiliado. El seguro más barato es para hombres jóvenes.

13 de marzo

- El sistema de ISAPRES ha tenido muchos problemas. Por distintos motivos:
 1. los contratos de ISAPRES son ininteligibles.
 2. hay cientos de planes y son todos muy distintos. Debiesen ser decenas, pero NO cientos.
 3. los planes debiesen ser comparables y no lo son.
 4. es un sistema de seguros y las personas no entienden esto. Los que no se accidentan o tienen siniestros, les pagan a los que si las tienen. Las personas con ISAPRES no entienden bien este punto.
 5. aumento de las primas de las ISAPRES. El legislador establece una fórmula para los aumentos, pero ésta es muy errada → es muy difícil de entender. En términos de seguros, las personas se van haciendo más caras cuando son de mayor edad. Las personas que pagan menos son los hombres antes de casarse. Algunos dicen que esto es “injusto” y “discriminatorio”, y, por lo tanto, actualmente hay del orden de más de 300.000 causas por los cambios de precios de los planes de las ISAPRES en los tribunales. Esto se da porque la fórmula del legislador está mal hecha. El legislador, la superintendencia se saca la responsabilidad, diciendo que no son problemas suyos, por lo que se ha llegado a muchísimos recursos de protección por este aumento injustificado del valor del plan. Se dice con estas sentencias que las ISAPRES no tienen justificación para aumentar el valor del plan.
- *primas= lo que uno paga por el plan
- La ley de ISAPRES y la superintendencia de ISAPRES se crean en la década del 80`.
- *La función general de una superintendencia, es generar que el **mercado que regule funcione de la forma más eficiente posible.**

CONTROL DE LA INFLACIÓN

- Hay 4 opciones:

A) Fijación de precios máximos menores al precio de equilibrio → beneficiar a los demandantes/consumidores

- En el año 1932, se produce un primer tipo de fijación de precios → la que favorece a los consumidores/demandantes, ya que estábamos en la mitad de la maldita recesión que surge desde 1929 (profunda y larga). Para esto, se fija un precio máximo menor al precio de equilibrio, y si una empresa se pasaba de este precio máximo se le aplicaban las sanciones del **DL 520**. Las personas en Chile vivían con un pan y una taza de té, había mucho desempleo, malas remuneraciones, etc. El efecto de esta fijación de precios, es que genera **escasez de bienes de primera necesidad** (el legislador le da este nombre, pero en realidad, no existen ya que van cambiando constantemente). La sanción que se da a las empresas que acapararen u ocultasen bienes, era la **expropiación** de las mismas (DL 520). Esto, generaba aún mayor escasez, ya que desincentiva a las empresas a querer seguir vendiendo.
- El objetivo de favorecer a los demandantes fijando los precios máximos bajo el precio de equilibrio NUNCA se logra con la fijación, ya que, al disminuir el precio, aumenta la Q_d y esto genera aun mayor escasez.
- *La escasez es la diferencia entre la Q_d y Q_s .
- En aquel entonces, la autoridad tuvo que hacer un listado de los bienes de primera necesidad (eran pocos en esa época).
- Hoy en día, se tiene la mala costumbre de creer que todos los bienes incluidos en el IPC son bienes de primera necesidad. Estos solo son los que se toman para calcular la variación de precios de un mes para otro (inflación mensual).
- Los bienes incluidos para calcular el IPC (alrededor de 300) deben ser ponderados de acuerdo a su importancia para la economía. No necesariamente concuerdan con ser bienes de primera necesidad, solo están en la lista para calcular la inflación mensual.
- En el último IPC se incorporaron bienes tecnológicos, por lo que se tienen que formar nuevos IPC. Dura 1 año su elaboración.
- El INE (Institución Nacional de Estadísticas) elabora el informe del IPC.
- **La inflación NO se controla a través de las fijaciones de precios.** Esto se debe a que se desequilibra la macroeconomía real (de bienes) con la macroeconomía monetaria. Si el producto crece un 5%, se debiese emitir un 5% y NO tanto más porque esto genera un exceso de circulante y esto genera inflación. DEBE haber una correspondencia o equilibrio entre la economía real (de bienes/productos) con la economía monetaria.

B) Fijación de precios mínimos mayores al precio de equilibrio → beneficiar a los productores/ofertantes

- Si la fijación de precios es de un precio mínimo sobre el precio de equilibrio, se genera **exceso de bienes**, ya que la Q_d es mucho menor a la Q_s .

- ¿A qué bienes se les aplica este precio mínimo? Los que tienen una **demand inelástica**, se concentró principalmente en unos pocos bienes agrícolas → se le aplicó al trigo, azúcar, aceite, etc. en Chile.
- ¿Quiénes financiaron los precios mínimos de las empresas? Los propios consumidores. El legislador quería garantizar un precio para generar empleos (ej: productores de remolacha, trabajadores de IANSA), y otros motivos. Cuando se abren las fronteras, entran muchos productores que compiten con IANSA.

C) **Subsidios del Estado para los productores**

- Una 3ª manera de luchar contra la inflación, es con subsidios del Eº para los productores. Esto es muy discutible, ya que se estarían ocupando recursos fiscales que pueden tener finalidades más relevantes. Esto se hace debido a la **competencia internacional**, ya que por los TLC que tenemos, hay un arancel efectivo del 0,7% (aunque la ley diga que es un 6% → los TLC modifican los aranceles), y muchas veces los productos extranjeros terminan siendo mucho más baratos que los locales. De hecho, muchísimos productos vendidos en Chile son chinos.

D) **Fijación de precios a los monopolios naturales**

- La 4ª razón para controlar la inflación son las fijaciones de precios a los monopolios naturales. Las tiene que hacer el **ESTADO** exclusivamente, por lo que NO son recomendaciones, sino que son **obligatorias**.
 - Las fijaciones de precios a estos monopolios naturales dependen del bien:
 - Agua: 5 años
 - Gas: 5 años
 - Ciertos bienes eléctricos: 25-35 años.
 - El TDLC decide cuáles bienes tendrán precios fijados, dependiendo de si hay o no suficiente competencia.
 - Los periodos de fijación del precio, no son determinados por nadie, pero son una moda, especialmente copiadas de Europa.
 - Los monopolios naturales NO tienen superintendencias, pero, aun así, tienen regulaciones. Estos son: electricidad, gas, agua y concesiones de obras públicas.
 - Lo que más se regula en ellas, es el **precio** de lo que el concesionario puede cobrar, porque tienen la condición de **monopolios naturales**. Al ser monopolios naturales, se deben **fijar los precios** para que éstos no sean altísimos y perjudiciales.
 - Desde 1932, se empieza a regular estos mercados. Y, se crea una ley que contiene sanciones al no ceñirse al precio fijado → **Decreto Ley (DL) 520**.
 - Hoy en día, se tienen fijados alrededor de 20 precios de monopolios naturales.
- NO puede haber fijaciones de precios sin sus sanciones correspondientes.
 - Cualquier fijación de precios que no sea de monopolios naturales es perjudicial, ya que se pueden generar múltiples fallos en el cálculo del precio que se va a fijar. Es más natural que sea el mercado mismo que regule el precio a través de sus curvas de oferta y demanda.

14 de marzo

- El precio de equilibrio NO existe, solo es una teoría muy útil. La autoridad trata de fijar los precios en un margen de 2% más o menos que el precio de equilibrio. Pero como este no existe, obliga a la autoridad a fijarlo mediante una fórmula que nunca función. Para la fórmula, se debe determinar: los costos de las empresas afectadas + nivel de utilidad razonable de esas empresas + inversiones razonables que debe hacer la empresa.
- La fijación de precios en Chile de productos que no fueran monopolios naturales, se hizo desde el año 32` hasta el 2000.
- La inversión se puede ver cada vez más relacionada con la tecnología. Ej: publicidades en videos en la tele.
- Hoy día, la regulación está concentrada en la fijación de precios de monopolios naturales. La fijación de precios de estos monopolios tiene una fórmula sumamente complicada, ya que debe incluir múltiples factores que puedan influir para todo ese periodo.
- La compañía de telecomunicaciones demandó al Eº por el precio que les habían fijado, alegando que se habían equivocado en operaciones matemáticas simples.
- Si los periodos de concesiones fuesen muy cortos, ninguna empresa se interesaría en invertir en estos productos por tan poco tiempo, ya que requiere mucha inversión.
- Concesiones de Obras Públicas
 - ¿Desde cuándo tenemos concesiones de obras públicas? Desde la década del 90`. Antes, eran financiadas por el Ministerio de Obras Públicas. En Europa y USA se utilizan desde antes este tipo de concesiones.
 - Había muchos detractores de esta política de obras públicas, ya que decían que esto significaba que los usuarios de obras públicas terminarían pagando lo que anteriormente pagaba el Eº, lo cual era muy discriminatorio.
 - Ej: túnel el melón.
 - Los peajes tienen fijación de precios, ya que son monopolios naturales. Mientras más concesiones hayan, más van a pagar las empresas, ya que sería una buena concesión.
 - ¿Qué ocurre cuando termina la concesión? Vuelve al Eº y éste vuelve a llamar a una nueva concesión.
 - Ha ocurrido con algunas concesiones, que se dejan a mitad de camino. Ej: empresa mexicana.
 - Con las concesiones, las empresas ganan solo con el dinero que pagan los usuarios de ellas.
 - Un gran error del Eº fue no querer hacer concesión en el puerto de Valparaíso, lo que ha generado que no se hayan hecho las remodelaciones necesarias, y, por lo tanto, el puerto de San Antonio (con una concesión que funciona bien) recibe la mayoría de los barcos que iban a Valparaíso.
 - Si llegase haber una crisis económica, se mantienen los precios fijados de los monopolios naturales, y los demás precios se mantienen liberalizados para permitir las fluctuaciones necesarias que regulen la economía.

REGULACIÓN CAMBIARIA

- ¿Qué pasa cuando hay fijación de precios en el valor del dinero? (tema cambiario)
 - Esta fijación parte en el año 32`.
 - El tema monetario tiene relación entre la moneda interna y monedas externas, especialmente respecto al dólar. De todas las transacciones internacionales, el dólar representa el orden del 40%. El dólar hace unos 30 años, representaba el orden del 80% pero ahora también es muy importante el yuan (moneda China), euros, etc.
 - Cuando llega a un importador chino, cambia su dinero a dólares, ya que es una moneda que tiene mayor aceptación en este minuto.
 - El mercado internacional determina el valor de cada moneda en relación a otras mediante las transacciones internacionales.
 - En el año 32` con la recesión, disminuyen las exportaciones al orden del 10% del total exportado antes de la recesión. Esto se debe a que como era una recesión mundial, los demás países no tenían interés en comprar productos chilenos, especialmente, nuestras exportaciones de cobre y salitre. Entonces, entraron al país sólo el 10% del dinero que antes entraba por las exportaciones, y, por tanto, hubo **escasez de divisas**. Esto generó que la autoridad decidiera **fijar los precios de las divisas**. Además, todos los exportadores le debían vender las divisas que recibían al Eº (comisiones de cambio internacionales) y posteriormente al BC. Si las personas no vendían las divisas, incurrían en delito cambiario, y, muchas personas fueron a la cárcel por este motivo. Las personas que no devolvían las divisas a Chile, también incurrían en delito cambiario.
 - A fines de la década del 30`, se vuelve a la normalidad (termina la crisis económica).
 - Hasta el año 2000, se mantiene el control cambiario debido a que cuando se le encomendó esta tarea al BC, éste intenta controlar la inflación mediante los valores de las otras divisas. Para esto, el BC intentaba mantener el cambio lo más bajo posible, para así mantener pequeñas las masas monetarias y evitar la inflación.
 - Si se fija un precio solo con el fin de mantener baja la inflación, pero sin tener en vista su relación con el resto de las divisas, se generan alteraciones en importaciones y exportaciones. Si es muy bajo el precio de la divisa, se importaba más, y si es muy alto el precio de la divisa, se exporta más.
 - Desde el año 2000 existe el MCF (mercado cambiario formal), en donde el valor de las divisas solo se calcula a partir de las transacciones internacionales, sin tener en vista la inflación.
 - Así, desde el año 2000, nace el **dólar observado** que se refiere a un valor determinado por todas las transacciones internacionales en dólares del día anterior. El dólar observado se observa en el MCF. Los que constituyen el MCF son los **bancos comerciales y toda otra institución autorizada por el BC para hacer cambios de divisas**.
 - Uno podría sostener que el dólar observado no existe, ya que es una media ponderada de las operaciones hechas el día anterior en el MCF.
 - Los bancos e instituciones autorizadas compran y venden divisas. El dólar comprador es el valor al cual compra el banco, y el vendedor es el valor al cual vende al banco. En definitiva, esto se ve respecto de la acción que realiza el **banco**.
 - El vendedor siempre es más alto que el comprador, para así **generar ingresos** (no necesariamente "ganan los bancos" → utilidades se ven después). Si la diferencia entre

el valor del comprador y vendedor es muy poca, a los bancos no les interesaría hacer compras y ventas de divisas. Los bancos que no estén interesados en realizar transacciones de divisas, ponen precios de dólar comprador y vendedor que no le interesen al público (menos bruscos), mientras, a los que, si les interesa, pondrán precios que a las personas les interesen.

- El precio de dólar comprador y vendedor considera todas las transacciones cambiarias ponderadas del día anterior.

19 de marzo

- La política cambiaria intenta incentivar las exportaciones e importaciones en un momento determinado.
- La política monetaria intenta dar la mayor estabilidad posible a la moneda nacional.
- *Hay 3 tipos de regulaciones fuera de las superintendencias:
 1. Monopolios naturales
 2. Regulación cambiaria/de divisas
 3. Regulación de las tasas de interés

REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS- CAPTACIÓN-COLOCACI3N-BONOS (TASA DE POLÍTICA MONETARIA)

- Hay un 3º tipo de regulación, que es con respecto a las tasas de interés cobradas en los depósitos y todo otro tipo de captaciones del sistema bancario, además, de todo tipo de colocaciones en el sistema bancario. Esta también ha sido una regulación problemática. Se ha creído que esta regulación puede incentivar el ahorro o la inversión, por lo que surge un problema entre la tasa de interés fijada y la tasa de interés de equilibrio.
- NO existen tasas de intereses de equilibrio (pero se utilizan para entender la teoría), sino que existen tasas de intereses de mercado.
- Si las tasas de intereses están por encima de la de equilibrio, la tendencia es a que bajen. Si las tasas de intereses están por debajo de la de equilibrio, la tendencia es a que suban.
- La autoridad descubre que puede fijar las tasas de intereses de captación y colocación bancaria. De hecho, una de las funciones financieras/crediticias que tiene el BC, y que se contempla en la LOC del BC es la fijación de las tasas de intereses.
- Los ahorrantes llevan sus recursos monetarios a la banca (tasas de captación). ¿Por qué lo hacen tanto en los bancos? Porque el banco les da mayor seguridad. En Chile, esto es muy claro, excepto por la crisis bancaria de los 80`.
- Los bancos tienen activos y pasivos.
 - activos: lo que el banco tiene → **préstamos**. Son los capitales que le tienen que devolver al banco junto con el interés correspondiente.
 - pasivos: lo que el banco debe → **depósitos**. Es lo que le debe el banco a millones de depositantes en términos de intereses y capital.
- Debe haber un balance entre activos y pasivos. Aunque haya equilibrio, puede haber problemas en los bancos. Esto se generaría cuando el banco suspenda sus pagos, y así se generaría un desequilibrio enorme.

- La morosidad bancaria hace que disminuyan los activos de los bancos. Por eso, la mayor regulación de las tasas de interés se da en términos de morosidad, y así se cubren los riesgos. Afortunadamente, en Chile la tasa de morosidad es baja (3-5%).
- ¿Por qué es importante que funcione bien la regulación de las tasas de interés?
Porque en un momento determinado van a haber muchos préstamos sin ser pagados, y es ahí, donde surgen las crisis económicas. De hecho, la última crisis bancaria mundial fue porque en USA estaban muy mal otorgados los créditos hipotecarios, y, por lo tanto, no se pagaron, y así, los bancos se quedaban con pocos activos.
- A los depositantes no se les pide mucho conocimiento del sistema bancario.
- ¿Cuál banco prefiero yo? (todos los bancos tienen tasas de interés distinta)
 - ✓ Por algo los bancos menos seguros brindan tasas de interés de captación más altas → tienen la necesidad de captar más dinero.
 - ✓ En cambio, los bancos más sólidos ofrecen las tasas de interés más baja.
 - ✓ Mientras más seguro es el banco, menor es la tasa de interés de captación.
 - ✓ El Banco Estado tiene la tasa de interés de captación más baja, ya que, por ser una institución estatal, la gente cree tener una buena garantía.
 - ✓ Sin embargo, los bancos pueden ser liquidados. Pero, el Eº le inyecta capital al Banco Estado si es necesario, por ende, es muy difícil que éste sea liquidado.
- En Chile, las diferencias de tasas de interés de captación entre bancos, es pequeña. Mientras que, en otros países las diferencias son enormes.
- De acuerdo con la LGB, se entrega toda la información fundamental trimestralmente de todos los bancos (incluyendo tasas de morosidad, etc.). Esto genera que los depositantes se puedan informar.
- La tasa de interés de **captación** se da por una relación entre los **ahorrantes** y el sistema bancario. El banco les ofrece a los ahorrantes una tasa de interés para que depositen su dinero en los bancos.
- La tasa de interés de **colocación** se da por una relación entre los **inversionistas** (demandantes) y los bancos (oferentes). Los bancos les dan dinero a los inversionistas (personas y empresas), que luego de un período, pagarán los préstamos con intereses (de colocación).
- La tasa de interés de colocación es superior a la de captación (captación < colocación). Con esto, el banco generará ingresos para pagar a los trabajadores, compras tecnológicas, etc. Si estuvieran en el mismo nivel las tasas, el banco no podría funcionar. Lo que le interesa al banco es el **diferencial** entre las tasas.
- Si la **tasa de interés de captación** está por debajo de la tasa de interés de captación de equilibrio, el Estado deberá fijar una tasa de interés de captación **mínima** sobre el precio de equilibrio. Así, muchas personas querrán ahorrar, pero los bancos no querrán recibir esos ahorros (porque la tasa de interés de captación es alta).
- Los bancos, después de recibir los ahorros, los prestan lo más rápido posible, ya que, por definición, los bancos son **intermediarios de dinero**. Mientras más rápido preste este dinero de los ahorrantes, será más eficiente, ya que, estaría ganando más por intereses de colocación.

- Si la **tasa de interés de colocación** está por encima de la de tasa de interés de colocación de equilibrio, la autoridad fijará tasas de intereses de colocación **máxima** bajo el precio de equilibrio. Así, muchas personas querrán pedir préstamos y el banco no los querrá otorgar (porque la tasa de interés de colocación es baja).
- La autoridad toma esas medidas (fijando tasas de interés de captación altas y tasas de interés de colocación bajas) para **fomentar el ahorro y la inversión**. Sin embargo, esto es peligroso, ya que si: ¹no se produce el diferencial entre las tasas de interés de colocación y captación, ²hay un diferencial muy bajo, o, ³la tasa de colocación se vuelve inferior a la de captación, los bancos deberán cerrar sus puertas (tienen más gastos que ingresos). Por lo tanto, por más de que la autoridad está autorizada a fijar las tasas de intereses respectivas, NO lo hace en la mayoría de los países.
- Lo que hace el BC en vez de fijar las tasas de interés de colocación y captación, es regular mediante los documentos que vende (**bonos**), con tasas de interés. El BC vende bonos constantemente, que son *instrumentos de deuda* que llevan la tasa de interés del BC.
- Los bonos son instrumentos de deuda que emite el BC. Éstos los puede dar a los bancos comerciales (para que éstos a su vez le otorguen préstamos con tasas de captación a los particulares) o a las personas (no influyen mucho).
- Si la tasa de los bonos es más atractiva que la de captación de los bancos, por cierto que habrá menor actividad bancaria.
- Si disminuye la tasa de interés de colocación, disminuye la tasa de interés de captación. Pero esto, no es automático. Va a disminuir la del BC primero y luego la de los bancos de captación y luego la de colocación.
- **Tasa de interés del BC < captación bancos < colocación bancos**
- La tasa de interés de captación de los bancos se debe ajustar a la tasa de interés de los bonos del BC porque si no, claramente las personas preferirían comprarle bonos al Estado que entregar sus ahorros a los bancos (menos seguros). Y, claramente, si aumenta la de captación de los bancos, aumenta la de colocación, para así, mantener el diferencial bancario y permitir que el banco pueda seguir funcionando.
- La tasa de interés de colocación es generalmente 1 o 2 puntos superiores a la de captación.
- Si uno analiza las tasas de intereses del BC, han tenido un comportamiento errático. El BC está más preocupado de la **inflación** y del **crecimiento de la economía**. Si el BC y los bancos aumentan sus tasas, las masas monetarias aumentan considerablemente, por lo que el BC debe estar analizando el efecto que tienen las tasas en el volumen de masas monetarias, y, por tanto, en la inflación del país.
- Si hay tasas más altas, se contrae el dinero circulante. Mientras que, si hay tasas más bajas, se expande el dinero circulante.

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL Dº

- El análisis económico del dº se refiere a cómo afectan medidas económicas a ciertas instituciones jurídicas.
- Esto surge en USA en la década del 60`. Ahora, todas las universidades de dº en USA tienen como mínimo un curso de análisis económico del dº.

- El análisis económico del dº se genera en dº económico.
- ¿Qué pretende el análisis económico del dº?
Analizar determinadas instituciones y actividades jurídicas y el impacto de éstas en la economía, ya sea, positivo o negativo.
→ **Regulación**: se determina si las instituciones son buenas, más o menos (regulares), o malas.
→ **Dº de competencia**: en USA funcionaba pésimo el dº de la competencia (alrededor de 1840 surge). Los europeos tienen dº de la competencia desde la década del 20`. Las normas de regulación respecto del dº a la competencia en Europa surgieron en torno a lo que era el Mercado Común Europeo (MCE) y la Unión Europea (UE).
*El *Tratado de Roma* tiene sólo 2 art sobre dº de competencia (para *Yrarrázaval* son geniales → toman toda la cultura de la competencia, y lo consagran en 2 art).
- La crítica que se hace con el análisis económico del dº se hace cuando la regulación y/o el dº de competencia no se cumplen.
- Para determinar la calidad de la institución, se debe medir el análisis económico, y en muchos casos, es muy difícil poder hacerlo. Por lo tanto, uno se queda con impresiones generales, pero esto es un análisis jurídico.
- El análisis económico bueno será cuando las **sanciones** se den en la manera adecuada → los casos más graves tengan las sanciones más graves, etc., es decir, que sean **proporcionales** a los incumplimientos normativos. Tiene estrecha relación con el concepto de **responsabilidad** ante un incumplimiento normativo. ¿Siempre se produce la proporcionalidad? No necesariamente, en efecto, muchas veces las sanciones son más altas o más bajas de lo debido.
- Las legislaciones captan y regulan a las instituciones DENTRO del sistema, NO los que están fuera.
- Donde se desarrolló más el análisis económico del dº fue en USA ya que tienen un sistema jurisprudencial, por lo tanto, las leyes no regulan tanto, lo que más regula son los jueces y tribunales.
- Algunos abogados de la universidad, consideran que el análisis económico del dº no tiene cabida en el dº continental porque no tenemos un dº jurisprudencial, y, por tanto, depende de cada caso. De hecho, los tribunales aprecian, por ejemplo, cuánto debiese pagar una persona al atropellar a otra, no hay un monto fijo, sino que depende de las partes.
- En resumen, los factores que influyen en el análisis económico del dº son varios, y uno de los más importantes es la **responsabilidad** sobre el incumplimiento de las normas y las sanciones correspondientes. Se analiza mucho si es que son proporcionales o no con respecto al daño infligido.

20 de marzo

DERECHO DE LA COMPETENCIA

- Es una materia sumamente compleja, porque la relación entre economía y dº se da todos los días. Hay una yuxtaposición entre dº y economía. Esto, se refleja en muchos aspectos, uno de ellos es la integración del **Tribunal de la Competencia (TDLC)** que se encuentra integrado por 5 ministros: 2 economistas y 3 abogados.

- En otros países, se integra solamente por abogados. Hay economistas por detrás que hacen informes económicos, pero solo fallan abogados.
- De hecho, este tribunal es de los pocos del mundo que tiene economistas fallando.
- Pero, en Chile, *Yrarrázaval* califica esta integración como muy **positiva**, ya que se complementan los economistas y abogados en términos de análisis económico y normativo.
- La razón de requerir ser abogado para estar en un tribunal es que, para fallar acorde al dº se debe conocer el dº.
- Para conocer y fallar sobre una causa económica, se debe saber dº, pero también economía.
- El aporte económico se hace por informes económicos que acompañan a la causa, y son hechos por las partes del caso.
- Entonces, ¿para qué están los economistas en la integración del TDLC? Para conocer los argumentos económicos de las partes y fundamentar la sentencia con argumentos económicos.
 - La **argumentación** que deben presentar las **partes** en la demanda, deben contener **todos los argumentos económicos involucrados desde el comienzo**. Tanto, es así, que, si se presenta una demanda sin los argumentos económicos, se vuelve inadmisibile.
 - El **fallo**, también debe contener la **argumentación económica** correspondiente.
- De esta manera, se obliga a los abogados a compatibilizar los argumentos económicos con los jurídicos. NO se puede separar lo jurídico de lo económico, ya que se dicta UN SOLO fallo. Por tanto, se tiene que compatibilizar los argumentos.
- Todo esto se relaciona con las **prácticas restrictivas (PR) de la competencia**, que son todas materias económicas (reguladas por el TDLC).
- El TDLC tiene por encima a la Corte Suprema. Este asunto es relevante porque la CS es solo integrada por abogados (en salas específicas), que saben poco y nada de dº de competencia (no son especializados en esto).
- La mayoría del dº de competencia está en la **jurisprudencia**, no solo en la ley, y los integrantes de la CS no conocen conceptos económicos básicos de competencia, la jurisprudencia en dº de competencia, etc.
- *Yrarrázaval* considera **utilísimo** que la CS esté sobre el TDLC (aunque sean solo abogados). Si el TDLC no estaría por debajo de la CS, se les estaría dando un poder gigantesco a estos 5 ministros.
- Para que llegue a la CS se demora 1-2 años en el TDLC y 1 más en CS aprox. Muchos critican el extenso tiempo que se demoran los fallos si son revisados por la CS.
- La CS analiza si las sanciones del TDLC son **razonables** o no. No entra de nuevo a analizar todo el problema (tienen 1000-2000 páginas aprox) que fue revisado por el TDLC.
- La CS recibe una relación del caso y los alegatos, y de acuerdo con esto decide si la sanción es adecuada o inadecuada. Si es muy inadecuada, revoca la sanción

del TDLC. Esto, ha ocurrido muy pocas veces. Generalmente, disminuye sanciones si las considera desproporcionadas, pero no revoca sanciones.

- **EMPRESAS**

- Generalmente se sancionan a las **empresas** por las PR de la competencia. Es muy raro que los demandantes (de bienes o servicios) hagan PR de la competencia.
- Si la CS no sabe lo que es una empresa, no puede sancionarlas. No hay una definición jurídica de empresa, y, son escasamente mencionadas por las leyes. Se podrían analogar con las sociedades, que están definidas por la ley, y están altamente reguladas por el dº comercial. Pero, NO todas las empresas son sociedades, ni todas las sociedades son empresas.
- En Chile, hasta hace no mucho tiempo, había más empresas que no formaban sociedad que las que si formaban sociedad.
- Entonces, ¿qué hace que algo sea una empresa? Es una **unidad económica donde hay una combinación de factores productivos** (bienes raíces, servicios del trabajo, capital, factor empresarial, tecnología), **con la finalidad de generar el mayor valor agregado posible**.
 - Las proporciones de cada uno de estos factores, difieren en cada empresa.
 - Para que sea una empresa, debe haber una unidad de los factores productivos, para así, generar el mayor valor agregado posible.
- En la sociedad, hay una personalidad jurídica de la sociedad. En la empresa que no es sociedad, no existe personalidad jurídica. En otras palabras, lo que hace que una empresa sea una sociedad, es su **personalidad jurídica**.
- El riesgo que corre una empresa que no es sociedad, es altísimo. Esto se debe a que como no hay personalidad jurídica, la **responsabilidad la asume la persona natural a cargo de la empresa**. Todas las empresas deberían asumir el status de sociedad para evitar este riesgo.
- Para incentivar a las empresas a que se transformen en sociedades, se reformó el sistema y ahora se puede constituir una sociedad de forma rápida y por internet. Las sociedades conllevan costos que las empresas no incluyen.
- En definitiva, la gran mayoría de las demandas son en contra de empresas (que pueden ser distintos tipos de sociedades o no ser sociedades). Si el demandado, no ha constituido una sociedad, la sanción es a la empresa y asume la persona natural a cargo). En cambio, si ha constituido una sociedad, la sanción es a la sociedad y NO a las personas naturales de la sociedad que han intervenido en los actos restrictivos de la competencia.
- Las empresas que no son sociedad, son generalmente pequeñas, en donde los gastos societarios son muy grandes para ellos.
- El hecho de ser sociedad, implica gastos no menores. Se le asignan muchas obligaciones que no son nada de baratas. Ej: debe tener un contador, libros de registro, etc.
- Si se es empresa, pero no sociedad, al pedir un préstamo al banco, le va a ir mal. Le van a dar un préstamo, pero siempre que deje en garantía todos los bienes familiares y personales que tenga el dueño.

- Una sociedad responde a los préstamos por el capital que tiene. En cambio, en las empresas (no sociedad) se responde por el patrimonio personal del dueño.
- ¿Por qué no se daría un préstamo a una empresa que tenga mayor capital que una sociedad? Porque la sociedad da un mayor grado de seguridad que la empresa. Está legalmente mejor constituida.
- ¿Por qué son tan pocas las sanciones a personas naturales?
 - *Juan José Romero* dice que se debe las pocas demandas en donde se demanda a la sociedad y además a las personas naturales importantes dentro de ellas (directorio, gerentes, etc.). Dice que se demanda mucho más solamente a la sociedad.
 - *Yrarrázaval* dice que esto se debe a que, si demando a las personas naturales, debo comprobar que esas personas intervinieron específicamente en las PR de la competencia. En cambio, con las personas jurídicas demandadas (las empresas que conforman sociedad) no se deben comprobar quiénes fueron específicamente los que desarrollaron las PR de la competencia.
- Las demandas a las PR pueden provenir de:
 - a) Fiscalía (FNE) → las demandas se denominan **requerimientos**.
 - b) Particulares → se denominan **demandas** a secas. Se presenta ante la FNE y se acompaña a ésta haciendo una demanda.
- **FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE)**
 - La Fiscalía tiene una función de **investigación**, y realiza todas las actividades que esta función implica.
 - Esto, la diferencia de otros países, en donde también la FNE puede sentenciar/resolver casos. Ahí se generaría un problema porque la FNE no puede ser juez y parte ya que sería arbitrario, por lo que tendrían que ser independientes las partes de cada función.
 - ¿Por qué se diferencia en Chile las funciones de la FNE, dejando sólo la de investigación? Sino, habría muchas instancias (porque aparte hay TDLC), y los casos se demorarían aún más en ser resueltos. En muchos países, la fiscalía si sentencia, pero en ellos NO hay TDLC.
 - En USA, en materias de competencia, sancionan las fiscalías, luego tribunales de apelación federales, y en última instancia la CS (solo escoge 150 casos al año entre todas las materias). Es muy raro que la CS escoja un caso de competencia.
 - La FNE NO es autónoma, sino que depende del Ministerio de Economía. Como no sanciona, es razonable que dependa del Ministerio. Si sancionara, sería ilógico que no fuera independiente (sería juez y parte).
 - ¿Mejora la eficiencia la FNE si fuese autónoma? No necesariamente. Solo debe funcionar bien, y, que los profesionales sean de buena calidad (son casi solo abogados (75%) y economistas (25%)). Si pudiera sancionar, debería ser autónomo.
 - El OPE implica que el Eº esté involucrado revisando las PR de la competencia. Algunas de estas PR son:

a) Colusión

- **Se descubre que, sin delación compensada, es muy difícil poder perseguir bien los casos de colusión**, ya que estos son acuerdos secretos, y no se firman acuerdos de colusión. Al ser secretos, son muy difíciles de descubrir, a menos que una de las partes confiese.
- ¿Cómo se han descubierto estos casos (supermercados, farmacias, pollos, confort)?
 - En el caso de los pollos y supermercados NO hay delación compensada.
 - En el caso de las farmacias y confort SI hay delación compensada.
- En los casos de delación compensada, es muy fácil tener pruebas. El delator entrega toda la información necesaria para la prueba.
- **Si no hay delación compensada, la FNE se demora muchísimo tiempo en investigar los casos.** Ej: en la colusión de supermercados, se demoraron más de 5 años en descubrir la colusión, gastando muchísimos recursos, y, no era tan relevante para el OPE según el profesor.
- Si no hay delación compensada (una empresa admite), la FNE puede investigar de 2 maneras:
 - de oficio → la FNE cree que hay colusión
 - cualquier persona puede ir a la Fiscalía y decir que hay colusión

b) Competencia desleal:

- Muchas empresas que tienen rencor con otras empresas, las demandan por competencia desleal, para así, hacerlos incurrir en costos. Porque sale muchas veces en el diario y así, va perdiendo prestigio.
- El Eº puede incurrir en PR. Por lo tanto, se sanciona las PR de la competencia a todo tipo de empresas, incluyendo las estatales.
- Hay cientos de conceptos económicos involucrados en los casos que revisa el TDLC. El primer concepto es el de empresa.

• **COSTOS DE LA EMPRESA**

- son los ***gastos que incurre la empresa para producir.***
- Hay algunos costos que son:
 - a) **directamente necesarios** para producir
 - b) **indirectamente necesarios** para producir. Ej: Coca-Cola gasta aprox un 50% de sus costos en publicidad.
- También, se hace una distinción entre:
 - a) **Costos fijos:** no cambian según el nivel de producción, son constantes. Ej: arriendo de un bien raíz.
 - b) **Costos variables:** dependen del volumen de la producción. Ej: trabajo, capital, etc.
- Además, existe:
 - a) **Costo medio:** costo promedio, es el costo por unidad producida. Resultado de dividir el costo total de la producción por el número de unidades producidas.
 - b) **Costo marginal:** costo agregado por producir una unidad más.

- Los costos son relevantes, ya que se deben comparar con los ingresos. Si no hay ingresos, no se pueden financiar los costos. Los **ingresos** se obtienen mediante las ventas.

21 e marzo

- Hay PR que tienen directa relación con los costos → **precios predatorios**. Se cobran precios muy bajos para eliminar/liquidar a las empresas de la competencia. Se debe comprobar que la empresa está incurriendo bajo el costo medio para que se sancione por PR. Hay muy pocos casos de precios predatorios que pasan por tribunales ya que es muy difícil comprobar esta práctica.
 - ✓ Caso LAN VS aerolínea de Punta Arenas: se logró comprobar porque algunos gerentes/ejecutivos de LAN admitieron que estaban teniendo precios predatorios.

- **INGRESOS DE LAS EMPRESAS**

- Este es el famoso $P \times Q$
- Las empresas producen para vender. Aquí se produce la relación entre costos e ingresos:
 - ✓ $C < I \rightarrow$ **beneficios** (diferencial entre $I - C$). Así, las empresas pueden funcionar bien. Las empresas quieren que los beneficios sean los mayores posibles, ya que éstos se van a transformar en **utilidades**, pero antes, se cobran **impuestos**, específicamente, el de la **renta de primera categoría y global complementario** (a los dueños de la empresa). Toda la estructura tributaria, está vista como los beneficios desde el punto de vista económico, y de las utilidades desde el punto de vista jurídico. El IVA NO grava la renta, sino, al valor agregado, que está dado por las diferencias entre las compras y las ventas de una empresa en un mes. La renta y el IVA tienen bases totalmente distintas (a los beneficios VS valor agregado).
 - ✓ $C > I \rightarrow$ **pérdidas**. En esta situación, la empresa deberá cerrar.
 - ✓ $C = I \rightarrow$ no hay ni pérdidas ni beneficios. La situación de la empresa deberá cambiar rápidamente.
- Se da la falacia de que el monopolio puede cobrar el precio que quiera. Para que sea eficiente, debe $\uparrow$ el % del precio (P) en un % mayor al % que $\downarrow$ la cantidad (Q). Si no, $\downarrow$ el ingreso.

- **MONOPOLIOS**

- Un **ingreso monopolístico**, es lo que la posición de la empresa le permite $\uparrow$ el % del P sin perjudicar de mayor manera el % de la Q . Ejemplo: si una empresa $\uparrow$ en un 30% el P y $\downarrow$ en un 20% su Q , el ingreso monopolístico es el del 10% del $\uparrow$ del P .
- Las **utilidades monopolísticas** son las utilidades obtenidas de ese $\uparrow$ del % en el P . Utilidades obtenidas del ingreso monopolístico.
- Las **empresas monopolísticas**, son definidas por muchos como “*único oferente de un bien o servicio determinado en un país determinado.*” Este es una definición errónea, ya que se estaría sancionando también a monopolios naturales (que son permitidos por la ley). Lo que se busca sancionar son las **PR**, es decir, actos que

generan las empresas para tratar de ser monopolios cuando en realidad, hay más empresas compitiendo.

- También existen **oligopolios** → 2-3 empresas en un mercado.
- Lo que importa, no es el nº de empresas contenidas en ese mercado específico, sino que, si éstas realizan o no prácticas que limiten la competencia.
- El mercado chileno es muy pequeño. El argentino es 3,5 veces mayor, el brasilero entre 10-12 veces mayor, etc. Uno se da cuenta del tamaño de los mercados por los productos ofrecidos.
- Los economistas nos han dicho que la definición de monopolio es, ***“único oferente de un bien o servicio determinado en un país determinado que afecten gravemente a los precios”.***
- Existen 3 tipos de monopolios:

a) **Legal**

- ✓ La ley, o, en nuestro caso la Constitución, le otorga a una empresa determinada el monopolio.
- ✓ En Chile se consagran 2 monopolios a nivel constitucional:
 1. **CODELCO:** El primero está en una disposición transitoria de la Reforma Constitucional de 1971 que habla sobre la nacionalización del cobre. Producto de esta nacionalización, nace CODELCO. Por tanto, el único dueño de las empresas del cobre es el Estado en forma exclusiva. Si se quisiera privatizar CODELCO, habría que hacer una reforma constitucional.
 2. **ENAP:** no aparece directamente, sino que aparecen los hidrocarburos líquidos y gaseosos, y dice que el único que puede explotarlos es el Estado a través de alguna de sus empresas (en este caso, ENAP).
- ✓ A nivel legal, hay varios monopolios:
 1. Correos de Chile
 2. Ferrocarriles
 3. ENAER (empresa nacional aeronáutica)
- ✓ ¿Estos monopolios están fuera de la aplicación de la ley? NO se cuestiona su calidad de monopolio. Pero, un monopolio estatal puede incurrir en las mismas PR que cualquier empresa privada, por lo que, también va a ser sancionada por ellas.
- ✓ La ley se aplica dentro de la frontera, por lo que no se sanciona PR hechas en otros países.

b) **Naturales**

- ✓ Tener más de una empresa, encarece el producto. Esto, igual es difícil de determinar que es más eficiente tener una empresa que más, por lo que es muy discutible la aprobación de monopolios naturales por el TDLC. El TDLC debe determinar si se debe liberalizar el precio (sin tener monopolios naturales) o no liberalizar (autorizando monopolios naturales)

- ✓ Se dan principalmente en el sistema de **redes**. Ej: distribución de energía eléctrica. En el caso chileno, se dan concesiones por ciudades.
- ✓ Ejemplo: telecomunicaciones (antes). Entel fue una de las empresas más sancionadas en la década del 80` por PR. Antes, para unirse al mercado de comunicaciones, tenían que unirse a la red de la Compañía de Teléfonos, no tenían su red propia. Y para que las personas pudieran tener teléfonos, tenían que ponerse en listas de espera porque había muy poca oferta.
- ✓ Otro ejemplo que se dio en Chile fue de los autos. Solo podían producir 3 marcas en Chile y éstos eran caros y malos. También se tenían que hacer listas de espera para comprar autos, esto es sinónimo de escasez.
- ✓ En la década del 60` y 70` se dan estos 2 casos (teléfonos y autos).
- ✓ Cada vez que una empresa nueva quiere entrar al mercado, las que ya están dentro le hacen la vida imposible a la nueva empresa para que entre al mercado.
- ✓ Los monopolios naturales van evolucionando a través del tiempo.

c) **De hecho**

- ✓ NO existe más de una empresa interesada en producir y vender un determinado bien.
- ✓ Un caso emblemático en Chile, es CCU. Fue monopolio de hecho por casi 70 años.
- ✓ Otro ejemplo es el caso de *Lever* que era la única empresa interesada en vender jabón.
- ✓ Hoy en día, casi no existen, ya que los aranceles están llegando casi a 0, y, por lo tanto, entran productos extranjeros al país.
- ✓ Los monopolios de hecho NO pueden evitar que entren otras empresas al mercado.
- ✓ Si los precios de un monopolio de hecho son altísimos, van a venir empresas extranjeras a competir.
- ✓ Hoy en día, la competencia se está dando en términos globalizados. Esto tiene un impacto (+) y (-).

- **PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA (PR)**

- A la ley no le interesan los monopolios, sino las prácticas restrictivas de la competencia.
- En su art 3, define su objeto como prácticas restrictivas de competencia.

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Art 3.- *El que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.*

*Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:
(...)*

- También, agrega en el art 3 bis, las omisiones que son consideradas como PR.
- Lo importante es el efecto negativo efectivamente producido por las PR. El efecto real sobre la competencia puede ser muy pequeño en un momento dado, pero después se puede transformar en uno enorme, y, por lo tanto, deben ser sancionadas por el mínimo efecto que tengan en ese minuto.
- Ej: fusión de Falabella y DIS, intentan fusionar empresas que apenas se topaban en algunas actividades. EL TDLC no permitió la fusión argumentando que a futuro podía tener un efecto muy negativo sobre la competencia, mientras que las empresas argumentaban que no se podía fallar sosteniéndose de esa hipótesis a futuro.
- Abusos de posición dominante. No se define en la ley cuáles son los requisitos para estar en posición dominante.
- En USA las PR se denominan *antitrust* por un desarrollo histórico. Los *trust* eran varias empresas que se ponían de acuerdo sobre la base de estructura societaria, donde se tomaban decisiones sobre la competencia. En otras palabras, había una empresa superior X que controlaba a las empresas inferiores (A, B, C, D), y la PR se daba en la X, y, por tanto, se generaba en la A, B, C y D. Se agregan nuevas prácticas en la evolución de USA, pero se sigue denominando igual.

26 de marzo

- **COMPETENCIA PERFECTA**

- Los mercados perfectos me ayudan a entender las imperfecciones que existen permanentemente en los mercados. Los 5 requisitos son tremendamente exigentes. Estos son:

1. Atomicidad

- ✓ Es la *mayor cantidad de oferentes posibles*. Lo posible depende del tamaño del mercado y del país en cuestión. En algunos países, la atomicidad se puede lograr con 3 empresas, en otros con 10, otros 20, etc.
- ✓ A mayor tamaño de la economía, mayor atomicidad, y a menor tamaño, menor atomicidad.
- ✓ Los monopolios naturales son los menos atomizados que existen (un solo oferente afecta los precios).

- ✓ No hay ninguna regla que me determine si un mercado es o no atomizado.
- ✓ No se puede consultar al TDLC respecto de la atomicidad, se le puede consultar respecto de la concentración de las empresas.
- ✓ Hay un cambio en la ley, durante mucho tiempo, fue voluntaria la consulta con respecto a la concentración, en cambio, ahora es obligatoria, pero dentro de ciertos márgenes/reglas establecidos por la ley para saber cuándo es obligatorio consultar y cuándo no.
- ✓ Se consulta, hoy en día, ante la **FNE** (quien la analiza), pero el TDLC tiene la facultad de revertir una decisión tomada por la FNE al respecto. Incluso, en algunos casos, se ha llegado a la CS como tribunal de última instancia al respecto. Si la concentración es aprobada por la FNE, se queda ahí, pero si es rechazada, entra el TDLC.
- ✓ La aprobación puede ser con condiciones, que, en el caso de las concentraciones, se denominan **mitigaciones**.
- ✓ Caso LAN-TAM: tuvo una serie de mitigaciones, por lo que se pasa a la CS, que termina disminuyendo estas mitigaciones.
- ✓ No se analizan concentraciones pasadas, sino **futuras**.
- ✓ Hoy en día, hay una tendencia a la **desconcentración** dada por la competencia internacional. La gran mayoría de los países, entre ellos Chile, han promovido una apertura de la economía hacia el CI, la inversión extranjera, las licencias extranjeras, los procesos de integración económica, etc. Quedando así, con economías abiertas, y con aranceles cada vez más bajos (6% y con los TLC queda en 0,8%, ya que las importaciones de los países que tenemos TLC es 0% en Chile). En resumen, la competencia internacional hace que se vayan desconcentrando los mercados, y de las formas más impresionantes. Ej: venta de productos chinos en Chile.
- ✓ La competencia internacional tiene un impacto sobre la economía interna enorme.
- ✓ Las concentraciones se pueden producir por ¹fusiones de empresas o por ²adquisiciones. Las concentraciones se producen cuando uno de los participantes quiere adquirir a otro participante.
- ✓ ¿Se dará concentración si uno que no es participante quiere adquirir de un participante? NO. Si solo se remplaza uno por uno, no se da concentración.
- ✓ Por el lado de la demanda, es muy difícil que se produzca una concentración. Si llegase a ocurrir se denominaría *monopsonio*. Para que esto ocurra, se requiere que la ley lo reconozca de alguna forma.
- ✓ El mayor monopsonio que tuvimos en Chile fue el caso del azúcar IANSA. La ley establece que había una empresa estatal (IANSA) como única productora del azúcar, pero no solamente eso, sino que esta empresa estaba obligada a comprarles a los productores de remolacha con la finalidad de proteger a los productores de remolacha con precios por encima del precio de equilibrio, así, garantizándole a los productores de remolacha este precio especial. Esto tuvo en efecto bastante positivo en un comienzo, ya que, aumentó ampliamente la producción de azúcar de remolacha (antes casi nada), abarcando casi todo el

mercado chileno del azúcar. Para esto, también se tuvo que aumentar el arancel del azúcar al máximo para evitar el ingreso de competencias extranjeras. Los precios de ventas eran muy caros (era de los precios de azúcar más caros del mundo). En definitiva, los consumidores de azúcar estaban pagándoles a los productores de remolacha. Según el profesor, esto es una muy mala política pública, aunque haya más empleo y seguridad para esos productores, ya que el Eº debería subsidiar directamente las actividades si lo va a hacer, no a través de los precios. Algunos creen que se debería haber disminuido el consumo de azúcar, pero el azúcar tiene una demanda inelástica.

2. Homogeneidad

- ✓ Se refiere a una *homogeneidad de los productos* que se están vendiendo.
- ✓ Entre más homogéneos sean los productos, hay más competencia. Entre más heterogéneos sean los productos, hay menos competencia. Esto es muy importante en el ámbito económico.
- ✓ El mercado de la leche es bastante homogéneo (tienen precios muy similares) a pesar de que haya como 30 tipos de leche.
- ✓ Si un mercado es homogéneo, el productor no puede aumentar drásticamente el precio, ya que bajaría su Q_d .
- ✓ No hay ningún producto que sea 100% homogéneo con otro.
- ✓ El problema se agranda cuando se mete la **publicidad** entre medio, ya que la publicidad trata de generar heterogeneidad en los productos, y así, que los demandantes los compremos a precios más altos. Ej: Coca-Cola y “bebidas b”.
- ✓ La única solución para este problema sería prohibir la publicidad, lo que sería muy malo.
- ✓ La publicidad tiene efectos (+) y (-). Como efectos positivos, se incluye que entrega información a los clientes (a veces más y a veces menos), ya que, de otra forma, el proceso de compra del consumidor sería muy complejo. Ej: publicidad de autos, evita que los clientes tengan que hacer largos estudios sobre qué auto comprar, ya que les muestra en qué detalles fijarse.
- ✓ La publicidad entrega más información cuando el producto es más sofisticado, y finalmente más caro. Ej: planes de celulares (mucha publicidad) VS planes de ISAPRES (nada de publicidad)
- ✓ El tema de fondo es lo que se denomina **publicidad comparativa**. Hay algunos países en donde está totalmente permitido, en otros está restringido, y en otros prohibido. *Yrarrázaval* se inclina por la primera opción, pero con algunas limitaciones, es decir que no haya una restricción por ley, sino que una restricción conceptual. Así, que las empresas que se quieran comparar puedan hacerlo con publicidad verdadera, objetiva, y que se pueda comprobar, no una maliciosa y engañosa. Otro tema importante a considerar son las marcas y patentes (tema jurídico), ya que no se puede utilizar el nombre ni marca de la otra empresa sin autorización para hacerlo, ya que ésta tiene dº de propiedad. Si existiese esta publicidad y no llegase a ser objetiva, se podría demandar por indemnización de perjuicios.

- ✓ La publicidad comparativa es la más efectiva de todas porque compara elementos que los consumidores necesitan saber. Ej: Pepsi challenge (Pepsi VS Coca-Cola → demanda a Pepsi por utilizar su modelo industrial).
- ✓ Hay veces que una empresa externa hace la publicidad comparativa. Ej: refrigeradores.

3. Transparencia

- ✓ Se refiere a una *transparencia del mercado*.
- ✓ La competencia es más perfecta cuando la transparencia es mayor, y es más imperfecta cuando la transparencia es menor.
- ✓ Ej: mercado de valores, de las acciones e instrumentos de deudas. Se puede transar en la bolsa (acciones de oferta pública, que son generalmente las empresas más grandes) o fuera de ella. La información que me entrega la bolsa es bastante, pero hay que tener alguna especialidad en el tema para entenderla. Me dice a cuánto se compran y venden las acciones pasadas (en distintos periodos (un día, mes o año)), cuántas se transaron, etc. Pero no da la información más importante para los accionistas: sobre la proyección hacia el futuro. Los accionistas compran por 2 motivos: ¹según utilidades y dividendos que me dan las acciones, y, ²comprar barato para vender caro (y sacar provecho). Nadie te asegura de que las acciones compradas baratas se venderán caras.
- ✓ El mercado bursátil es un mercado bastante transparente, y, cuando hay un movimiento raro, la autoridad interviene finalmente. La autoridad que interviene es la CMF, anteriormente la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros). Ej 1: si un día cualquiera las acciones bajan en más de tanto (descenso brusco), se suspende la venta de esas acciones. Ej 2: ningún empleado de la empresa puede comprar ni vender acciones de la propia empresa (porque tiene información privilegiada que todavía no ha llegado al mercado).
- ✓ Hay otros mercados que prácticamente no tienen transparencia. Ej: La Vega.
- ✓ La transparencia, finalmente, queda vinculada al tipo del mercado al cual nos estamos refiriendo.

4. Libre entrada a los mercados

- ✓ Esto significa que *no haya trabas legales o de hecho que impidan que una empresa nueva que no estaba en ese mercado se incorpore a éste*.
- ✓ Cuando las trabas son legales están establecidas por ley, es decir, establecidas por el legislador. Ej: las farmacias deben tener un químico farmacéutico en cada farmacia, por un tema sanitario (bio-equivalentes, recetas retenidas, etc.). Esto es una traba porque para las farmacias pequeñas, el químico farmacéutico es un costo altísimo. Además, la ley establece una disminución de los químicos farmacéuticos, por lo que son escasos y caros. Las 3 farmacias principales se han preocupado que los remedios no se puedan vender en los supermercados (esto existe en todas partes del mundo salvo en Chile).

- ✓ Muchas veces las restricciones establecidas por la ley pueden estar bien intencionadas, pero pueden generar efectos económico bastante nocivos. Ej: Uber.
- ✓ Las peores trabas son las fácticas, o, de hecho, no las de dº. Ej: las trabas portuarias, y, los trabajadores del cobre están tomando las mismas medidas. Los trabajadores se van a huelga en el momento más delicado posible, y todos los años la autoridad tiene que ceder, y tiene que entregarles un bono por término del conflicto (de 15 millones hacia arriba, por lo que es muy atractivo hacer huelgas). Se discute mucho por este altísimo monto (que no se encuentra establecido en la ley).

*Hay 3 categorías de trabajadores portuarios: ¹autorizados (carnet para trabajar), ²“medio pollo” (autorizados por el autorizado), ³“cuarto de pollo” (autorizados por el “medio pollo”). Estas son las trabas portuarias, ya que no permite el libre ingreso de trabajadores a los puertos, a menos que estén autorizados.

5. Libre movilidad de los factores

- ✓ Esto consiste en que *una parte de los trabajadores* (significativa) *se puedan trasladar a nuevas actividades para obtener mejores remuneraciones*.
 - ✓ Ej: en Chile, cuando el precio del salitre o del carbón comenzaron a bajar, muchos trabajadores debieron trasladarse a otras actividades.
 - ✓ Esto no es fácil en la práctica, debido a que los trabajadores se van especializando en sus respectivos puestos.
- Como consecuencia de los distintos requisitos de la competencia perfecta, surgen los distintos tipos de empresas que existen con respecto a la competencia: ¹empresas competitivas, ²de competencia imperfecta (la mayoría) y ³empresas monopólicas (la minoría).

LEY DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA (DL 211) (LDLC)

- Es un texto de 1973, y a pesar de todos los numerosos cambios, se ha querido mantener esta ley.
- La ley previa era del año 1959, y ésta contenía normas sobre la libre competencia (LC). Muchas personas ni siquiera mencionan esta ley ya que tuvo muy poca aplicación. De hecho, del año 59` al 73` hubo un orden de 100 casos, que, de hecho, eran bastante primarios en materia de competencia.
- Esta norma surge en el año 59` porque en el año 57` el *Tratado de Roma* de la Comunidad Económica Europea (CEE) establece por 1º vez normas con respecto a la competencia aplicables a los países miembros de la CEE (en aquel entonces, 6 países: Francia, Italia, República Federal Alemana (RFA), Bélgica, Holanda, Luxemburgo). Dentro del Tratado de Roma (aprox 100 art), 2 se referían a la competencia. Aunque pareciera raro, se incluyen porque la competencia es fundamental para la libertad de movimiento de las empresas (una de las 3 libertades otorgadas por la MCE) *(las 3 libertades de la CEE son: ¹bienes, ²capitales y ³personas). Ej: si una empresa alemana se instala en Francia, debe conocer bajo qué régimen de competencia opera, y así analizar si le conviene instalarse en Francia o no.
- Esta normativa del 59` funcionó poco en Chile porque:
 1. Nadie creía en ella (no era tema).
 2. Por la composición de la *comisión antimonopolio*, que debía perseguir monopolios por su nombre, y no había claridad de que en realidad lo que debía perseguir eran las PR.
 3. Las sanciones se aplicaban escasamente, y eso que existía el delito antimonopolio. Esto se debe a que es muy difícil sancionar un delito monopolístico. Como es delito, tengo todas las exigencias del dº penal. No son meras multas. Finalmente, los delitos monopolísticos no pueden ser determinados por los TDLC porque no son tribunales del crimen, entonces, una vez que termina el caso, el FNE puede ingresar el caso a los Tribunales del Crimen, y, ahí pasa a ser un requirente más. *No se han presentado casos así en Chile.
- La normativa del año 73` se empieza a modificar muchas veces. La más relevante es la de los años 2003-2004, en donde se **crea el TDLC**.
- Toda la estructura de la competencia, es relativamente nueva, antes había **comisiones**: resolutive y preventivas. Había una comisión resolutive y varias preventivas (una por región). La central preventiva era la de la región metropolitana, que tenía la obligación de analizar los casos de esta región, más todos los otros casos que incluyeran a más de una región. Ej: si había un caso que involucrara a la III y IV, no lo tomaba ninguna de estas comisiones, sino que la de la RM, que era la central.
- Los miembros de estas comisiones, eran *ad honorem*, es decir, sin ninguna remuneración (por el honor de ser miembro de alguna de las comisiones). El sistema posterior exigió otorgarles remuneraciones razonables al TDLC. *Yrarrázaval* está muy contento con la evolución que ha tenido esta ley.
- La **FNE**, que NO estaba contemplada en el año 73`, se incorpora cada vez más en este sistema.

- La LDLC (DL 211) ha tenido varias modificaciones.
 - Son de especial importancia la reforma:
 - 2003: incorpora el TDLC.
 - 2009: incorpora la delación compensada para los casos de colusión.
 - El resto de las modificaciones han ido ordenando y adecuando la ley. Esto se debe a que el dº de la competencia tiene una inmensa evolución, al igual que el análisis de la economía con respecto a la competencia. Esto es en razón de que las PR son cada vez más sofisticadas.
- La **jurisprudencia** sobre dº de competencia es inmensa. En esta ley, la jurisprudencia adquiere una inmensa relevancia.
 - Hay que tener mucho cuidado con la jurisprudencia, ya que en nuestro país no es vinculante.
 - A pesar de que no sea vinculante, es muy importante la jurisprudencia en el dº de la competencia.
 - En el art 3 se hace una mención a distintas PR (muy amplia).
 - Inciso 1: contiene la definición de PR.
 - Inciso 2: menciona a título ejemplar distintas PR. Pero, no dice en qué consiste ni cuál es su contenido mínimo.
 - La jurisprudencia analiza cada uno de los casos donde hay requerimientos de la FNE o demandas de empresas. *Las demandas de la FNE se denominan *requerimientos*.
 - En síntesis, para saber dº de la competencia, hay que conocer la jurisprudencia. Esta jurisprudencia no está publicada en ninguna parte. Hay que buscar en la página de la FNE los distintos casos.
 - Este análisis jurisprudencial es tremendamente difícil, porque a pesar de que el tribunal tiene ciertas líneas determinadas, a veces, las cambia porque hay nuevos conceptos o antecedentes.
 - Ej: durante mucho tiempo la distribución exclusiva estuvo prohibida, pero, hoy día no lo está. Acá cambió el criterio, pero el Tribunal dijo expresamente este cambio de criterio (ahora, se debe analizar el mercado en cuestión para determinar si hay práctica restrictiva).
 - Cuando hay delación compensada, el delator le entrega al tribunal toda la información sobre cómo operaba la colusión. En cambio, cuando no hay delación compensada, el TDLC y la FNE deben investigar hasta el último detalle para ver si van a llegar a la conclusión de si hay o no colusión.
 - La ley es muy simple e *Yrarrázaval* está a favor de esto.
 - Uno podría pensar que el ideal de un dº de la competencia es una larga enumeración de las PR en la ley. Esto es justo lo contrario de lo que tenemos en Chile (sólo incluidas en el art 3). Esta postura diría que para la seguridad y certeza jurídica se necesita hacer un listado de estas prácticas, y, si se llegasen a descubrir nuevas prácticas, se debiesen agregar.
 - Si se le entrega la ley con listado a una persona común y corriente, no entendería nada. Por lo tanto, este sistema sería pésimo.

- En la ley de protección al consumidor y de competencia desleal, se enumeran/tipifican todas las conductas que pueden ser sancionadas.
- Sería una **ineficacia espectacular** tipificar las PR por 2 motivos:
 1. La tipificación no solo se trata de enumerar las prácticas, sino de establecer cuáles son las condiciones necesarias para incurrir en esa práctica. Entonces, serían muchísimas páginas.
 2. Además, la incorporación de prácticas significa una modificación a la ley, por lo tanto, pasaríamos por el proceso legislativo cada vez que se quiera incorporar una nueva práctica.
- ¿Las PR podrían estar incluidas en decretos supremos (DS) o en reglamentos? NO, porque la CPR establece en su art 19 N°21 la reserva legal en materia económica, por lo que esta materia debe respetar las normas legales que la regulen. El dº de la competencia es regulación (de materia económica) por lo que no se puede modificar a través de DS o reglamentos.
- En resumen, hay 2 modalidades respecto del dº de competencia, una ¹brinda certeza jurídica y la otra ²brinda eficacia. *Yrarrázaval* prefiere la 2º (eficacia).
- Ahora sí, en la jurisprudencia uno debiese esperar **consistencia**. Sería un desconcierto total que cambie de línea en cada juicio. Esto crearía incertidumbre. Distinto es a una jurisprudencia bastante consistente, que, cuando hay cambios los anuncia el TDLC o CS.
- El inciso 1 del art 3 da la definición general de PR.
- **Títulos de la ley:**
 - **Título I: Disposiciones Generales.** A juicio de *Yrarrázaval* es el más sustantivo e importante de la ley. No tiene muchas normas.
 - **Título II: Del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia**
 - **Título III: De la Fiscalía Nacional Económica**
 - **Título IV: De las Operaciones de Concentración**
 - **Título V: De las Sanciones Penales**
- Se puede utilizar la jurisprudencia -en temas de dº de competencia- como argumento para los juicios, y así, razonar sobre la tesis que se está defendiendo. El TDLC considera esta jurisprudencia (no necesariamente, pero da mucha importancia a la defensa).

I. TÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES

○ Art 1

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1- La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados.¹

Los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley.²

- ¹**Inc 1:** el objeto de la ley es la promoción y defensa de la LC en los mercados. No hay tema de la competencia en lo que no sean mercados.
- ²**Inc 2:** la corrección, prohibición o represión de las PR le corresponde exclusivamente a la LDLC. Hoy en día, dentro del dº regulatorio, las superintendencias y CMF pueden aplicar sanciones, pero respecto de las PR solamente serán los órganos mencionados por esta ley. Esto es muy relevante pues en muchos países se confunde el dº regulatorio con el dº a la competencia.
- La LDLC busca que las licitaciones sean competitivas, muchas veces se da que las licitaciones tienen PR, es decir, no se hacen licitaciones abiertas. A veces incluyen ciertos requisitos para que se la gane una empresa en específico, que es la única que cumple con esos requisitos.
 - Caso licitación para nuevos pasaportes y carnets de identidad del registro civil:
Se presentan unos franceses y Sonda. La nueva licitación fue adjudicada a los franceses. Sonda demanda al registro civil porque las bases de la licitación prácticamente los excluía de ganar esa licitación ya que le daban un puntaje muy alto a la experiencia y los franceses la tenían mientras que Sonda no. Si no fuera por este problema de la competencia, hay otras instancias para ser reclamada, pero como influye la competencia, debe registrarse bajo la ley de la competencia.
- En definitiva, la LDLC SOLO se preocupa de materias de competencia, y, los temas regulatorios les corresponden a las autoridades regulatorias. Al profesor le llama mucho la atención que hay algunas demandas en materia de competencia que en la misma se establece que se recurre a la CMF y a los tribunales. Esta demanda se descarta, pues, si es que esta demanda es de competencia, se debe demanda por competencia. No porque sea barato se debe recurrir a distintos tribunales.

○ Art 2

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2- Corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados.

- Luego, en la ley se hace una larga enumeración de las atribuciones del tribunal y de la fiscalía. Estas son muy distintas.

▪ FISCALÍA (FNE):

- ❖ la función de la FNE es **investigar** con todas las ramificaciones que tiene.
- ❖ Esta fiscalía (FNE) no se debe confundir con el Ministerio Público que se dedica fundamentalmente en materias penales y que, por cierto, tiene distintas atribuciones a la de la FNE. Pero, hay ciertas atribuciones comunes:
 1. Investigación (atentados contra la competencia VS temas penales principalmente)
 2. Allanamiento, debe ser con autorización del TDLC o jueces de garantía.
 - ✓ Ej: la fiscalía económica hizo un allanamiento a los supermercados de manera muy pública, se llevan programas, computadores, etc.
 3. Intercepciones telefónicas de cualquier naturaleza
 4. Intercepción de mails.
 - ✓ Ej: revisión de millones de mails de las farmacias (colusión). Aumentaban precios de remedios bajo receta.

→ Los 3 últimos son mecanismos que facilitan la investigación a la fiscalía, ya que ésta es una atribución exclusiva de la fiscalía.

▪ TDLC:

- ❖ El TDLC NO investiga, esa es una facultad exclusiva de la FNE.
- ❖ El TDLC recibe el expediente de la FNE, con un requerimiento (demanda), se incorpora a la investigación en donde analizan la información y luego viene la prueba, en donde se prueban solamente los hechos, NO el dº (se sabe o no se sabe, no se prueba excepto en internacional privado).
- ❖ La prueba de LC es muy compleja y se demora mucho tiempo, además requiere por lo menos a un ministro del TDLC escuchando toda la prueba que puede ser a través de documentos, testigos, resolución de oposiciones (se cita al gerente de la contraparte para que afirme ciertas cosas realizadas por él), etc.
- ❖ La prueba es el fundamento de hecho del fallo.
- ❖ Se han dado casos en donde la prueba se considera suficiente por algunos ministros e insuficiente por algunos otros (ej: caso gas).
- ❖ El TDLC **falla**.
- ❖ El fallo se puede denominar de 2 maneras:
 - a) **Sentencia**: si se da por demanda (de particulares) o requerimiento (por parte de la FNE).
 - b) **Resolución**: si se da por consulta.
- ❖ Hay muchas más sentencias (80%) que resoluciones (20%) porque en Chile cada vez se consulta menos.
- ❖ En el periodo 73`-90`se consultaba muchísimo (había más resoluciones que sentencias). Se revierte esta situación porque la gran mayoría de los temas de LC ya fueron consultados.
- ❖ Ej: casi todos los centros comerciales fueron consultados.
 - ✓ Esto se debe a que tienen un mecanismo bien raro: tienen dueños del centro comercial + dueños de “tiendas anclas” (líder, jumbo,

etc.) + dueños de otras tiendas. Se podrían llegar a sumar 400-500 dueños.

- ✓ Para que opere bien el centro comercial, el dueño de éste debe ser capaz de **discriminar** entre las tiendas (sus clientes). Debe hacer que las tiendas operen “como un solo todo”, no, por ejemplo, teniendo puras peluquerías.
- ✓ Las “tiendas anclas” son relevantes porque sus dueños son poderosos y pueden llegar a complicar al dueño del mall. Eliminarlas hace al centro comercial menos atrayente.
- ✓ Una de las PR es la discriminación. Si se es muy severo en esto, el centro comercial no funcionaría ya que se podrían instalar puras tiendas similares, y el éxito de un mall se da porque el cliente pueda comprar todo lo que necesita/quiere en el mismo lugar.
- ✓ Se consulta si el esquema del centro comercial atenta contra la LC o no. La respuesta fue que no afectaba la competencia.
- ✓ Caso centro comercial La Florida: se instala 1º un centro comercial y cuando supo que se iba a instalar uno relativamente cerca, les impuso a sus tiendas la prohibición de instalarse en el otro mall. Esto es un atentado a la competencia. Se defienden muy bien ante la demanda.
- ❖ Consultar permite evitar que un contrato se vuelva nulo.
- ❖ Una causa en el TDLC demora entre 6-18 meses en ser resuelta. Se demora mucho en las pruebas.

→ En definitiva, los únicos a cargo de la competencia en Chile, son el TDLC y la FNE.

○ Art 3

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3- *El que¹ ejecute² o celebre³, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención⁴ que impida, restrinja o entorpezca⁵ la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos⁶, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley⁷, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. (...)*

- **Inc 1:** se da una tipificación general. Cada palabra es muy relevante.
 - ¹*El que* se refiere a cualquier persona -natural o jurídica, pública o privada-. Inclusive al Eº, mediante el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aeronáutica, etc.
 - ✓ Algunos consideran que esto es demasiado amplio (incluir al Eº). *Yrarrázaval* piensa que no hay ninguna razón para dejar ni al Eº ni a las empresas públicas fuera del ámbito de jurisdicción de esta ley porque están realizando comportamientos económicos en los que pueden incurrir –y, de hecho, han incurrido- en PR.
 - ✓ Hay países que dejan al Eº y las empresas públicas fuera del ámbito de esta ley.

- ¹Otro tema que plantea este *el que* es lo que pasa con las PR fuera del país que tiene efectos en Chile.
 - ✓ Por ejemplo, colusión de refrigerados en Brasil. Este caso fue sancionado por el TDLC y confirmado por la CS, porque lo que importa son los **efectos**.
 - ✓ Si hay efectos en Chile, el ámbito de la ley también los incluye.
 - ✓ Por más de que la ley chilena no es extraterritorial, si los efectos se generan en Chile, se puede sancionar.
- ¹Un tercer tema que plantea este *el que* es lo que pasa con las PR que hagan los exportadores chilenos.
 - ✓ Si se puede sancionar, pero debe tener algún efecto en Chile.
 - ✓ Siempre va a haber algún tipo de efecto en Chile. Si este es pequeño, la sanción será menor.
 - ✓ Hay ciertos países que tienen extraterritorialidad para la LDLC.
 - El caso más importante es USA, en el que su legislación de la competencia es extraterritorial, por lo que se persigue a las empresas norteamericanas sin importar el lugar donde estén operando.
 - Las 2 mayores sanciones de la UE en materia de dº de competencia en el último tiempo han sido a *Google* y *Microsoft*.
 - El problema que se plantea es que, si USA persigue a esas empresas, estarían bajo 2 legislaciones con distintos criterios.
 - Esto, es un tema jurídico muy complejo. Está el cuestionamiento sobre quién debe sancionar a la empresa ya que, como principio universal, nadie puede ser sancionado 2 veces por la misma conducta.
 - Esto choca con la soberanía nacional de los países en donde se encuentran las empresas norteamericanas. Se terminaría dando una “carrera” por quien juzga primero, pero esto no tiene ningún sentido.
 - *Yrarrázaval* tiene dudas acerca de la eficacia de esta ley extraterritorial. Empiezan a chocar las legislaciones por las que se deben sancionar. En estos casos, la de la UE y USA.
 - USA sólo podría sancionar si no hay ley o la ley es pésima (insuficiente). Si no, no debería sancionar (no puede).
 - Muchos afirman que hay mayor desarrollo de dº competencia en la UE que en USA.
- En conclusión, “*el que*” tiene un alcance enorme.
- ²La **ejecución**, generalmente, es individual de una empresa.
- ³La **celebración** –ya sea de contratos o de convenios- es por lo menos bilateral.
- Entonces, “*el que ejecute o celebre*” puede ser de una persona, varias personas, una empresa o varias empresas. En definitiva, acá se incluyen los **oligopolios** (que por el lado de la demanda se denominarían *oligopsonios*).
 - ✓ En el art 3 inc 2 letra b), los oligopolios no son sancionados por la ley, al igual que los monopolios.
 - ✓ Entonces, ¿cuándo un oligopolio va a ser sancionado por la ley? Cuando esas pocas empresas -de un determinado mercado- llegan a un acuerdo restrictivo de la competencia.

- ✓ Por lo tanto, se entiende que la celebración de actos o contratos puede ser entre cientos de empresas o pocas empresas, lo importante es que no abusen de su posición dominante. Esto queda establecido en el art 3 inc 2 letra b). La gran mayoría de las posiciones dominantes son de oligopolios, pero no son por el hecho de existir, sino por el hecho de abusar de esa posición monopólica.
- ⁴Sanciona cualquier hecho jurídico, acto jurídico o convención. Cualquiera de estas alternativas que tenga un efecto jurídico, va a ser sancionado por el TDLC.
- El Eº también está comprometido en el dº de la competencia, ya que se comprometen/regulan empresas del Eº y organismos del Eº (Ministerios de Obras Públicas, Dirección General de Aeronáutica, municipalidades, etc.). De hecho, un tercio del listado son empresas u organismos del Eº. Por lo tanto, se entiende que el Eº también puede incurrir en PR.
- ⁵La persona ("el que") debe *impedir, restringir o entorpecer* la LC.
 - Impedir* es la palabra más absoluta, es un 100%.
 - Restringir* sería un término medio.
 - Entorpecer* sería el término más suave.
- ✓ Cualquiera de estas prácticas -que impidan, restrinjan o entorpezcan la competencia- serán denominadas **prácticas restrictivas de la competencia**.
- ✓ ¿Quién determina cuáles son las prácticas restrictivas? El TDLC.
- ✓ ¿Sobre qué actos, hechos o convenciones investiga la FNE? Sobre los que considera que pueden estar **impidiendo, restringiendo o entorpeciendo la competencia**.
- ✓ En definitiva, el ámbito de acción del TDLC y de la FNE serán las PR.
- ✓ Se ha tratado de clasificar las prácticas restrictivas, y hoy en día, estaríamos en el orden de treinta y algo. Pero si uno ve un libro de dº de la competencia europea, ya van en trescientas y algo. Cada vez van surgiendo nuevas PR.
- ✓ ¿Por qué no se habla de *prácticas anticompetitivas*? Porque anticompetitiva puede ser un término muy genérico. En todo el mundo, ya no se habla de prácticas anticompetitivas, sino que de prácticas restrictivas.
- ⁶la frase "*o que tienda a producir dichos efectos*" le cae pésimo a los economistas, pero muy bien a los abogados.
 - ✓ Para los economistas, esto es sancionar el **intento** de incurrir en una PR. Dan una serie de argumentos sofisticados sobre esto, incluyendo cómo se prueba el intento, el qué pasa si se frustra el intento y no les resulta la práctica restrictiva, etc. En el caso frustrado, habría 0 efectos sobre la competencia, entonces, ¿se debería sancionar?
 - ✓ La crítica que le hace *Yrarrázaval* a los economistas es que para que se vea la consecuencia de los monopolios, debe pasar mucho tiempo (3 meses o más). Por lo tanto, si no se sanciona el intento de PR, tendríamos que esperar a las consecuencias, y eso puede ser muy tarde y fatal para la economía.
 - ✓ Para los abogados, se debe sancionar porque lo que importa es que se intente o ejecute la PR.

▪ **COLUSIÓN:**

- ✓ Cuando las empresas que tienen distintos costos se ponen de acuerdo en un solo precio, se beneficia a la más ineficiente y se perjudica a la más eficiente (en término de costos).
- ✓ Si los costos son muy distintos, los ingresos también lo serán. Así, en virtud del acuerdo:
 - las empresas más ineficientes tendrán más ingresos que los que estaban teniendo, por lo que le deberían dar un bono a esos gerentes.
 - las empresas más eficientes tendrán menos ingresos que los que estaban teniendo, por lo que echarán a esos gerentes.
- ✓ Estos acuerdos de precios no durarán en el tiempo, a lo más 1 semana.
- ✓ Hay un acuerdo histórico en el mundo en el cual el acuerdo duró mucho tiempo: monopolio del petróleo en la década del 70`. Los países productores y exportadores de petróleo llegaban a acuerdos de precios constantemente, en donde se fijaba el precio y las cantidades que iban a producir. Este monopolio funcionó bien hasta que 2 países –los más eficientes: Kuwait y Arabia Saudita- se retiraron del acuerdo ya que los menos eficientes nunca le dieron un % mayor de acuerdo a su eficiencia, y ahí, el monopolio se vino abajo. Este monopolio fue un perjuicio a la economía mundial enorme. *Yrarrázaval* dice que no se debería haber producido un monopolio de oferentes, sino que, de demandantes, y, esto nunca se produjo.

28 de marzo

- ⁷*“será sancionado con las medidas señaladas en el art 26 (...)”.*
 - ✓ Acá, hay una primera aproximación a cuáles serán las sanciones de las prácticas restrictivas.
 - ✓ En el art 26 se mencionan **5 sanciones** posibles para las PR, que, son totalmente distintas.
 - ✓ Las sanciones son muy severas, y, dentro de la legislación económica, son las más severas de todo el sistema.
 - ✓ Las sanciones en el art 26 están planteadas en relación con las sentencias del TDLC. Entonces, en vez de mencionarlas al comienzo (dentro de las normas generales), las menciona como parte de las sentencias del TDLC (en esa sección).

○ **Art 26: Sentencia del TDLC y Sanciones para las Prácticas Restrictivas**

TÍTULO II - DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 26- *La sentencia definitiva será fundada¹, debiendo enunciar los fundamentos de hecho, de derecho y económicos con arreglo a los cuales se pronuncia.² En ella se hará expresa mención de los fundamentos de los votos de minoría, si los hubiere.³ Esta sentencia deberá dictarse dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contado desde que el proceso se encuentre en estado de fallo.⁴*

En la sentencia definitiva, el Tribunal podrá adoptar las siguientes medidas:⁵

a) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones de la presente ley;⁶

b) Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior;⁷

c) Aplicar multas a beneficio fiscal⁸ hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido⁹ o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción.¹⁰ En el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, el Tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma equivalente a sesenta mil unidades tributarias anuales.¹¹ Las multas podrán ser impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo.¹² Las multas aplicadas a personas naturales no podrán pagarse por la persona jurídica en la que ejercieron funciones ni por los accionistas o socios de la misma. Asimismo, tampoco podrán ser pagadas por cualquiera otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial en los términos señalados por el artículo 96 de la ley N°18.045, de Mercado de Valores, ni por los accionistas o socios de éstas.¹³ En el caso de las multas aplicadas a personas jurídicas, responderán solidariamente del pago de las mismas sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la realización del mismo.

Para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese; la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo, la calidad de reincidente por haber sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas durante los últimos diez años, la capacidad económica del infractor y la colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación;¹⁴

d) En el caso de las conductas previstas en la letra a) del artículo 3°,¹⁵ podrá imponer, además, la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada;¹⁶

e) En el caso de la conducta prevista en la letra a) del artículo 3° bis, podrá aplicar una multa a beneficio fiscal de hasta veinte unidades tributarias anuales por cada día de retardo contado desde el perfeccionamiento de la operación de concentración.¹⁷

○ **Inc 1:**

- ¹La sentencia debe ser **fundada**.

✓ Las fundamentaciones de las sentencias han ido incrementándose a través

del tiempo, con la función de hacerlas lo más fundadas posible.

- La sentencia conduce a la aplicación de las sanciones.
- ²Se debe enunciar los fundamentos de **hecho, de dº y económicos**.
 - ✓ Cualquier otra sentencia, menciona solo fundamentos de hecho y de dº. Solo este tribunal agrega los fundamentos económicos.
 - ✓ Esto es una consecuencia de la integración del TDLC. Para eso están los 2 economistas que forman parte de los ministros del TDLC. Y, son ellos los que deben hacer la argumentación económica del caso.
 - ✓ Mientras los ministros del TDLC que son abogados se preocupan de la argumentación de dº, los economistas se preocupan de la económica.
 - ✓ La argumentación económica es muy técnica, y, por lo general va acompañada de muchos informes bastante complicados.
 - Por ejemplo, en el caso de concentraciones, los argumentos económicos son los determinantes del fallo, porque tiene un análisis económico del mercado relevante y el impacto que tiene la concentración en el mercado. Lo que importa en las concentraciones es que tenga un abuso de la posición dominante, y esto es un análisis meramente económico.
 - En los casos de competencia desleal, los argumentos económicos tendrán poca relevancia, salvo que quién esté realizando la competencia desleal esté abusando de su posición dominante. Ahí entra a considerarse el mercado relevante. De hecho, en la demanda misma, el demandante debe describir el mercado relevante. Ésta es una condición de la demanda misma, por lo que, si no se incluye, se puede desestimar el caso. La descripción del mercado relevante es un criterio de admisibilidad de la demanda.
 - ✓ La integración del TDLC chileno es considerada por *Yrarrázaval* como muy buena, ya que otros tribunales que no lo tienen, erran generalmente en lo económico. Los ministros economistas han hecho un gran aporte en el último tiempo en las sentencias por su perspectiva económica.
 - Fusión Falabella-Líder: fue antes de que se hiciera obligatoria la consulta para las concentraciones. Ellos consultan voluntariamente. Estas empresas están en mercados bien distintos, pero el TDLC dice que no pueden fusionarse ya que encuentra peligrosa esta fusión hacia el futuro.
- ³Lo que está persiguiendo la ley es que, si llegan a haber votos de minoría, deben ser **argumentados** ya que le encuentra un valor a la argumentación de los votos disidentes.
- ⁴Después de los alegatos y de que no haya ninguna cuestión pendiente, el TDLC tiene un plazo de **45 días** -desde que el proceso se encuentre en **estado de fallo**- para **dictar la sentencia**.

○ **Art 26 inc 2: Medidas/Sanciones que puede aplicar el TDLC**

- ⁵Las medidas que puede aplicar el TDLC ante las PR son 5, y, son todas muy distintas.
- Estas NO son excluyentes, por lo que se pueden aplicar más de una.

- **Letra a)**
 - ⁶**Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a las disposiciones de la presente ley.**
 - ✓ La ley quiere abarcar todo.
 - ✓ El TDLC es el que decide si se va a modificar alguna cláusula, o, si se pondrá término al contrato en su totalidad.
 - ✓ La modificación o el término de los actos, contratos, etc. tiene una **connotación jurídica enorme**. En ocasiones sólo se les pone término a ciertas cláusulas del contrato, pero muchas veces se disuelve el contrato completo. Esto afecta el principio de la **autonomía de la voluntad**, sin embargo, se privilegia el **OPE** por sobre esta.
 - ✓ Para un civilista o comercialista esta sanción es una barbaridad ya que:
 - i. Les quita seguridad jurídica a los contratos válidamente celebrados.
 - ii. El único que puede modificar o poner término a los contratos es el **poder judicial**, NO un tribunal de la competencia (tribunal especial) y más todavía si está integrado por 2 economistas.
 - Esto se vuelve aún más extraño si este contrato ya está celebrado.
 - Esto, le confiere mucho poder al TDLC, y, por lo tanto, el TDLC ha sido muy prudente de aplicar esta sanción. La ha aplicado a contratos que no han sido celebrados, o que su término no va a tener una repercusión relevante. De hecho, el TDLC no sanciona todas las cláusulas de no competencia, sino solo las que realmente tienen un impacto en la competencia.
 - ✓ *Yrarrázaval* está completamente de acuerdo con que esta sanción esté contenida en la ley.
 - ✓ ¿Qué actos o contratos puede modificar o poner término? Aquellos que afectan la competencia, SOLAMENTE aquellos.
 - ✓ Afortunadamente en Chile el tema de modificación o término de contratos no es tan trágico ya que, hoy en día, con la inmensa jurisprudencia que tenemos en Chile, la gran mayoría de los abogados (o los que han estudiado más esta materia) saben o debieran saber cuándo hay PR en los contratos. Al identificarlas, le comunican a la parte que los contrata que cierta cláusula es peligrosa desde el punto de vista de la LC. Éstas se podrían modificar directamente, o, la empresa puede hacer **consultas** al TDLC.
 - ✓ Puede que la PR se encuentre en un **sistema**, como es en el caso de las **franquicias**:
 - Se dan principalmente en:
 - a) **Comida rápida**
 - ❖ Caso McDonald's. El operador no tiene una relación contractual, de trabajo ni de honorarios con McDonald's. Se limita al operador a comprar productos de determinadas empresas en determinadas condiciones. El operador ni siquiera puede elegir a sus proveedores.
 - b) **Tiendas de ropa**

c) Hoteles

- ❖ En el caso de la franquicia del hotel, intervienen alrededor de 3 o 4 empresas distintas.
- ❖ Se genera un enjambre de contratos que corresponden a un sistema en el que intervienen empresas totalmente distintas en un mismo producto final.
- ❖ Todas estas prácticas analizadas de forma independiente, serían PR, pero los TDLC no las consideran como tales ya que forman parte de un sistema, al igual que los centros comerciales.

→ Las franquicias tienen una estructura muy especial, al igual que, los **centros comerciales**. Éstas, forman parte de un sistema que deberá ser aprobado o rechazado.

- ❖ Las franquicias tienen un dueño (empresa franquiciadora) y varios operadores (se le entrega la franquicia).
- ❖ Al operador le interesa vender lo más posible ya que participa de un % de las ventas del local del cual él es operador.
- ❖ Si el operador es totalmente independiente al dueño de la franquicia, y está recibiendo una cantidad de instrucciones del dueño, uno podría decir que esto limita la competencia. Pero como forma parte del sistema de franquicias, el TDLC considera que no se está limitando la competencia.
- ❖ Si el operador hace cosas distintas a lo que el dueño de la franquicia le dice que haga, se le quita la franquicia (y de un día para otro). Ej: si el franquiciador no quiere que haya desayunos, no van a haber.
- ❖ ¿Por qué hay centros comerciales que les va muy bien y hay otros que les va muy mal? Porque a los que les va muy bien se debe a que el dueño del centro comercial decide que empresas va a tener y dónde las va a ubicar, en cambio, a los que les va mal tienen empresas de un mismo rubro pegadas unas a las otras.

→ Todo el sistema de franquicias es algo relativamente reciente en Chile (aprox 30 años), en cambio, en USA llevan aprox 70 años.

→ Hay limitaciones incuestionables de la LC, por lo que se consultó todo el sistema de franquicias ante la comisión preventiva de aquel entonces. La comisión preventiva, luego de un análisis muy cuidadoso de todas las relaciones contractuales entre el operador y franquiciador, llega a la conclusión de que NO se afecta a la competencia. Y, desde ese entonces, no hay ningún cuestionamiento a estas obligaciones entre operador y franquiciador.

- Esta sanción se ha aplicado a veces de forma notoria, y a veces de forma menos notoria.
- Caso exportación de frutas: El tema de fondo era cuál era la naturaleza jurídica de los contratos de exportación de frutas. Se discutía si era de compraventa o consignación. Generalmente, la exportación de fruta en Chile se hace de la siguiente manera: los productores le entregan la fruta a la empresa exportadora

(unos pocos lo hacen de forma independiente, pero se terminan dando cuenta que el mercado de la fruta en el extranjero es tan complicado que no vale la pena). La empresa exportadora puede:

a) Comprar la fruta (compraventa)

b) Tomar la fruta en consignación.

- ❖ Esto significa que al productor le van a pagar en la medida que sostenga determinados precios en el extranjero por la empresa exportadora.
- ❖ Si a la empresa exportadora le va bien, le transfiere más recursos al productor. Pero, si le llega a ir mal, perjudica al productor.
- ❖ En definitiva, el productor depende de los resultados de venta en el exterior.
- ❖ Esto es muy riesgoso, pero le da al productor una mejor compensación si se vende su fruta. Si no se quieren correr riesgos, se hacen contratos de compraventa, pero, se recibe una menor cantidad de dinero por la fruta.
- ❖ Para el productor es muy complejo, ya que debe confiar en la empresa exportadora.
- ❖ Cuando la fruta sale, no lleva la individualización del productor, sino que de la empresa exportadora.
- ❖ Como son peligrosos, los productores de fruta que han crecido, se instalan con una pequeña oficina en el país donde van a vender la fruta las empresas exportadoras. Esto se debe a que no confían de la liquidación unilateral hecha por la empresa exportadora, y prefieren ver exactamente a cuánto le están comprando los supermercados a las empresas exportadoras.

→ Situaciones como éstas fueron resueltas por el TDLC que afirmó que son 2 sistemas contractuales completamente distintos, y que especialmente los contratos de consignación debían reunir una serie de características para que fueran válidos. Algunos piensan que el TDLC no tenía que meterse en esto, pero en realidad, si tenía que declarar los requisitos para estos contratos de consignación ya que se estaban produciendo muchas restricciones a la competencia por la falta de claridad del contrato.

- Caso Cláusula Radial del supermercado de la Florida: Se instala un 1º centro comercial y después un 2º. Se establece en los contratos con las tiendas del 1º centro comercial la prohibición de instalarse a 5 km a la redonda. Estos contratos fueron celebrados libremente por cada una de las tiendas. Entonces, ¿por qué llega el TDLC y la CS a terminar contratos celebrados libremente? Porque atentan contra la competencia.
- Los fallos de la CS en materia de LC se dan en la 3ª sala, pero con composiciones que van cambiando. Las salas, en general, van cambiando de composición. Algunos se mantienen en la misma sala, pero otros se cambian.
- Para asegurarse que un contrato no atente contra la LC, se realiza una consulta al TDLC que:
 - a)** acepta el contrato
 - b)** indica qué cláusulas deben modificarse para que se acepte el contrato.

- Generalmente, se hacen las consultas antes de la celebración del contrato.
- Cada vez son menos las consultas porque la gran mayoría de las consultas ya fueron hechas.
- Antes del 2004, existían **comisiones preventivas** en materia de la LC.
 - ✓ Estas comisiones existían en cada región del país, por lo que existían 13 comisiones preventivas: 12 (una de cada región) + 1 en la RM que era la **comisión preventiva central**.
 - ✓ Las consultas que incluían solamente a una región, caían en la comisión preventiva de tal región.
 - ✓ Las consultas que incluían solamente a la RM, caían en la comisión preventiva central.
 - ✓ Las consultas que incluyeran a más de una región, también caían en la comisión preventiva central, no caían en alguna de las comisiones preventivas de las regiones involucradas.
 - ✓ Las comisiones preventivas centrales funcionaron del año 73'-2003. En estos 30 años de existencia, la gran mayoría de los dictámenes (esta es la palabra técnica) de las comisiones preventivas centrales, se referían a consultas con respecto a todos los contratos imaginables.
- Con la modificación del 2003, se establece que va a ser el TDLC quien resuelva las **consultas** ya que desaparecen las comisiones preventivas.
 - ✓ Acá, el TDLC se empieza a complicar cada vez más ya que agregó tal cantidad de requisitos o condiciones para las consultas que desincentivaron las consultas, que a juicio de *Yrarrázaval* en materia de competencia son muy relevantes.
 - ✓ Si uno ve cualquier año del TDLC hay alrededor de 15-20 sentencias y 1-2 consultas respondidas.
- ¿Cuál es el incentivo para consultar? Una consulta aprobada genera el **efecto de cosa juzgada**, y, por lo tanto, la consulta respondida afirmativamente permite que se realice el contrato hasta que haya otra sentencia que la cambie. Si no hay una sentencia que lo cambie, lo puede desarrollar sin ningún problema.
- Las consultas NO pueden derivar en una sanción, sino que deriva en el rechazo o aprobación/aceptación, y, en algunos casos en una aprobación con condiciones/mitigaciones (se dan muchos casos de aprobación con condiciones en las concentraciones).
 - ✓ Fusión LAN-TAM: en este caso las condiciones eran bastante duras, por lo que la CS eliminó algunas –ante un reclamo de LAN- por considerar que éstas no estaban dentro del ámbito de la fusión (ej: eran vuelos de LAN a Perú o Ecuador, siendo que el mercado relevante era Brasil y Chile).
- Las consultas se hacen generalmente antes de celebrar los contratos. También, se pueden hacer después de la celebración, pero se exponen a que el contrato que ya está en operación sea declarado nulo, y, tener que asumir todas las consecuencias que esto conlleva (despido de trabajadores, etc.). Por lo tanto, si en una empresa se está viendo si consultar o no, el gran incentivo es consultarlo antes para los efectos de que no haya problemas después.

○ **Letra b)**

- **⁷Ordenar la modificación o disolución de personas jurídicas de dº privado.**
 - ✓ Se puede notar que acá quedan fuera las personas jurídicas de dº público. *Yrarrázaval* no entiende porqué, ya que éstas también pueden incurrir en PR. De hecho, se discute qué pasaría en el caso de las personas jurídicas de dº público. Pero, que el TDLC disuelva una empresa pública es un poco excesivo, aun así, si ha sancionado varias veces a empresas públicas.
- Esta sanción es la sanción más extrema o radical que puede existir, ya que se está disolviendo a una persona jurídica de dº privado que contraviene las normas de la ley. Esto genera una cantidad de consecuencias enormes, porque es una empresa que está totalmente activa y que, en un momento dado, el TDLC la disuelve.
 - ✓ Al ser tan radical, -felizmente a juicio del profesor- se ha aplicado muy poco esta sanción en Chile.
 - ❖ Caso asociaciones gremiales utilizadas para colusión: se ha aplicado esta sanción especialmente a las asociaciones gremiales. Casi todos los casos de disolución de asociaciones gremiales son porque son utilizadas como vehículo para el acuerdo de las empresas coludidas. Ej: microbuses, taxis, etc. En muchos casos, forman la asociación gremial para coludirse, ya que es muy fácil crear las asociaciones gremiales.
 - ❖ Caso Pollos (colusión): fue una de las sanciones del caso de los pollos, es decir, la disolución de la Asociación de Productores Agrícolas. Esta asociación era el vehículo que utilizaban las 3 empresas productoras de pollo para ponerse de acuerdo en las participaciones en los mercados. Además, se impusieron multas muy altas.
- Para aplicar esta sanción, el TDLC debe tener el convencimiento de que el problema está en la asociación.
- La disolución de empresas grandes ha sido realizada sólo por USA: telecomunicaciones y combustible.
 - ✓ En el caso de telecomunicaciones, se descubre que las empresas más grandes tenían cables con una posición más dominante en los mercados, por lo que incurrían en prácticas restrictivas permanentemente. Este caso llega a la CS y resuelve que se dividiera la empresa, por lo que existen empresas distintas con el mismo nombre (pertenecen a estados distintos).
 - ✓ El caso del combustible fue resuelto de igual manera por la CS.
 - ✓ Estos casos, tienen muchos escritos a favor y en contra de los fallos.

○ **Letra c)**

- **⁸Multas a beneficio fiscal.**
- Esta sanción, se aplica en casi todos los casos.
- Las multas son a beneficio fiscal. Por lo tanto, NO se pagan a la afectados, sino al fisco. Los afectados NO obtienen ningún peso por sanciones de la letra c). De esta manera, se contempló en la ley que los afectados pueden demandar por indemnización de perjuicios. Esto se ha ido desarrollando a nivel mundial. De hecho, en algunos países se habla del dº de la competencia:

- i. Público: multas a beneficio fiscal.
- ii. Privado: indemnización de perjuicios por los daños a las personas afectadas.
 - La ley en Chile, ha ido flexibilizando todo este tema. Pero, todavía no se alcanza el desarrollo que ha tenido en otros países (en dº privado de la competencia).
 - Por ejemplo, en Europa, USA, Japón, etc. los afectados -por PR- pueden recurrir a los tribunales de justicia desde el día 1. Esto implica que los tribunales de justicia deben saber materias de competencia. De esta manera, la jurisprudencia en materia de LC va saliendo prácticamente de cualquier tribunal, pero, en término de **daños**. Vale decir, lo que analiza el juez NO es la PR, sino el daño causado.
 - En cambio, en Chile, un juez civil o juez de la Corte de Apelaciones no tiene por qué saber materias de competencia ya que nunca le va a llegar un caso sobre estas materias. Solamente los ministros de la CS deben saber para efectos de la reclamación.
 - ❖ Caso papel tissue: en este caso, hubo demanda paralela por indemnización por perjuicios, pero, se hizo por otra vía: por una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. La demanda por daños a los consumidores fue colectiva y el resultado de ésta fue la entrega de los 7.000 pesos.
 - Probar los daños no es nada de fácil.
 - ❖ Caso farmacias: una cadena de farmacias indemnizó (poco, pero lo hizo). Ahí, los afectados estaban más claros, eran los consumidores de esos 200 y tantos medicamentos durante un período de 7 meses. En cambio, en el caso del papel éramos todos los consumidores de papel durante todo el período de tiempo. Esta situación fue mucho menos grave que la del papel tissue.
 - ❖ Caso pollos: el tema es muy complicado. Se alega que había un precio mínimo obligatorio para los pollos en el acuerdo entre los supermercados y sus proveedores. Calcular el daño de esto, es muy difícil.
 - La indemnización de perjuicios se hace por otra vía.
 - ❖ Caso LAN-DAP: la aerolínea de Punta Arenas (DAP) luego de ganar en materia de competencia, demanda por indemnización de perjuicios a LAN con montos muy grandes. Dicen que ese es el daño cometido por haberla querido sacar de la competencia mediante un descuento espectacular en los vuelos de LAN de Santiago-Punta Arenas y Punta Arenas-Santiago.
- ¿Por qué se paga la multa al fisco si el que sufrió el daño fue el afectado? Por el OPE, ya que, en definitiva, se está violentando todo el sistema.
 - ✓ Caso vitaminas: este mercado está totalmente coludido a nivel mundial.
 - ✓ Caso refrigeradores: un acuerdo entre una empresa norteamericana y brasileña en Brasil afectaba el precio de los refrigerados en Chile. Este caso fue fallado en Chile por más de que la colusión se produjo en Brasil, ya que los

efectos se generaron en Chile, por lo que sí se puede sancionar en el país.

- A *beneficio fiscal* se refiere que son ingresos para el Fisco, pero éste no ha sido un ingreso muy relevante para el fisco. En cambio, para el sancionado puede ser un monto significativo, y, especialmente si el sancionado, además de la persona jurídica (generalmente es el 1º sancionado) es una persona natural.
 - ✓ En el caso de las sanciones de valores, la SVS/CMF (actual) ha pedido el máximo de la sanción, y cuando el asunto llega al TC resuelven que la sanción a la persona natural es injusta y desproporcionada.
 - ✓ Por lo tanto, se debe distinguir entre sanciones a personas naturales y jurídicas.
- Durante mucho tiempo, la ley contemplaba multas con unos máximos (20.000 unidad tributaria anual, 30.000 UTA, etc.).
- *Unidad tributaria anual (UTA)=las UTMx12. Las multas eran cantidades enormes.
- En una de las últimas modificaciones de la ley, nos pasamos a otro sistema de multa. Las multas podrán ser:
 - i. ⁹Hasta una suma equivalente al **30% de las ventas** correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el **periodo** por el cual se haya extendido la infracción.
 - Acá empiezan los problemas, porque las empresas ofrecen varios tipos de productos. Pero, se debe identificar cuáles son los productos o servicios vendidos que contienen la infracción. Esto es bastante difícil.
 - Además, se debe identificar por cuánto tiempo se llevó a cabo esta práctica.
 - ii. ¹⁰Hasta el **doble del beneficio económico** obtenido por el infractor.
 - Beneficio= Ingresos (PxQ)-Costos
 - De todas formas, se sigue con problemas. Es muy difícil determinar cuál es el beneficio económico del infractor.
 - Además, se debe identificar por cuánto tiempo se llevó a cabo esta práctica.
 - Para el cálculo del beneficio, se considera los cambios en la inflación, de las divisas, etc. Esto en Chile, es bastante fácil. Se aplica el IPC inicial y final y se obtiene el factor de ponderación que se le debe dar a las cantidades que ahí aparecen.
 - Entonces, la ley le da al TDLC la capacidad de elegir entre estos 2 montos.
 - Acá, empieza un **análisis económico muy complejo**: debe analizar cuál fue el impacto económico de la PR. Además, se debe analizar cuánto tiempo duró esa PR. El daño a ese mercado en específico va a depender de la duración de la PR.
 - Caso supermercados: es muy difícil determinar el impacto económico de no poder cobrar bajos mínimos, es decir, de no hacer liquidaciones por parte de los supermercados. En este caso, la PR duró 3 años (en los pollos dura más de 10 años, en las farmacias dura 7 meses).
 - Este análisis es muy complejo, pero es fundamental para determinar el monto de la multa. El criterio anterior decía que el TDLC y la CS podían

imponer cualquier monto hasta un máximo. Esto tenía ciertos criterios, pero eran muy generales.

- iii. ¹¹Si el TDLC no logra determinar las ventas ni el beneficio económico, podrá aplicar multas hasta por una suma de **60 mil UTA** que son 34.776.000.000 pesos aprox (UTM calculada a 48.300).

→ Este máximo fue utilizado antes de la modificación actual de la norma. Hubo distintos máximos según las distintas modificaciones de la ley.

→ *Romero* hace un estudio en el que analiza las sanciones a través del tiempo. Su conclusión –compartida por *Yrarrázaval*– es de que los montos de las sanciones por multas eran relativamente bajos.

¿Por qué el TDLC no aplicó multas más altas?

Había una tendencia de la FNE de pedir prácticamente en todas las causas el máximo de la multa. *Yrarrázaval* no comparte este comportamiento de la FNE, de hecho, para su juicio es malo ya que no le da ningún criterio al TDLC. La FNE debería hacer una ponderación de la gravedad, y, no colocar en el mismo saco colusiones, competencias desleales, precios predatorios, etc. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que hacía el TDLC era rebajar la cantidad pedida por la FNE. Si la CS llegaba a revisar el caso, también bajaba los montos porque los seguía considerando altos. El TDLC le bajaba la multa a casi a la $\frac{1}{2}$, y posteriormente la CS le rebajaba a la $\frac{1}{2}$ del nuevo monto.

Yrarrázaval considera que no se empezó a analizar más a fondo que todos los casos son distintos y que el monto de la multa importa ya que da una señal de qué es lo más relevante, qué es lo que afecta más y menos a la competencia, etc.

→ Hay varios casos de infracciones a la propiedad industrial o intelectual. La gran mayoría de estos casos, tiene sanciones muy bajas o no tienen, porque hay una ley especial de propiedad industrial intelectual, por lo que, si hay una defraudación, mal uso de una marca ajena, etc. se debe recurrir a su tribunal especial con su procedimiento especial NO al TDLC ya que no afecta sustancialmente a la competencia.

- ¹²Se puede demandar tanto a la **persona jurídica** como a la **persona natural**, no son excluyentes. El TDLC podrá aplicar las multas a personas naturales, pero no el delito penal monopólico, que será aplicado por los tribunales penales. En la gran mayoría de los casos, se ha sancionado a la persona jurídica y NO a las personas naturales.

✓ *Romero* hace una crítica a la falta de sanciones a personas naturales. *Yrarrázaval* no está para nada de acuerdo con esta crítica.

✓ **¿Cuándo el TDLC puede sancionar a una persona natural?**

Cuando tenga **pruebas fehacientes** de que esa persona natural intervino efectivamente en el caso. En materia de competencia, es muy difícil probar esta intervención. Incluso, se ha demostrado en los grandes casos de colusión, que éstos no fueron analizados ni siquiera por el directorio, por lo que no se encuentran en las *actas del directorio*.

→ La responsabilidad principal de los directores proviene de su actuación en

una sala legalmente constituida denominada *directorio*.

→ Si se trata la PR y cierto director se opone, queda establecido en el acta de directorio y éste se exime de responsabilidad por ésta. Si no está en el acta, es igualmente responsable.

→ Caso colusión de las farmacias: es uno de los casos en donde se sanciona a personas naturales, hay responsabilidad personal. Acá, la demanda personal la hizo el Ministerio Público ante la Justicia del Crimen (Tribunales Penales) mediante una norma del Código Penal. Los 12 ejecutivos de farmacias y laboratorios salieron libres (con clases de ética), porque, a pesar de que el tribunal lo tomó con la mayor seriedad, no pudo llegar a la conclusión de que estas personas habían infringido tal norma de manipulación de precios. La tipificación de los delitos se hace con muchos detalles ya que debe ser lo más clara posible. En este caso, la demanda personal es penal.

→ Hay pugnas entre la FNE y la Fiscalía del Ministerio Público con estas demandas penales. La Fiscalía del Ministerio Público dice que le estarían quitando jurisdicción, pero los asuntos son económicos, por lo que los únicos que deberían ejercer la acción penal en el caso de las colusiones, debería ser la FNE. Como no se puede sancionar 2 veces por lo mismo, se lleva a cabo el proceso penal por el que demandó primero.

- ¹³Si a una persona natural le aplicaran incluso la vigésima parte de la multa, ésta desaparece, es incapaz de pagarla. Y, más encima, posteriormente la ley menciona que, si la sanción es a una persona natural, **no puede ser pagada por NADIE más**, solamente puede salir del bolsillo de la persona natural sancionada.
- ¹⁴Se refiere a los factores que debe tomar en consideración el TDLC para la determinación de las multas. Esta enumeración ha ido aumentando a través del tiempo. Son 6 factores bien relevantes para la determinación de la multa:
 1. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción
 2. La gravedad de la conducta
 3. El efecto disuasivo (de la multa)
 4. La calidad de reincidente
 5. La capacidad económica del infractor
 6. La colaboración que éste haya prestado a la FNE antes o durante la investigación
- ✓ Por cierto, no siempre influyen todos estos factores, pero la suma de éstos conduce indiscutiblemente a la aplicación del máximo de la multa.
- ✓ Desgraciadamente, la FNE -a pesar de que es un criterio para el TDLC- no ha considerado los factores cuando pide las sanciones, y, generalmente termina pidiendo el máximo. Intentan maximizar los casos. Además, se excusan diciendo de que como el TDLC siempre baja las multas, van a pedir el máximo para que la sanción no sea tan pequeña. Esto no es muy bueno según *Yrarrázaval*.
- ✓ A través de estos criterios, el TDLC baja las multas.

○ **Letra d)**

- ¹⁵Esta sanción se da para las conductas del art 3 letra a), que se refieren a las **colusiones**.
- ¹⁶**La sanción es la prohibición de contratar con órganos de la administración del Eº.** Esta prohibición sería por 5 años desde la ejecución de la sentencia definitiva.
- Esta sanción no le convence mucho a *Yrarrázaval*, no le parece muy lógica ni razonable esta sanción. Porque para algunos sancionados no tendrá ninguna relevancia ya que no contratan con el Eº o lo contratan de forma muy de vez en cuando; pero, hay otras empresas que están permanentemente contratando con el Eº, por lo que, si se les sanciona de esta manera, puede ser una sentencia de muerte para la empresa. Ésta se debe declarar en reorganización/reutilización.
- *Yrarrázaval* considera o tiene dudas -en los pocos casos en que se ha aplicado esta sanción- de si se están cometiendo graves injusticias.
 - ✓ En dº laboral, se ve algo similar. Cualquier práctica antisindical resuelta por los tribunales implica una prohibición de contratar con el Eº.
→ Caso PUC: la Universidad Católica tiene esta prohibición (algunos creen que la práctica antisindical fue inventada) por lo que no recibe recursos del Eº.

○ **Letra e)**

- ¹⁷Se refiere a las **multas a beneficio fiscal por el retardo en el pago de las multas en el caso de concentraciones**.
- Esta multa es enorme: **20.000 UTA por cada día de retardo** contado desde el perfeccionamiento de la operación de concentración.

○ *El caso del pago de los 7.000 por la colusión del confort se da por una sanción del dº del consumidor, no del dº de competencia.

○ ¹⁸Hay otra sanción que NO está incluida en el art 26: **SANCIÓN PENAL**. Para estos efectos, la ley incorporó un capítulo especial para la sanción penal (título V), en el cual se desarrolla todo este tema.

- La sanción penal procede solamente con respecto a las **colusiones**. Procede cuando el TDLC haya fallado el tema, y, en ese momento, el TDLC le puede solicitar a la FNE que inicie la acción penal en los tribunales ordinarios del crimen.
- Obviamente, esa sanción penal viene después de terminado el caso. Antes, se realizaba frente a los tribunales ordinarios, en cambio, ahora se necesita que el TDLC le dé la autorización a la FNE para que inicie la acción penal.
- Delitos penales de materias de LC:
 - ✓ Hemos tenido esta legislación de delitos del año 73` al 2003, pero hubo 0 casos. Hubo unos pocos casos (4-5) en donde el TDLC cita al FNE para que iniciara la acción penal, pero el fiscal fracasó en los tribunales ordinarios del crimen porque el tipo penal es mucho más exigente que el tipo monopólico por la gravedad del asunto. La diferencia se plantea en **dolo penal**, es decir, para poder sancionar en materia penal debe existir *dolo penal* que se refiere a la *intención positiva de incurrir en el tipo penal*. Por eso, existe una gran variedad de eximentes penales, atenuantes penales y agravantes penales. El

mismo tipo penal va a ser revisado según la intención que tuvo el sujeto.

- ✓ Las categorías penales son distintas a las monopólicas. Por lo tanto, el fallo del TDLC y la CS no van a responsabilidad penal, van a responsabilidad en materia de LC.
- ✓ Entre 2003 y 2016, no hubo sanción penal para estos delitos.
- ✓ En el 2016 se vuelve a reincorporar la sanción penal. Desde 2016 hasta la actualidad, no se ha pedido ni aplicado la sanción penal porque las exigencias que tiene la sanción penal son altísimas.
- ✓ La sanción penal es muy relevante en cuanto a la intimidad de las personas. Se plantea para los casos de **colusión**.

2 de abril

- El art 26 contempla las sanciones que puede imponer el TDLC. Estas son:
 - 1. Modificación o término de actos o contratos** (muy importante)
 - 2. Disolución o modificación de personas jurídicas de dº privado**
 - 3. Multas**
 - 4. Prohibición de contratación con el Eº**
 - 5. Multa por retardo en el pago de multas**
 - 6. *Sanción penal** (no incluida en el art 26)

○ **Art 3**

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3- *El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso.*

Se considerarán, entre otros¹, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos², los siguientes:

a) Los acuerdos o prácticas concertadas³ que involucren a competidores entre sí⁴, y que consistan en⁵ fijar precios de venta o de compra⁶, limitar la producción⁷, asignarse zonas o cuotas de mercado⁸ o afectar el resultado de procesos de licitación⁹, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.¹⁰

b) La explotación abusiva¹¹ por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos¹², de una posición dominante en el mercado¹³, fijando precios de compra o de venta¹⁴, imponiendo a una venta la de otro producto¹⁵, asignando zonas o cuotas de mercado¹⁶ o imponiendo a otros abusos semejantes.¹⁷

c) Las prácticas predatorias¹⁸, o de competencia desleal¹⁹, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.²⁰

d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí²¹, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil unidades de fomento en el último año calendario. Con todo, sólo se materializará esta infracción si transcurridos noventa días corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido umbral, se mantuviere la participación simultánea en tales cargos.

○ **Art 3 inc 1:** explicado en las p. 35-39

○ **Art 3 inc 2:** se da una tipificación a título ejemplar. Se incluyen 4 situaciones distintas (a-b-c-d).

- ¹Entre otros, hace referencia a que es a título ejemplar.
- ²Repite la frase del inciso 1. Esta frase es muy amplia. Esta amplitud se da como tendencia en prácticamente todas las legislaciones del mundo.
- ¿Para qué existen estos ejemplos si perfectamente se podría quedado con el inc 1 solamente? Los ejemplos tienen un efecto didáctico.
- La jurisprudencia ha ido elaborando sobre cada uno de estos ejemplos/conceptos. Las PR no son definidas por la ley, sino que por la jurisprudencia.
- En la ley se enumeran las PR, pero sin una descripción de la PR, salvo en el caso de la colusión. Por eso, cada palabra de la letra a) es relevante.

○ **Letra a)**

- Habla sobre la **colusión**. Es la única PR descrita detalladamente por la ley.
- ³Debe haber 2 o más empresas, ya que no existen acuerdos o prácticas concertadas de una sola empresa.
- ⁴Se habla sobre acuerdos entre empresas que involucren a competidores entre sí, acá, se está refiriendo a los mercados involucrados, el famoso **mercado relevante**.

Esto, no está definido por la ley, sino que por la FNE y por la jurisprudencia. Así, uno se da cuenta que la **jurisprudencia nos está aportando una infinidad de elementos fundamentales para entender la ley.**

- ⁵ Los acuerdos o prácticas concertadas que afecten a un mercado relevante deben consistir en:
 1. ⁶ **Fijar precios de venta o de compra.**
 - ❖ Esto es uno de los casos más clásicos de colusión, es decir, las fijaciones de precios entre las empresas competidoras.
 2. ⁷ **Limitar la producción.**
 - ❖ Para así, mantener los precios lo más alto posible entre las empresas concertadas.
 3. ⁸ **Asignarse zonas o cuotas de mercado.**
 - ❖ Ha habido varios casos sobre esto, especialmente antes de la conformación del TDLC, es decir, del periodo del 73` al 2003 hubo muchos casos de asignaciones de zonas o cuotas.
 - ❖ Esto consiste en que las *empresas competidoras se distribuyen los mercados para no competir.*
 - ❖ Caso Coca-Cola: asigna embotelladoras en todo el territorio.
 4. ⁹ **Afectar el resultado de procesos de licitación**
 - ❖ Por tanto, serían procesos de licitaciones *falsos* ya que las empresas *antes del proceso se estarían poniendo de acuerdo para tratar de cobrarle al Eº lo más posible*, especialmente a través del MOP (Ministerio de Obras Públicas).
 - ❖ Caso asfalto: empresas productoras de asfalto tenían toda una concertación (colusión entre ellas) para presentarse ante las distintas licitaciones del MOP. Esto tenía 2 fines:
 - a) no competir entre ellas
 - b) que el precio fuese lo más alto posible
 - ❖ Caso licitación de ambulancias: misma cuestión que en el asfalto.
 5. ¹⁰ **Acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores.**
 - ❖ La condición de: *conferirle poder de mercado a los competidores* debe cumplirse para determinar que es una colusión.
 - ❖ Si no se cumple la condición, no es colusión.
 - ❖ El concepto de *poder de mercado* no es definido por la ley, sino que es definido por la jurisprudencia y fiscalía.
- La FNE ha ido emitiendo **instrucciones** a través del tiempo.
 - ✓ Ya va como en la instrucción nº15.
 - ✓ Son largas y complejas.
 - ✓ Sirven de guía, NO son obligatorias. Para que fuesen obligatoria, la FNE tendría que tener una facultad normativa.
 - *El SERNAC pidió tener facultades normativas y el TC le dijo que no porque no tenía las condiciones necesarias para poseer la facultad normativa.

- Algunos han dicho que dentro de la letra a), hay **colusiones duras y blandas**.
 - ✓ Las **colusiones duras** estarían dentro de las primeras 5 líneas hasta la palabra “licitación”. Es decir, los acuerdos o prácticas concertadas deben consistir en el numeral 1-2-3-4 mencionados anteriormente.
 - ✓ Las **colusiones blandas** estarían desde la palabra “así” en adelante. Es decir, los acuerdos o prácticas que consistan en el numeral 5.
 - ✓ La ley NO hace esta distinción de tipos de colusiones, solo habla de colusión.
 - ✓ La historia fidedigna de la modificación de esta norma nos muestra que en el año 2016 se incorpora la parte final que correspondería a las “colusiones blandas”.
 - ✓ Entonces, los que afirman la distinción dicen que las colusiones hasta el 2016 eran sólo duras (porque solo incluía la primera parte de la letra a)).
 - ✓ Como consecuencia, el standard probatorio de la colusión dura es totalmente distinto al de la colusión blanda.
 - La colusión blanda tiene un standard probatorio superior.
 - La colusión dura es una colusión *per se* (por sí misma), por lo tanto, la FNE no tiene que demostrar mayormente, sino la existencia de la colusión y de los elementos que la CS ha determinado al respecto.
 - La colusión blanda no es *per se*, y, por lo tanto, la práctica se determina como restrictiva razonablemente por la jurisprudencia. Acá el standard probatorio es muy alto.
 - Esta distinción viene del *dº* anglosajón: las prácticas *per se* y *no per se*.
 - Las prácticas *per se* han ido desapareciendo, y algunos (Yrarrázaval no quiere) las están haciendo resucitar diciendo que si se determina que se incurre en una práctica mencionada en las primeras 5 líneas (del numeral 1 al 4), la FNE no tendría que probar prácticamente casi nada: solo que existió la colusión, sin tener que entrar en análisis económicos, jurídicos, etc.
 - Caso supermercados: esto es importante, porque ya se está viendo en el caso de los supermercados. El probatorio por parte de la FNE fue bastante pobre a juicio de Yrarrázaval. La CS le va a decir a la FNE “usted creyó que estaba ante colusión enorme y no la está”.
 - La colusión existía, pero por un periodo de 7 meses y se refería al precio mínimo de los pollos (ninguna de las 3 empresas podía comprar de los distintos proveedores a un precio menor al mínimo, con el efecto que hubiese liquidaciones del pollo).
 - ¿Qué efecto económico tenía la colusión de los supermercados? Muy pocos. Y, por lo tanto, los supermercados plantean que de acuerdo a una regla de razonabilidad -que ha regido en Chile siempre- es decir, de un análisis de fondo económico y jurídico, no daba ni para las sanciones aplicadas por el TDLC ni para los argumentos dados por el TDLC. Se estima que ésta fue una de las sanciones más débiles dictadas por el TDLC.

→ Es muy difícil que toda esta argumentación sea pública, por lo que se ha dado una gran discusión pública sobre este tema.

→ Este tema no es menor ya que si se aplicara la regla *per se* no se consideraría esta práctica como colusión, pero a lo mejor si para el caso de las farmacias.

- ✓ Este tema tampoco deja ser menor en el caso de que no haya delación compensada. La institución de la delación compensada, existe para las **colusiones** y NO para las otras prácticas. Las delaciones compensadas indiscutiblemente le entregan a la FNE una cantidad de información espectacular. La FNE le puede exigir **toda** la información que quiera al confesor, y, si no la obtiene, se puede quitar la delación compensada (especie de “amenaza” para que entreguen la información).
- ✓ *Yrarrázaval* considera que el **standard probatorio de la colusión debe ser alto** por las sanciones que implica y por la gravedad que tiene. De hecho, la CS chilena ha afirmado varias veces que la colusión es la práctica más dañina por lejos que puede existir en materia de competencia porque son competidores que se ponen de acuerdo, generalmente en el precio, o de otros factores que quedan mencionados en la ley.
- ✓ Y, por cierto, en la ley no hay estándares probatorios distintos, es decir, no se distingue el standard probatorio para colusiones duras y para colusiones blandas.

○ **Letra b)**

- La letra b) es para los **abusos de posición dominante**.
- Es una de las más complejas, ya que se debe analizar el mercado y si esa conducta es razonable o no desde el punto de vista de la LC.
- ¹¹El abuso (en la explotación abusiva) también es determinado por el TDLC.
- ¹²La explotación abusiva puede ser unilateral, bilateral o multilateral.
- ¹³Debe ser una explotación abusiva de empresa(s) con posición(es) dominante(s) en el mercado. Generalmente son más actuaciones de más de una empresa.
- La definición de *posición dominante en el mercado* NO se da en la ley, sino que en la jurisprudencia.
- ¿Por qué se exige la explotación abusiva por parte de empresas que tenga una posición dominante en el mercado?
Se exige la **posición dominante en el mercado** para poder ser sancionado. Este es el punto de partida para la mayoría de las prácticas que se señalan abajo. Si no tienen posición dominante en el mercado, no se pueden sancionar las prácticas, y, de hecho, se han rechazado requerimientos o demandas por este motivo. Estas exigencias se dan en varias prácticas como precios predatorios, competencia desleal, etc.
- Si la empresa no tiene una posición dominante en el mercado y hace precios predatorios, le va a ir pésimo. Por lo tanto, es razonable que se sancionen a las empresas con posición dominante en el mercado que hagan una explotación abusiva de su posición.

- La posición dominante en el mercado se determina por el **análisis que hace la FNE sobre el mercado en cuestión.**
- Cuando se demanda, por esta explotación abusiva de la posición, se tiene como exigencia de la demanda describir el mercado que ocupa y los argumentos económicos y jurídicos utilizados.
- No hay reglas para determinar el mercado que ocupa una empresa, ya que depende del tipo de bien.
 - La posición dominante NO significa tener más de un 50% del mercado necesariamente.
 - La posición dominante implica tener una posición en el mercado que le permita hacer una PR real y efectiva (ej: precios predatorios, competencia desleal, etc.).
- Muchas de las sentencias del TDLC son interesantes en sus resultados porque no se sancionan porque el impacto en el mercado no fue mayor, es decir, no se podía sancionar porque no existía una real posición dominante en el mercado.
 - En estos casos, generalmente no se le cobran las costas.
 - Si se le cargan las costas a una empresa es porque no tuvo ningún motivo razonable para mitigar o porque está perdiendo en un 100% del juicio.
- La explotación abusiva (con posición dominante en el mercado) se da en los siguientes casos:
 1. ¹⁴**Fijando precios de compra o venta.**
 - ❖ Está repetido en la letra a) del art 3 que habla sobre las colusiones.
 2. ¹⁵**Imponiendo a una venta la de otro producto.**
 - ❖ Imponer a una venta la de otro producto se denomina **venta atada**.
 - ❖ Esto uno lo ve permanentemente, en donde te venden un pack de productos y no se pueden comprar los productos por separado.
 - ❖ Puede ser realizada por las empresas con posiciones dominantes y ésta estará abusando de su posición dominante.
 - ❖ En el caso de la *venta atada*, el TDLC dice que, *si los mismos productos se venden por separado, no importa*. Esto es lógico. Vale decir, cuando me obligan a comprar una serie de productos que yo no deseo porque la única forma de acceder al producto que quiero se encuentra en venta atada, se da una PR. Entonces, si se venden los mismos productos de forma separada, NO se da PR.
 - ❖ Generalmente, los productos vendidos en forma separada serán más caros porque en la *venta atada* se está haciendo una promoción.
 - ❖ Prohibir todas las *ventas atadas* sería absurdo. Pero éstas no pueden provenir de una explotación abusiva por parte de empresas con posiciones dominantes en los mercados. Ej: en cualquier establecimiento comercial existen *ventas atadas*.
 3. ¹⁶**Asignando zonas o cuotas de mercado**
 - ❖ Se repite en la letra a).
 4. ¹⁷**Imponiendo a otros abusos semejantes.**
 - ❖ Yrarrázaval dice *"es como si al legislador se le acaba la ocurrencia de otras prácticas"*.

○ **Letra c)**

- Se refiere a las **prácticas predatorias y competencia desleal**.
- ²⁰ Hay una **condición común** para las prácticas predatorias y competencia desleal: se deben realizar con el **objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante**.

1. ¹⁸Prácticas predatorias

- ❖ Las prácticas predatorias se refieren a los casos en que una empresa baja sus precios por debajo del **costo medio/costos inevitables** con el fin de eliminar a la competencia. *El TDLC empieza a denominar *costos inevitables* haciendo referencia a los *costos medios*.
- ❖ Caso LAN VS DAP:
 - Esta práctica consistió en que LAN (antes de la libertad de tarifas que existe hoy día) decidió disminuir los precios de los vuelos entre Santiago y Punta Arenas para liquidar a DAP (esto se supo después de la prueba).
 - DAP demandó a LAN alegando precios predatorios (había descuentos de 50% que en ese entonces eran altísimos).
 - Al mantener estos descuentos por un periodo de tiempo, se liquidaría a DAP.
 - La demanda dio resultados favorables para DAP ya que varios funcionarios de LAN confesaron (los análisis de costos los conocen generalmente pocas personas).
 - La sanción a LAN fue bastante alta.
 - La sanción fue a beneficio fiscal -como lo establece la ley- y DAP recibió dinero mediante el sistema de **indemnización de perjuicios** que es un sistema paralelo al de la LDLC, pues se demanda en tribunales ordinarios por el **daño**, NO por la práctica predatoria (esto ya fue sancionado por el tribunal competente que en este caso es el TDLC).
 - Por lo tanto, el juez civil que analiza este tema, NO puede analizar el expediente, sino que toma datos de cuánto ascenderían los daños de una empresa por este efecto.
 - DAP también le gana a LAN en los tribunales ordinarios.
 - NO se está castigando 2 veces la misma causa, en una se sanciona por la falta de la competencia (con multa fiscal), y en la otra, por los daños incurridos a la empresa perjudicada (indemnización de perjuicios).
 - Hay países en donde los particulares pueden demandar perjuicios en materia de competencia desde el día 1, entonces, se está demandando paralelamente por el daño de LC ante la justicia ordinaria y por la PR ante tribunales especiales (como el TDLC).
- ❖ El gran problema de los precios predatorios es la **prueba**. Se debe probar que la empresa bajó sus precios por debajo del **costo medio/costos inevitables** con el fin de eliminar a la competencia.
- ❖ Estas no son liquidaciones ni rebajas para vender más, sino que tienen el fin de **eliminar a la competencia**.

- ❖ Se debe probar que la finalidad de la empresa -al bajar los precios por debajo del costo medio- es para eliminar la competencia. Ciertamente, no se sancionaría a una empresa que está pésimo y que la única manera de salir adelante es incurriendo en precios predatorios.
- ❖ Implícitamente se está afirmando en la ley que se debe hacer un análisis completo del caso de precios predatorios.

2. ¹⁹Competencia Desleal (CD)

- ❖ Son totalmente distintas a las prácticas/precios predatorios. Incluso, podrían estar en letras distintas.
- ❖ Hay toda una ley que habla sobre la CD.
- ❖ El problema aquí es que en la gran mayoría de los países –no en el nuestro- no se considera la CD como una PR, sino como una infracción a la LCD.
- ❖ España si la considera como práctica restrictiva de la competencia, y nosotros copiamos esto en nuestra legislación.
- ❖ *Yrarrázaval* considera que la CD NO es una PR, pero cuando exista una ley al respecto.
- ❖ La LCD es relativamente reciente en Chile.
- ❖ ¿Qué es la CD? Hay una infinidad de figuras de CD que vamos a estudiar en dicha ley (se encuentran tipificadas NO a título ejemplar), pero antes de esa numeración, la ley considera como CD ***lo que afecta a las buenas relaciones comerciales y especialmente a la buena fe.***
- ❖ Uno empieza a descubrir que es muy difícil que alguna de esas prácticas (de CD) se constituya como PR. De hecho, el profesor no conoce ninguna de las tipificadas que haya terminado como PR (ni antes de la ley, ni después de la ley).
- ❖ En definitiva, la LCD dice que entre los que compiten, estas prácticas tipificadas son indebidas, no son propias, no son éticas, van en contra de la buena fe en las prácticas comerciales. Es un concepto de estar **afectando a otras empresas competidoras, pero, en el buen nombre, en la reputación, etc. pero NO en los % con respecto de los mercados en los que operan.**
- ❖ Si eso fuese tan claro, ¿por qué hay varios casos de CD? Porque se sigue recurriendo al TDLC con respecto a la LDLC en vez de recurrir por la LCD. Esto se debe a que la LDLC establece **sanciones más duras**. Además, los casos de CD ni aparecen en la prensa, mientras que los de LC aparecen muchas veces en la prensa. Hay más distinciones, pero no las menciona.
- ❖ Si hubiese casos de CD que afectaran a la competencia, conviene llevarlo como una PR y no como CD.

○ Letra d)

- Este concepto de *participación simultánea* se utiliza en muchas partes del mundo y lo copiamos.

- Fue incorporado en el año 2016, y, según algunos es incomprensible porque es un tema de dº comercial NO de dº de la competencia. Y no ha habido ninguna modificación del dº comercial al respecto.
 - ²¹Habla sobre la **participación simultánea** de un ejecutivo o director de una empresa en relación a otra empresa, las cuales son competidoras.
 - El único pedazo de este inc que se relaciona con la competencia es la de participación simultánea (de ejecutivos o directores) en empresas competidoras.
- **Resumen art 3 inc 2:**
 - a) **Colusión**
 - b) **Explotación abusiva de la posición dominante**
 - c) **Prácticas predatorias y competencia desleal**
 - d) **Participación conjunta del ejecutivo o director en una empresa en relación a otra que son competidoras**
 - Uno podría llegar a la conclusión de que perfectamente la ley podría incluir sólo el inc 1 en el art 3 y no pasaría absolutamente nada. Muchas definiciones de conceptos de LC se dan en la jurisprudencia, además de que las letras del inc 2 son a título ejemplar.
 - **Art 3 bis**
 - Se incorpora a la ley en el año 2016.
 - *Yrarrázaval* considera que no está muy bien ubicado ahí porque establece sanciones para los casos de **concentraciones**, y hay un capítulo especial dedicado a las concentraciones más adelante (título IV).
 - En el art 3 bis se mencionan las prácticas de concentraciones que serán sancionadas por las sanciones establecidas en el art 26. (*No profundizamos en cuáles son estas prácticas sancionadas).
 - **Art 4:**

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4- No podrán otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos que impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades económicas, salvo que la ley lo autorice.

- *Cada palabra es muy importante.
- Este art ha ido cambiando a través del tiempo, pero lo fundamental es que la **ley es la única que puede autorizar concesiones, autorizaciones o actos que permitan conceder monopolios**.
- Los monopolios legales son consecuencia del art 4. En definitiva, es solamente la ley la que puede conceder un monopolio legal. En el caso chileno solamente a **empresas del Eº**, nunca hubo monopolios legales concedidos a privados.
- Todo el sistema de concesiones (con un desarrollo espectacular en Chile) está bajo esta norma.
- La ley de **concesiones** permite otorgar una concesión sujeta a determinados criterios (ej: licitación abierta y pública, etc.), incluso más, en el caso de las

concesiones de obras públicas la ley exige que haya un camino alternativo, esto muchas veces no se cumple, porque, además, es carísimo. La ruta alternativa va a ser del Eº. Se cumple más en las rutas hacia el sur que hacia el norte. El MOP muchas veces exige el camino alternativo para disminuir el poder de mercado de la concesionaria, esto debido a que los consumidores no pueden elegir otras alternativas o reclamar los precios.

- En las **autorizaciones** ocurre lo mismo.
 - ✓ Ej quiosco: requiere de autorización municipal. No se le puede estar dando un monopolio a ese quiosco.
 - ✓ Ej farmacia dentro de la posta: la autoridad puede dar autorizaciones, pero sin otorgar un poder monopólico, en otras palabras, no pueden durar por 30 años. Por 5-8 si se podría. Hay una limitación en el Código Sanitario, en donde las farmacias deben estar a x metros una de otra.
- A fin de cuentas, lo que se exige es que la autoridad al dar la concesión o autorización sea lo más razonable posible para no otorgar el poder monopólico al particular.

3 de abril

II. TÍTULO II: DEL TRIBUNAL DE LA LIBRE COMPETENCIA

- Desde el año 2003 está este título (con la reforma). A partir de mayo del 2004 se empiezan a dictar sentencias desde este tribunal.
- Este título recoge muchas ideas que ya estaban incluidas en nuestro sistema de LC.
- Una de las ideas más importantes que recoge este título es la de comisiones **preventivas y resolutivas**:
 - Antes del tribunal, existía 1 comisión resolutive y 13 preventivas porque había 13 regiones. Había 12 comisiones preventivas (a secas) y 1 que era la comisión preventiva central en la RM que tomaba las causas de la RM + las causas que abarcaban a más de una región.
 - Las comisiones preventivas tenían como función principal las **consultas**. Llegaron a tener del orden de 1500 dictámenes. El 90% de ellos eran de la comisión preventiva central y 10% de las otras comisiones preventivas.
 - Se puede notar un problema serio en un país como el nuestro. ¿Qué pasa en las regiones cuando no hay comisiones preventivas? Se hace muy complicado que desde las regiones se consulte. Hay una disposición que le da algunas facilidades para consultar desde las regiones, pero no ha sido muy buena. Esto genera una disminución de las consultas provenientes de las regiones.
 - El nº de consultas ante la comisión preventiva central también disminuyó considerablemente.
 - Por lo tanto, a pesar de que hoy en día se puede consultar (a partir del 73`, cuando se crea la LDLC), el nº de consultas ha disminuido considerablemente.
 - Otro factor importante que se agrega a la disminución de consultas (además de problema de regiones) es que la gran mayoría de las materias relevantes ya habían sido consultadas, y se cubre todo el espectro de PR.
 - La función consultiva de las comisiones preventivas tiene un valor muy grande hoy en día porque la gran mayoría de las materias ya están consultadas y resueltas.

- La composición de las comisiones preventivas fue cambiando a través del tiempo.
- Las comisiones preventivas **NUNCA fueron tribunales**. Algunos los denominaron órganos administrativos u otros nombres, pero nunca fue tribunal porque NO tenía facultades para resolver controversias.
- Las comisiones preventivas podían rechazar las consultas, pero no podía sancionarlas. Al rechazarlas, la consulta subía a la comisión resolutive que ésta sí era un tribunal (especial), y, por lo tanto, podía sancionar. Las sanciones eran bajas (así lo analiza *Romero*) aunque fueran temas controvertidos. Pero, indiscutiblemente no existieron ni uno de los grandes casos que se dan hoy en día.
- En materia de **concentraciones de empresas**, eran **voluntarias** las consultas de concentración. Pasan a ser **obligatorias** bajo el TDLC, y ni siquiera desde el comienzo de éste, sino que, en una de las últimas reformas de la ley.
- Hoy en día, no son obligatorias las consultas sobre todas las concentraciones de empresas, sino que las que están sobre una determinada cantidad determinada por la ley y por un decreto del Ministerio de Economía.
- Sobre concentraciones pequeñas, no es obligatorio consultar, pero, se gana **seguridad jurídica**. Siempre que hay fallos afirmativos en favor del consultante, no se puede cambiar ese criterio, salvo que, se declare otra sentencia que revierta lo anterior.
 - ✓ La demanda nueva debe hacerse invocando dicha sentencia anterior y los nuevos hechos o circunstancias que hacen que la respuesta a la situación anterior no sea adecuada para la situación actual.
 - ✓ No se puede entrar a reclamar porque simplemente no le gustó la resolución anterior.
- Si no consulta, celebra el contrato y después lo demandan, corre el riesgo de que le boten todo el esquema, anulando el contrato.
 - ✓ Caso Cláusula Radial (La Florida)
- Caso Parque Arauco: duda si debe consultar o no.
 - ✓ El esquema de un centro comercial es muy especial, en donde se dan muchos aspectos restrictivos a la competencia.
 - ✓ Ej: los dueños de los locales le deben entregar al dueño del centro comercial una parte de sus utilidades, y, además, el dueño determina qué tiendas se instalan y dónde.
 - ✓ El Parque Arauco argumentó que es un nuevo esquema y se debe entender como tal, las comisiones lo aprobaron. Ahí recién se empieza a invertir.
 - ✓ En cambio, Apumanque no consultó y ha tenido problemas inmensos por esas restricciones.
- Si las comisiones preventivas, absolvían las consultas, las comisiones resolutive hacían todo lo demás, que es mucho, porque indiscutiblemente la parte sancionatoria es muy relevante.
- Hoy en día, el TDLC absuelve consultas, aplica sanciones, dicta sentencias, dicta auto acordados, dicta instrucciones, etc. Vale decir, las facultades del TDLC que anteriormente tenía la comisión resolutive, son amplísimas.

- La composición de la comisión resolutive es el antecedente de la composición actual del TDLC, pero con algunas modificaciones relevantes:
 1. Sobre la **composición** de la comisión resolutive:
 - ❖ Había 3 abogados y 2 economistas, pero designados de forma muy distinta a la actual:
 - Era presidido por un ministro de la CS, a su vez, designado por la CS. El hecho que la presidiera un ministro de la CS fue fundamental porque estaba presente en el tribunal (de la comisión resolutive) la visión jurídica de fondo de quiénes después iban a tener que resolver en caso de que se reclamara. Siempre se ha podido reclamar, pero indiscutiblemente, cuando ese ministro de la CS no está, hay más posibilidades de que se produzca cambios muy importantes entre la resolución del tribunal y la de la CS.
 - Los otros 2 abogados y 2 economistas tenían un origen distinto:
 - 1 economista y 1 abogado eran designados por el Ministro de Hacienda y Economía.
 - El otro abogado y economista debían ser decanos de dº y economía de las universidades reconocidas.
 2. Sobre las **remuneraciones**:
 - ❖ Bajo el sistema anterior al 2003, los miembros de las comisiones preventivas y resolutive trabajaban *ad honorem*, es decir, sin ningún pago por ningún concepto.
 - ❖ En cambio, hoy en día, los miembros del TDLC tienen un pago que está descrito por la misma ley. Esta remuneración es igual a la del FNE. Indiscutiblemente, no parecía muy razonable que ciertas personas ejercieran sus funciones en las comisiones sin pago a pesar de toda la carga de trabajo que aumentando bastante.
- El aporte de las comisiones (preventivas y resolutivas) fue importante, y gran parte del éxito del TDLC (a juicio de *Yrarrázaval*) se debe a estas comisiones.

○ **Art 5**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5- *El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional¹ especial² e independiente³, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema⁴, cuya función será prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia⁵.*

- ¹Es un órgano **jurisdiccional** sujeto a la CS.
- ²Es un tribunal **especial** en 2 sentidos:
 - a) En cuanto a la materia, es específica. Un tribunal será denominado *especial* cuando esté abocado a una sola materia, en este caso a la LC.
 - b) En cuanto a su conformación, es un tribunal integrado por 2 economistas que no saben dº. Esta fórmula se aplica posteriormente a los tribunales medioambientales (abogados y especialistas en el tema).

- ³Es **independiente** en relación a todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
 - ✓ Uno podría decir que el Ejecutivo a través de la FNE (dependiente del Ministerio de Economía) puede ejercer presión sobre el TDLC. Esto NO ES CIERTO porque la FNE interviene en las causas del TDLC como **parte**, NO a través de informes o cosas por el estilo. La FNE interviene mediante los **requerimientos** que son demandas de la FNE.
 - ✓ Las demandas comunes al TDLC se denominan *demandas* a secas. Esta distinción se hace para diferenciar las demandas de la FNE de las de particulares.
 - ✓ Hoy en día, la independencia del TDLC respecto al poder judicial es **total salvo por el mecanismo de recurso de reclamación**.
 - ❖ Anteriormente, el presidente del TDLC era ministro de la CS por lo que claramente no era independiente.
 - ❖ Algunas personas ven la cantidad de revocaciones de sentencias del TDLC como una falta de independencia del TDLC. *Yrarrázaval* no lo ve así, piensa que, si uno va al fondo del asunto, él tiende a estar más de acuerdo con la CS que con el TDLC.
 - ❖ Caso gas: el TDLC falla 4-1 y la CS luego falla 0-5, estando todos de acuerdo con el ministro del TDLC que falló en contra. Esto sería un “supremazo”. Ese ministro había dicho que la prueba fue débil, y, por tanto, no podía fallar en favor de la colusión. La CS toma esto y afirma que la prueba si había sido débil, y, por tanto, revierte el fallo.
 - ❖ Además, siempre el superior jerárquico podrá decir algo distinto, y eso, no será quitarle independencia.
 - ❖ Sería peligrosísimo darle independencia total al TDLC, ya que se le estaría otorgando al TDLC la facultad de dar la opinión definitiva de casos muy delicados. Muchas de estas materias son muy discutibles, y el criterio para fallar puede cambiar.
 - ❖ *Yrarrázaval* es muy partidario de que el TDLC esté debajo de la CS.
 - ❖ Otros piensan que es ilógico porque la CS no sabe mucho de LC.
 - ❖ *La CS de USA falla del orden de 100 casos al año, mientras que la chilena del orden de 3000. Esa CS es muy selectiva y elige los casos que ella considera interesantes y relevantes.
- ⁴La CS tiene la superintendencia directiva, correccional y económica.
- ¿Cómo se ejerce esta superintendencia en otro tipo de tribunales? Hay varios mecanismos, y uno de ellos es a través del **recurso de queja**. Ante cualquier falta o abuso grave por parte de los ministros (del TDLC en este caso) o del juez en general, se puede llegar de queja a la CS. Primero se presenta a la Corte de Apelaciones, y luego se apela el resultado de esa queja a la CS. Así, la CS puede fallar ante la falta de un juez/ministro.
- Acá, NO hay recurso de queja. Sería una aberración. Se hace a través del **recurso de reclamación**, es el único recurso contemplado por la ley, y lo contempla muy bien a juicio de *Yrarrázaval*.

- ✓ Este recurso le permite a la CS ejercer la superintendencia que el art 5 le da de una forma especial: confirma o modifica las sanciones, y, no entra a calificar brutalmente si los ministros lo hicieron bien, regular o mal, es decir, confirma o cambia las sanciones sin entrar en mayor detalle.
- ✓ Si la CS revoca la sanción, debe dar sus razones de por qué está revocando, pero con respeto al TDLC que ha gastado meses analizando el expediente. Todo el análisis de la prueba lo hace el TDLC NO la CS.
- ✓ Al cambiar, puede aumentar o disminuir la sanción.
- ✓ Diferencia recurso de queja y de reclamación:
 - ❖ **De queja:** analiza si hubo por parte de los que decidieron, falta o abuso grave.
 - ❖ **De reclamación:** se produce porque simplemente -ya sea la FNE o una de las partes- no quedó satisfecho con el fallo del TDLC.
 - En un comienzo, se pensó limitar un poco la reclamación porque había demasiados casos que llegaban a la CS, y que estaban impidiendo el análisis de otros casos. *Yrarrázaval* no es para nada partidario de esta idea.
 - Incluso algunos pensaban que debía haber una consignación importante para llegar a la CS. *Yrarrázaval* tampoco es partidario de esta idea.
 - *Yrarrázaval* considera que estas prácticas son discutibles, y, por lo tanto, debe existir un recurso que permita apelar ante una insatisfacción de la sanción.
- ⁵La **función** del TDLC será prevenir, corregir y sancionar los atentados a la LC.

○ **Art 6: composición del TDLC**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 6- *El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estará integrado por las personas que se indican a continuación:*

a) Un abogado¹, que lo presidirá, designado por el Presidente de la República² de una nómina de cinco postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de antecedentes.³ Sólo podrán participar en el concurso quienes tengan una destacada actividad profesional o académica especializada en materias de libre competencia o en Derecho Comercial o Económico⁴, y acrediten a lo menos 10 años de ejercicio profesional.⁵

b) Cuatro profesionales universitarios expertos en materias de libre competencia, dos de los cuales deberán ser abogados y dos licenciados o con post grados en ciencias económicas.⁶ Dos integrantes, uno de cada área profesional, serán designados por el Consejo del Banco Central previo concurso público de antecedentes⁷. Los otros dos integrantes, también uno de cada área profesional, serán designados por el Presidente de la República, a partir de dos nóminas de tres postulantes, una para cada designación, confeccionadas por el Consejo del Banco Central, también mediante concurso público de antecedentes.⁸

El Tribunal tendrá dos suplentes, un abogado y un licenciado o con post grado en ciencias económicas.⁹

No podrá ser elegido como miembro titular o suplente del Tribunal, quien haya desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes convocado para el nombramiento respectivo.¹⁰

El Presidente de la República designará al abogado suplente y el Consejo del Banco Central al licenciado o post graduado en ciencias económicas, conforme al procedimiento señalado en la letra b) precedente, para lo cual se podrán considerar las mismas nóminas y concursos previstos para el nombramiento de los titulares.

Los concursos mencionados en las letras a) y b) precedentes deberán fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas, respectivamente, mediante un auto acordado de la Corte Suprema y un acuerdo del Consejo del Banco Central.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal, éste sesionará bajo la presidencia de uno de los restantes miembros titulares de acuerdo al orden de precedencia que se establezca, mediante auto acordado del Tribunal.

El nombramiento de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se hará efectivo por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

Los integrantes del Tribunal tendrán dedicación exclusiva en el desempeño de su cargo durante el período para el cual fueron nombrados. En consecuencia, no podrán prestar servicios de ningún tipo a personas naturales o jurídicas, o ejercer en cualquier forma aquellas actividades propias del título o calidad profesional que poseen.

Los ministros suplentes no tendrán dedicación exclusiva. Sin embargo, el desempeño de su cargo es incompatible con la condición de asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia a personas naturales o jurídicas sometidas a la jurisdicción del Tribunal. Se considerará que asesora o presta servicios profesionales si percibe cualquier clase de remuneración, honorario o regalía de parte de personas naturales o jurídicas que asesoran o prestan servicios profesionales en dichas materias.¹²

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el desempeño como integrante del Tribunal será compatible con los cargos docentes, hasta por doce horas semanales.¹³

○ **Letra a)**

▪ Se refiere al **presidente del TDLC**:

- ✓ ¹Debe ser un **abogado**.
- ✓ ²Designado por el **Presidente de la República**. NO pasa por el Congreso, al igual que el presidente del BC.
- ✓ Es el único ministro del TDLC que puede designar el Presidente de la República.
- ✓ ³El Presidente los designa de a partir de una nómina de **5 postulantes confeccionada por la CS** mediante concurso público, en otras palabras, la CS abre un concurso público para la designación del presidente del TDLC.
- ✓ Ese concurso público es cada vez más formal (*Yrarrázaval* afirma que esto es positivo). Normalmente se presentan como 30-35 candidatos y la CS debe confeccionar la quina. La CS ha propuesto a personas con curriculums muy distintos, desarrollos profesionales muy distintos, pero todos deben ser abogados para presentarse al concurso.
- ✓ La decisión por parte del Presidente de la República no es fácil ya que le llegan 5 concursantes con curriculums muy distintos.
- ✓ ⁴La CS califica quién tiene o no una *destacada actividad profesional o académica* que debe estar *especializada en materias de LC, D^o comercial o económico* (la académica).
- ✓ ⁵Debe tener a lo menos 10 años de ejercicios profesional.
- ✓ A juicio de *Yrarrázaval*, son todas condiciones **mínimas** que deben tener los concursantes. De hecho, algunos pueden considerar que 10 años de experiencia son pocos, pero si se aumenta, limita mucho a los concursantes.
- ✓ La ley pretende que haya una multiplicidad de concursantes. La CS, en definitiva, les toma un examen a estos concursantes.
- ✓ El BC designa de forma directa o indirecta a los otros 4 ministros del TDLC. Hace tiempo empiezan con los exámenes difíciles para los concursantes. Por ejemplo, les piden que den un juicio crítico sobre los casos más recientes. Incluso, han preguntado si han leído ciertos art de Inglaterra sobre la materia, etc.

○ **Letra b)**

▪ Se refiere al **resto de los ministros del TDLC**.

- ✓ ⁶Los otros 4 miembros deben ser **profesionales universitarios expertos en materias de LC**. Se dividen en: 2 abogados y 2 licenciados o con post grados en ciencias económicas.
- ✓ ¿Por qué se establece "*con post grados en ciencias económicas*" si estos los pueden tomar abogados, ingenieros, periodistas, etc. (Finalmente, se estaría abriendo la categoría)? Porque la ley quiere que se incorporen otros profesionales con post grados en ciencias económicas (ej: ingenieros civiles industriales). Aun así, la gran mayoría han sido economistas.

- ✓ ⁷1 abogado y 1 licenciado/post grados en ciencias económicas serán designados por el **Consejo del BC** previo concurso público de antecedentes. Se da una asignación directa del BC.
- ✓ ⁸El otro abogado y otro licenciado/post grados en ciencias económicas serán designados por el **Presidente de la República** a partir de 2 nóminas de 3 postulantes (terna) confeccionadas por el Consejo del BC mediante concurso público de antecedentes. Se da una asignación indirecta del BC. Este concurso es mucho más exigente que el de la CS.
- ⁹Habrán 2 ministros suplentes: 1 abogado y 1 licenciado/post grados en ciencias económicas. Así, se mantiene la misma estructura.
 - ✓ Los ministros suplentes pueden tener otros trabajos, pero, así como los ministros titulares tienen incompatibilidades, los suplentes también las tienen (son distintas). Se ha tratado de que las incompatibilidades para los titulares sean absolutas, pero que para los suplentes sean relativas. La razón es bastante práctica, ya que, si se aumentan las incompatibilidades para ministros suplentes, habrá muy pocos interesados, salvo que tengan en vista ser ministros titulares en un futuro. Es muy poco atractivo económicamente ser ministro suplente si hay muchas incompatibilidades.
 - ✓ Los suplentes están para los casos de enfermedad, inhabilidad, etc. No es muy corriente. De hecho, la gran mayoría de las sentencias llevan la firma de los 5 ministros **titulares**. Son muy pocos en los que entra un suplente. Esto se debe a que el ministro titular tiene interés de participar en todas las reuniones ya que su remuneración va a depender en parte de eso. Entonces, hay un incentivo de que el ministro titular participe del caso. Los suplentes tendrán una remuneración solamente en la medida que replacen a los titulares. Entonces, la ley contempla todo un **sistema de incentivos** para que la gran mayoría de las sentencias sean conocidas por los 5 ministros titulares.
- Luego, empiezan a aparecer algunas prohibiciones muy importantes:
 - 1. ¹⁰No puede ser elegido como miembro titular o suplente, quien haya desempeñado el cargo de **Fiscal Nacional Económico** o cualquier **cargo directivo en la FNE** en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes.
 - Esto se hace para mantener independencia entre la FNE y el TDLC.
 - Así, el TDLC no se contamina de las posiciones que tenga la FNE.
 - Esta prohibición ha sido progresiva en las distintas modificaciones de la ley.
 - En un comienzo, el personal de la FNE era también personal del TDLC. Ahora, se separaron.
 - El TDLC es integrado solo por 9 personas, *Yrarrázaval* dice que esto es lo *mínimo minimorum* de integración para un tribunal de esta categoría. Todo el resto del personal trabaja en la FNE.
 - *Yrarrázaval* considera que esta separación es positiva, ya que por más de que la FNE investiga y se conduzca a cierto resultado, puede darse que el TDLC tenga otro criterio.

2. *Hay varios incisos que no menciona porque se entienden con la simple lectura.
3. ¹¹Los ministros titulares tendrán **dedicación exclusiva** en el desempeño de su cargo.
4. ¹³Lo único que pueden hacer el ministro titular es **docencia** y siempre que **no sean más de 12 horas semanales que le dedique a la docencia**.
 - Esto fue agregado en la modificación del año 2016.
 - Antes del año 2016, a través de la dedicación exclusiva, los ministros no podían ejercer la profesión de economistas o abogados en materia de LC.
 - *Yrarrázaval* considera esto razonable ya que un ministro no puede estar ocupando sus conocimientos para los efectos de dar servicios en materia de LC.
 - Después, se empezó a plantear que no podía ejercer en la profesión de abogado o economista.
 - Y, en el 2016 se llega a la conclusión de que **no se puede ejercer ni en la profesión de abogado/ economista ni prestar servicios de ningún tipo**.
 - *Yrarrázaval* considera esto una exageración y que es malo para el sistema porque los candidatos van a ser cada vez menos.
 - *Yrarrázaval* cree que la dedicación exclusiva siempre debiese existir, pero elevar la categoría a absoluta significa que los ministros no puedan realizar ninguna actividad de ningún tipo; no solamente la de su profesión, sino que no pueden dar ningún servicio de ningún tipo. Entonces, la única remuneración de los ministros sería la contemplada en la ley.
 - Los ministros trabajan 3 días a la semana, ¿y qué harían los otros 2? Esto supone que los ministros tienen un trabajo enorme. En realidad, fallan del orden de 10 casos al año. Hay algunas bastante complicadas y otras bastante sencillas.
5. ¹²Los ministros suplentes **no tendrán dedicación exclusiva**. Pero, tiene incompatibilidades (las menciona solamente: asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la LC). Obviamente, estas incompatibilidades no son de la misma naturaleza que las del titular.

○ **Art 7**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7- *Antes de asumir sus funciones los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia prestarán juramento o promesa de guardar la Constitución y las leyes de la República, ante el Presidente del Tribunal, y actuará de ministro de fe el Secretario del Tribunal. A su vez, el Presidente lo hará ante el Ministro más antiguo, según el orden de sus nombramientos, y actuará de ministro de fe el Secretario del Tribunal. Finalmente, el Secretario y los relatores prestarán su juramento o promesa ante el Presidente.*¹

*Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia permanecerán seis años en sus cargos², pudiendo ser designados por sólo un período sucesivo, conforme al procedimiento señalado en el artículo anterior.*³

*No obstante, el Tribunal se renovará parcialmente cada dos años.*⁴

*El Tribunal tendrá el tratamiento de "Honorable", y cada uno de sus miembros, el de "Ministro".*⁵

- ¹**Inc 1:** es completamente protocolar (“prestar juramento o promesa”).

- **Inc 2:**
 - ²La duración de los integrantes del TDLC (titulares y suplentes) será de **6 años**.
 - ³Se pueden renovar por 6 años más solo por un periodo sucesivo. Si no es sucesivo, claramente puede ser reelecto.
 - A fin de cuentas, lo que quiere la ley es que los ministros duren 12 años en el ejercicio de sus cargos. El ministro que termina su periodo y quiera ser reelegido, debe presentarse como cualquier otro al concurso público, pero tiene una gran ventaja que es el conocimiento de todos los casos de los últimos 6 años.
 - Por lo tanto, por regla general, los ministros han durado 2 periodos sucesivos. Luego de estos 12 años, no se dedican más a materias de LC.
- **Inc 3:**
 - ⁴El tribunal se renovará parcialmente cada 2 años. *Yrarrázaval* dice que esto es inteligente a su juicio ya que así, se evita una renovación total. Este mecanismo también es utilizado por el Consejo del BC.
- **Inc 4:**
 - ⁵El trato de “honorable” -al TDLC- y “ministro” -a sus miembros- le asigna una categoría que según *Yrarrázaval* corresponde. La comisión resolutive no tenía este trato.

4 de abril

- El TDLC empezó a operar en el año 2004 con una ley modificatoria del 2003.
- El TDLC viene a remplazar a las comisiones preventivas y resolutive que funcionan desde el 73` al 2003.
- Una de las características en común de ambas comisiones era que trabajaban *ad honorem*, es decir, por el honor de ser miembro de tal comisión y, por lo tanto, sin remuneración alguna. En cambio, hoy en día, los miembros del TDLC si reciben remuneración.
- **Art 8: Santiago**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 8.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá su sede en Santiago.¹

- ¹El Tribunal tendrá sede en **Santiago**.
- Al eliminar las comisiones preventivas regionales, se centraliza el sistema. A *Yrarrázaval* no le gusta esto.
- Antes, había un escaso funcionamiento de las comisiones preventivas regionales: del orden de 1500 dictámenes de estas comisiones, 10% provenía de resoluciones de las regionales y 90% de la central. Esto nos muestra que nuestro país está demasiado centralizado y lo centralizamos aún más. Más adelante, hay una norma que facilita que se hagan demandas desde las regiones, pero ha funcionado muy poco, por lo que nota que el sistema está bastante centralizado.

○ **Art 9: Funcionamiento**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 9.- *El Tribunal funcionará en forma permanente¹ y fijará sus días y horarios de sesión². En todo caso, deberá sesionar en sala legalmente constituida³ para la resolución de las causas, como mínimo tres días a la semana.*

El quórum para sesionar será de a lo menos tres miembros, y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, dirimiendo el voto de quien presida en caso de empate. En lo demás se estará a lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título V del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto fuere aplicable.

- ¹El tribunal funcionará en forma **permanente**, es decir, durante todo el año. De hecho, ya no existe el feriado judicial en el mes de febrero.
- ²En la actualidad, sus días son lunes, martes y miércoles fundamentalmente.
- ³La **sala legalmente constituida** significa que *todos los ministros deben estar físicamente presentes*. NO hay sesiones por teléfono, por televisión, etc.
 - ✓ Este concepto es muy relevante en el Consejo del BC. En la ley del BC, queda expresado el concepto de *sala legalmente constituida*.
 - ✓ Esto es muy relevante, porque significa que debe haber una citación, actas de la sesión y debe quedar constancia de la votación de los ministros. Esto funciona igual en el BC. Por lo tanto, no hay resoluciones en la que se le saque la firma a un ministro, ya que todos deben estar presentes.
 - ✓ Si hay causa de inhabilidad, el ministro se inhabilita para conocer de la causa hasta el final de la causa, no se reincorpora para ver la causa. Entonces, los ministros inhabilitados no ven esta causa hasta su resolución (al igual que en los tribunales ordinarios). Sería absurdo, por ejemplo, que se inhabilitara a un ministro solo para los alegatos.
 - ✓ Si hay un ministro que no participa de la resolución por no estar presente, la resolución no tendrá la firma de éste en la sentencia, pero éste si habrá participado del resto del proceso resolutorio.

○ **Art 10: Remuneración ministros**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 10- *La remuneración¹ mensual de los integrantes titulares del Tribunal será la suma equivalente a la remuneración bruta mensualizada de carácter permanente del cargo de Fiscal Nacional Económico². Los integrantes suplentes, en su caso, recibirán mensualmente la suma de treinta unidades tributarias mensuales y, además, la suma de diez unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan en la que no concurra el titular correspondiente, con un máximo de sesenta unidades tributarias mensuales, cualquiera que sea el número de sesiones a las que hayan asistido.³*

En el caso de ausencia injustificada, calificada por la mayoría de los demás miembros del Tribunal, al ministro titular se le descontará un monto equivalente al 50% de lo que haya recibido el suplente que lo hubiera reemplazado.⁴

- ¹Remuneración es el concepto laboral NO sueldo.
- ²La remuneración de los ministros **titulares** será **igual a la del FNE**.

- ³Los **suplentes** recibirán una suma de 30 UTM + 10 UTM por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 60 UTM por sesiones (al final, puede ganar hasta 90 UTM al mes, pero esto sería un caso muy raro).
- El criterio de los suplentes es bastante distinto al de los titulares, y con bastante razón.
- En este tribunal, hay muy poca suplencia, es decir, en la gran mayoría de los casos concurren los 5 ministros titulares.
- Por la forma en la que está planteada la ley, cuando un ministro titular se inhabilita, no se descontaría a su remuneración el monto que deberá ser pagado al ministro suplente.
- ⁴La ausencia injustificada ocurre muy poco. Si hay ausencia injustificada, se le descontará un monto equivalente al 50% de lo que haya recibido el ministro suplente que lo reemplazó.
- Hoy en día, se está utilizando muchísimo a los ministros suplentes para tomar las larguísimas pruebas (muchos días). Lo único que se exige para tomar la prueba, es que sea ministro, no se indica en la ley si debe ser titular o suplente.

○ **Art 11: Inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades de los miembros del TDLC.**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 11- *Los miembros del Tribunal podrán perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o recusación declaradas, en virtud de las causales contempladas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.¹*

En todo caso, se presume de derecho² que el ministro titular o suplente, según corresponda, también estará inhabilitado cuando:
(...)

- ¹Los miembros del TDLC pueden perder su competencia para conocer determinados asuntos por implicancias o recusaciones declaradas en virtud de las normas del Código Orgánico de Tribunales (COT).
- En el COT hay un largo listado de posibles implicancias y recusaciones de los ministros (causales). Esta lista se detalla en el art 195 y 196 del COT, y, en esta ley se agregan algunas más.
- Una típica “titerillada” de última hora, es que los abogados inhabilitan a los ministros que no les gustan. Ahora, una vez que los abogados los inhabilitan, los mismos ministros deben declararse inhabilitados, porque se podrían estar alegando implicancias o recusaciones que realmente no existen en el caso.
- ²En el **inc 2** dice “*se presume de dº*”, esto significa que **no se admite prueba en contra**. Por lo tanto, si el ministro está en la situación de la letra a) o b) debe inhabilitarse si o si (sin pruebas). Se resumen el a) y b) en casos de parentesco y que haya prestado servicios a una de las partes.
- Las demás implicancias o recusaciones, que están incluidas en el COT si admiten prueba en contrario, en la cual el ministro puede argumentar que le están planteando la inhabilidad solo para que salga del caso, pero que no hay ninguna base.

- Ejemplo causal de implicancia: amistad entre el ministro y los abogados. El ministro debe decir que efectivamente lo conoce pero que la amistad no va a distorsionar el criterio en el fallo, en efecto, que el *recurso de recusación* es infundado. Incluso, si el ministro quiere ser más deferente podría decirle al resto de los ministros que juzguen ellos si creen que por esa consideración de amistad no debiese participar en el caso.
- Hay una serie de causales muy genéricas, y es en ellas donde se admite prueba en contrario. Están incluidas en el COT.
- El sistema de inhabilidades es fundamental para que el sistema sea **independiente**.
- Caso Corte de Rancagua: todos los ministros están acusados de tener ciertas relaciones con partes que intervinieron en ciertos casos.
- Después de la a) y b) dice cosas que no son relevantes para el estudio.

○ **Art 11 bis: Prohibiciones**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 11 bis- Sin perjuicio de lo establecido en los incisos octavo y noveno del artículo 6°, los integrantes titulares y suplentes del Tribunal no podrán ser administradores, gerentes o trabajadores dependientes, ni asesorar o prestar servicios profesionales, a personas naturales o jurídicas que hayan tenido la calidad de parte en alguna causa que conoció el respectivo ministro¹, por el plazo de un año contado desde que dicho ministro cesó en su cargo, salvo que la dictación de la sentencia sobre una causa que hubiera conocido el ministro se encontrare pendiente, en cuyo caso el término de un año se contará desde la notificación de la sentencia.
(...)

- ¹Los ministros titulares o suplentes no podrán ser administradores, gerentes o trabajadores dependientes, ni asesorar o prestar servicios profesionales a personas que hayan tenido la calidad de parte en alguna causa que conoció el respectivo ministro.
- Es una prohibición de que los ministros sigan desarrollando actividades profesionales, de asesoría, etc.
- Esto es para asegurar la **mayor probidad**.
- Hay un desarrollo bastante extenso de esto, pero no es importante para el estudio.

○ **Art 12: Causas de cesación de las funciones de los ministros**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 12- Los miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cesarán en sus funciones por las siguientes causas¹:

- a) Término del período legal de su designación²;**
- b) Renuncia voluntaria³;**
- c) Destitución por notable abandono de deberes⁴;**
- d) Incapacidad sobreviniente.⁵**

Se entiende por tal, aquélla que impide al integrante ejercer el cargo por un período de tres meses consecutivos o de seis meses en un año.⁶

- e) No cumplir lo dispuesto en los incisos octavo y noveno del artículo 6°.⁷**

Las medidas de las letras c), d) y e) precedentes se harán efectivas por la Corte Suprema, a petición del Presidente del Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema.⁸

La resolución que haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.⁹

Producida la cesación en el cargo, si el tiempo que le restare fuere superior a ciento ochenta días deberá procederse al nombramiento del reemplazante de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 6o de esta ley. En el caso de las letras b), c) y d) precedentes, el reemplazante durará en el cargo el tiempo que restare del respectivo período.¹⁰

- ¹El art 12 incluye 5 causas por las que los ministros cesan en el ejercicio de sus funciones:

a) ²Término del período legal de su designación

- ❖ El período es de 6 años y puede ser reelegido un período seguido más.
- ❖ En la mayoría de los casos se renuevan, por lo que están 12 años.
- ❖ Para renovarse, el ministro debe postularse a los concursos públicos. No es automático.
- ❖ La posibilidad de que el ministro sea reelegido es bastante alta debido a que el conocimiento que ha adquirido en el TDLC tiene mucho valor. Pero, ahí va a ser fundamentalmente el Consejo del BC (o CS en el caso del presidente del TDLC) el que deberá ponderar si incluirlo como ministro directo o incluirlo en las ternas (quina en caso de presidente).
- ❖ No puede estar 18 años sucesivos, pero si puede volver a postularse en períodos no sucesivos/descontinuados.

b) ³Renuncia voluntaria

- ❖ No ha ocurrido en el TDLC.
- ❖ Caso BC: sí ocurrió luego de que la secretaria de un consejero del BC (*Carlos Massad*) -que era su amante- le mandaba información confidencial del BC a la sociedad *Inverlink*. Esta sociedad quebró luego de que se supo esto.

c) ⁴Destitución por notable abandono de deberes.

- ❖ Aunque parecería muy amplio, tiene todo un procedimiento muy exigente que viene a continuación: “*las medidas de la letra c) (...)*”.
- ❖ Se revisa por la CS.

d) ⁵Incapacidad sobreviniente

- ❖ *Yrarrázaval* cree que no ha ocurrido.
- ❖ ⁶Incapacidad sobreviniente es aquella que una vez en el cargo le impide participar durante **3 meses consecutivos o 6 meses en un año**.
- ❖ Esta también es revisada por la CS.

e) ⁷No cumplir con el inciso 8 y 9 del art 6.

- ❖ El art 6 habla sobre una serie de formalidades que deben cumplir los ministros.
- ❖ A juicio de *Yrarrázaval* es la menos importante.
- ⁸Las medidas de la letra c), d) y e) se harán efectivas por la **CS a petición del presidente del TDLC o 2 de sus miembros**.
- ⁹La resolución que haga efectiva la destitución, deberá señalar cada uno de los **hechos** en que se funda y los **antecedentes** tenidos a la vista para este efecto.
- Para *Yrarrázaval* es bastante razonable que la destitución corresponda a la CS y que ésta esté fundada.
- ¹⁰Si quedan más de 180 días, se debe nombrar a otro ministro, un remplazante. Si quedan menos de 180 días, queda un suplente en el cargo.

○ Art 13: Planta del TDLC

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 1. DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 13- La Planta del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia será la siguiente:

<i>Cargos</i>	<i>Grados³</i>	<i>Números</i>
<i>Secretario Abogado¹</i>	<i>4º</i>	<i>1</i>
<i>Relator Abogado</i>	<i>5º</i>	<i>1</i>
<i>Relator Abogado</i>	<i>6º</i>	<i>1</i>
<i>Profesional Universitario del ámbito económico</i>	<i>5º</i>	<i>1</i>
<i>Profesional Universitario del ámbito económico</i>	<i>6º</i>	<i>1</i>
<i>Jefe Oficina de Presupuesto</i>	<i>14º</i>	<i>1</i>
<i>Oficial Primero</i>	<i>16º</i>	<i>1</i>
<i>Oficial de Sala</i>	<i>17º</i>	<i>1</i>
<i>Auxiliar</i>	<i>20º</i>	<i>1</i>
<i>Total Planta²</i>		<i>9</i>

Adicionalmente, se podrá contratar personal en forma transitoria, cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, previa visación de la Dirección de Presupuestos.³

El personal de planta del Tribunal se regirá por el derecho laboral común⁴. Con todo, tendrá el mismo régimen remuneratorio de dedicación e incompatibilidades del personal de planta de la Fiscalía Nacional Económica.

(...)

- *No es necesario saberse de memoria toda la composición de la planta del TDLC.
- ¹El cargo más alto de la planta es el de Secretario Abogado.
- ²*Yrarrázaval* considera que esta planta (9 trabajadores) es **insuficiente** considerando el trabajo que tiene actualmente el TDLC.

- ✓ Todos los años, los presidentes del TDLC piden aumentar la planta en su cuenta anual y nunca les han hecho caso. Desde el 2004 que se viene planteando este tema en las cuentas anuales.
 - ✓ Esto es un tema presupuestario, y no hay mucho interés por parte del ejecutivo ni legislativo de aumentar las plantas.
 - ³Se puede contratar más personal, pero de forma **transitoria** cuando las necesidades del TDLC lo requieran.
 - ✓ Para los casos de colusión, por ejemplo, han contratado a 1 o 2 personas adicionales.
 - ⁴El personal de planta del TDLC se regirá por el **dº laboral común**.
 - ✓ Aunque como está dentro del aparato administrativo, debiese regirse por el estatuto administrativo. En el caso del BC pasa lo mismo.
 - ✓ ¿Por qué razón se rige por el dº laboral común y no por el estatuto administrativo?
 - Se aplica el común por lo rígido que es el estatuto administrativo.
 - Se prueba esta rigidez con lo siguiente: el estatuto administrativo no permite que se despida a ningún trabajador salvo con sumario administrativo que tiene muchas complejidades.
 - Ejemplo U. de Chile: hay ciertos profesores que no van nunca y no los pueden despedir por las complejidades del sumario administrativo.
 - Por lo tanto, a juicio de *Yrarrázaval*, parece lógico que se aplique el dº del trabajo común en el caso del TDLC y BC, y así, se puede despedir con la indemnización correspondiente.
 - ³Todos los que están en planta, están ordenados por **grado** que están hechos en función de la escala única de remuneraciones.
 - ✓ El 1º grado es el Presidente de la República.
 - ✓ El 2º grado corresponde a los Ministros de Eº y Ministro de la CS.
 - ✓ El último grado es 35 aprox.
 - ✓ Esta ordenación se hizo hace tiempo y tenía bastante sentido. *Yrarrázaval* dice que hoy en día, no se gana mucho en virtud de los grados. Todo el resto, se gana con bonos, asignaciones, etc.
 - ✓ Esta escala da mucha rigidez al sistema de planta. Ejemplo: no puede haber más de un auxiliar, éste debe renunciar o morirse para que se cambie.
- *Del art 14-17 se entienden con la simple lectura. No los analizamos en clases.

○ **Art 18: Atribuciones del TDLC**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 18- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones que pudieren constituir infracciones a la presente ley;¹

2) Conocer, a solicitud de quienes sean parte o tengan interés legítimo en los hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse² distintos de las operaciones de concentración a las que se refiere el Título IV, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de esta ley, para lo cual podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos;³

3) Dictar instrucciones⁴ de carácter genera⁵ de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares⁶ en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella;

4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda⁷, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia⁸, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas.⁹ En todo caso, el ministro receptor de la propuesta deberá manifestar su parecer sobre ésta. La respuesta será publicada en el sitio electrónico institucional del Tribunal, de la Fiscalía y del Ministerio de que se trate;¹⁰

5) Substanciar, a solicitud exclusiva del notificante de una operación de concentración, el procedimiento de revisión especial de operaciones de concentración, cuando éstas hubieren sido prohibidas por el Fiscal Nacional Económico conforme a lo establecido en el artículo 57;¹¹

6) Dictar, de conformidad a la ley, los autos acordados que sean necesarios para una adecuada administración de justicia;¹² y

7) Las demás que le señalen las leyes.¹³

▪ Hay atribuciones del TDLC que están:

a) En la LDLC (DL 211). Son 6.

b) ¹³Fuera de la LDLC (DL 211), pero que están en otras leyes que le dan atribuciones al TDLC.

-Ejemplo fijación de precios de los monopolios naturales: La ley de electricidad, agua potable, gas, etc. le dan la atribución al TDLC para que intervenga. **La intervención del TDLC es decir si para ciertos bienes hay suficiente competencia o no:**

→ Si hay suficiente competencia, el bien pasa a tener un **precio libre**.

→ Si dice que no hay suficiente competencia, el precio seguirá estando **fijado** por la autoridad.

→ Hay casos muy importantes en los que se ha pedido que se dejen libres los precios y el TDLC dice que no porque según los antecedentes que tienen no hay suficiente competencia.

→ Estas peticiones pueden volver al TDLC ya que los monopolios naturales evolucionan a través del tiempo. Y, de esta manera, los bienes que no tenían competencia pueden empezar a tenerla.

→ Uno de los casos más famosos es el de las telecomunicaciones. La evolución de este mercado en los últimos 20 años ha sido impresionante.

→ Generalmente la autoridad que debe fijar el precio (Ministerio de Economía, Subsecretaría de Telecomunicaciones, etc) es la que le consulta esto al TDLC. La autoridad está fijada por la ley respectiva.

▪ **Atribuciones del TDLC:**

1. ¹Esto se refiere a **conocer**:

a) **Requerimientos** de la FNE

- ❖ El requerimiento de la FNE no le da un status especial al ser conocido por el TDLC, solo se trata como parte demandante.
- ❖ La FNE como parte demandante representa en el requerimiento a la comunidad entera en función del OPE.

b) **Demandas** de cualquier empresa o persona

2. ²Es la norma sobre **conocer las consultas de contratos y operaciones de concentración**.

✓ Se amplía a *todos los que tienen un interés legítimo sobre el asunto*. En el N°1 solo puede intervenir la FNE o la parte.

✓ *Legitimación activa*: término procesal que se refiere a quiénes pueden demandar o intervenir.

→ En el caso de la demanda, tendrán legitimación las partes o la FNE (N°1).

→ En el caso de las consultas, tendrán legitimación las partes, FNE y personas con interés legítimo (N°2).

✓ Los que tienen un interés legítimo SOLO pueden intervenir en las **consultas** NO en las demandas.

✓ El mismo TDLC determina cuándo existe interés legítimo para intervenir en las consultas.

→ Por ejemplo, a CONADECUS (Corporación Nacional de Consumidores y Precios) a veces se le ha reconocido interés legítimo y otras veces no.

→ Caso fusión LAN-TAM:

-CONADECUS interviene en la fusión LAN-TAM, y, por lo tanto, se demoran 1 año y medio más en aprobar la fusión.

-CONADECUS era completamente contraria a la fusión ya que afirmaba que la fusión iba a afectar a los consumidores de líneas aéreas.

-El planteamiento de CONADECUS era que con la aprobación de la fusión los precios iban a subir, y, por lo tanto, los consumidores se verán afectados.

-Efectivamente, la fusión no significó un alza de precios. Por el contrario, con el sistema que tienen actualmente las líneas aéreas, indiscutiblemente los precios siguen bajando.

-Los precios de los vuelos van variando constantemente por los programas computacionales sofisticados que tiene las líneas aéreas con el fin de llenar los aviones como sea. Ejemplo: incentivan con ofertas, encarecen los vuelos para los que compran a último minuto, etc.

-Por lo tanto, hoy en día, no hay una tarifa aérea, sino que miles de tarifas

aéreas. Y, por tanto, el temor de CONADECUS de que aumentaran los precios no sucedió.

- ✓ ³Pueden intervenir en los hechos, actos o contratos **existentes o por celebrarse**. La gran diferencia jurídica que se produce entre ambos casos es que:

- a) En los casos de contratos que están **por celebrarse**, se puede modificar alguna disposición para que se apruebe.

Además, si la consulta es aprobada, se puede desarrollar toda la inversión sin problema salvo que después el mismo TDLC cambie de parecer sobre la base de nuevos antecedentes.

- b) En los casos de contratos **existentes** que no sean aprobados, se vuelven nulos los contratos. *Hay que despedir personal, etc.

→ La demanda de limitación a la LC para la nulidad del contrato, la puede hacer:

- i. empresa afectada por esta PR
- ii. empresa que está incurriendo en la PR, aunque haya celebrado libremente el contrato, y de esta manera, se esté aprovechando de su propio dolo.

-Caso Mall La Florida: En definitiva, muchos locatarios habían celebrado libremente el contrato de la Cláusula Radial de los 5 Km, pero luego afirman que por más de que aceptaron firmar esos contratos, el OPE está por sobre la autonomía de la voluntad, y así, la CS anula la Cláusula Radial por ser restrictiva a la competencia.

-Si a una de las partes que incurre en la PR le baja el remordimiento de conciencia será el TDLC el que anula el contrato con todas las consecuencias que esto puede traer, y, por lo tanto, el ideal es siempre consultar **antes** de la celebración del contrato. Consultar después puede ser muy peligroso.

- ✓ **Las consultas de operaciones de concentración se vuelven obligatorias en el 2016.**

→ La consulta se debe hacer en los casos establecidos en la ley, es decir, en los que se está sobre un umbral mínimo.

→ La consulta de operación de concentración se presenta ante la FNE que deberá analizar la concentración.

*esta mejor dicho "*se presenta la operación de concentración*", que "*se consulta la operación de concentración*"

→ La FNE tiene 3 modalidades ante estas consultas:

- a) Aprueba. Hasta ahí llega, y, por lo tanto, se puede realizar la concentración, que puede ser una fusión de empresas, adquisición de dº o acciones de otras empresas, etc.

- b) Rechaza. El afectado puede recurrir al TDLC, y, posteriormente a la CS.

- c) Aprobar con condiciones. El consultante puede recurrir al TDLC cuando las condiciones no son satisfactorias para él. Y, si incluso el TDLC las mantiene, se puede recurrir ante la CS.

→ El hecho que sea obligatorio genera que la presentación ante la FNE deba ser anterior a la celebración de la concentración. De hecho, hay ciertos plazos mencionados.

3. ⁴Acá el TDLC está **dictando instrucciones** de carácter general para determinados actos o contratos.

✓ ⁵El **carácter general** se refiere a que son afectables a todas las empresas que estén en esa situación.

✓ ⁶Estas instrucciones NO son obligatorias para las partes.

→ Al decir "*considerarse*" significa que las partes puedan estar en acuerdo o desacuerdo.

→ La empresa que no esté de acuerdo con la instrucción, puede celebrar un contrato distinto a la instrucción de carácter general ya que estas instrucciones sólo deben considerarse.

→ De todas formas, las empresas que celebren contratos distintos a los mencionados en las instrucciones, deben saber que el TDLC piensa en forma distinta, y, por lo tanto, si no tiene muy buenos argumentos, perderá el caso con el TDLC. Si tiene excelentes argumentos, tal vez gane.

→ Entonces, la ley no lo indica como obligatorio ni voluntario, sino como "*deberán considerarse*", y esto, es un tema bien delicado.

→ Esto se ha producido en telecomunicaciones y otra serie de materias bien técnicas.

✓ Caso exportación de frutas (consignación VS compraventa/a firme):

→ La consignación puede terminar en algo ruinoso para el productor, pero, si lo hace es porque el precio en consignación es más tentador, es decir, más alto ya que se corren riesgos.

→ El TDLC dicta instrucciones sobre esto debido a que se empiezan a mezclar ambos contratos y nadie entendía nada. Entonces, se empezó a decir que en los contratos de consignación había un mínimo a firme que se debía pagar pase lo que pase. Pero, se dan una serie de excepciones que hacen que es mínimo no sea tan firme.

✓ *Yrarrázaval* dice que el TDLC ha dictado menos instrucciones de las que él hubiese deseado. Él cree que se podrían haber obviado muchos problemas con la previa dictación de instrucciones.

✓ El TDLC ha sido bastante prudente en la dictación de instrucciones de carácter general, vale decir, solamente cuando llega al convencimiento de que se necesita cierta regla de LC fundamental en cierta materia, dictará una instrucción. No existe una proliferación de instrucciones.

✓ Algunas instrucciones se encuentran contenidas en las sentencias. La razón de ser de esa instrucción se da a partir de ese caso. Al conocer una instrucción de carácter general a partir de una sentencia, se entiende de mejor manera y se encuentra más razonable la instrucción.

9 de abril

4. ⁷El TDLC puede **proponer al Presidente** de la República a través del Ministro de Estado que corresponda:
 - a) ⁸**La modificación o derogación de preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la LC.**
 - ❖ Es una proposición que se funda en el conocimiento que va adquiriendo el TDLC en ciertas materias. Así, llega a la conclusión de que es la ley o el reglamento el que está mal concebido desde el punto de vista de la LC.
 - ❖ Hasta ahora, la gran mayoría de las proposiciones han sido acogidas por el Presidente de la República.
 - Caso taxis: durante mucho tiempo en Chile, para ser taxista había que ser miembro del sindicato de taxistas, y así, se restringía la actividad. El TDLC propuso que se derogara la exigencia de pertenecer al sindicato. Después, se transformó en que, para ser taxista, se debe pagar una cuota de incorporación, que, hoy en día es de alrededor de 10 millones. Ésta es otra traba para la LC. En un momento dado, se congeló la cantidad de taxistas; esto era otra traba. Este sistema de taxistas se repite en todas partes del mundo. Todos tienen anomalías desde el punto de vista de la LC.
 - Caso trabajadores portuarios: el esquema de trabajadores portuarios es bastante irregular desde el punto de vista de la LC porque pueden trabajar solamente los que tienen carnet para trabajar, y éste se encuentra limitado. Esto permite que los trabajadores con carnet –cuando se cansan o no desean trabajar más– puedan transferir sus dº a otros trabajadores que entran por cesión de dº de los trabajadores oficiales. Los nuevos trabajadores también pueden ceder sus dº. Todo esto es anómalo desde el punto de vista de la competencia. *Sistema de *pollo, medio pollo y cuarto de pollo*.
 - Caso fútbol: al igual que en el caso anterior, también existe un traspaso de pases entre jugadores y entre entrenadores.
 - ❖ Entonces, uno encuentra dentro de la legislación, tanto a nivel de la ley como a nivel de reglamentos, muchas situaciones en donde se hace referencia a la competencia.
- b) ⁹**La dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas.**
 - ✓ Entonces, la facultad N°4 se refiere a proponer al Presidente de la República para la **modificación, derogación y dictación** de normas legales y reglamentarias que tengan relación con la LC.
 - ✓ ¹⁰Las peticiones se derivan a los ministros correspondientes, que deberán responder publicando su respuesta en el sitio web del TDLC, de la FNE y del ministerio del cual se trate.

5. ¹¹Se refiere a la **revisión** que hace el TDLC de las operaciones de **concentración** luego de ser rechazadas por la FNE. Estas concentraciones se desarrollan después en su título correspondiente en la siguiente ley.
- ✓ Las operaciones de concentración se presentan a la **FNE**, algunos afirman que esto se podría prestar para cosas raras debido a ésta no es independiente del poder ejecutivo. Sin embargo, como la FNE es el órgano de **investigación**, y toda operación de concentración debe ser analizada, la FNE será la encargada de analizar las operaciones de concentración. Estos análisis son bastante complejos porque el efecto de las concentraciones en la competencia -mucho, poco o nada- depende del **mercado** en cuestión. Debe analizarse el efecto en Chile y de hoy día (el efecto actual), ya que las concentraciones van cambiando de país en país y de momento en momento.
 - ✓ Hay actividades en nuestro país que se han concentrado mucho y otras que se han desconcentrado.
 - Ejemplo actividad desconcentrada, teléfonos: por mucho tiempo estuvo muy concentrado el mercado. El único vendedor de teléfonos era la Compañía de Teléfonos, y para las llamadas internacionales era ENTEL. La escasez de teléfonos para aprovecharse de este monopolio era enorme, y, por lo tanto, uno se debía inscribir en listas de espera para comprar un teléfono en las cuales uno podía llegar a esperar 2-3 años. Esto ocurrió en la década del 80`. Luego, se liberalizó la Compañía de Teléfonos y ENTEL.
 - ✓ La tendencia a nivel mundial, es a mayor concentración, y por eso, que este tema es muy relevante. La tendencia es a mayor concentración debido a las **economías de escala**. Las economías de escala han sido progresivas, y cada vez hay más economías de escala y menos competidores para un determinado mercado.
 - Ejemplo actividad concentrada, autos: a nivel mundial, existen del orden de 10 fabricantes de automóviles. Uno se confunde y piensa que este número es mayor, pero en realidad, ha habido muchas fusiones y adquisiciones. 10 fabricantes a nivel mundial es poquísimo.
 - ✓ Las economías de escala están intimamente relacionadas con la **tecnología**.
 - ✓ Por las economías de escala, indiscutiblemente el tema de las concentraciones va a estar cada vez más presente y los criterios al respecto deberán adecuarse a la nueva realidad. Si se rechaza la gran mayoría de las concentraciones, en definitiva, se tendrán actividades cada vez más ineficientes: varias empresas, pero cada vez más ineficientes porque son empresas demasiado pequeñas.
 - Ejemplo actividad concentrada, estanco automotriz en Chile: solo 3 empresas extranjeras fueron autorizadas por el Eº para ensamblar automóviles en Chile y se prohibía entrar al país otros automóviles. Esto fue un desastre ya que los autos fueron bastante malos y muy caros. En

Chile nunca se debió haber hecho esto, ya que hoy día se estima que producciones de menos de 1 millón de unidades es antieconómico.

- ✓ Una de las formas para concentrar una actividad económica es a través de la compra o la fusión de una empresa actualmente existente.
 - ✓ La ley traspasa de voluntaria a **obligatoria** la consulta de operaciones de concentración a partir de ciertos umbrales que estudiaremos después. Se adjudica a la **FNE** para que investigue. La FNE puede hacer varias cosas porque tiene un procedimiento corto y otro largo.
 - ✓ Sobre la FNE se encuentra el TDLC. Por lo tanto, si la concentración es aprobada por la FNE, no llega al TDLC. Pero, si la concentración es rechazada, llega al TDLC, y también puede llegar a la CS ante un rechazo del TDLC.
 - ✓ En definitiva, el sistema contempla una investigación con un resultado por parte de la FNE y el reclamo frente al TDLC.
 - ✓ Puede haber condiciones para la concentración, que también se denominan **mitigaciones**. Las condiciones obviamente son para la aprobación, no el rechazo. El rechazo es absoluto. Hay mucha discusión sobre estas mitigaciones.
 - Caso LAN-TAM: el listado de condiciones es bastante largo y son bastante complejas. LAN no se queda tranquilo y lleva el caso a la CS, que le sacó algunas condiciones. La CS argumentó que las mitigaciones que removió estaban fuera del foco de la LC; eran temas técnicos fuera de la LC. Deja solo las condiciones que tienen directa relación con la competencia de LAN-TAM con el resto de las aerolíneas, ya que el TDLC tiene solamente jurisdicción sobre temas de la competencia, no sobre temas técnicos de cada aerolínea.
 - ✓ *Yrarrázaval* considera bueno el cambio de consultas voluntarias a obligatorias. Aun así, esto trae sus costos:
 - a) La dedicación de la FNE a estos temas se eleva cuando se vuelven obligatorias. Se vuelve un tema preferente en la FNE, y el resto queda un poco en segundo plano.
 - b) El umbral debe estar balanceado:
 - Si es muy bajo estoy obligando a consultar una infinidad de concentraciones.
 - Si se eleva el umbral, el grupo de consultas obligatorias de concentraciones disminuye, y se podrá afectar la LC.
 - *Aun así, la ley dice que una empresa bajo el umbral que tiene dudas, puede consultar, pero las que están **obligadas** a consultar son las que están **encima del umbral**.
 - *El umbral es un límite -que después en la ley se indica cómo se establece- que permite distinguir cuáles concentraciones se deben consultar y cuáles no.
6. ¹²El TDLC tiene la facultad de **dictar auto acordados** –de conformidad a la ley- que sean necesarios para una adecuada administración de justicia.

- ✓ Los auto acordados son un *conjunto de reglas obligatorias, establecidas en este caso por el TDLC, y, que son en su gran mayoría reglas procesales.*

7. ¹³ ***Las demás que le señalen las leyes.***

- ✓ Por lo tanto, **cualquier ley le puede dar una jurisdicción al TDLC en materias que sean de competencia.**
 - Ejemplo monopolios naturales: TDLC puede determinar –si la ley de esa materia lo señala- si existe o no competencia en ese monopolio natural.
 - Si considera que no hay suficiente competencia → precios se mantienen fijados.
 - Si considera que hay suficiente competencia → precios pasan a ser libres.
- ✓ Yrarrázaval tiene dudas de algunas competencias otorgadas al TDLC por ciertas leyes.
 - Ejemplo libertad de expresión: la ley le dio jurisdicción al TDLC para que determinara si la compra de una radio u otra afectaba o no a la competencia. Yrarrázaval considera que se debe distinguir la libertad de expresión de la LC.
- ✓ Siempre que una ley especial le de jurisdicción al TDLC en materia de competencia, éste debe tomar esta atribución.

- Del art 19 en adelante empieza la parte procesal. Anteriormente, está la parte sustantiva.
 - Hay un gran desarrollo del procedimiento en el TDLC.
 - En la ley del 73` había pocas normas respecto al procedimiento.
 - Éste ha sido principalmente desarrollado por las modificaciones que se han hecho a la ley.
 - La gran cantidad de normas procesales se hace necesaria por el **debido proceso**. Por muy especial que sea, éste es un tribunal que resuelve una controversia, y, por lo tanto, debe regirse bajo el debido proceso.
 - Dentro de la ley hay varios procedimientos distintos: para consultas, demandas, y concentraciones. ¿Por qué hay procedimientos distintos dentro del mismo tribunal? Porque son materias con naturalezas jurídicas distintas.
 - En subsidio a las reglas procesales mencionadas en esta ley, se aplica el **Código de Procedimiento Civil** (CPC) y NO el Código Procesal Penal.
 - ¿Por qué no el penal si tenemos nuevamente el delito monopolístico (73`-2003 y reincorporado en el 2016)?
 - Esto se debe a que la sanción penal incluida por esta ley es tratada por los tribunales penales, y esto es después de que haya una sentencia ejecutoriada del TDLC, NO es paralelo.
 - El TDLC NO aplica la sanción penal, sino que, le entrega a la FNE la facultad o la obligación de iniciar la acción penal tribunales penales.
 - No hay que confundirse; el hecho de que exista el delito monopolístico como sanción no cambia el procedimiento.
 - La sanción penal está reservada para cuando el TDLC lo determine de esa forma después de todo el análisis que se ha hecho.

-Lo único que hace el TDLC es entregarle facultades al fiscal para que inicie la acción penal con todas las reglas penales que correspondan.

-En Chile, la acción penal es posterior a la sentencia del TDLC, NO paralela.

- Caso colusión farmacias: es el único caso en donde se dio paralelamente la acción penal. Se hizo un requerimiento de la FNE por el aumento del precio de 200 remedios aprox en 7 meses + la Fiscalía del Ministerio Público inicia la acción penal bajo el Código Penal contra 12 ejecutivos de las farmacias. Pero, en este caso, fue la Fiscalía del Ministerio Público por su propia cuenta la que empezó el proceso penal en virtud de la norma del Código Penal que habla de una **manipulación artificiosa de los precios**. En esta causa, le fue bastante mal al Ministerio Público porque en materia penal el principio fundamental es el **dolo penal**, y si éste no se prueba, no hay sanción. Los MMC no entendieron el tema y lo ilustraron diciendo que no es posible que no se condene a los ejecutivos de las farmacias. El Ministerio Público se estaba refiriendo a un procedimiento penal con un tipo totalmente inadecuado. El Código Penal tiene una figura que no es la colusión propiamente tal, sino que es afectar significativamente los precios. Y, esta sanción nunca ha sido aplicada porque nadie la había considerado anteriormente. Por tanto, cuando se intenta aplicar en el caso de las farmacias, la confusión es inmensa y en los medios salía que no era posible que los ejecutivos salieran libres de este caso. La justicia penal consideró que ese tipo penal no daba para condenar a los ejecutivos.

○ **Art 19: Procedimiento para demandas y requerimientos**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 19- El conocimiento y fallo de las causas a que se refiere el número 1) del artículo anterior¹, se someterá al procedimiento regulado en los artículos siguientes.

- ¹Este se refiere al procedimiento para las **demandas y requerimientos**.
- El procedimiento para las consultas y concentraciones se tratan más adelante y por separado ya que son materias esencialmente distintas. Son mucho más sencillos que el de la demanda (en el que hay controversia y se requiere el debido proceso).

○ **Art 20: Procedimiento para Demandas y Requerimientos**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 20- *El procedimiento será escrito, salvo la vista de la causa¹, público² e impulsado de oficio por el Tribunal hasta su resolución definitiva³. Las partes deberán comparecer representadas en la forma prevista en el artículo 1º de la ley Nº18.120, sobre comparecencia en juicio.⁴*

El procedimiento podrá iniciarse por requerimiento del Fiscal Nacional Económico o por demanda de algún particular⁵, la que deberá ser puesta en inmediato conocimiento de la Fiscalía. El requerimiento o demanda deberá contener la exposición clara y determinada de los hechos, actos o convenciones que infringirían la presente ley⁶ e indicar el o los mercados en que incidiría la presunta infracción.⁷ En el evento que la demanda o requerimiento no contenga las indicaciones señaladas previamente o cualquiera otra de las exigidas por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y demás reglas aplicables, el tribunal dará un plazo de tres días hábiles para que el demandante o requirente subsane dichas omisiones.⁸ Vencido el plazo anterior sin haber sido subsanadas las omisiones, el tribunal mediante resolución fundada podrá no admitir a tramitación la demanda o el requerimiento.⁹ Admitido el requerimiento o la demanda a tramitación, se conferirá traslado, a quienes afecte, para contestar dentro del plazo de quince días hábiles o el término mayor que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.¹⁰

Las acciones contempladas en esta ley, prescriben en el plazo de tres años¹¹, contado desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en que se fundan¹². Esta prescripción se interrumpe por requerimiento del Fiscal Nacional Económico o demanda de algún particular, formulados ante el Tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, las acciones para perseguir las conductas previstas en la letra a) del artículo 3º prescribirán en el plazo de cinco años¹³, y el cómputo de la prescripción no se iniciará mientras se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de la acción.

Asimismo, las multas que se impongan para sancionar un atentado a la libre competencia, prescriben en dos años, contados desde que se encuentre firme la sentencia definitiva que las imponga.¹⁴ Esta prescripción se interrumpe por actos cautelares o compulsivos del Tribunal, del Fiscal Nacional Económico o del demandante particular.

La prescripción de las acciones y la de las multas que se impongan para sancionar un atentado a la libre competencia, no se suspenden a favor de ninguna persona.

Sin perjuicio de las disposiciones generales, las acciones civiles derivadas de un atentado a la libre competencia prescriben en el plazo de cuatro años¹⁴, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva.

○ **Inc 1:**

▪ El procedimiento será:

a) ¹**Escrito, salvo la vista de la causa.**

-La vista de la causa es cuando el tribunal entra a conocer formalmente de la causa. Anteriormente, habrá estudiado el expediente, pero hay un momento determinado en el cual terminada la prueba el tribunal determina que está listo para la vista de la causa.

-El punto más importante en la vista de la causa son los **alegatos**. En 30 min (generalmente) deben sintetizar todo el punto fundamental del caso, por lo que se debe ser muy selectivo para ser exitoso. Se deben transmitir sólo los

aspectos fundamentales en el fallo, porque los hechos, las pruebas, el expediente, etc ya son conocidos.

- b) ²**Público**. Salvo en algunos aspectos -que veremos más adelante- en donde se establecen excepciones para ciertos aspectos del proceso.
- c) ³**Impulsado de oficio por el tribunal**. El TDLC es el que se debe preocupar de darle la mayor rapidez posible. Lo que no es impulsado por el TDLC, es impulsado por las partes.
- d) ⁴Las partes deben ser representadas por **abogados**.

○ **Inc 2:**

- ⁵El procedimiento puede iniciarse por **requerimiento** –del FNE- o **demanda** –de algún particular.
- ⁶El requerimiento o demanda deben tener una **exposición clara y determinada de los hechos, actos o convenciones que infrinjan la ley**.
- ⁷Además, se debe indicar el/los **mercado(s)** en que incidiría la presunta infracción. Ésta, es una **condición de admisibilidad**, por lo que no se puede demandar hasta conocer los mercados afectados.
- Si el TDLC considera que la posición no es clara y determinada y no tiene una descripción razonable de los mercados, no se aceptará la demanda o el requerimiento.
- El **mercado relevante** no está definido en la ley ni en ninguna parte. Pero, se ha definido en desde el punto de vista geográfico y de los bienes involucrados, es decir, que área es afectada y qué productos están involucrados.
- El mercado relevante será analizado caso a caso. Éste análisis por parte de la FNE es muy importante, porque, en definitiva:
 - ✓ Si se amplía el mercado, el efecto de la práctica es menor.
 - ✓ Si se circunscribe el mercado, el efecto será mayor.
- En definitiva, se presenta la demanda que debe tener algunas características precisas. Si no las tiene, el TDLC puede desechar esa demanda, ese análisis es el de **admisibilidad**.
- ⁸Si hay ciertos temas omitidos el TDLC le puede dar un plazo de 3 días hábiles para que lo corrija. Esto es sólo si el TDLC quiere hacerlo.
- ⁹Si no se subsanan dichas omisiones, el TDLC –mediante resolución fundada- podrá no admitir a tramitación la demanda o requerimiento.
- ¹⁰Una vez admitido el requerimiento o la demanda, se conferirá traslado a quienes afecte para que contesten en un plazo de 15 días hábiles o un plazo mayor señalado por el TDLC que no puede ser superior a 30 días.
 - ✓ Estos 15 días son muy fatales para la parte demandada/requerida porque dependiendo en buena medida de la sustancia de esta contestación, es que al demandado/requerido le va a ir mejor o peor en el caso.
 - ✓ Se puede extender hasta por 30 días mediante una petición al TDLC que debe ser concedida por el tribunal. Generalmente, el TDLC concede la extensión.

○ **Inc 3 en adelante: Prescripción**

- El tema de la prescripción es muy relevante. La prescripción le da un **plazo para poder reclamar y no hacerlo en un futuro lejano**. El periodo de prescripción puede ser discutible.
- El objetivo/razón de fondo de la prescripción es **dar tranquilidad y seguridad a las personas**. Sería tremendo poder reclamar por acción penal algo que ocurrió hace 30 años atrás, y además es muy difícil poder probarlo.
- La ley de Defensa de la LC tiene varios plazos de prescripción:

a) 3 años:

- ❖ Este es el 1º plazo que se menciona, e, *Yrarrázaval* dice que es el más general de todos.
- ❖ ¹¹Las **acciones contempladas en esta ley** prescriben en un plazo de **3 años**.
- ❖ ¹²Se debe contar el plazo desde la **ejecución de la conducta atentatoria de la LC**. Se debe distinguir entre:
 - i. **Ejecución inmediata**: se idea y ejecuta de inmediato. **Si la infracción está en un contrato con una fecha determinada, es la fecha del contrato**. Ahí parten los 3 años.
 - ii. **Ejecución diferida en el tiempo**: se idea antes de los 3 años, pero se ejecuta posteriormente. La jurisprudencia ha sostenido que no rige la prescripción desde que se firmó, ya que el daño a la competencia sigue existiendo, y, por lo tanto, se ha estimado que los demandados/requeridos no pueden argumentar de que como firmó hace más de 3 años se prescribe. **Si es una infracción que transcurre en el tiempo, es desde el momento que se termina con la infracción**. Ahí recién parten los 3 años.
- ❖ El tema de la prescripción puede llegar a liquidar el mejor de los casos.
 - **Caso colusión de ambulancias**: la FNE sostuvo que los 3 fabricantes de ambulancias en Chile -solo ensamblaje, el resto no es hecho en Chile- se habían coludido en esa licitación. Pero, el TDLC determinó que esa acción había prescrito. En este caso, habían pasado 4 años.
- ❖ En algunos casos, se ha aceptado la violación de la prescripción, y en otros no. Uno diría que el TDLC es totalmente discrecional para aceptar o no la prescripción. El TDLC debe aplicar la regla, pero no es fácil para los casos de infracciones constantes en el tiempo. Es difícil de determinar cuándo termina el efecto concreto contrario a la competencia.

10 de abril

b) 5 años:

- ❖ ¹³Las acciones para perseguir conductas mencionadas en **el art 3 letra a)**, es decir, las **colusiones** prescriben en un plazo de **5 años**.

c) 2 años:

- ❖ ¹⁴Este plazo de prescripción es para las **multas** que se impongan para sancionar un atentado a la LC. En definitiva, se tiene 2 años para requerir el pago de la multa correspondiente, sino prescribe.

d) 4 años:

- ❖ ¹⁴ Acciones civiles derivadas de un atentado a la LC.

○ Art 21: Sistema de Notificación para Requerimientos o Demandas

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 21- *La notificación del requerimiento o de la demanda, con su respectiva resolución, será practicada personalmente por un ministro de fe¹, entregando copia íntegra de la resolución y de los antecedentes que la motivan. El Tribunal podrá disponer que se entregue sólo un extracto de estos documentos.*
(...)

- ¹Tanto la demanda, el auto de prueba –el escrito que determina qué se tiene que probar-, como la sentencia deberán notificarse **personalmente** para que no haya ninguna duda de que fueron notificados y así no empiecen a correr los plazos sin conocimiento de las partes.

○ Art 22

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 22- *Vencido el plazo establecido en el artículo 20, sea que se hubiere evacuado o no el traslado por los interesados, el Tribunal podrá llamar a las partes a conciliación.¹ De no considerarlo pertinente o habiendo fracasado dicho trámite, recibirá la causa a prueba por un término fatal y común de veinte días hábiles. Acordada una conciliación, el Tribunal se pronunciará sobre ella dándole su aprobación, siempre que no atente contra la libre competencia.² En contra de la resolución que apruebe una conciliación podrá deducirse, por personas admitidas a litigar que no hubieren sido parte en ella, el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 27.*

Serán admisibles los medios de prueba indicados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil³ y todo indicio o antecedente que, en concepto del Tribunal, sea apto para establecer los hechos⁴ pertinentes.⁵ El Tribunal podrá decretar, en cualquier estado de la causa y aun después de su vista, cuando resulte indispensable para aclarar aquellos hechos que aún parezcan oscuros y dudosos la práctica de las diligencias probatorias que estime convenientes.

(...)

Se podrá decretar un término probatorio⁶ extraordinario para rendir prueba fuera de la Región Metropolitana de Santiago, cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia declare que existe motivo fundado para ello.⁷

(...)

El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.⁸

○ Inc 1: Conciliación en materia de LC

- ¹Una vez presentada y contestada la demanda, el TDLC podrá llamar a **conciliación**. NO es obligatorio, sino facultativo.
- La conciliación se está utilizando cada vez más.
- La conciliación es una acción por parte del TDLC en la cual **llama a las partes para ver si puede haber un acuerdo antes de seguir con el juicio**.

- Solamente se puede aplicar a **demandas** NO requerimientos. La FNE, muchas veces, antes de presentar el requerimiento, ve si se puede hacer algún arreglo con la otra parte.
- Si hay un requerimiento, ¿puede conciliar la FNE renunciando a que continúe el caso? Algunos sostienen que sí y otros que no. A juicio de *Yrarrázaval*, depende de la materia de que se trata la PR. Para él, indiscutiblemente una colusión no puede conciliarse, ya que ésta es o no es. Otras materias si pueden conciliarse.
- ²De hecho, la ley contempla en el art 22 que va a ser el **TDLC en sala legalmente constituida el que debe aprobar la conciliación**.

○ **Inc 2: La Prueba**

- ³Los medios de pruebas admisibles serán los mencionados en el art 341 del CPC.
 - ✓ Este código tiene una enumeración de los medios de prueba. Algunos ejemplos son: documental, testimonial, absolucón de posiciones, peritajes, etc.
- ⁵Además, incluye “y todo indicio o antecedente que, (...) sea apto para establecer los hechos pertinentes”.
 - ✓ Se puede decir que no era necesario mencionar la 1ª parte porque después admite todo indicio apto para establecer los hechos pertinentes, entonces, en definitiva, se amplía a cualquier prueba. Ejemplos: grabaciones, conversaciones, mails, etc.
 - ✓ Entonces, la amplitud de los medios de prueba en la ley de la LC es enorme. Esto se hace para la **eficacia** de la ley.
- ⁴Los medios de prueba sirven para probar los **hechos** NO los dº. El dº se aplica, pero no se prueba.
- Existen pruebas regladas y no regladas. En cierto tipo de juicios, por la naturaleza que tienen, se limitan los medios de prueba, por ejemplo, en los juicios civiles. Pero, en materia económica, cada vez estamos inclinándonos más a una prueba no reglada.
- En este art, hay medios de prueba reglados -que vendrían siendo los del art 341 del CPC- y luego continua con los no reglados - “todos los indicios (...)”-.
- ¿Por qué en una ley de la competencia es fundamental que sea tan amplia la aceptación de la prueba? **Se hace muy incómodo para las partes que incurrn en PR**. Se pueden incluir como medios de prueba: conversaciones por teléfono pinchadas, borradores, mails, etc.
 - Caso farmacia: en 10 mails se indicaba claramente la colusión. Se expresa en ellos el mecanismo de alza de precios que utilizaron. Estos no estaban firmados por gerentes, directores ni dueños de las empresas correspondientes, sino, por ejemplo, por el subgerente de marketing.
 - Caso papel tissue: los hechos determinantes para el TDLC fueron las reuniones en la Compañía de Bomberos de Germania. Nadie se reúne en una compañía de bomberos para acordar precios.
- El tema de la prueba es gravitante, y, en los casos en donde la prueba es mala, generalmente la FNE pierde.

- Cuando la prueba es muy mala por parte del demandante, el TDLC puede sancionarlo con costas, debe pagar las **costas del juicio**.
 - ✓ Las costas del juicio son fundamentalmente la de los abogados e informes que se hayan formulado. No son costas demasiado altas.
 - ✓ Han existido varios casos con asignación de costas.
 - ✓ La FNE NO paga las costas del juicio, el resto de los demandantes si pueden llegar a pagar.
- Después, viene una serie de reglas con respecto a la prueba que son de fácil lectura.
- **Art 22 inc 5: Periodo Probatorio**
 - ⁶Hay un período probatorio, en el que se deben probar **hechos** NO dº.
 - ✓ El único dº que se prueba en Chile es el dº extranjero.
 - ✓ Los hechos probados deben ser contradichos por las partes, ya que, si son aceptados por las partes, no se deben probar.
 - El periodo probatorio es largo. Por lo tanto, el probatorio alarga el juicio, pero es la única forma.
 - ⁷El TDLC puede conceder un período probatorio extraordinario para rendir pruebas fuera de la RM cuando el TDLC lo considere pertinente.
- **Art 22 inc 11: Reglas de la Sana Crítica**
 - ⁸El art 22 termina con un concepto fundamental: *“El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.”*
 - Hay 3 criterios fundamentales para apreciar cualquier prueba:
 - a) Apreciación de la prueba reglada. El CPC da los criterios de valor de las pruebas. Entonces, es el mismo código el que le está otorgando el valor respectivo.
 - b) Apreciación de la prueba en conciencia. Queda al criterio del tribunal la valoración de la importancia de la prueba es importante. No sigue ninguna pauta establecida por el código, sino que es en la conciencia del tribunal. Esto se utilizó mucho en Chile.
 - c) Apreciación de acuerdo con la sana crítica. El diccionario se refiere a la *sana crítica* como *principio de razonabilidad y de lógica*. Se ha ido imponiendo en la legislación chilena, reemplazado a la apreciación en conciencia, ya que el TDLC debe **justificar** la conclusión con **argumentos** razonables y lógicos.
- **Art 23: Vista de la causa**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 23- Vencido el término probatorio, el Tribunal así lo declarará y ordenará traer los autos en relación¹, fijando día y hora para la vista.² El Tribunal deberá oír alegatos de los abogados de las partes cuando alguna de éstas lo solicite.³

- Se puede pasar varios meses, incluso años en el término probatorio.

- ¹Los relatores serán los que determinen qué papel juega la relación de los casos. Ellos redactan los autos en relación.
 - ✓ En algunos casos se llaman *relatores*, y en otros, *secretarios relatores*, pero esto da lo mismo.
 - ✓ Lo importante, es que siempre debe haber una relación, que se refiere a un **resumen del caso** lo más objetivo posible (sin tomar partidos, solo debe resumir).
 - ✓ Las relaciones en estos tribunales colegiados siempre anteceden a los alegatos.
- ²Una vez vencido el término probatorio, el TDLC debe declararlo y ordenará traer los **autos en relación**, fijando día y hora para la vista.
- ³El TDLC debe oír los alegatos de los **abogados** de las partes cuando los soliciten.
 - ✓ Las partes no alegan por sí mismas, sino que tienen representantes legales (abogados).
 - ✓ Casi siempre se solicitan alegatos.
 - ✓ Hay alegatos extraordinarios, y otros muy malos.
 - Esto depende de si el abogado se concentra o no en los puntos relevantes del caso, explicando los temas claves para la sentencia -en los 30 min que le otorgan para alegar-, el resto se encuentra en el expediente.
 - Es muy raro que los ministros concedan alargar el tiempo de alegato.
 - Algunos ministros toman nota en los alegatos, ya que lo se está exponiendo, no está en la relación ni el expediente. Y, esos argumentos, le permitirán resolver el caso.
 - El ministro nunca llegará a conocer el caso con la profundidad que lo conocen las partes, por lo que en los alegatos se debe recalcarles a los jueces los puntos claves que le facilitarán la resolución del caso.
- Votos disidentes han empezado a jugar un papel muy importante en materia de LC porque sirven como precedente para casos futuros.
 - ✓ Caso productores de gas vendiéndole a los hospitales públicos: todo el caso parecía ser colusión, pero la duda estuvo en la prueba. Hubo un ministro del TDLC que dijo que la prueba no lo convence, que era pobre para sentenciar. Fue un 4-1 en el TDLC, pero al llegar a la CS se da vuelta en un 0-5. Los 5 de la CS dicen que la prueba no era clara.
 - ✓ Por lo tanto, entre la sentencia del tribunal y la sentencia de la CS, los votos de minoría en el TDLC son muy relevantes ya que se puede revertir. En la CS, los votos disidentes son bastante menos importantes ya que NO hay una instancia superior que los revise. Solo tendría importancia para un caso posterior.

- **Art 24: Cuestiones accesorias a lo principal**
- **Art 25: Medidas Cautelares**

11 de abril

- **Art 26: Sentencia del TDLC y Sanciones para las Prácticas Restrictivas¹**

- **Art 27: Recurso de Reposición y Reclamación**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 27- Las resoluciones pronunciadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, salvo la sentencia definitiva, serán susceptibles del recurso de reposición¹, al que podrá darse tramitación incidental o ser resuelto de plano.

Sólo será susceptible de recurso de reclamación, para ante la Corte Suprema², la sentencia definitiva que imponga alguna de las medidas que se contemplan en el artículo 26³, como también la que absuelva de la aplicación de dichas medidas⁴. Dicho recurso deberá ser fundado⁵ y podrá interponerlo el Fiscal Nacional Económico o cualesquiera de las partes⁶, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro del plazo de diez días hábiles⁷, contado desde la respectiva notificación. Este plazo se ampliará con el aumento que corresponda al lugar en que tenga su domicilio el afectado, si éste fuere distinto al de la sede del Tribunal, de conformidad con la tabla a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. (...)

- **Inc 1: Recurso de Reposición**

- ¹Las resoluciones del TDLC serán susceptibles del **recurso de reposición**, salvo la sentencia definitiva.
- Se está **recurriendo al mismo tribunal** para que cambie la sentencia. En Chile, generalmente se admite la reposición por cosas muy menores, por ejemplo, errores matemáticos, faltas de ortografía, etc.
- El que resuelve la reposición es el mismo tribunal. Entonces, ganar una reposición que cambie la sentencia es prácticamente imposible.
- El verdadero recurso, vendrá a ser el de **reclamación**. Éste se encuentra en el inc 2 de este art.

- **Inc 2: Recurso de Reclamación**

- ²Serán susceptibles del **recurso de reclamación** ante la **CS** las sentencias del TDLC que:
 - ³impongan alguna de las medidas del art 26 (que son las 5 sanciones de las prácticas restrictivas).
 - ⁴absuelvan la aplicación de las medidas del art 26.
- Así, el reclamo queda muy abierto. *Yrarrázaval* considera que así debe ser.
- ⁵El recurso debe ser **fundado**.
- ⁶El recurso podrá interponerlo tanto el **FNE**, como cualquiera de las **partes**.
- ⁷Hay un plazo de **10 días** para interponer el recurso de reclamación.
- Este recurso, es generalmente un recurso relativamente fácil de 3-4 páginas. Este recurso **sirve para que la CS** en su 3º sala (donde se ven los temas de competencia) **revise el caso**.

¹p. 39-52

- A pesar de llegar todo el expediente a la CS, los ministros generalmente lo analizan solamente de la relación de los alegatos. Por eso, hay algunos que dicen que es muy superficial el análisis de la CS, y que es mejor que no existiese el recurso de reclamación. Afirman que se debería terminar el caso en el TDLC. *Yrarrázaval* no opina igual. Cree que el aporte de la CS ha demostrado a través del tiempo un muy buen sentido común para analizar la **razonabilidad de la sentencia**, y para eso, no se requiere un largo estudio del expediente.
- Del total de los casos reclamados, hay una tendencia a que hayan modificaciones por parte de la CS, y ésta ha ido aumentando a través del tiempo. Los ministros de la CS se han dado cuenta de que la responsabilidad que ellos tienen es importante y deben transmitírsela al TDLC.
 - ✓ Caso productores de gas: le muestran al TDLC que la prueba es muy relevante. Este es el caso del 4-1 TDLC y 0-5 CS.
- La CS puede aumentar, disminuir o mantener las sanciones impuestas por el TDLC.

16 de abril

○ **Art 29: CPC supletorio**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 29- Las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil se aplicarán supletoriamente al procedimiento mencionado en los artículos precedentes,¹ en todo aquello que no sean incompatibles con él.²

- ¹Cualquier materia que no esté tratada en las reglas del TDLC en materia procesal, se le aplicará el CPC –Libros I y II- en todo lo que no fuera incompatible.
- ²Si hay alguna incompatibilidad entre la norma del CPC y la del TDLC, prima la del TDLC.

○ **Art 30: Acción de indemnización de perjuicios**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 30- La acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada, se interpondrá ante ese mismo Tribunal¹ y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. Las resoluciones pronunciadas en este procedimiento, salvo la sentencia definitiva, sólo serán susceptibles del recurso de reposición, al que podrá darse tramitación incidental o ser resuelto de plano. Sólo será susceptible de recurso de reclamación, para ante la Corte Suprema, la sentencia definitiva.
(...)

- *Yrarrázaval* considera este art muy importante.
- Se refiere a la acción de indemnización de perjuicios que haya lugar con motivo de una sentencia definitiva ejecutoriada. Por lo tanto, aquí, se reconoce la posibilidad de que todos los afectados recurran a este procedimiento (indicado en

el art 30).

- Este art, fue modificado en el año **2016** de forma importante:
 - ✓ Hasta el año 2016, una vez obtenida la sentencia final ejecutoriada, había que recurrir a los **tribunales ordinarios** de justicia.
 - ✓ ¹A partir del 2016, el tema de la indemnización, lo resuelve el mismo **TDLC**.
 - ❖ Este cambio es importante, pero todavía no se sabe las proyecciones que tiene ya que solo ha habido 1 caso en el que se ha presentado esta situación.
 - ❖ Hay personas de acuerdo y en desacuerdo con este cambio.
 - De acuerdo: Indiscutiblemente, que el tema sea resuelto por el TDLC en vez de los tribunales ordinarios, da la impresión de que se le está dedicando una mayor importancia; además, el tema de la indemnización lo está resolviendo el mismo tribunal que dictó la sentencia, por lo tanto, es muy claro que el tribunal no tiene que entrar en ninguna consideración adicional, sino que, solo debe analizar a cuánto asciende el daño de las personas afectadas.
 - Desacuerdo: El aspecto inconveniente que tiene, es que se le asigna al TDLC una función que no ha cumplido y le quita tiempo que podría utilizar en otros asuntos. El análisis de la indemnización por perjuicios no es nada fácil, y los tribunales ordinarios tienen una experiencia enorme al respecto. Además, la experiencia en los tribunales ordinarios no había sido nada de mala, ya que éstos no analizaban la PR de la competencia, sino, solamente el daño sufrido por las personas. Este análisis se hace bajo ciertas categorías de dº civil.
- En otros países, el tema es muy distinto con respecto a la indemnización por perjuicios. En ellos, se permite que las personas afectadas puedan recurrir a los tribunales correspondientes desde el día 1. Esto significa que los tribunales ordinarios conocen de muchas materias de LC porque se está demandando por una PR que produce daño, y, por lo tanto, ese tribunal ordinario debe analizar si existe o no la PR, y si existe o no el daño causado por esa PR. Esto explica que la jurisprudencia norteamericana y europea sobre LC sea gigantesca. Muchos consideran este sistema más eficiente que el nuestro, ya que el chileno puede ser muy purista, y, de hecho, genera muy pocas sentencias, de hecho, al año hay del orden de 10 sentencias del TDLC.
- En definitiva, en Chile no se puede iniciar una causa de LC sin haber pasado por este sistema. El sistema contempla la **exclusividad**, vale decir, no se puede demandar por indemnización de perjuicios sino se ha finalizado con sentencia ejecutoriada del caso.

- **Art 31: Procedimiento de las consultas distintas a las de operaciones de concentración**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 31- *El ejercicio de las atribuciones a que se refieren los números 2), 3) y 4) del artículo 18, así como la emisión de los informes que le sean encomendados al Tribunal en virtud de disposiciones legales especiales, se someterán al siguiente procedimiento:*

1) El decreto que ordene la iniciación del procedimiento¹ se publicará en el Diario Oficial² y en el sitio de Internet del Tribunal y se notificará, por oficio, a la Fiscalía Nacional Económica, a las autoridades que estén directamente concernidas y a los agentes económicos que, a juicio exclusivo del Tribunal, estén relacionados con la materia, para que, en un plazo no inferior a quince días hábiles, éstos y quienes tengan interés legítimo puedan aportar antecedentes.

(...)

3) Vencido el plazo señalado en el número 1, el Tribunal deberá citar a una audiencia pública, la cual se llevará a efecto dentro de un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días contado desde la notificación, la que se practicará mediante un aviso publicado en el Diario Oficial y en el sitio de Internet del Tribunal, para que quienes hubiesen aportado antecedentes puedan manifestar su opinión.³

(...)

- La consulta tendrá un procedimiento distinto a la demanda, ya que tienen una naturaleza jurídica distinta.
 - ✓ En la consulta no hay partes en controversia, sino, consultantes.
 - ✓ Los consultantes pueden ser cualquiera: instituciones públicas, empresas del Eº, empresas Yrarrázaval, particulares, etc.
- A juicio de Yrarrázaval, en Chile, el sistema de consultas fue muy exitoso, especialmente entre el 73` y el 2003.
 - ✓ En estos 30 años se consultó prácticamente de todo.
 - ✓ Él considera que esto fue muy relevante para la etapa posterior, con la creación del TDLC en el 2003 (empieza a funcionar en el 2004).
 - ✓ La sola comisión preventiva central falló más de 1000 consultas.
 - ✓ El interés por consultar fue enorme. Esto se debe a que con la resolución de la consulta se obtiene una **especie de cosa juzgada**. Ésta consiste en que, si es resuelta afirmativamente, la parte consultante puede realizar ese contrato o convención sin ningún problema, salvo que de acuerdo con nuevos antecedentes haya una resolución distinta. Si no hay nuevos antecedentes, puede seguir realizando tal actividad. Esto se ha visto en el caso de las franquicias y centros comerciales.
 - ✓ Entonces, la aprobación de la consulta otorga **seguridad jurídica** en materia de LC.
 - ✓ Por el contrario, si la consulta se refiere a actos o contratos ya celebrados y es rechazada por el TDLC –o anterior comisión preventiva central-, ese acto NO se puede realizar desde el punto de vista de la LC.
 - ✓ Este tema ha sido muy relevante con respecto a las condiciones impuestas por el TDLC –anteriormente por la comisión preventiva central- para la aprobación de una consulta, también denominadas **mitigaciones**.

- ✓ Hoy en día, la gran mayoría de las consultas más relevantes –principalmente de operaciones de concentración- van acompañadas de condiciones. Y, si no se cumplen las mitigaciones, viene entonces la sanción.
 - ❖ Caso supermercado SMU: la FNE estimó que no se cumplieron ciertas mitigaciones impuestas en la consulta hecha para la adquisición de otros supermercados. La empresa se defendió en que las condiciones en la forma en que se encontraban planteadas, no se podían cumplir. Los obligaba a vender otros supermercados que no había podido vender.
 - ❖ Caso LAN-TAM: la FNE argumentó que LATAM no estaba cumpliendo con ciertas mitigaciones impuestas.
- ✓ Por lo tanto, a pesar de que las consultas de prácticas son cada vez menores, no dejan de ser relevantes en el caso de las concentraciones.
- Las consultas NO son sentencias, sino RESOLUCIONES.
- El art 31 cambió a través del tiempo de forma importante porque el procedimiento de la consulta empezó a ser cada vez más complejo, especialmente, en el sentido de que pueden participar en el procedimiento las personas o empresas que se sientan afectadas. Por lo tanto, el interés del legislador fue que intervinieran muchas personas y empresas. Esto hace que un procedimiento que era relativamente rápido, pasara a ser cada vez más lento.
 - ✓ De hecho, es típico, por ejemplo, en los casos de concentraciones que se presenten 30 personas o empresas en la audiencia pública. En la audiencia se pueden presentar todos los que lo hayan solicitado y que reúnan una serie de requisitos.
- ¹El procedimiento parte con un decreto del TDLC que ordena la iniciación del proceso de consultas, instrucciones, propuestas al presidente e informes. *Yrarrázaval* habla principalmente del procedimiento de consultas.
- ²Este decreto debe ser publicado en el Diario Oficial (hoy en día es digital).
- Después, viene todo un extenso procedimiento para que todos los interesados estén enterados.
- ³Luego, hay una gran audiencia, que hoy en día está demorando varios días. Ésta es para los efectos de escuchar a todos los que expresen interés en el asunto.
- Además de esta lentitud, en el caso de las concentraciones se aplica un mecanismo totalmente distinto. Uno diría que esto puede afectar mucho las consultas de las concentraciones, pero, éstas las resuelve fundamentalmente la FNE NO el TDLC. Al TDLC se puede acceder en el caso de que la FNE rechace la concentración. Por lo tanto, este procedimiento ha quedado fundamentalmente para las consultas de PR que no sean concentraciones.

○ **Art 32: Efectos de la aprobación de la consulta para operaciones de concentración**

TITULO II – DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA - 2. DE LAS ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 32- Los actos o contratos ejecutados o celebrados de acuerdo con las decisiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o de acuerdo con las resoluciones de la Fiscalía Nacional Económica para el caso de las operaciones de concentración no acarrearán responsabilidad alguna en esta materia¹, sino en el caso que, posteriormente, y sobre la base de nuevos antecedentes, fueren calificados como contrarios a la libre competencia por el mismo Tribunal, y ello desde que se notifique o publique, en su caso, la resolución que haga tal calificación.²

En todo caso, ni los ministros que concurrieren a la decisión, ni el Fiscal Nacional Económico, según correspondiere, se entenderán inhabilitados para los nuevos pronunciamientos que eventualmente tuvieran lugar.³

○ **Inc 1:**

- Es la parte sustantiva, mientras que el art 31 es la parte procesal.
- ¹Los actos o contratos ejecutados o celebrados de acuerdo a las decisiones del TDLC o FNE –en concentraciones-, no acarrearán responsabilidad alguna en esta materia. Vale decir, se puede realizar esas actividades sin responsabilidad alguna ya que fueron aprobadas por el TDLC o FNE.
- ²Salvo, en el caso de que se presenten posteriormente **nuevos antecedentes** que califiquen a la actividad como contraria a la LC.

○ **Inc 2:**

- ³Agrega algo muy relevante que se refiere a que ni los ministros del TDLC ni el FNE estarán inhabilitados para los nuevos procedimientos que tuvieran lugar. Porque probablemente los que deben resolver son los mismos que fallaron, puede haber cambiado 1-2, pero no se puede inhabilitar a todos los ministros por haber fallado el caso anteriormente. Por lo tanto, el hecho de participar en el fallo anterior no lo inhabilita, porque en caso contrario, se podrían quedar prácticamente sin sala para fallar.

III. TÍTULO III: DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

- Muchos art son de simple lectura.
- **Art 33:**

TITULO III-DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Artículo 33- *La Fiscalía Nacional Económica será un servicio público descentralizado¹, con personalidad jurídica y patrimonio propio², independiente de todo organismo o servicio³, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.⁴*

La Fiscalía Nacional Económica tendrá su sede en Santiago.⁵ Estará a cargo de un funcionario denominado Fiscal Nacional Económico⁶, que será nombrado por el Presidente de la República⁷ mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previstos en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento por una sola vez.⁸

El Fiscal Nacional Económico cesará en sus funciones por las siguientes causales:⁹

- a) Término del período legal de su designación.¹⁰*
- b) Renuncia voluntaria aceptada por el Presidente de la República.¹¹*
- c) Destitución por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.¹²*
- d) Incapacidad.¹³*

La remoción por las causales señaladas en las letras c) y d) será dispuesta por el Presidente de la República, con el informe favorable de la Corte Suprema, a requerimiento del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.¹⁴ El informe favorable deberá ser emitido por el pleno de la Corte, especialmente convocado al efecto, y deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

(...)

- **Inc 1:**
 - Características FNE:
 - ✓ ¹**Servicio público descentralizado.** Al referirse a la FNE como un *servicio público descentralizado* está diciendo que la FNE no tiene independencia con respecto del **Ministerio de Economía** (depende de él). Así ha sido desde un comienzo, y, pareciera propio que sea parte de este ministerio.
 - ✓ ²**Con personalidad jurídica y patrimonio propio.**
 - ✓ ³**Independiente** de todo organismo o servicio.
 - ✓ ⁴Sometido a la **supervigilancia del Presidente de la República** a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
 - Hoy en día, el Ministerio se denomina de Economía, Fomento y Turismo. Antes, se denominaba Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ya que surge en el s.XX a raíz del terremoto de Chillán, además, se crea la CORFO. *El Ministerio de Hacienda es del s.XIX.
- **Inc 2:**
 - ⁵La FNE tendrá su sede en Santiago, al igual que el TDLC.
 - Esta disposición se establece en el año 2003.
 - Anterior al año 2003, existía otra estructura, en la cual había 12 fiscalías regionales y el fiscal nacional -que también era fiscal de la RM-. Vale decir, se reproduce el mismo esquema existente para las comisiones preventivas. Había fiscales muy

buenos y otros que eran muy malos, y ésta diferencia se podía apreciar notoriamente.

- Por lo tanto, a partir del año 2003, está todo concentrado en Santiago.
- ⁶La FNE estará a cargo de un funcionario denominado *Fiscal Nacional Económico*.
- El FNE no tiene nada que ver con el Ministerio Público ni el Fiscal Nacional del Ministerio Público. Este es un sistema paralelo referente exclusivamente a la Ley de la Competencia.
 - ✓ ¿Por qué se han dado ciertos roces entre ambas fiscalías? (*en el caso de las farmacias es muy notorio)
 - ❖ Caso Farmacias: la Fiscalía del Ministerio Público llevó este caso a tribunales del crimen desde el día 1, no esperando para nada el pronunciamiento del TDLC ni de la CS. Esto lo hace basándose en que se había infringido el art 285 del Código Penal que sanciona la *manipulación de precios*. La Fiscalía consideró que había una manipulación de precios equivalente a una colusión, que a juicio de *Yrarrázaval* es totalmente raro y no tiene ninguna equivalencia con la colusión. Dice que las manipulaciones de precios existen en el Código Penal desde el s.XIX, y nadie se podría haber imaginado una colusión en el s.XIX. Pero, equivocadamente la Fiscalía del Ministerio Público siguió adelante con el juicio, y, le fue pésimo. Esto se debe a que era un tema de LC, NO penal. La Fiscalía del Ministerio Público argumentó que las facultades penales son atribuibles a ésta, y, que una ley no le puede impedir ejercer sus atribuciones de llevar una materia penal a los tribunales del crimen. Al final, afortunadamente según *Yrarrázaval* prosperó la idea de que, si el TDLC y el FNE no lo consideran suficientemente grave, no se inicia la acción penal. Entonces, esto no es automático, sino que debe haber una sentencia final ejecutoriada que mencione que además de las sanciones impuestas por la LDLC, el FNE debe iniciar la acción penal correspondiente en virtud del delito tipificado en la ley, que se refiere al delito monopólico.
- ⁷El FNE será nombrado por el Presidente de la República.
 - ✓ Por lo tanto, acá no interviene ni la CS ni el Consejo del BC -como ocurre en el caso del TDLC-.
 - ✓ Es razonable que así sea, porque el FNE es dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía.
 - ✓ No se presentan ternas o quinas, como si se hace en el caso de los ministros del TDLC. Aun así, los nombramientos de los FNE durante el tiempo han sido bastante afortunados. Éstos deben ser abogados y tener buenos conocimientos en materia de LC. Si el presidente llegase a nombrar a un mal FNE, tendrá que asumir las consecuencias del mal nombramiento.
 - ✓ Este es un nombramiento delicado que hace el Presidente de la República, ya que es a través del FNE y de la FNE que el sistema de competencia funciona mejor o peor.
 - ✓ La calidad del FNE se nota en la eficiencia que tiene. Los mejores se han

metido en los temas de fondo mucho mejor, además, tienen mayor conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel internacional, es decir, cuáles son las tendencias a nivel internacional, etc. Los más malos tienen una visión mucho más restringida de la materia.

- ⁸Durará 4 años en el ejercicio de su cargo con posibilidad de otros 4.
 - ✓ Esto se diferencia de la duración de los ministros, que duran 6 años con posibilidad de otros 6.
 - ✓ En ambos casos, sólo se pueden renovar por un periodo consecutivo más.

○ **Inc 3: Causales de Cesación del FNE**

- ⁹El FNE cesará en sus funciones en 4 causales:
 - a) ¹⁰**Término del período legal de su designación**
 - ❖ Será a los 4 años, o a los 8 años si es reelecto.
 - b) ¹¹**Renuncia voluntaria aceptada por el Presidente de la República**
 - ❖ Debe ser aceptada por el Presidente de la República. Éste se puede negar a su renuncia.
 - c) ¹²**Destitución por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones**
 - ❖ Esto se presta para confusiones. ¿Qué se entiende por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones?
 - ❖ Las negligencias se están considerando ampliamente.
 - Ejemplo alcaldes: hoy en día, estamos viendo a alcaldes que lo están pasando pésimo por no pagarle a los profesores la deuda histórica que hay en materia previsional, y, de hecho, algunos están yendo a la cárcel. A lo mejor, por no pagar esa deuda, está haciendo una magnífica gestión.
 - d) ¹³**Incapacidad**
- ¹⁴En el caso de la destitución y de la incapacidad, la remoción deberá ser aprobada por el Presidente de la República con el informe favorable de la CS, a requerimiento del Ministerio de Economía.
 - ✓ Por lo tanto, no son automáticas estas cesaciones, sino que, es requerida por el Ministerio de Economía con el acuerdo del Presidente de la República y luego de la CS.
 - ✓ Hasta hoy en día, no se ha aplicado la letra c) ni d).

○ **Art 35: Planta de la FNE**

TITULO III-DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Artículo 35- Fíjase a contar del día primero del mes siguiente a la publicación de esta ley, la siguiente planta para la Fiscalía Nacional Económica¹:
(...)

- ¹Este art es muy extenso, ya que tiene 50 personas en planta. En realidad, hay 108 personas en la FNE aproximadamente.
- Todos los servicios del Eº, tienen una planta determinada por ley. Esto es así porque la Cº lo dice en función de la aplicación del **estatuto administrativo** para estos efectos.

- La aplicación de la ley en cuanto a la planta se refiere a que el cargo de FNE es 1 y solamente 1 –con grado 1-, lo sigue el Subfiscal que es 1 persona –con grado 2-, luego, vienen 7 personas con cargo de Jefe de Departamento –con grado 3- y 4 Jefes de Departamento –con grado 4-, etc.
- Todo esto significa que no pueden haber más de las personas indicadas por la ley para determinada función. Y, por lo tanto, las personas no podrán ascender de cargo a menos que alguien superior se retire o se muera. En definitiva, el estatuto administrativo es sumamente **rígido**.
- Si es tan rígido, ¿Por qué no se derogan las plantas? Por razones presupuestarias.
 - ✓ La Ley de Presupuesto contempla cantidades de gastos por cada servicio público, entre ellos, la FNE.
 - ✓ En el presupuesto está determinando el monto total de gasto en las plantas respectivas, y, ningún servicio público puede gastar más de lo que le corresponde según lo indicado por la Ley de Presupuesto.
 - ✓ La excepción a esto son los *gastos reservados*, que según *Yrarrázaval* se deberían derogar ya que lo único que han generado son problemas muy serios. Tenían una finalidad, pero se han gastado de una forma distinta. Ej gasto reservado: fuerzas armadas.
- Ahora, ¿cómo se financia las remuneraciones del resto de los que trabajan en la FNE si no están en la planta? Todos los servicios, o la gran mayoría, tiene otro ítem que se llama *a honorarios*.
- Entonces, dentro del mismo servicio, hay 3 categorías distintas de trabajadores (todos trabajan juntos): en la planta, a honorarios, contrato de trabajo sin estar en la planta.
 - ✓ La consecuencia jurídica de esto es muy relevante, ya que el trabajador de planta no puede ser despedido sino en virtud de un sumario administrativo. Y, despedir a alguien por sumario administrativo es sumamente complejo.
 - ❖ Caso Universidad de Chile: hay trabajadores que llegan en la mañana y se van ya que saben que tienen la protección del sumario administrativo que hace que sea muy difícil su despido.
- En definitiva, la FNE tiene 3 tipos de trabajadores distintos -realizando las mismas funciones- y con 3 regímenes distintos:
 - ✓ De planta → Estatuto administrativo.
 - ✓ Contrato de trabajo → Código del Trabajo.
 - ✓ A honorarios → NO tiene protección, ya que no está bajo el amparo del Código del Trabajo.
- Las remuneraciones de estos 3 tipos de trabajadores son distintas:
 - ✓ De planta → están determinadas por el presupuesto otorgado a la planta para todos los servicios. Pero, a esta remuneración se le han ido agregando bonos y otras cosas, por lo que no podremos saber en realidad cuánto gana un trabajador en planta.
 - ✓ Contrato de trabajo → remuneración convenida por las partes.
 - ✓ Honorarios → remuneración convenida por las partes.
 - ✓ Generalmente, los contratados a honorarios y algunos contratados por

contrato de trabajo, tienen mejores remuneraciones que los que están en planta (puede llegar a ser el doble), y, por lo tanto, terminan siendo odiados por los trabajadores de planta.

- La cantidad de anomalías generadas en la FNE por el tema de los trabajadores es bastante grande.

○ **Art 39: Facultades de la FNE**

TITULO III-DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Artículo 39- El Fiscal Nacional Económico, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúe.¹ Podrá, en consecuencia, defender los intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones.²

Serán atribuciones y deberes del Fiscal Nacional Económico³:

a) Instruir las investigaciones que estime procedentes para comprobar las infracciones a esta ley, dando noticia de su inicio al afectado.⁴ Con conocimiento del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile deberá poner a disposición del Fiscal Nacional Económico el personal que éste requiera para el cumplimiento del cometido indicado en esta letra o ejecutar las diligencias específicas que le solicite con el mismo objeto.⁵

El Fiscal Nacional Económico, con conocimiento del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de reservadas.⁶

Asimismo, el Fiscal Nacional Económico podrá disponer de oficio o a petición del interesado, que ciertas piezas del expediente sean reservadas o confidenciales, siempre que tengan por objeto proteger la identidad de quienes hayan efectuado declaraciones o aportado antecedentes en conformidad al artículo 39 bis, o que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, o resguardar la eficacia de investigaciones de la Fiscalía.⁷

(...)

b) Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los tribunales de justicia, con todos los deberes y atribuciones que le correspondan en esa calidad.⁸

(...)

c) Requerir del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y la adopción de medidas preventivas con ocasión de las investigaciones que la Fiscalía se encuentre ejecutando;⁹

d) Velar por el cumplimiento de¹⁰ sus propias resoluciones en las materias a que se refiere el Título IV de esta ley¹¹, así como de los fallos y decisiones que dicten el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los tribunales de justicia en las materias a que se refiere esta ley;¹²

e) Emitir los informes que solicite el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en los casos en que el Fiscal Nacional Económico no tenga la calidad de parte;¹³

f) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos, de las municipalidades o de las empresas, entidades o sociedades en que el Estado o sus empresas, entidades o sociedades, o las municipalidades, tengan aporte, representación o participación, quienes estarán obligados a prestarla, como asimismo, a proporcionar los antecedentes que obren en sus archivos y que el Fiscal Nacional Económico les requiera, aun cuando dichos antecedentes se encuentren calificados como secretos o reservados, de conformidad a la legislación vigente, caso este último en que se requerirá la autorización previa del Tribunal.¹⁴

g) Requerir de cualquier oficina, servicio o entidad referida en la letra anterior, que ponga a su disposición los antecedentes que estime necesarios para las investigaciones, denuncias o querellas que se encuentre practicando o en que le corresponda intervenir.¹⁵

(...)

h) Solicitar a los particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo de las investigaciones que practique.¹⁶ Las personas naturales y los representantes de personas jurídicas a los que el Fiscal Nacional Económico requiera antecedentes o informaciones cuya entrega pudiere irrogar perjuicio a sus intereses o a los de terceros, podrán solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que deje sin efecto total o parcialmente el requerimiento.¹⁶

(...)

Quienes estén obligados a dar respuesta a las solicitudes de información efectuadas por el Fiscal Nacional Económico e injustificadamente no respondan o respondan sólo parcialmente, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de hasta dos unidades tributarias anuales por cada día de atraso, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 39 ter, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 42;¹⁷

n) En casos graves y calificados de investigaciones destinadas a acreditar conductas de las descritas en la letra a) del artículo 3º,¹⁸ solicitar,¹⁹ mediante petición fundada²⁰ y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,²¹ autorización al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que corresponda de acuerdo al turno,²² para que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la Fiscalía Nacional Económica que indique la solicitud, proceda a:²³

n.1) Entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, a allanar y descerrajar;²⁴

n.2) Registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de la infracción;²⁵

n.3) Autorizar la interceptación de toda clase de comunicaciones²⁶, y

n.4) Ordenar a cualquier empresa que preste servicios de comunicaciones, que facilite copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ella.²⁷

(...)

t) Las demás que señalen las leyes.²⁸

- ¹El FNE, en el ejercicio de sus funciones, será **independiente** de todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúe.
 - ✓ Esto es muy importante, especialmente en los casos en que el demandado sea una institución pública. Por ejemplo, municipalidades, ministerios, Dirección General de Aeronáutica, etc.
 - ✓ Felizmente, hasta ahora siempre se ha respetado la autonomía, vale decir, si la FNE llega a la conclusión de que hay una PR, no ha sido amenazada -ni nada por el estilo- por parte de los órganos públicos.
- ²En consecuencia, podrá defender los intereses que le están encomendados en la

forma que estime arreglada a dº según sus propias apreciaciones. Este es el resultado de la independencia.

- ³Las atribuciones y deberes del FNE llegan hasta la letra t), pero ésta indica “*las demás que señalen las leyes*”, por lo que hay más que solo las de este art.

○ **Letra a): Investigación**

- Es una de las atribuciones más relevantes y fundamentales de la FNE.
- ⁴Se refiere a la facultad de **investigar**.
- ⁵Con conocimiento del pdte del TDLC, se le pide a la PDI que participe de en ciertos aspectos de la investigación, que aparecerán más delante de una forma muy amplia.
 - ✓ Las facultades que tiene la PDI para estos efectos son las mayores que conocemos dentro de nuestro sistema jurídico. Y, esto se ha ido ampliando, incluyendo **allanamientos, interceptaciones telefónicas, interceptaciones de mails**, y otras.
 - ✓ La FNE no tenía esta facultad inicialmente. Se incluye en el año 2003, en donde la FNE va a adquirir facultades de investigación muy grandes. Luego, con las modificaciones del 2009 y 2016, se alcanza el mayor grado de facultades investigadoras.
 - ✓ Por regla general, se debe estar en conocimiento del pdte del TDLC. Pero, las más delicadas, deberán tener autorización del TDLC y además de un ministro de la Corte de Apelaciones. Por lo general, estas autorizaciones son otorgadas ya que indiscutiblemente se está en una etapa que no se sabe qué se puede encontrar, y, por lo tanto, ni el TDLC ni el ministro de la Corte de Apelaciones piden mayores antecedentes (ya que no se saben mucho).
- La investigación puede iniciarse:
 - a) **De muto propio (de oficio)**: se refiere a cuando simplemente la FNE se dio cuenta de la existencia de una anormalidad en determinado mercado, y, sin denuncia alguna inicia la investigación, en la que puede llegar a la conclusión de que efectivamente hay una práctica para la cual necesita la integración de la PDI, y ahí se producen los allanamientos y cosas por el estilo.
 - b) **Por un particular**: El particular va a hablar con la FNE y la convence de que inicie la investigación. Este es un tema complicado, ya que ese particular puede ser el competidor del denunciado, y, por lo tanto, le va a presentar información incompleta y sesgada, por lo que la FNE debe llevar a cabo la investigación sobre la base que a lo mejor lo que está diciendo el denunciante es falso. Si lo que dice el denunciante es falso se lo puede sancionar, pero esta sanción es muy leve. La FNE es cada vez más rehacia a esto, ya que el particular podría ir a denunciar por su propia cuenta ante el TDLC.
- ⁶El carácter reservado de las investigaciones –mencionado en el inc 2 de la letra a)- es un tema muy relevante para el **éxito** de la investigación. El carácter reservado se puede dar tanto para las investigaciones de oficio (de *muto propio*) como para las que se dan a partir de una denuncia de un particular.
 - ✓ Entonces, durante la investigación la regla general pasa a ser lo que era la

- ✓ excepción en el TDLC.
- ✓ En el TDLC uno también puede pedir reserva, pero se otorgará ocasionalmente porque se entiende que el expediente que llevó la FNE -después de la investigación- al TDLC es **público** salvo que haya una razón.
- ✓ ⁷Las razones que justifican la reserva se dan a partir del tipo de información que maneja la FNE. Típicamente, la FNE parte pidiendo en sus investigaciones toda la información con respecto a los balances, las ventas, ingresos, precios, etc del período de tiempo que estime conveniente. Y esto no es menor, vale decir, si esta información cae en manos de un competidor, es fatal para la empresa, ya que el competidor tendrá una ventaja enorme.
- En esta letra, se plantea la facultad de investigar en términos generales. Pero, lo de las nuevas facultades (ej: allanamiento) están incluidas más adelante porque se incorporan con las modificaciones mencionadas. Especialmente tienen relación con las **colusiones**, y se refiere a los **allanamientos**, **intercepciones de conversaciones telefónicas, mails y otras formas digitales de comunicación**.
- **Letra b): Representación del interés general de la colectividad**
 - ⁸Se refiere a **actuar como parte** representando el **interés general de la colectividad** en el orden económico, ante el **TDLC** y los **tribunales de justicia**.
 - ✓ Ante el TDLC se hace a través del requerimiento.
 - ✓ Si al FNE no le va bien en el TDLC, puede reclamar ante la CS ya que tiene el comportamiento como parte. Pero, lo más probable es que le vaya mal porque si la FNE perdió en el TDLC es muy raro que la CS revierta la decisión. En el mejor de los casos, puede aumentar un poco las sanciones, pero en la gran mayoría de los casos, simplemente confirma la decisión del TDLC ya que NO analiza todo el expediente –ni siquiera sus partes más fundamentales-, sino lo que analiza es el **recurso de reclamación** y la **vista de la causa** en su relación y en sus alegatos. Por lo tanto, la revisión no es muy profunda. Aun así, *Yrarrázaval* está de acuerdo con que exista el recurso de reclamación, y, por tanto, la revisión de los casos por la CS en donde resuelve el sentido común de los casos.

17 de abril

- ✓ Esta representación es muy delicada porque en muchos casos es el requirente, y, como requirente no solamente tiene la obligación de presentar los requerimientos en forma completa desde el punto de vista jurídico y económico, sino que, además, en la causa de la prueba **le corresponde generalmente probar**. Esto es fundamental. Quien deba probar, por regla general será, el demandante en las demandas y FNE en los requerimientos. Esto se denomina en dº el **peso de la prueba**, y se refiere a quién debe probar.
- ✓ Aquí se ha planteado un tema muy complicado, porque algunos han sostenido que en los casos de colusión la FNE no tiene el peso de la prueba, sino que la tienen los coludidos. *Yrarrázaval* no está para nada de acuerdo con esta teoría, pero hay muchos que están repitiendo esta idea en el sentido de que en los casos de colusión se invertiría el peso de la prueba, y, en vez de

quedar en manos de demandante/requirente quedaría en manos de los coludidos. Esto es por un concepto que viene del dº anglosajón, en éste existe lo que se llaman las **prácticas per se**, es decir, por sí mismas. Durante mucho tiempo, especialmente en el dº norteamericano se decía que en los casos de colusión el peso de la prueba no lo tenía la FNE de allá.

- ✓ **El punto fundamental es que en ciertos casos muy graves –como es el caso de la colusión–no hay necesidad de probar, y el peso de la prueba pasaba a los coludidos.**
 - ✓ Esta regla *per se* se ha ido diluyendo en USA, por lo que hoy día prácticamente no situaciones así. Hoy en día, en vez de la regla *per se*, TODO se debe probar en USA. Todo se debe probar en materia de LC en todas partes del mundo.
 - ✓ Entonces, bajarle la exigencia a lo que correspondería a la FNE en los casos de colusión no le parece a *Yrarrázaval*, pero algunos creen que debiese ser así. Además, cuando uno va a analizando los casos que hemos tenido, uno no sabe dónde está el acuerdo colusivo, lo único que se exhibe es el acuerdo y nada más, por lo que una regla *per se* no indicaría la existencia de la colusión.
 - ✓ Por lo demás, no hay en la ley –a juicio de *Yrarrázaval*– algo que justifique esta argumentación (regla *per se*), porque si en último término el legislador dijera que se debe tener la regla *per se*, estaría actuando bajo una competencia que no tiene, ya que en Chile no existe esta regla, es solo una construcción doctrinaria que *Yrarrázaval* no comparte.
 - ✓ La prueba de la PR generalmente es la parte más fundamental, por eso es que hoy en día una función muy importante del TDLC es **recibir la prueba**. Los ministros del TDLC gastan semanas y meses enteros para recibir especialmente pruebas testimoniales, pueden llegar a ser 40-50 testigos. Cada testimonio puede durar 1 hora u hora y media.
- **Letra c): Requerir al TDLC realizar cierta atribución**
- ⁹Según esta facultad, la **FNE le requiere al TDLC que ejerza alguna de las atribuciones que no está ejerciendo.**
 - Esto NO es obligatorio para el TDLC.
 - ✓ Por ejemplo, le dice al TDLC que a lo mejor es bueno ciertas normas con respecto a determinados contratos.
 - ✓ Caso contrato de exportaciones de frutas: no son nada de fáciles. Los efectos del contrato dependen de si éste se califica como:
 - ❖ *Compraventa*: no debiera haber ninguna implicancia en la LC.
 - ❖ *En consignación*: la exportadora la recibe a condición de su éxito en el extranjero. Y, de hecho, puede haber algunos productores que terminen incluso debiéndole a los exportadores. Porque la exportadora le hizo ciertos adelantos, y resulta ser después que la fruta se pudrió u otras situaciones.
 - La FNE de acuerdo a las investigaciones que desarrolla, le puede sugerir al TDLC que realice determinadas funciones.

- **Letra d): Velar por el cumplimiento de resoluciones, fallos y decisiones**
 - ¹⁰**Velar por el cumplimiento de:**
 - a) ¹¹**Sus propias resoluciones en materia de concentraciones** (referidas por el Título IV de esta ley).
 - ❖ El grueso del trabajo en las concentraciones lo tiene la FNE.
 - ❖ El TDLC solo se pronuncia con respecto de:
 - casos rechazados.
 - casos en los cuales las condiciones de la concentración son consideradas inadecuadas.
 - b) ¹²**Fallos y decisiones dictadas por el TDLC o tribunales justicia en materias referidas a esta ley.**
- **Letra e): Emitir informes para TDLC**
 - ¹³Se refiere a la **emisión de informes solicitados por el TDLC.**
 - Puede ser que el TDLC en un momento determinado, frente a una materia quiera tener una información mucho más acabada desde el punto de vista jurídico, económico o ambos. Y, como el TDLC no se debe dedicar a hacer informes ni cosas por el estilo, le va a solicitar a la FNE que los haga.
 - Esto lo hace la FNE generalmente en los casos sobre **prácticas nuevas** que existen en todas partes del mundo. Tanto es así, que hoy en día hay una red de fiscalías. En este momento, hay más de 80 fiscalías o lo correspondiente en el mundo interconectadas. Entonces cuando llegan nuevas situaciones, perfectamente puede ser que el TDLC le pida a la FNE un pronunciamiento acerca de cuáles son las tendencias que se están dando a nivel mundial al respecto.
- **Letra f): Solicitar colaboración**
 - ¹⁴**Solicitar la colaboración de organismos y servicios públicos, de municipalidades, etc.**
 - Esto también puede ser fundamental, ya que hay ciertos temas que se van repitiendo.
 - ✓ Ejemplo licitaciones hechas por municipalidades:
 - ❖ Hubo muchos casos sobre esto en un comienzo del TDLC porque las municipalidades no se imaginaban los problemas de LC que podían existir en las licitaciones, y fueron saliendo todos estos problemas.
 - ❖ El proceso de licitación se puede prestar para una PR. Tanto es así, que posteriormente se incorporó como uno de los casos en el art 3 (menciona cuáles prácticas serán sancionadas).
 - ❖ De ahí entonces, en un momento determinado, el TDLC le pidió a las municipalidades que antes de llamar a una licitación debían presentarle las bases de esta licitación. *Yrarrázaval* está totalmente en desacuerdo con esto porque eso significa una burocracia fundamental.
 - ❖ Existía la **exigencia de experiencias previas en esa actividad** para el otorgamiento de la **licitación**.
 - ❖ Esto se prestaba para que la misma empresa que estaba realizando

monopólicamente la actividad, siguiera con ese monopolio.

- ❖ Por lo tanto, el TDLC llega y dice que las licitaciones deben ser transparentes.
- ❖ Después, lo que hizo el TDLC fue que no va a seguir pidiendo aprobación anterior a la licitación, pero le menciona ciertos temas sobre los cuáles debe tener cuidado.

○ **Letra g): Requerir antecedentes**

- ¹⁵**Requerir** –a cualquier oficina, servicio o entidad mencionada- que ponga a su disposición **los antecedentes** que estime necesarios para las **investigaciones, denuncias o querellas** que se encuentre practicando o que le corresponda intervenir.

○ **Letra h): Solicitud a particulares de información y antecedentes**

- ¹⁶**Solicitar a los particulares las informaciones y antecedentes** que estime necesarios con motivo de las investigaciones.
- Los requerimientos de información de la FNE a las empresas son impresionantes. Pueden llegar a ser de 15 a 20 temas distintos. Para cumplir con el requerimiento, se deberán entregar muchísimas carpetas con información y antecedentes.
- Los particulares están **obligados** a entregar toda esa información.
 - ✓ ¹⁷Y, tanto es así, que se incorporó recientemente una **sanción** bastante fuerte para el caso de que no se entregue la información.

○ De la i) a la m) se entienden con una simple lectura.

○ **Letra n): Colaboración de Carabineros o PDI**

- ¹⁸Letra n) SOLO se aplica para los casos de **colusiones** (esa es la letra a) del art 3).
- ¹⁹La **solicitud** para realizar estas investigaciones requiere una serie de requisitos bastante exigentes:
 - ✓ ²⁰**Petición fundada.** Para que la parte afectada se pueda defender. Esto aparece permanentemente en la legislación económica, y es muy razonable que así sea.
 - ✓ ²¹**Con aprobación previa del TDLC.**
 - ✓ ²²**Con autorización del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.**
- Todas las autorizaciones que del TDLC y la Corte de Apelaciones de Santiago ante estas solicitudes de la FNE se obtienen **secretamente/privadamente**, sino, no tendrían ningún efecto.
- ²³La solicitud de la FNE es que **Carabineros o PDI** -bajo la dirección de un funcionario de la FNE indicado por la solicitud- **proceda a:**
 - n.1)** ²⁴**Entrar a recintos** públicos o privados y, si fuere necesario, a **allanar y descerrajar**.
 - n.2)** ²⁵**Registrar e incautar** toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de la infracción.
 - ❖ Caso supermercados: fue fallado por el TDLC y ahora se encuentra en la CS. Ahí, lo que se hizo (hace 4-5 años atrás) fue de que se llegó entonces

a incautar toda la documentación, y se llevaron los computadores y todos los programas, etc de las 3 las cadenas de supermercados más importantes en Chile. Todo esto se hizo al mismo tiempo (en todos los supermercados solicitados) y con un despliegue policial que nunca antes se había visto en Chile. Las empresas ni siquiera sospechaban que los estaban investigando (llevaban aprox 1 año).

→ Por un lado, es razonable de que la FNE tenga facultades muy amplias, pero, los perjudicados no tienen muchos dº. La FNE se demoró 5 meses en devolver los computadores, y esto genera un gran efecto económico en las empresas.

n.3)²⁶ **Autorizar la interceptación** de toda clase de comunicaciones.

n.4)²⁷ **Ordenar** a cualquier empresa que preste servicios de comunicaciones, que **facilite copias y registros de las comunicaciones** transmitidas o recibidas por ella.

- La letra n) constituye un verdadero ítem en esta materia. Fue incorporada en la modificación del 2009 y después en la del 2016. Y, ha ido agregando situaciones que no se contemplaban anteriormente.

○ **Letra t):**

- ²⁸Este art termina con *“las demás que señalen las leyes”*.

○ **Art 39 bis: Delación Compensada**

TITULO III-DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Artículo 39° bis- *El que intervenga en alguna de las conductas previstas en la letra a) del artículo 3° podrá ser eximido de la disolución contemplada en la letra b) del artículo 26 y obtener una exención o reducción de la multa a que se refiere la letra c) de dicho artículo, en su caso, cuando aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables.¹*

Para acceder a uno de estos beneficios, quien intervenga en la conducta deberá cumplir los siguientes requisitos:²

1.- Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el Tribunal;³

2.- Abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la solicitud, salvo que la Fiscalía autorice expresamente su divulgación, y⁴

3.- Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente después de presentar su solicitud.⁵

Para acceder a la exención de la disolución o multa, en su caso, además de cumplir los requisitos señalados en el inciso anterior, quien intervenga en la conducta deberá ser el primero que aporte los antecedentes a la Fiscalía, dentro del grupo de responsables de la conducta imputada.⁶

Para acceder a una reducción de la multa, además de cumplir los requisitos señalados en el inciso segundo, quien intervenga en la conducta deberá aportar antecedentes adicionales a los presentados por el primero que haya acompañado antecedentes a la Fiscalía en virtud de este artículo.⁷ En todo caso, la rebaja de la multa que solicite el Fiscal en su requerimiento se limitará exclusivamente al segundo que haya aportado antecedentes y no podrá ser superior al 50% de la multa que de otro modo habría sido solicitada.⁸

(...)

○ **Inc 1:**

- ¹La **delación compensada** se refiere a una figura en la que una empresa que realizó una PR junto con otras, puede confesarse y de esta manera se exime de ciertas responsabilidades. Esto permite que la investigación se lleve a cabo de una manera mucho más fácil y el TDLC puede exigirle todo lo que quiera a esta empresa.
- La delación compensada es una institución nueva en la LDLC. Ciertos aspectos bien relevantes existen a partir del año 2009, y otros a partir del 2016. Vale decir, en el 2016 se perfeccionó –a juicio de *Yrarrázaval*- la delación compensada, incorporada en el 2009.
 - ✓ La incorporación de la delación compensada en el 2009 fue bien curiosa, ya que al mismo tiempo se estaba produciendo el caso de las farmacias, pero esta figura todavía no había sido definitivamente aprobada por el Congreso.
 - ✓ Caso farmacias:
 - ❖ Por lo tanto, lo que hizo *Farmacias Ahumada* fue una especie de delación compensada con la FNE, pero que no estaba en la ley.
 - ❖ Entonces, hubo muchos cuestionamientos de algunos que decían “cómo le permite la FNE llegar a una delación compensada cuando la ley todavía

no rige, sólo se está tramitando este proyecto”.

- ❖ Este tema fue tan importante que subió al TDLC, y éste se mostró de acuerdo con la delación compensada entre *Farmacias Ahumada* y la FNE, ratificando así el acuerdo entre las partes mencionadas.
- ❖ Esto significó que *Farmacias Ahumada* pagara el equivalente a 1 millón de dólares para quedarse fuera del caso, y, por lo tanto, las cadenas de farmacias que fueron verdaderamente sancionadas a nivel del TDLC y CS fueron las otras 2 (*Cruz Verde* y *Salcobrand*). *Farmacias Ahumada* se la sacó muy barata, porque a las otras empresas se les aplicó el máximo de la multa que se podía aplicar.
- ❖ El gran impulsor del acuerdo era *Farmacias Ahumada*. Ésta se adelanta al proyecto de ley todavía no aprobado y llega a un acuerdo con la FNE para pagar el equivalente de 1 millón de dólares.
- ✓ Este incidente es bien curioso. Se planteaba que mientras no se haya aprobado la incorporación de esta institución, no se puede utilizar. Los otros decían que por las facultades amplias de la FNE se puede utilizar y luego será el TDLC el que considere si es pertinente o no.
- Al comienzo –tanto en Chile, como en otros países que incorporan la delación compensada- ésta no fue muy efectiva, y hubo muy pocos casos de colusiones con delación compensada. Por lo tanto, en la UE, USA y Chile se tuvo que modificar los criterios de delación compensada para hacerla más atractiva.
- ¿Por qué siguen existiendo tantos casos de colusión cuando ya existe un esquema de delación compensada bastante desarrollado? Porque los coludidos creen que es difícil que uno de ellos se confiese. Porque, además, esta confesión requiere de la concurrencia de muchos elementos.
 - ✓ Caso colusión papel tissue: la argumentación de los suecos en contra de la papelería, fue de que la papelería era la que la había coaccionado para entrar en la colusión, y, que ellos no tenían ningún interés en la colusión. Al único interesado de la colusión, de mantener su 75% de mercado era la papelería. (Los suecos tenían un 20%). Por lo tanto, los suecos dicen que la delación compensada de la papelería no debiese correr, y que debiese correr la delación compensada de ellos (que se hace 2 meses después de la de la papelería).
- El delatante debe dar todos los elementos de la colusión, y, si la FNE no queda contenta con los elementos entregados, no acepta la delación compensada. Esto es totalmente discrecional.
 - ✓ Por eso, a la papelería le fue sacando cada vez más información.
 - ✓ Si se niega a dar información, no se otorga la delación compensada.
- La delación compensada en nuestro sistema jurídico prácticamente no había existido antes de este caso de las colusiones (papel tissue).
 - ✓ Por ahí existe una que tal vez aparezca en dº tributario, sin embargo, se ha dado muy poco en el país.
 - ✓ También había otra en materia aduanera. Si uno acusaba a una persona que no había pagado lo correspondiente a dº de aduanas, incluso le daban un

premio.

- ✓ Pero fuera de esos casos, es algo que no estaba dentro de nuestro sistema.
- ✓ Pero, ha estado dentro del sistema anglosajón desde hace mucho tiempo, y especialmente los norteamericanos lo consideran como muy razonable que exista. De ahí fue copiado por la UE, y, posteriormente por varios países latinoamericanos y otras partes.
- ✓ Esto demuestra que es una institución nueva y para muchos repugnante, porque significa que uno de los que estuvieron en la colusión acusaron esto y con esto se exime de responsabilidad.
 - *Yrarrázaval* no lo considera así en materia de LC y en materia de colusiones porque está comparando que la eficacia en materia de colusiones es directamente proporcional a la eficacia de la delación compensada.
- ✓ Incluso, después de que se incorporara la delación compensada, ha habido colusiones bien importantes sin delación compensada.
 - ❖ Pollos: no hubo delación compensada.
 - Los productores de pollo se negaron a reconocer que existía colusión, y, por lo tanto, no se delatan.
 - Esto porque no existe evidencia del acuerdo entre ellos.
 - Todo el foco de la FNE eran en las funciones que realizaba la Asociación de Productores de Aves (APA). APA es una asociación gremial integrada por los productores de pollo.
 - Lo que hacía APA –razón por la cual se los condena- era que planteaba hacia el futuro cuál debiera ser la producción de pollos en Chile. De ahí uno diría, ¿cuál es el acuerdo colusorio?, ya que éstos son realizados por muchas instituciones. El problema era que esto era para **mantener determinados % de mercado para cada uno**. Los % eran aproximadamente de 70%, 20% y 10%.
 - Lo que hacía APA era un estudio técnico que calculaba la producción y las ventas para los años siguientes. El tema está en que, si no seguían estos %, quebraran las empresas más pequeñas. Pero, a juicio de *Yrarrázaval* el TDLC dijo –y después confirmado por la CS- que esto era un acuerdo que **incide en los precios**, porque si no se respetaban los márgenes, había sanciones entre ellos.
 - APA argumenta que el mercado relevante no es solamente el mercado chileno, sino, que hay agregarle las importaciones de pollo del extranjero. Entonces, durante mucho tiempo si discutió si esas importaciones afectaban esos % acordados.
- Por lo tanto, el sistema se vuelve muy complicado para la FNE, TDLC y CS si no existe la delación compensada.
 - ✓ Caso papel tissue: se hace mucho más fácil el caso por la delación.
 - ✓ Caso pollos: el estudio se demoró alrededor de 3 años porque no hubo delación.
 - ✓ Caso supermercados: no hay delación. Por lo tanto, la FNE ha tenido que investigar el precio de los proveedores de pollos a los supermercados. En esto

se demoró entre 3 y 4 años. Lo hace para descubrir que entre las 3 cadenas había un acuerdo con respecto a los precios mínimos de pollos. El acuerdo mínimo era para evitar las liquidaciones de pollos en los supermercados. ¿Qué impacto económico tiene esto? Bien poco a juicio de *Yrarrázaval*, y, por lo tanto, no le extrañaría que la CS cambiara el fallo radicalmente o sustancialmente con un gran escándalo añadido.

- Hoy en día, el que **delata sale libre**, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley. Por más de que esto puede sonar como un *incentivo perverso*, en realidad no lo es, ya que otra empresa lo puede delatar antes. Esto se encuentra muy relacionado con el problema económico del *dilema del prisionero*. Por lo tanto, es difícil pensar para una empresa la conveniencia de la colusión para después delatarse. Por lo menos, hasta ahora no se ha producido este caso.
 - ✓ Caso vitaminas a nivel mundial: se le asigna a una empresa alemana la responsabilidad de construir el cartel, y después fue ella misma la que delata la colusión. Pero, no se llegó a la conclusión de lo que haya hecho *ex profeso*. Generalmente se hace por lo atractivo que es el precio acordado.
- En el caso chileno, la delación compensada **NO la exime de responsabilidad penal de los ejecutivos**.
 - ✓ Caso farmacias: hubo 2 ejecutivos de farmacias que lo pasaron bastante mal en tribunales penales porque la prueba era muy evidente: ellos lo habían firmado y el acuerdo era 1-2-3 (uno subo el precio hoy, otro mañana y otro pasado mañana). No había por dónde liberarse. Lo que los liberó fue que el tipo penal del código del s.XIX obviamente que no era para esos efectos.
 - ❖ *Yrarrázaval* considera que se debería derogar el art 285 del Código Penal luego de la experiencia con las farmacias. Porque si es un tema de LC nos vamos al tipo penal de la ley que se encuentra más adelante claramente descrito en la LDLC. Y, no puede haber duplicidad de tipos penales sobre la misma materia, de lo contrario, es un caos.
- El tema que se está discutiendo en varias partes del mundo es si debiese existir o no una disminución de sanción para los 2º o 3º que se delaten.
 - ✓ En algunos casos se da una disminución del orden del 50%, 25%, etc.
 - ✓ Porque hay veces en que el 1º delatante no tiene toda la información, y, puede ser que la información que entregue un 2º o 3º complemente esa información y ayude mucho al caso.
 - ✓ Esto es complicado.

○ **Inc 2:**

- ²Para acceder a algún **beneficio** de la **delación compensada** en los casos de **colusión**, se deben cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos son copulativos, vale decir, deben ir todas a la vez, no por separado.
 1. ³**Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el TDLC.**
 - ❖ Deben ser precisos, veraces y comprobables para que constituyan una

prueba suficiente.

2. ⁴**Abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la FNE haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la solicitud, salvo que la FNE autorice expresamente su divulgación.**

- ❖ Esto es así porque puede ser que el delator no haya presentado todas las pruebas, e incluso, que la FNE rechace la delación. Entonces, en definitiva, lo permite esto es que sea la FNE la que maneje los tiempos del conocimiento público.
- ❖ Tanto es así, que la ley se pone en el caso que se ordene archivar los antecedentes, vale decir, en los casos que no los considere suficientes. Salvo que la FNE autorice expresamente su divulgación.
- ❖ Entonces, la clave la tiene la FNE. Ésta es la que determina cuándo se divulga una delación compensada.
 - En el caso del papel tissue y otros casos de delación compensada, la FNE los divulgó cuando tenía la seguridad de que reunía todos los elementos del caso para poder ganar el caso, vale decir, todos los antecedentes que le permitían tener una **prueba sólida** para el caso.
 - Caso papel tissue: la FNE le da bastante importancia al lugar de reunión de la colusión, que era la Bomba Germania. Esto se debe a que quienes asisten obviamente sabían que era para una colusión. Y, también es obvio que lanzar los computadores al Canal San Carlos demuestra intención de coludirse.
- ❖ En definitiva, en los casos de colusión obviamente lo importante es ir a la FNE construyendo el caso sobre la base de muchos antecedentes que se le entregan. Tanto es así, que en la sentencia tanto del TDLC y como de la CS, estos temas salen como si fueran fundamentales. Aunque no son fundamentales, demuestran la **intención de coludirse**.

3. ⁵**Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente después de presentar su solicitud.**

- ❖ Es obvio que después de presentada la solicitud, se debe terminar la actividad colusiva.

○ **Inc 3:**

- ⁶Para acceder a la **exención de disolución o multa**, además de cumplir los requisitos señalados en el inc anterior, quien intervenga en la conducta deberá ser el **1º que aporte** los antecedentes a la FNE dentro del grupo de responsables de la conducta imputada.
 - ✓ La disolución es para el caso de personas jurídicas.
 - ✓ Para eximirse tanto de la disolución como de la multa, se debe ser el 1º delatante.

○ **Inc 4:**

- ⁷Para acceder a una **reducción de la multa** –además de cumplir con los requisitos del inc 2- quien intervenga en la conducta debe dar **antecedentes adicionales** a

- los presentados por el 1º delator.
- En la legislación chilena, sólo el 1º delator se **exime** de responsabilidad. Y, la **reducción** de la multa corresponde para el **2º delator**.
- En el caso de la UE, la reducción también se puede dar para un 3º o 4º delator.
- ⁸La **reducción no puede ser superior al 50% del monto de la multa** que de otro modo hubiese sido solicitado.
- Luego, el art continúa con la parte procedimental en materia de delación compensada.
- *La FNE se financia a través del presupuesto, al igual que el TDLC.

IV. TÍTULO IV: DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

- Este título es totalmente nuevo. Se incluye en la modificación del año 2016.
- **Antes** de este título nuevo, era **voluntario** consultar las operaciones de concentración.
- A pesar de que no era obligatorio, se consultaron probablemente la gran mayoría de las operaciones de concentración.
- Entonces, ¿cuál era la necesidad de pasar de un sistema voluntario a uno **obligatorio**? Nuevamente, por la **experiencia internacional**. Prácticamente en todos los países -poco a poco- habían pasado a ser las consultas sobre concentraciones de voluntarias a obligatorias. Esto ocurrió debido a que se estimaba que el sistema voluntario era muy complejo de administrar porque indiscutiblemente que una infinidad de concentraciones no iban a ser consultadas.
- El riesgo jurídico existente antes del 2016 de no consultar era altísimo.
 - ✓ Caso LAN-TAM: si no hubiese sido consultado, el TDLC y la CS podría haber llegado en un futuro y decirles que se debe terminar la fusión. Ese es el desastre más grande que puede existir porque las empresas donde se producen las concentraciones van cambiando íntegramente todo.
 - ❖ ¿Habrá sido conveniente para LAN fusionarse con TAM?
 - LAN era una empresa mucho más consagrada y sólida que TAM –ni relevante ni prestigiada-.
 - Tras la fusión, bajaron los resultados de LAN de forma considerable.
 - Solamente ahora LAN está volviendo a los resultados de antes de la fusión. Entonces, uno diría que esta fusión fue un desastre.
 - No se produjo un aumento inmediato en los resultados de LAN y TAM tras la fusión.
 - ❖ Con esto, uno va entiendo de que existen concentraciones que resultan y otras que no resultan. De hecho, hay empresas que han desaparecido por el hecho de fusionarse con otras que no correspondían.
 - Ha habido funciones de bancos que han sido un desastre.
 - ❖ Las **economías de escala** no son una cosa mágica, y no por ser más grandes necesariamente les va a ir mejor.
 - ❖ A nivel mundial en materia de aeronavegación, se ha expandido y existen

muchas líneas aéreas nuevas que ofrecen precios *low-cost* a tarifas insólitas (los pasajes en avión pueden llegar a salir más baratos que en bus).

→ A las empresas les interesa viajar con el máximo de la capacidad. De esta manera, tienen programas computacionales que ofrecen diversos precios por los mismos vuelos según algunos factores, como, por ejemplo, la antelación de la compra.

- **A partir del 2016**, las consultas sobre operaciones de concentración pasan a ser **obligatorias**.

18 de abril

- Desde el 2016 hasta ahora, se han presentado más de 100 operaciones de concentración.
 - La gran mayoría de ellas han sido aprobadas.
 - Existe una aprobación rápida y una aprobación lenta.
 - Muy pocas consultas de concentraciones –en este período- han sido rechazadas.
 - El sistema ha funcionado razonablemente bien.
 - ✓ Algunos critican la **lentitud** en el proceso y la **cantidad de documentación** que se pide de acuerdo con ciertas normas dictadas por la FNE, que por cierto no están en la ley.
 - ✓ También hay un reglamento para el efecto, éste fue dictado por el Ministerio de Economía.
 - ✓ Entonces, en definitiva, con respecto a la **regulación de las operaciones de concentración** existe:
 - ❖ Normas de la **ley**. Son las más importantes.
 - ❖ Normas de la **FNE**. Incluyen toda la mecánica, por ejemplo, qué documentos se presentan, en qué forma se presentan, etc.
 - ❖ Normas reglamentarias del **Ministerio de Economía**.

- **Art 46:**

TÍTULO IV - DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

Artículo 46°- Se sujetarán a las normas establecidas en este Título las operaciones de concentración que le sean notificadas a la Fiscalía Nacional Económica, según lo prescrito en los artículos siguientes.¹

- ¹Lo primero que hace la ley -respecto a la regulación de las operaciones de concentración- es mencionar en el art 46 que las operaciones de concentración se deben sujetar a las normas de este título.
 - ✓ Por lo tanto, solamente se aplican estas normas para las concentraciones de empresas que estén por **encima del umbral**. Éstas están **obligadas por ley** a consultar.
 - ✓ Incluso, se permite que concentraciones de empresas por debajo del umbral voluntariamente consulten. Esto se da por un asunto de **seguridad jurídica**.

○ **Art 47: Definición operación de concentración**

TÍTULO IV - DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

Artículo 47- Se entenderá por operación de concentración todo hecho, acto o convención, o conjunto de ellos, que tenga por efecto que dos o más agentes económicos¹ que no formen parte de un mismo grupo empresarial² y que sean previamente independientes entre sí³, cesen en su independencia en cualquier ámbito de sus actividades⁴ mediante alguna de las siguientes vías:⁵

a) Fusionándose, cualquiera que sea la forma de organización societaria de las entidades que se fusionan o de la entidad resultante de la fusión.⁶

b) Adquiriendo, uno o más de ellos, directa o indirectamente, derechos que le permitan, en forma individual o conjunta, influir decisivamente en la administración de otro.⁷

c) Asociándose bajo cualquier modalidad para conformar un agente económico independiente, ⁱdistinto de ellos, que desempeñe sus funciones de ⁱⁱⁱforma permanente.⁸

d) Adquiriendo, uno o más de ellos, el control sobre los activos de otro a cualquier título.

Para los efectos de lo dispuesto en este Título, se entenderá por agente económico toda entidad, o parte de ella, cualquiera que sea su forma de organización jurídica o aun cuando carezca de ella, que ofrezca o demande bienes o servicios.¹⁰ Se considerará asimismo como un agente económico el conjunto de activos tangibles o intangibles, o ambos, que permitan ofrecer o demandar bienes o servicios.

- Es un art muy complicado porque pretende **definir cuándo se producen las operaciones de concentración.**

○ **Inc 1:** menciona cuándo se está ante una operación de concentración.

- ¹Indiscutiblemente, deben ser **2 o más** agentes económicos para que sea una concentración.
- ²**No** pueden formar parte del **mismo grupo empresarial.**
 - ✓ Se excluye del término de concentración a las empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial, ya que éstas tienen los mismos dueños, entonces, no tendría ningún sentido.
 - ❖ Por ejemplo, si *Santa Isabel* y *Jumbo* se juntasen, no calificarían como una concentración.
 - ✓ Los grupos empresariales se van reorganizando permanentemente dentro del grupo. Vale decir, ciertas empresas se traspasan los activos unos a otros, etc.
 - ✓ El *grupo empresarial* se encuentra definido por la **Ley de Valores (LVS)**. Incluso, cada cierto tiempo la CMF (anteriormente la SVS) da a conocer públicamente cuáles son los grupos empresariales. En este momento, son del orden de 100 grupos empresariales en Chile, es decir, 100 grupos de empresas que caen dentro de la definición que da la LVS.
- ³Deben ser empresas **independientes entre sí.**
 - ✓ Vale decir, no pueden ser de un mismo grupo empresarial.
 - ✓ Deben ser independientes entre sí antes de efectuar la concentración.
- ⁴Deben estar **cediendo su independencia** -en cualquier ámbito de sus actividades- mediante las **vías** que se mencionan a continuación.
 - ✓ Acá surge el ejemplo de los **joint ventures** (empresas conjuntas).
 - ❖ Los *joint ventures* son **uniones de 2 o más empresas que lo hacen con el**

fin de realizar proyectos en común.

- ❖ Hoy en día, especialmente en los grandes proyectos hay muchos *joint ventures*. Esto se debe a la incapacidad de que una sola empresa tenga todo el capital para los efectos de realizar lo que va a hacer el *joint venture*, o simplemente para asociar empresas que incorporan al proyecto elementos distintos como: capital, tecnología, etc.
 - ❖ En Chile, hay muchos *joint ventures* en materias mineras, ya que son proyectos enormes en los cuales se asocian 2 o más empresas para realizar un proyecto en común.
 - ❖ No es fácil dilucidar el tipo de *joint venture*. En algunos *joint ventures* desaparecen las empresas originales, en otros continúan las empresas, y, en otros continúan parcialmente las empresas originales. Entonces, hay una infinidad de situaciones.
 - ❖ Curiosamente esta figura tan importante prácticamente no está definida en ninguna parte.
 - ❖ De los *joint ventures* están surgiendo problemas tributarios. En definitiva, ¿éstos tienen que tener un Rut de *joint venture* o pueden operar con los Rut de las empresas aportantes?
 - ❖ Esta figura está siendo cada vez más utilizada, y, especialmente en los grandes proyectos de inversiones.
- **Inc 2:** ⁵Las vías mencionadas, o, mejor dicho, las **4 maneras** por las que se considerará una operación de concentración son:
- a) ⁶Fusión de empresas.**
- ✓ No importa la forma de organización societaria de las entidades que se fusionen, ni la entidad resultante de ésta fusión.
 - ✓ Toda fusión sobre el umbral (con una posición de mercado dominante) será sancionada.
 - ✓ Esto se estudia en dº comercial con lujo de detalle, porque existen distintos tipos de fusiones, y es muy importante la distinción que existe entre ellos para los efectos comerciales.
 - ✓ La letra a) es muy amplia. Se refiere a la fusión al margen de:
 - ❖ la forma de organización societaria de las empresas que se fusionan.
 - ❖ la entidad resultante de la fusión.
 - ✓ Entonces, todo tipo de fusión que esté por **encima del umbral**, obviamente debe ser **consultado**.
- b) ⁷Adquisición de dº o acciones.**
- ✓ Debe adquirir dº que le permitan **influir decisivamente en la administración de otro**.
 - ✓ Este también es un tema comercial de gran envergadura porque lo que importa en la adquisición es el **resultado**. Y, si por ese resultado la empresa que adquiere, tiene un **control de la empresa adquirida** al margen del cual es el % de la adquisición, estará ante una operación de concentración.
 - ✓ Esto en el mundo comercial se produce permanentemente.

- ✓ Por ejemplo ¿qué pasa si una empresa adquiere el 10% de otra empresa? ¿Se considera adquisición o no? ¿Se considera que tiene que pedir la autorización de la FNE?
 - ❖ Depende del % que tengan los otros miembros.
 - ❖ Entonces ese 10% puede ser muy relevante o muy irrelevante, por ejemplo, para la elección del directorio.
 - ❖ Esto va a depender de cómo se comporta el resto de los accionistas. Por ejemplo, si son muchos accionistas, pero se juntan para la elección de directorio terminarán representando un % muy alto.
 - ❖ Esto se debe a que las elecciones de directores en las SA se hacen por **cifras repartidoras**, entonces, en definitiva, todo depende del comportamiento de los accionistas.
 - ❖ Ejemplo: pelea de médicos y accionistas en la Clínica Alemana
- ✓ Clubes de fútbol: Yrarrázaval desconoce que haya concentraciones. En definitiva, hay algunos con más accionistas y menos accionistas, pero una concentración propiamente tal no la ve. Poder calcular el umbral de un club de fútbol es muy complicado. En el resto, el umbral depende de las ventas.
- ✓ La adquisición de una parte de la empresa es **directa o indirectamente**.
 - ❖ La *indirecta* se refiere a que se pueden utilizar otras sociedades y otras personas para los efectos de las adquisiciones. Acá se debe probar que detrás de los compradores indirectos están los directos.
 - ❖ Entonces, la ley dice que le da lo mismo si la adquisición es directa o indirecta.
- c) ⁸**Asociaciones o joint ventures.**
 - ✓ Se refiere a asociaciones bajo cualquier modalidad para formar un agente económico ⁱindependiente, ⁱⁱdistinto de ellos, y, que desempeñe sus funciones de ⁱⁱⁱforma permanente.
- d) ⁹**Adquisición de activos que le permitan tener el control de otro.**
 - ✓ Puede ser a cualquier título.
 - ✓ En dº comercial se estudia el concepto de *control*.
 - ❖ Generalmente, el control es una situación *de hecho*, entonces, en definitiva, no es fácil analizar cuándo una empresa ha adquirido el control sobre otra.
 - ❖ Es más fácil de determinar cuándo adquiere un 50%, pero en los casos donde adquiere un 5% por ejemplo, y con ese % tiene el control de otro, se debe analizar con mayor detalle.
 - ✓ Generalmente, se genera más la letra b) que la d). Pero, hay casos en donde los activos comprados son % muy altos con el interés de tomar administración de la empresa, o, tener una voz decisiva en actos de administración de la empresa. Entonces, ahí es donde se generaría el control. El concepto de *control comercial* es tremendamente amplio.
- ¹⁰Esta disposición termina indicando que, para los efectos de este título, se entenderá por **agente económico** a cualquier entidad -o parte de ella- que esté **ofreciendo o demandando bienes y servicios**.

○ **Art 48: Cálculo del umbral**

TÍTULO IV - DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

Artículo 48- *Deberán notificarse a la Fiscalía Nacional Económica¹, en forma previa a su perfeccionamiento², las operaciones de concentración que produzcan efectos en Chile³ y que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:⁴*

a) Que la suma de las ventas en Chile de los agentes económicos que proyectan concentrarse haya alcanzado, durante el ejercicio anterior⁵ a aquel en que se verifique la notificación, montos iguales o superiores al umbral establecido mediante resolución dictada por el Fiscal Nacional Económico.⁶

b) Que en Chile, por separado, al menos dos de los agentes económicos que proyectan concentrarse hayan generado ventas, durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifique la notificación, por montos iguales o superiores al umbral establecido mediante resolución dictada por el Fiscal Nacional Económico.⁷

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las ventas se calcularán de la siguiente manera:⁸

(...)

Estarán obligados a practicar la notificación de la que trata este artículo, conjuntamente, los agentes económicos que hayan tomado parte en la operación de concentración.⁹ Los terceros que no hayan tomado parte en la operación de concentración no podrán practicar la notificación.

(...)

El reglamento podrá contemplar un mecanismo de notificación simplificada, que requiera del notificante acompañar una menor cantidad de antecedentes para ciertas operaciones o categorías de operaciones de concentración.¹⁰

Las operaciones de concentración que no igualen o superen los umbrales referidos en las letras a) y b) de este artículo podrán ser notificadas en forma voluntaria por los agentes económicos que proyectan concentrarse. Las notificaciones voluntarias se sujetarán a las mismas reglas que las obligatorias, en la medida que la operación no se haya perfeccionado al momento de la notificación.¹¹

(...)

- Este art es sumamente complejo.

○ **Art 48 inc 1:**

- ¹Todo el proceso de concentración se hace en la **FNE**.
 - ✓ El TDLC solamente se mete en los casos de rechazo o con respecto a las condiciones para que ésta sea aprobada. Fuera de eso, no se mete el TDLC.
- ²La consulta debe hacerse en forma **previa** al perfeccionamiento de la concentración.
 - ✓ Vale decir, no se puede realizar una concentración por sobre el umbral si no hay autorización otorgada por parte de la FNE.
 - ✓ Esto es tan relevante que hace que a veces se considera este proceso como una **traba** para realizar determinados proyectos de inversión.
 - ❖ Esto es parecido a lo que ocurre en materia medioambiental.
 - Existen 2 tipos de proyectos medioambientales:
 - a) **Evaluación de impacto ambiental (EIA)**. Hay ciertos proyectos que no pueden empezar a realizarse sin la autorización de las autoridades ambientales. Se les debe hacer una *evaluación de impacto ambiental*.

b) Declaración de impacto ambiental. Lo único que se requiere es una *declaración de impacto ambiental*. En estos casos, el proyecto puede comenzar sin autorización de la autoridad medioambiental. La declaración permite iniciar el proyecto. Después, ese proyecto debe acomodarse a las exigencias que le vayan poniendo a ese proyecto.

-Caso Costanera Center: lleva como 10 años porque se le han incorporado nuevas exigencias medioambientales, también provenientes de obras públicas y de otras partes. Y, por lo tanto, este proyecto no se ha podido concluir justamente por estas exigencias.

→ La gran diferencia de los casos medioambientales con los de concentración, es que en los casos de concentraciones están establecidas todas las fechas por lo que el proceso es relativamente **rápido**.

-Incluso la FNE ha hecho **formularios** para la concentración. Así, se sabe cuáles documentos se deben presentar en los distintos proyectos de concentración.

-Además, ha establecido reglas internas –denominados **instructivos** por la FNE- con respecto a cómo opera la FNE en relación a la aprobación de los proyectos.

-En cambio, en materia medioambiental no existe ni formularios ni instructivos. Esto explica que haya muchos proyectos medioambientales cuya aprobación demora 3-4-5-10 años (10 en el caso del Costanera Center).

-Yrarrázaval dice que ojalá esto no ocurra en materias de concentraciones porque sería malo ya que en el mundo comercial las cosas se mueven con una cierta velocidad.

▪ ³La operación de concentración debe producir **efectos en Chile**.

✓ Por lo tanto, una operación de concentración entre empresas chilenas que están operando en Argentina, no debe ser consultada.

❖ Ejemplo, si se une Falabella y Cencosud (ambas empresas son chilenas) en Argentina: ¿Cómo se determina si tiene efectos en Chile o no? Las 2 empresas están establecidas en Chile, además, sus accionistas son en la gran mayoría chilenos.

→ Esto es complicado de resolver, a causa de los efectos de materia de LC. Hay distintos criterios al respecto. Algunos creen que los efectos se refieren a las consecuencias que traen para Chile los ingresos obtenidos en Argentina (criterio bastante estricto), otros, creen que los efectos deben ser efectos reales, y, que en definitiva esa operación de concentración en Argentina tenga efectos sobre los mercados chilenos.

❖ Ejemplo refrigeradores: el caso de la colusión en Brasil entre refrigeradores brasileños y refrigeradores a nivel mundial fue traído a Chile.

→ En este caso hubo delación compensada en Brasil NO en Chile.

→ La CS –con buen criterio a juicio de Yrarrázaval- dijo que esa colusión tenía efectos en Chile, y, por tanto, sancionó a la empresa que no se había

delatado (empresa brasilera).

→ Lo hace porque se afectó el precio de los refrigerados en Chile de estas 2 grandes marcas (brasileira y mundial).

→ En este caso, el argumento de la empresa brasilera y la mundial era que esta colusión no tenía efectos en Chile. Decían que se había hecho en Brasil y para el mercado brasilero. La CS sostiene que de por mucho que se haya hecho en Brasil y para el mercado brasilero, tenía efectos sobre el precio de los refrigeradores en Chile (porque era la pieza más importante de los refrigeradores).

- ⁴El umbral no está establecido en la ley, sino que está establecido en el **reglamento** con autorización de la ley. Pero, la ley le plantea las **bases para el cálculo del umbral** en la letra **a) y b)**.

○ **Inc 2: Letra a)**

- ⁶Que la suma de las **ventas en Chile** haya alcanzado -durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifique la notificación- montos iguales o superiores al umbral establecido por la FNE.
 - ✓ Se refiere a la suma de las ventas de los que se **unen**.
 - ✓ ⁵El *ejercicio anterior* se refiere a todas las ventas en los 12 meses anteriores.
 - ✓ En este momento, la cifra impuesta para las ventas es de **1.800.000 UF** (aprox 75 millones de dólares).

○ **Inc 3: Letra b)**

- ⁷Que en Chile, por separado, al menos 2 de los que proyectan concentrarse hayan generado **ventas** -durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifique la notificación- por montos iguales o superiores al umbral establecido por la FNE.
 - ✓ Se refiere a las ventas **por separado** de al menos 2 agentes económicos por un monto igual o superior -que actualmente está fijado por la FNE- a **290.000 UF** (aprox 12 millones de dólares).

- Las cantidades de la letra a) y b) no son caprichosas. Lo que hizo la FNE –y a juicio de *Yrarrázaval* muy bien hecho- fue que se basó en **umbrales de otros países parecidos a Chile**, y, lo determinó de acuerdo a eso. Por lo tanto, hoy en día hay una equivalencia razonable entre este umbral con el de Brasil, México, etc.

○ **Inc 4:**

- ⁸El art continúa indicando que “*para los efectos de lo dispuesto en este art, las **ventas** se calcularán de la siguiente manera*”. Después menciona cómo se entienden las ventas en 3 casos, pero no profundizaremos en esto.
 - ✓ Para calcular las ventas de una empresa hay muchos métodos distintos. Y, por lo tanto, la ley especifica los cálculos que se deben hacer para calcular las ventas del período anterior.

- **Inc 9:**
 - ⁹Estarán obligados a practicar la notificación **conjuntamente** los agentes económicos que hayan tomado parte en la operación de concentración.
 - ✓ Esto se hace para que la presentación sea una. Sino, habría varias presentaciones sobre un mismo caso, y probablemente con cifras distintas.
 - Después, viene la parte procesal del art.
 - Las operaciones de concentración deben ser notificadas en el **Diario Oficial**.
- **Inc 12:**
 - ¹⁰Después, opera una serie de plazos para **procedimientos cortos y largos**.
 - ✓ Esta distinción la hace la FNE dependiendo por la **complejidad** de la concentración. El procedimiento que se utilizará en cada caso es determinado por una decisión propia de la **FNE**.
 - ❖ Si los antecedentes son muchísimos o no son claros, generalmente la FNE se va a ir a **procedimiento largo**.
 - ❖ Por el contrario, si es una concentración relativamente sencilla y con documentación clara, lo puede despachar por el **procedimiento corto**.
 - ✓ Actualmente, del orden del 80% tiene procedimiento corto y 20% largo. Esos % pueden cambiar a través del tiempo.
- **Inc 13:**
 - ¹¹De todas formas, se pueden consultar **voluntariamente** operaciones de concentración que no igualen o superen los umbrales referido en las letras a) y b) de este art. Éstas consultas se sujetarán a las **mismas reglas** que las consultas obligatorias si la operación no se ha perfeccionado al momento de la notificación.
- **Art 51**

TÍTULO IV - DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN
Artículo 51- La resolución que ordene el inicio de la investigación será publicada resguardando la información confidencial de los notificantes.¹

 - Éste es otro art procesal.
 - ¹*La resolución que ordene el inicio de la investigación será publicada resguardando la información confidencial de los notificantes.*
 - ✓ Porque indiscutiblemente que, en los casos de investigación, las empresas competidoras estarán muy interesadas en tener acceso al expediente para tener información confidencial.
 - ✓ Por lo tanto, el tema de la **reserva** y de la **confidencialidad** está permanentemente presente en la ley.
- La consulta/notificación de la operación de concentración va a terminar con una de las 3 alternativas siguientes:
 1. **Aprobación.** Hasta ahí llega el caso.
 2. **Rechazo.** Se puede reclamar ante el TDLC y posteriormente ante la CS.

- ✓ Aquí, el TDLC hace algo parecido a la CS con respecto a las sentencias del TDLC: entra a analizar si la decisión de la FNE es razonable o no es razonable. El TDLC puede aprobar, rechazar o aprobar con condiciones la notificación que anteriormente fue rechazada por la FNE.

3. Aprobación con condiciones. El consultante puede recurrir al TDLC cuando las condiciones no son satisfactorias para él. Y, si incluso el TDLC las mantiene, se puede recurrir ante la CS.

V. TÍTULO V: DE LAS SANCIONES PENALES

- Las sanciones penales existieron en esta ley desde el año 73-2003. Vale decir, 30 años de experiencia con sanciones penales en la LDLC. Estos 30 años reflejaron que por lo menos en el sistema jurídico chileno es muy difícil que haya sanciones penales efectivas para casos de LC.
- Vuelven estas sanciones en el 2016. Aquí se incorpora este título a la ley.
- En aquel entonces, el procedimiento no era tan distinto al actual. De hecho, el esquema es bastante parecido.
- Entre el año 73-2003 la **comisión resolutive** era la que tenía que decidir si le pedía o no al FNE que iniciara la acción penal en la justicia del crimen. Esto tiene la misma forma actual, en donde el **TDLC** NO determina la acción penal, sino que determina que la FNE inicie la acción penal.
- En este periodo de 30 años, la ley contemplaba la sanción penal en donde la comisión resolutive le pedía al FNE que iniciara la acción penal.
- Hubo 5 casos estos 30 años, y en todos a la FNE le fue mal en la justicia del crimen. Le fue mal por 3 razones:
 1. Para sancionar, se debe tener **dolo penal**, es decir, *intención de causar daño*.
 2. Además, estaban tipificados los delitos en términos muy **generales**. Esto, implica que el demandado pueda argumentar que no tenía idea de que estaba incurriendo en esta práctica por la cual se lo está imputando como excepcionalmente grave (por algo es sanción penal).
 3. Un tercer tema, es que la sanción penal, por regla general, se aplica a las **personas naturales** NO jurídicas. Y, la gran mayoría de las sanciones en materia de LC son a las personas jurídicas. Esto se hace así porque lo que le importa a la FNE es el comportamiento de la persona jurídica, que, por cierto, es mucho más fácil de probar que el comportamiento de las personas naturales.
 - En definitiva, estos 3 elementos básicos explican de que a pesar de que la ley contemple sanciones penales, son bastante poco eficaces. Asustan mucho, pero en realidad no se aplican mucho.
 - Es por esto que a nivel mundial la UE no contempla sanciones penales. En cambio, USA si las contempla. ¿Qué sistema será mejor?
 - Ya existe una gran diferencia entre ambos sistemas, por una parte, USA contempla que prácticamente todas las sanciones son **negociables**. Esto para la UE y para Chile es una aberración. Entonces, lo que hacen las autoridades de LC en USA es pedir la sanción penal, y al día siguiente tiene al ejecutivo negociando para tratar de salvarse. Y, generalmente no se le aplica la sanción

penal porque se llega a un acuerdo anteriormente. Lo que se negocia es una disminución de la pena, y, generalmente para tratar de llegar a sanciones pecuniarias más que la sanción de reclusión.

- Desde el año 2016 en adelante, por más de que ha habido casos importantes, no ha existido la petición del TDLC a la FNE para que inicie la acción penal.
- **Art 62: Sanción penal para colusiones**

TÍTULO V - DE LAS SANCIONES PENALES

Artículo 62°.- *El que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, u órganos públicos¹, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. ²*

Asimismo, será castigado con inhabilitación absoluta³ temporal⁴, en su grado máximo, para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales⁵, el cargo de director o gerente de empresas del Estado o en las que éste tenga participación⁶, y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o profesional.⁷

- **Inc 1:**
 - ¹Se está refiriendo a la **sanción para las colusiones**.
 - Lo que se menciona en este inc es prácticamente lo mismo a lo indicado en el art 3 letra a) de la LDLC, que se refiere a las colusiones.
 - ²La pena será entre **3 años** (presidio menor en su grado máximo) y **10 años** (presidio mayor en su grado mínimo) de cárcel.
 - El Código Penal establece una tabla que contempla las distintas penas y la duración que tienen.
- **Inc 2:**
 - ³Estas inhabilitaciones -a juicio de *Yrarrázaval*- son extremadamente duras porque es una inhabilitación **absoluta** de ejercer estos cargos. Y, por lo tanto, las personas involucradas además pueden recibir esta sanción.
 - ⁴Estas inhabilitaciones son absolutas **temporales**, por lo que se debe determinar el tiempo por el cual estarán inhabilitados.
 - Asimismo, será castigado con **inhabilitación absoluta temporal**, en su grado máximo para **ejercer el cargo**:
 - ✓ ⁵de director o gerente de una SA abierta o sujeta a normas especiales.
 - ✓ ⁶de director o gerente de empresas del Eº o en las que éste tenga participación.
 - ✓ ⁷de director o gerente de una asociación gremial o profesional.
- Luego, vienen unas reglas bastante complejas que son de dº penal (los numerales de este art). Ahí, se habla de las circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes.

○ Art 63

TÍTULO V - DE LAS SANCIONES PENALES

Artículo 63- *Estarán exentos de responsabilidad penal por el delito tipificado en el artículo 62 aquellas personas que primero hayan aportado a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes de conformidad al artículo 39 bis.¹ El requerimiento del Fiscal Nacional Económico individualizará a las personas exentas de responsabilidad penal y dicha calidad será así declarada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.*
(...)

- Este art es bastante curioso porque contempla la **delación compensada**, que anteriormente está en el art 39 bis.
- Esto se hace así porque como se incorporó todo un capítulo para la sanción penal, se estimó prudente que se repitiera -en sus conceptos más fundamentales- la delación compensada.
- Estarán **exentos de responsabilidad penal** -por el delito tipificado en el art 62- los 1º delatores.
- Luego, se da una cantidad de normas con respecto a esta materia.

○ Art 64

TÍTULO V - DE LAS SANCIONES PENALES

Artículo 64- *Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica¹, la que podrá interponerla una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,² sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.³ Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.*

El Fiscal Nacional Económico deberá interponer querella en aquellos casos en que se tratare de hechos que comprometieren gravemente la libre competencia en los mercados.⁴
(...)

La interposición de la querella o la decisión de no formularla deberá tener lugar a más tardar en el plazo de seis meses, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.⁵
(...)

- Este art es muy relevante.
- ¹Las **investigaciones** de los hechos de sanciones para **colusiones** SOLO se podrán iniciar por querella formulada por la **FNE**. Vale decir, el único querellante es el FNE.
- ²La **querella** se puede interponer SOLO cuando la cuando hay una **sentencia definitiva ejecutoriada del TDLC**. Vale decir, el FNE puede ejercer la acción penal cuando la sentencia esté ejecutoriada. Puede estar ejecutoriada en 2 alternativas:
 1. Pasó a la CS y se genera la sentencia ejecutoriada.
 2. No se reclama la sentencia del TDLC, por lo que pasa a estar ejecutoriada.
- ³El hecho de que no sea admisible alguna denuncia u otra querella se refiere a que el delito en materia de LC **solamente lo ejerce la FNE** después de haber sentencia

ejecutoriada, por lo tanto, el Ministerio Público tiene que salirse de todo esto. La aceptación de esto por parte del Ministerio Público costó muchísimo.

- ⁴El **FNE deberá interponer querella** en los casos en que se tratase de hechos que comprometieran **gravemente la LC** en los mercados. Vale decir, es el FNE el que califica si debe iniciar la querella según si el caso es grave o no.
- ⁵Luego, se otorga un plazo de **6 meses** para la decisión de hacer o no la querella. Y, después entonces, empieza una querella como cualquier otra.

○ **Art 65: Prescripción acción penal del delito de colusiones**

TÍTULO V - DE LAS SANCIONES PENALES

Artículo 65- La acción penal para la persecución del delito descrito en el artículo 62 prescribirá en el plazo de diez años, contado desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¹

- ¹La acción penal para la persecución del delito -de las **colusiones**- **prescribirá** en un plazo de **10 años**.
- *Hay 5 tipos de prescripciones dentro de la misma ley: existe una prescripción normal de 3 años (residual), y especiales de 2 años (multas), 4 años (acciones civiles), 5 años (acciones para caso de colusiones), y, la de 10 años (solamente para la acción penal).

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LPC) (Ley 19.496)

- Todos los países poseen una Ley de Protección al Consumidor.
- En Chile, la 1ª ley fue de la década 80`. Era una ley muy corta, pero bastante clara con respecto de los hechos que se sancionaban bajo la ley. Se sancionaban los 7 hechos –a juicio de *Yrarrázaval*- más importantes, se describían relativamente bien, y, se establecía de que la jurisdicción competente para estos efectos eran los **jueces de policía local (JPL)**, como lo sigue siendo para muchos casos.
 - ¿Por qué se habrá preferido en la Ley de Protección al Consumidor la jurisdicción de los JPL?
 - Porque los JPL en Chile se encuentran en todas partes.
 - Además, por el tipo de materias que han tratado los JPL, que se dedica fundamentalmente a los casos de tránsito, patente de alcoholes, etc.
 - La justicia de policía local está organizada en función a las comunas.
 - La gran mayoría de los JPL son abogados, y, excepcionalmente hay algunos casos en los cuales no son abogados. Y, los jueces tienen bastante experiencia en la materia de los casos que tratan. No son –como los consideran algunos- jueces de inferior nivel. Pero el tipo de asuntos en el cual se le agrega la PC, obviamente que son de menor cuantía, y, fundamentalmente lo que hacen los JPL es establecer la **indemnización de perjuicios** por las infracciones (tránsito, alcoholes, etc.).
 - En muchos casos, las sentencias de los JPL son apelables a veces ante los jueces civiles, o, a veces ante la Corte de Apelaciones.
 - En el contexto de la PC, la gran mayoría de los casos se tratarán con un procedimiento corto, sin necesidad de abogados y en la cual las **audiencias** van a ser muy relevantes, incluso, en muchos casos hay una sola audiencia y las partes deben llegar con toda la prueba a la audiencia. Lo que en materia de LC se demora varios meses, en materia de JPL se soluciona en una audiencia.
 - El gran tema es el hacer de estos casos lo más cercanos a las personas, específicamente a los consumidores. Y, efectivamente eso se obtiene con los JPL. Esto, ha sido muy controvertido. Algunos creen que esta materia debiese ser tratada por los jueces civiles porque éstos le darían una categoría mayor a la LPC. Pero, toda la jurisdicción civil se encuentra totalmente atochada.
 - Un 75% de las causas de jurisdicción civil son de cobranzas. Justamente, hay una comisión que está trabajando en este momento para la reforma del procedimiento civil, y ésta ha dicho que en la medida que la justicia civil esté atochada por causas de cobranza no puede funcionar adecuadamente.
 - ✓ En otros países, estas causas ni siquiera llegan a los tribunales porque tienen sistemas especiales para la cobranza.
 - Además, está el recurso de protección en contra de las ISAPRES, que en este momento son del orden de 300.000.
 - Todo esto va distorsionando el quehacer del poder judicial.
 - El gran inconveniente que tiene este sistema –a juicio de *Yrarrázaval*- es que la jurisprudencia a penas se publica ya que para los otros jueces no tiene ninguna importancia. Y, a pesar de que la jurisprudencia tiene menor importancia que en

el caso del dº de la LC, igual tiene importancia, ya que es relevante saber cómo fallan otros jueces.

- ¿Por qué proteger al consumidor?
 - Si estas legislaciones son relativamente recientes, durante siglos y siglos no se protegió al consumidor.
 - Una cosa es proteger la competencia, y, otra cosa muy distinta es proteger al consumidor.
 - En la competencia, lo que se está protegiendo es una de las bases fundamentales del sistema económico.
 - Pero, en relación a la PC, existen legislaciones buenas, regulares o malas.
 - Se protege al consumidor por las **asimetrías** existentes entre el *proveedor* y *consumidor*. ¿Por qué se produce asimetría?
 - Uno puede decir que se producen asimetrías en todas partes, por ejemplo, en materia laboral o en cualquier contratación (por ejemplo, en seguros).
 - Las asimetrías existen y van a seguir existiendo, entonces, lo que pretende la ley es reducirlas, no eliminarlas. No puede eliminarlas porque no se dará nunca una igualdad de condiciones; siempre hay una parte que sabe más que la otra. Por lo tanto, lo que pretende una ley como esta es **reducir la asimetría** con respecto de que en esta relación -generalmente de compraventa-. Si uno como consumidor desea saber más para mis decisiones de consumo, debe investigar. La ley dice que hay ciertos aspectos de esta relación contractual –entre consumidor y proveedor- que serán tipificados y sancionados. La tipificación se hace en la ley.
 - ✓ En esta ley, hay una gran cantidad de normas reglamentarias. Son tantas, que muchas veces resulta ininteligible, por ejemplo, las que tratan sobre el SERNAC financiero.
- ¿Por qué la LPC pasó de tener 2 páginas a ser tan extenso?
 - Por el **art 19 N°21 CPR**. Esto, es regulación, y, el único que puede regular en Chile es el legislador NO el SERNAC.
 - Incluso, en la última modificación de la ley se pretendía que SERNAC tuviera ciertas facultades normativas, que, de hecho, fueron aprobadas por el Congreso, pero rechazadas por el TC en razón del art 19 N°21 CPR. El TC dijo que, si se le otorgaban facultades normativas al SERNAC, el sistema se iba a terminar distorsionando totalmente.
 - El problema es ¿hasta dónde llega la regulación?, y, ¿dónde deja de ser regulación propiamente tal y pasa a ser una mera aplicación de la ley? Esto es una línea bastante delgada.
 - *Yrarrázaval* comparte el criterio del TC de que las facultades normativas que estaba teniendo el SERNAC eran inconstitucionales.
- ¿No habrá además de la asimetría, alguna otra razón para esta protección?
 - Supongamos que no existiera la ley de protección al consumidor, y, uno entra a un supermercado, entonces, ¿cómo compro?
 - Hay del orden de 10.000 bienes distintos en los supermercados, entonces ¿cómo compro?
 - Se supone que debería elegir entre miles de bienes distintos que hay dentro de

ese supermercado, entonces, uno diría que de acuerdo con la clase de producto que quiera consumir, pero uno no sabría la variedad de productos que existen.

- En definitiva, sería absolutamente caótico no tener una LPC.
 - ✓ Implicaría que el consumidor tuviera que gastar mucho tiempo para tomar decisiones simples.
 - ✓ El consumidor necesita cierta **información** que, debe ser **verdadera**. Por lo tanto, gran parte de los tipos que hay en la ley tienen relación con esto, es decir, que el proveedor –a veces de forma obligatoria y otras de forma voluntaria- entregue información, y que, sobre la base de esta información, el consumidor tome la decisión respecto a su compra.
 - ✓ Esto, no es sencillo, y, por eso que existen los famosos sellos en la comida. Los sellos en la comida son una forma simplificada de entregarle información a los consumidores. Estos, han generado una cantidad de problemas impresionante porque el reglamento sobre los alimentos es de las cosas más cuestionadas que hay.
 - ✓ Hoy en día, las decisiones de consumo se deben hacer de forma **rápida**, y por eso, se hace necesaria la **mayor cantidad de información**.
 - ✓ Para analizar esas compras, uno necesita cierta información clave para tomar de forma correcta las decisiones.
 - ✓ Uno como consumidor se equivoca todos los días. Porque muchas veces no compramos ni lo más barato ni lo de mejor calidad, porque no hacemos la comparación o el estudio científico de cuál era el producto que nos convenía.
- Por lo tanto, las **asimetrías** y la **rapidez** en las decisiones de consumo juegan un papel muy importante en relación a la ley.
- La ley establece **normas sobre protección de los dº de los consumidores**.

I. TÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

○ Art 1: Objetivo y definiciones

TITULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

Artículo 1- *La presente ley tiene por objeto¹ normar las relaciones entre proveedores y consumidores², establecer las infracciones en perjuicio del consumidor³ y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.⁴*

Para los efectos de esta ley se entenderá por:⁵

1.- Consumidores⁶ o usuarios⁷: *las personas naturales o jurídicas⁸ que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso⁹, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales¹⁰, bienes o servicios.¹¹ En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores.¹²*

2.- Proveedores: *las personas naturales o jurídicas¹³, de carácter público o privado¹⁴, que habitualmente¹⁵ desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.¹⁶*

No se considerará proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.¹⁷

3.- Información básica comercial: *los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones¹⁸ que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor¹⁹, en cumplimiento de una norma jurídica.*

Tratándose de proveedores que reciban bienes en consignación para su venta, éstos deberán agregar a la información básica comercial los antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados financieros cuando corresponda.²⁰

En la venta de bienes y prestación de servicios,²¹ se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio²² que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso²³ y los términos de la garantía cuando procedan.²⁴ Se exceptuarán de lo dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a granel.²⁵

La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios²⁶ que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno.²⁷ Respecto de los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que acceden.²⁸

4.- Publicidad: *la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio²⁹, entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato.³⁰ Son condiciones objetivas aquellas señaladas en el artículo 28.*

5.- Anunciante: *el proveedor de bienes, prestador de servicios o entidad que, por medio de la publicidad, se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios³¹ cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad, o motivarlo a su adquisición.*

6.- Contrato de adhesión: *aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.³²*

7.- Promociones: *las prácticas comerciales, cualquiera sea la forma que se utilice en su difusión, consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más favorables que las habituales, con excepción de aquellas que consistan en una simple rebaja de precio.³³*

8.- Oferta: *práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria, en relación con los habituales del respectivo establecimiento.³⁴*

- El art 1 es muy necesario –a juicio de *Yrarrázaval*- ya que **define el ámbito de aplicación de la ley**.
 - Acá se entra en problema con el dº de competencia, ya que se llevan muchos casos de PC -y de CD- al dº de la competencia. Esto se hace porque las **sanciones a la competencia son mucho mayores**, ya que se está afectando al OPE, y esto es mucho más grave.
 - El art 1 define ciertos conceptos. Esto es relativamente nuevo en dº económico. Se plantea en la década del 90` con la Ley de Bases Generales del Medioambiente (en esta ley hay del orden de 20 definiciones). Se vuelve necesario porque era un tema muy desconocido y muy técnico.
 - Estas definiciones jurídicas son necesarias para el buen entendimiento de la ley.
- **Inc 1:**
- ¹El objetivo de la ley es:
 1. ²**Normar** las relaciones entre proveedores y consumidores.
 2. ³**Sancionar**, vale decir, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor.
 3. ⁴**Señalar el procedimiento** aplicable a esta materia. Hay un procedimiento especial para la protección del consumidor. Las normas procesales de esta ley son muchísimas.
- **Inc 2:**
- ⁵Acá empieza a dar las definiciones de ciertos conceptos que se tratarán constantemente en la ley.
 - En las 2 primeras definiciones que da la ley, entra en muchos detalles concretos porque el legislador quiere dar claridad con respecto de quiénes están demandando y a quien se está demandando.
 - ✓ Esto se denomina en procesal como *legitimación activa* –demandante- y *legitimación pasiva* –demandado-.
 - ✓ Los demandantes son los *consumidores*, y los demandados los *proveedores*.
 - ✓ Pero, para ser *consumidor* se requiere de varias características que son copulativas, es decir, se deben cumplir todas.
 - Se da una relación **civil** (consumidores) y **mercantil** (proveedores).
- 1. CONSUMIDORES O USUARIOS**
- ✓ Existe una distinción entre *consumidor* y *usuario*:
 - a) ⁶Consumidor: de bienes y productos.
 - b) ⁷Usuarios: de servicios.
 - A *Yrarrázaval* nunca le ha convencido esta diferenciación, para él, todos son *consumidores*.
 - ✓ ⁸Pueden ser **personas naturales o jurídicas**. Aun así, la gran mayoría son personas naturales.
 - ✓ ⁹La ley solo contempla como consumidor los que intervienen mediante un **acto jurídico oneroso**. Por lo tanto, la ley no contempla los actos *gratuitos*. La

distinción entre *oneroso* y *gratuito* es la siguiente:

- a) Oneroso: hay contraprestaciones. La consecuencia es el pago.
*El contrato que más se utiliza, es el de compraventa, y para éste se requiere de **precio** y **cosa**. Indiscutiblemente, si hay precio, el acto es oneroso.
 - b) Gratuito: hay gratuidad. La consecuencia es que no se paga.
- ✓ ¹⁰La persona –natural o jurídica- debe –mediante acto oneroso- adquirir, utilizar o disfrutar como **destinatario final**.
 - ❖ El acto de consumo es una *satisfacción de necesidades*, y no tiene satisfacción de necesidad el que compra para después vender. Está realizando una actividad económica, pero NO es un acto de consumo.
 - ❖ La ley define al *consumidor* al que adquiere, utiliza o disfruta un bien o servicio para su **propio uso**.
 - ❖ Por lo tanto, esta ley NO les da protección a los compradores de bienes intermedios, ni a los que son consumidores intermedios, es decir, los que compran para vender posteriormente.
 - ✓ ¹¹El consumidor puede adquirir, utilizar o disfrutar tanto **bienes**, como **servicios**.
 - ✓ ¹²Se es consumidor o se es proveedor; no se puede ser ambos al mismo tiempo.

2. PROVEEDORES

- ✓ ¹³Pueden ser **personas naturales o jurídicas**. Aun así, la gran mayoría son personas jurídicas.
- ✓ ¹⁴También, pueden ser personas de **carácter público o privado**. *Yrarrázaval* considera que esto está demás porque se entendería también si no estuviese.
- ✓ ¹⁵Por lo tanto, se requiere de **habitualidad**, y esto, desde el punto de vista jurídico se debe **probar por el demandante**.
 - ❖ Sería muy difícil poder definir la habitualidad en la ley.
 - ❖ Una definición de la habitualidad sería ignorar la realidad de los hechos, ya que depende del bien en cuestión. Puede ser que una operación al día lo haga habitual, o, puede ser que una operación al mes lo haga habitual.
 - ❖ La habitualidad la deberá entender cada juez en cada circunstancia porque la ley no da un concepto de habitualidad.
 - ❖ *Tampoco se define el concepto de habitualidad en la LGB.
- ✓ ¹⁶Deben desarrollar actividades de **producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización** de bienes o de prestación de servicios a consumidores. Y, por éstas deben cobrar un **precio o tarifa**.
 - ❖ Si no se cobra precio o tarifa, el contrato deja de ser oneroso.
 - ❖ A juicio de *Yrarrázaval* esta enumeración es inútil porque se entiende como *toda actividad económica por la que se cobre precio o tarifa*.
- ✓ ¹⁷**NO** se considerarán como proveedores a las personas que tengan un **título profesional Y** ejerzan su actividad de forma **independiente**.
 - ❖ Se deben reunir estas 2 condiciones para no ser considerado proveedor.

- ❖ Entonces, la gran mayoría de los abogados, médicos, ingenieros y otros no son considerados como *proveedores*.
- ❖ Si las personas con título profesional ejercen la actividad como un empleado de alguna institución proveedora, si caen dentro de la categoría de proveedora.
- ❖ Los malos ejercicios de las profesiones, van por un carril distinto, no por la LPC. Correrán por los colegios profesionales y juicios de indemnización de perjuicios.
- ❖ El trabajador **independiente** será aquel que **no tiene empleador**, y, por lo tanto, no tiene contrato de trabajo.
 - A éste le pagan con “boletas a honorarios”.
 - La legislación laboral solo protege a los trabajadores dependientes, y, a los independientes ni los considera ya que no tienen a quién reclamarle.
 - La relación de trabajo es una relación de **dependencia o subordinación**, y, tiene toda la protección del Código del Trabajo.
 - En cambio, los independientes (del orden del 15-20%) no tienen ninguna protección porque no tienen contrato de trabajo, dependencia ni subordinación.
 - Ejemplo UC: hay profesores dependientes –a tiempo completo, con contrato de trabajo- e independientes –le pagan con boleta-.

3. INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL

- ✓ ¹⁸Son **datos, instructivos, antecedentes o indicaciones** que el proveedor debe suministrar.
- ✓ ¹⁹El suministro de esta información -por parte del proveedor- es **obligatorio por ley**. En otras palabras, la información por el hecho de ser obligatoria por ley, cae dentro del concepto de *información básica comercial*.
 - ❖ Ejemplo medicamentos: en todo remedio deben venir las instrucciones de éste.
- ✓ ²⁰Los proveedores que reciben los bienes **en consignación** para su venta, deben agregar a la *información básica comercial* los **antecedentes** relativos a su **situación financiera**, incluidos los estados financieros cuando corresponda. Esto es para darle **seguridad** al productor.
 - ❖ Las compraventas pueden ser *a firme* o *en consignación*.
 - a) Compraventa a firme: toda la compraventa se perfecciona en el momento que hay cosa y precio.
 - b) Compraventa en consignación: es una venta condicional para que el vendedor venda posteriormente ese bien. Acá, hay un riesgo de por medio, por lo que, el precio que recibiría el productor al pactar en consignación es mayor que si pacta por compraventa a firme (en donde la exportadora corre los riesgos).
 - Caso proveedores de frutas y exportadoras: hacen venta en consignación.
 - El resultado de esta venta depende de la cantidad y precio al que se

vende en el mercado extranjero.

-Si no venden, el productor no recibe nada en las consignaciones.

-En el caso de la fruta, se dejó un mínimo firme (muy pequeño) para cubrir los costos de préstamos y otros.

-Hay muchos bienes que se venden en consignación.

- ✓ ²¹En la **venta de bienes y servicios** se considerará también como *información básica comercial*:

- a) ²²**Identificación del bien o servicio.**

- *A *granel* no llevan identificación.

- b) ²³**Instructivos de uso.**

- Es fundamental para algunos bienes.

- c) ²⁴**Términos de la garantía cuando procedan.**

- Es relevante especialmente en el caso de los electrodomésticos, autos y otros.

- En algunos productos, las garantías son igual de importante que los productos que se están comprando. Acá, se parte de la base de que algunas de sus piezas o el producto en su totalidad puede fallar.

- Por lo tanto, los instructivos de uso tienen una cierta importancia, pero las garantías tienen una muchísima mayor.

- ✓ ²⁵Se **exceptuaran los bienes a granel** de la información requerida por ese inciso (letra a-b-c).

- ❖ A *granel* se refiere que **no se identifica quién es el productor.**

- ❖ Ejemplo frutas a granel: por tener esta característica son más baratas. Para demandar la mala calidad de frutas *a granel* será más difícil ya que se deberá demandar al supermercado y éste se va a exceptuar diciendo que ellos no son los productores.

- ✓ ²⁶La información debe ser suministrada al público por el **medio** que el proveedor estime conveniente, pero debe cumplir con 3 características: este debe ser: **claro, expedito y oportuno.**

- ✓ ²⁷Además, los plazos de prescripción son muy cortos, por lo tanto, la información básica comercial debe asegurar un acceso **claro, expedito y oportuno.**

- ❖ Esto también es un problema, porque un 60-70% de las personas en Chile –según las encuestas- no entienden la información básica comercial.

- ✓ ²⁸Será **obligatoria** la entrega de los **instructivos de uso** de los bienes y servicios cuyo uso normal representa un **riesgo** para la integridad y seguridad de las personas **conjuntamente** con la venta del bien o servicio por el cual se está pagando. Así, se aseguran de que efectivamente las normas de uso se tienen desde el momento en que se compra.

- ❖ Caso juguetes para niños: esto es muy relevante en este caso, porque algunos pueden llegar a ser mortales para los niños muy pequeños.

4. PUBLICIDAD

- ✓ Esto es bastante curioso. En Chile, no existe una ley de publicidad, hay una Ley de Medios, pero es distinto medios que publicidad.
- ✓ Acá el tema de la publicidad es relevante, porque es la publicidad con respecto de los bienes que se están ofreciendo y que los consumidores están demandando.
- ✓ ²⁹La publicidad es la comunicación que el **proveedor dirige al público** por cualquier medio idóneo al efecto, para **informarlo y motivarlo** a adquirir o contratar un bien o servicio.
 - ❖ Se debe distinguir entre publicidad *informativa* y *motivacional* (bebidas alcohólicas y no alcohólicas, Kino, loto, etc.).
 - ❖ Las características de estos tipos de publicidad difieren bastante.
 - ❖ Se deben combinar estos tipos de publicidades.
- ✓ ³⁰Se debe incorporar al contrato las **condiciones objetivas** contenidas en la publicidad.
 - ❖ Entonces, si la publicidad me da ciertas condiciones objetivas, y yo compro ese bien y no se cumplen esas condiciones, hay un fallo de la publicidad. La publicidad lo hizo creer que esa condición era parte del contrato.

5. ANUNCIANTE

- ✓ Muchas veces se confunde con el concepto de *publicidad*.
- ✓ ³¹El anunciante es el **proveedor de bienes** que por medio de la publicidad se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios. En definitiva, se refiere a la **empresa proveedora que está realizando publicidad**.
- ✓ Hay que agregar como elemento, las **agencias de publicidad**.
 - ❖ Para la LPC, el **anunciante es el proveedor NUNCA la agencia de publicidad**, ya que éstas solo actúan bajo previo consentimiento de la empresa proveedora.
 - ❖ La agencia de publicidad cobra como comisión del orden del 15%.
 - ❖ La función de la agencia es preparar toda la publicidad para que se pueda publicar.
 - ❖ Las agencias de publicidad son intermediarias entre la empresa proveedora y el MMC en donde se va a publicar el bien o servicio.

6. CONTRATO DE ADHESIÓN

- ✓ Hay múltiples definiciones de *contrato de adhesión*, por eso la ley específica a qué se refiere para estos efectos.
- ✓ ³²Se refiere a aquel contrato cuyas cláusulas han sido propuestas **unilateralmente** por el **proveedor, sin que el consumidor**, para celebrarlo, **pueda alterar su contenido**.
 - ❖ Si el consumidor puede alterar su contenido, deja de ser un contrato de

adhesión.

- ✓ La **tendencia** desde el punto de vista contractual es que haya **más contratos de adhesión** por el concepto de **consumo masivo**.
 - ❖ Estos, se producen más en ciertos productos y servicios que en otros.
 - Algunos ejemplos de contratos masivos son con ISAPRES, compañía de teléfonos, etc.
- ✓ La LPC NO está prohibiendo los contratos de adhesión –esto sería absurdo-, sino, que los está reglamentando (esto se ve más adelante).
- ✓ Acá aparece nítidamente la relación entre la PC y dº civil.
 - ❖ En ciertos países, el tema de los contratos de adhesión está tratado en el capítulo correspondiente a contratos del CC.
 - ❖ En otros países, el tema de los contratos de adhesión se trata en una ley separada que no es la LPC sino la Ley de Condiciones Generales de las Contrataciones (LCGC).
 - ❖ En Chile, se trata dentro de la LPC, que según *Yrarrázaval* es la peor de las alternativas porque:
 - Más que una práctica contraria al consumidor es una **asimetría**. El proveedor proporciona todo el contrato (diciendo al consumidor “firme aquí y estamos listos”) y el consumidor no puede decir nada sobre ninguna modificación.
 - Además, hay una **asimetría de información**. El proveedor tiene toda la información, y, el consumidor tiene muy poca, salvo que haya tenido una mala experiencia con respecto de algunos contratos en el pasado.
 - Y, por lo tanto, lo que trata las normas del CC en otros países o las LCGC es regular este tema muy complejo –cada vez más complejo-.
 - Prohibir o regular estrictamente el contrato de adhesión no tiene ningún sentido -según *Yrarrázaval*-.
 - Los contratos entre el MOP (Ministerio de Obras Públicas) y las concesionarias están llenas de problemas por querer utilizar contratos de adhesión. De hecho, hay un caso en el que se alegaba y con buenos fundamentos de que el MOP le debía las platas por el terremoto del 2010.
 - Es mejor regular los contratos de adhesión por el CC o por una Ley General de Contratación que por la Ley de Protección al Consumidor, ya que, con el sistema chileno, **solo se aplica para relaciones entre proveedores y consumidores y NO para todas**. Debería estar en una **ley general**.
 - Han habido muchísimos problemas por haber limitado los contratos de adhesión a la LPC. Los problemas se dan por no saber si las normas de contrato de adhesión de esta ley se aplican solamente a los contratos entre proveedores y consumidores, o, si se aplican en cualquier otro caso de contrato de adhesión. Algunos sostienen que como se encuentra dentro de la ley, se aplica solo para los contratos de adhesión entre proveedores y consumidores. Pero, otros afirman que estas normas son de carácter general. Y, si son de carácter general ¿por qué no se

encuentran en el CC o una ley general que regule esto?.

7. PROMOCIONES

- ✓ ³³Se refiere a las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes y servicios en **condiciones más favorables** que las habituales, con excepción a las que consistan en una simple rebaja de precio.
- ✓ El proveedor realiza la promoción cuando se quiere deshacer rápidamente de los productos. En el caso de la ropa, se hace típicamente por cambio de temporada. En definitiva, las promociones verdaderas se dan por una causa. Si en una tienda sale permanentemente que está en promoción, en realidad, tiene precios mentirosos.
- ✓ Lo que quiere resguardar la ley son exigencias para éstas promociones, ya que le preocupa la relación entre consumidores-proveedores.
- ✓ Una simple rebaja de precios por pagar al contado, o, con determinada tarjeta NO es promoción.
- ✓ La promoción es cuando hay toda una campaña de divulgación para los efectos de deshacerse de cierta mercadería.

8. OFERTA

- ✓ Es en relación con las ofertas comerciales NO ofertas económicas.
 - ✓ ³⁴Se refiere a la práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes y servicios a **precios rebajados en forma transitoria** en relación a los habituales.
 - ✓ Las promociones y las ofertas son bastante parecidas. Y, muchas veces en la ley se toman juntas.
- La ley tiene estas 8 definiciones para precisar la definición de cada uno de estos conceptos ya que no se definen en ninguna ley general.

○ **Art 2: Ámbito de aplicación de la ley**

TÍTULO I-ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

Artículo 2- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley:¹

a) Los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor;²

b) Los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas;³

c) Los actos o contratos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor o usuario el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo;⁴

d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto del Párrafo 4º del Título II; de los Párrafos 1º y 2º del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren.⁵

No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación;⁶

e) Los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización⁷, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la ley Nº 19.472, y⁸

f) Los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud⁹, con exclusión de las prestaciones de salud; de las materias relativas a la calidad de éstas y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud; de la acreditación y certificación de los prestadores, sean éstos públicos o privados, individuales o institucionales y, en general, de cualquiera otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales.¹⁰

- El ámbito de aplicación de la LDLC son todas las actividades económicas para la competencia. En cambio, el ámbito de aplicación de la LPC es bastante más complicado, y, en el art 2 y art 2 bis se mencionan las situaciones sujetas a esta ley.
- El art 2 menciona 6 casos sujetos a esta ley.
- ¹Dice “*quedan sujetos a las disposiciones de esta ley*” porque si no lo hubiese dicho, habría dudas de si estos casos están dentro o fuera de la ley. Por lo tanto, establece expresamente que estos sí están incluidos.
- Además de estos 6 casos del art 2, todas las relaciones entre consumidores y proveedores están sujetas a esta ley (mencionado en el art 1).
- Las 6 situaciones comprendidas dentro de la ley son:
 - a) ²Actos jurídicos que -de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales- tengan el carácter de **mercantiles (de comercio) para el proveedor y civiles para el consumidor**.
 - ❖ Nuestro Código de Comercio está estructurado sobre la base que lo regula el Código de Comercio son los actos de comercio, y, los define uno

por uno (son del orden de veinte y algo).

→ Por ejemplo, la actividad de los bancos es considerada como acto de comercio porque la ley lo dice.

- ❖ En Chile se distinguen los *actos comerciales* y de los *actos civiles*, y, cada uno se rige por su propio código.
- ❖ En Argentina, se refunden estos actos en un solo código llamado Código Civil y Comercial, vale decir, se acabaron los actos de comercio en Argentina. Por lo tanto, un contrato de compraventa está tratado en el Código Civil y Comercio, y, tienen las mismas reglas una compraventa civil que una comercial.
- ❖ En definitiva, está diciendo de que si el proveedor es comerciante –y está un acto de comercio descrito en el art 3-, y, el consumidor no es comerciante –y está haciendo un acto civil- es un **acto que queda dentro de la ley**.

b) ³Actos de comercialización de **sepulcros o **sepulturas**.**

- ❖ Han habido dudas al respecto, por lo que el legislador lo incluye bajo la LPC.
- ❖ El dueño del terreno es por ejemplo “*Parque del Recuerdo*”, y esta SA les vende a las personas las sepulturas.
- ❖ Hay una relación contractual con respecto a las sepulturas, y esta relación está regulada por la LPC.
- ❖ Como habían dudas de si estaba dentro o no de la ley, se explicita en el art 2 que si están incluidas.

c) ⁴Actos o contratos en que el proveedor suministra al consumidor/usuario el uso o goce de un **inmueble por periodos determinados.**

- ❖ Los periodos pueden ser continuos o discontinuos.
- ❖ Los periodos no pueden ser superiores a 3 meses.
- ❖ El inmueble debe estar amoblado y debe ser para fines de descanso o turismo.
- ❖ En definitiva, se está refiriendo a que los “*arriendos de veraneo*” caen bajo la aplicación de la ley, pero bajo una serie de condiciones.

d) ⁵Contratos de **educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria.**

- ❖ Solamente en ciertos aspectos cae bajo la regulación de la ley, y debe seguir procedimientos determinados.
- ❖ ⁶Luego, dice que **NO** queda sujeto a esta ley recurrir ante tribunales por la **calidad** de la educación o por las **condiciones académicas**.

e) ⁷Contratos de **venta de viviendas realizados por empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU).**

- ❖ ⁸Se excluye de esta ley lo que tiene relación con las normas de calidad de la vivienda, que se encuentra incluido en la ley N° 19.472.
- ❖ Cualquier otro aspecto, se encuentra regido por esta ley.

- f) ⁹Actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de **servicios** en el ámbito de la **salud**.
 - ❖ ¹⁰Se excluye a las prestaciones de salud, de las materias relativas a la calidad de éstas y a su financiamiento, y otras.
 - ❖ En general, se excluye toda materia regulada por leyes especiales.
- Los 3 últimos son bastante complicados.

○ **Art 2 bis**

TITULO I-ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

Artículo 2 bis- *No obstante lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo¹:*

- a) En las materias que estas últimas no prevean;²*
- b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento, y³*
- c) En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales.⁴*

- Es *bis* porque es una modificación posterior a la ley madre.
- Entra en la relación entre LPC y la actividad económica regulada. El legislador debe plantearse ¿cuál de estas va a primar?
- ¹Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, SALVO:
 - a) ²**En las materias que estas últimas no prevean.**
 - ❖ Por lo tanto, si hay **leyes especiales** con respecto de las actividades mencionadas anteriormente, se regirán por esas leyes, de lo contrario, por la LPC.
 - ❖ Esto tiene bastante importancia porque dentro de la actividad económica regulada, no es tan fácil discernir si tiene o no estos tipos en su regulación. Por lo tanto, la 1ª discusión que se plantea entre las partes es si se aplica o no la LPC (si hay ley especial, debe regir esa). Y, se da mayor complicación cuando las normas no son equivalentes. A veces en la actividad económica regulada, se trata ciertos temas en líneas generales, pero no de forma tan específica como lo hace la LPC, entonces, ahí ¿cuál rige?
 - Ejemplo LGB: no prevé la gran mayoría de situaciones de prácticas que vamos a analizar, por lo tanto, se rigen por la LPC. Si la previera, rige la ley especial.
 - Como la línea divisoria es muy difícil, se incorporó a esta ley todo un

capítulo que se refiere al SERNAC financiero que tiene normas muy complicadas. Esto ocurre porque se quiso aplicar a la actividad bancaria la legislación de PC. Además, la ley indica que los bancos no están obligados a tener el sello del SERNAC financiero, pero los que lo tienen, tendrán algunas ventajas. La gran mayoría de los bancos no optaron por el SERNAC financiero, por lo que este capítulo de la ley es bastante poco útil, más bien, ha sido un total fracaso. *Yrarrázaval* no conoce ningún banco que esté dentro del SERNAC financiero.

b) ³En lo relativo al **procedimiento** en las causas en que esté comprometido el **interés colectivo o difuso** de los consumidores o usuarios, y el dº a solicitar **indemnización** mediante dicho procedimiento.

- ❖ Las causas de interés colectivo o difuso son un tema de especial relevancia para el proveedor. En Chile, están adquiriendo cada vez más importancia, y permanentemente van apareciendo (casi no existían hace 10 años).
- ❖ Caso Banco Estado: 3 millones de clientes demandan al banco porque según ellos, el cálculo de intereses que estaba haciendo el banco para ciertas operaciones estaba incorrecto. Esto, se tranzó ya que, si no, el banco podría quebrar.
- ❖ Entonces, lo que se está estableciendo es que si hay un procedimiento -como lo hay- con respecto de demandas colectivas o de interés difuso, se debe ceñir a ese procedimiento y no al procedimiento general de la LPC.
- ❖ Lo mismo ocurre con el dº a pedir indemnización de perjuicios. Aquí, es más curioso todavía porque uno diría que el mayor interés que tienen los consumidores para demandar es la obtención de la indemnización de perjuicios (también existen sanciones de multas a beneficio fiscal). Al igual que en el dº de la competencia, la indemnización de perjuicios se ha vuelto muy relevante. Aquí el tema es que la indemnización de perjuicios solicitada por los consumidores se ceñirá al procedimiento general de indemnización de perjuicios. Esto es bastante lógico –según *Yrarrázaval*– porque indiscutiblemente se aplican los criterios generales, etc.

25 de abril

c) ⁴En lo relativo al dº del consumidor/usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser **indemnizado** de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales.

- ❖ Plantea con mayor precisión el tema de indemnización de perjuicios.
- ❖ Surge a causa del incumplimiento de la relación contractual.

II. TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES

PÁRRAFO 1º - LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSUMIDOR

- Tiene menor importancia, ya que establece disposiciones generales que resultan ser bastante obvias. Se refiere a los dº y deberes del consumidor.
- Los dº del consumidor van saliendo a medida que se va avanzando en la ley. Aquí, la ley solo hace una enunciación general de esos dº.
- **Art 3**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 1º - LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSUMIDOR

Artículo 3- Son derechos y deberes básicos del consumidor:¹

a) La libre elección del bien o servicio.² El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo;³

b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos⁴, y el deber de informarse responsablemente de ellos;⁵

c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios;⁶

d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios⁷, la protección de la salud⁸ y el medio ambiente⁹ y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles;¹⁰

e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales¹¹ en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea¹², y

f) La educación para un consumo responsable¹³, y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido.¹⁴

Son derechos del consumidor de productos o servicios financieros:¹⁵

a) Recibir la información del costo total del producto o servicio¹⁶, lo que comprende conocer la carga anual equivalente a que se refiere el artículo 17 G, y ser informado por escrito de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas.

b) Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras.¹⁷

c) La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas.¹⁸

d) Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía, entre las alternativas que le presente la institución financiera.¹⁹

e) Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento.²⁰

- ¹Son dº y deberes básicos del consumidor:

a) Letra a)

❖ ²Libre elección del bien o servicio.

❖ ³El **silencio NO constituye aceptación** en los actos de consumo. Esto significa que, si no se dice nada a la hora de la oferta, no se forma el consentimiento.

❖ En dº comercial se estudia la formación del consentimiento -se describe en este código-. ¿Cuándo se forma el consentimiento cuando se contrata? El Código de Comercio establece una serie de reglas bien importantes con respecto de la oferta de una parte y la aceptación de la

otra parte, porque quiere saber con la mayor certeza posible ¿cuándo se formó el consentimiento? ¿cuándo hay contrato entre las partes?

- ❖ Este tema se ha ido complicando cada vez más, especialmente con los contratos tecnológicos. En ellos, estamos recibiendo una enorme cantidad de ofertas con respecto a distintos tipos de productos. Entonces, ¿cuándo se forma el consentimiento en los contratos tecnológicos?
- ❖ La rapidez con la que se mueven los contratos tecnológicos, lo hace cada vez más complicado.
- ❖ “*El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo*” es una regla especial dentro de la LPC. Es muy razonable –según Yrarrázaval– porque si constituyera formación del consentimiento, obviamente estaríamos contratando una cantidad de cosas que en realidad no quisiéramos.
- ❖ Hay materias en dº comercial en donde el silencio si constituye aceptación, por lo tanto, el legislador debe establecer expresamente que, para efectos de los actos de consumo, el silencio no constituye aceptación.

b) Letra b)

- ❖ 4Dº a **información veraz y oportuna** sobre bienes y servicios, su **precio, condiciones de contratación** y otras **características** relevantes de los mismos.
- ❖ Esto se menciona porque hay muchos actos de consumo que tienen bastante complejidad.
 - Hay algunos que son muy simples (ej: comprar en La Vega, estoy viendo el bien y lo acepto).
 - Pero, la gran mayoría de los actos de consumo son más complejos, ya que tienen instrucciones de uso, garantías, etc.
- ❖ Obviamente que, a mayor precio, mayor complejidad.
 - Por ejemplo, que me engañen en la compra de una manzana tiene un efecto mínimo, pero, si me engañan en la compra de un auto o refrigerador, el tema es mayor.
- ❖ La mención de información **veraz y oportuna** nos lleva a comprender el objeto fundamental de la ley, que, se refiere a **evitar el fraude/engaño** en los actos de consumo.
- ❖ Antes de la década del 80`, en donde no existía la LPC, ¿cómo se defendían los consumidores? ¿estaban totalmente desprotegidos? Se defendían a través del **dº civil**, especialmente mediante el **contrato de compraventa** -este contrato está muy desarrollado-, y, especialmente a través de 2 situaciones que se pueden producir. Estas situaciones se dan en una compraventa y llevan a todos los efectos de incumplimiento por parte del vendedor:

1. Vicio de evicción

- Cuando el vendedor no es verdaderamente el dueño de la cosa que se está vendiendo.
- Contempla distintas modalidades para que el comprador no se vea afectado por una situación en la que él supuso que quién le estaba vendiendo la cosa era el dueño.
- Ejemplo: persona coleccionaba estatuas, pero quien se las vendió las había robado, y, por lo tanto, hay un vicio en la compra.

2. Vicio redhibitorio

- Cuando la cosa comprada no cumple los objetivos que tiene. Puede cumplir con una parte de sus funciones, pero no en su totalidad.
- Este vicio se aplica más exactamente a las situaciones de PC.
- Ejemplos: refrigerador no enfría, lavadora no lava, etc.

➤ Ambos vicios son tratados con mucho detalle por Andrés Bello.

❖ La pregunta entonces es ¿qué necesidad hay de tener una LPC si se tienen esas reglas del CC (con mucha jurisprudencia y doctrina)? Esto porque es necesario proteger al consumidor. **La ley le quita esta materia al CC para poder darle al consumidor un procedimiento expedito para resolver este tipo de situaciones.**

❖ ⁵**Deber** del consumidor de **informarse** responsablemente de los bienes y servicios que adquiere.

❖ Indiscutiblemente, esta protección no puede abarcar a todo tipo de compraventas o a todo tipo de contrato de consumo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la compra de un automóvil no me proteja la ley, pero protege de cosas más chicas? Esto se debe a que en ciertos casos se supone que el consumidor debe ser **diligente**, y, por lo tanto, debe leer la garantía, leer el manual de instrucciones e informarse en general.

c) Letra c)

❖ ⁶**No ser discriminado arbitrariamente por proveedores** de bienes y servicios.

❖ Este no es un tema menor, porque la ley habla de *discriminación arbitraria*.

→ En Chile, no se sanciona la *discriminación* a secas afortunadamente – según *Yrarrázaval*-, sino, que se sanciona la *discriminación arbitraria* mencionada en el art 19 N°22 de la CPR.

- Inc 1: no discriminación arbitraria por parte del **Eº**.
- Inc 2: no discriminación arbitraria por parte del **legislador**.

❖ Este tema no es fácil, ya que hay varias razones que justifican que a veces los proveedores no les vendan a determinados consumidores.

→ Ejemplo USA: hay pastelerías o florerías que le niegan la venta de sus productos a parejas homosexuales.

❖ El tema de la arbitrariedad en estos actos de compraventa puede ser por razones de sexo, raza, etc. Pero, también por razones estrictamente comerciales o económicas.

→ Ejemplo préstamos bancarios: estos casos han llegado al TDLC, y otras veces se plantean bajo la LPC.

- Si se lleva al TDLC, se debe probar 1º que hay un abuso de posición dominante, sino, estaríamos llenos de casos en que no se produce verdaderamente un efecto negativo en la competencia.
 - Hay muchos proveedores que le otorgan créditos a los consumidores. Si el consumidor no paga ese crédito y quiere volver a comprarle al mismo proveedor, ¿puede sostener el consumidor de que se lo está discriminando arbitrariamente porque no se le quiere otorgar el crédito? Se da una controversia, ya que el consumidor califica esto como una discriminación arbitraria, pero, el proveedor no la considera como una discriminación arbitraria, sino como razonable o justificable, ya que el consumidor tiene una deuda pendiente con él.
- ❖ En el caso del consumo, la discriminación se da a causa **relaciones** que existen entre consumidor y proveedor.

d) Letra d)

❖ Incluye 4 elementos:

1. ⁷El dº a la **seguridad** en el consumo de bienes y servicios es bastante razonable.
2. ⁸La protección de la **salud** se refiere especialmente en la venta de los medicamentos.
3. ⁹Protección del **medioambiente**.
4. ¹⁰Deber de **evitar los riesgos** que puedan afectarle.

e) Letra e)

❖ ¹¹El dº a la **reparación e indemnización** adecuada y oportuna de todos los **daños materiales y morales** en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor.

❖ ¹²El deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea.

❖ La LPC incorpora la indemnización de los **daños morales**.

→ Los daños morales han pasado a ser un gran tema más allá de esta ley, sino en el dº en general.

→ Los daños morales son aquellos que afectan la honra de una persona, su salud, su imagen, etc.

→ El problema de los daños morales es que son **incuantificables**, y esto pasa a ser una pesadilla para los tribunales para resolver los casos.

-Ejemplo: una persona mata a otra en un accidente de tránsito (sin intención de matarla). El daño moral se debe retribuir a la familia de esa persona (en cuánto afectó al grupo familiar). Se pueden determinar los daños materiales, pero es muy difícil determinar el daño moral (asciende a millones).

→ El criterio de la CS en estos casos es que asignará el daño moral según la **capacidad de pago del demandado**. Uno podría decir que los

tribunales son muy discrecionales al tomar esta determinación, pero, se deben adoptar ciertos criterios.

→ Algunas salas son más abiertas a otorgar indemnización por daños morales que otras, por lo tanto, llega la CS a establecer un criterio más definitivo al respecto.

→ *Yrarrázaval* es muy partidario con la aplicación que les da la CS a los daños morales.

→ En el caso de la PC específicamente, los **fraudes** cometidos -generalmente en la compraventa de un bien- producen daños materiales y/o daños morales. Estamos hablando de pocos casos verdaderos, pero, muchas veces para inflar las demandas, demandan por daños morales en actos de consumo por cantidades astronómicas.

f) Letra f)

❖ ¹³El dº a la **educación** para un consumo responsable.

❖ ¹⁴El deber de celebrar operaciones de consumo con el **comercio establecido**. Esto a juicio de *Yrarrázaval* es un disparate, pero obviamente hubo presiones para incluir esta disposición. Así, todas las personas que compren en mercados informales sentirán alguna preocupación por lo que están haciendo.

▪ ¹⁵**Son dº del consumidor de productos o servicios financieros:**

a) Letra a)

❖ ¹⁶Recibir la **información del costo total** del producto o servicio.

❖ Esto SI se produce en la práctica. Aparece el precio al contado y el precio a crédito.

→ Acá se empieza con problemas, ya que en la información del crédito el consumidor debe tener algún conocimiento básico desde el punto de vista financiero, para así, ser capaz de comparar la compra al contado de la compra a crédito.

→ Si fuera un análisis sencillo, prácticamente nadie compraría a crédito porque en la medida que el crédito sea por un período mayor de tiempo, el precio que esa persona está pagando puede llegar a ser mucho mayor que el precio al contado (incluso el doble). Pero, esta comparación implica una serie de cálculos matemáticos.

→ Por lo tanto, la ley obliga a que, si se va a vender a crédito, se debe informar el valor de éste. Acá nos encontramos con una **asimetría** de información muy importante.

b) Letra b)

❖ ¹⁷Conocer las **condiciones objetivas** que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al **crédito** y para otras operaciones financieras.

❖ Acá también hay un tema de información, porque probablemente, buena parte de las personas que están comprando no entienden bien esas condiciones.

- ❖ El crédito –servicio financiero- es un préstamo de consumo bastante más sofisticado.

c) Letra c)

- ❖ ¹⁸La **oportuna liberación de las garantías** cuando se compra a crédito.
- ❖ Esto se refiere a que una vez que se ha pagado el crédito, oportunamente se debe devolver las garantías al consumidor.

d) Letra d)

- ❖ ¹⁹**Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía.**

e) Letra e)

- ❖ ²⁰**Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento.**

- En definitiva, aquí hay 5 dº que se refieren a los productos o servicios financieros bien complicados, y, que más adelante en la ley aparecen relacionados con el SERNAC financiero.
- En la actualidad se presenta el problema de que los actos de consumo son cada vez más rápidos, en cambio, la parte jurídica/contractual es lenta necesariamente.
- Los contratos masivos están siendo cuestionados por ser de adhesión la gran mayoría de ellos. No es fácil llegar a un equilibrio en donde, por un lado, se protege al consumidor, pero por el otro lado, que éste no estorbe al procedimiento que el mismo consumidor desea que sea rápido.
- Ningún consumidor realmente lee todo el contrato antes de firmar, suponen que los términos y condiciones son relativamente razonables, y si no fueran razonables, esto produciría una controversia en las redes sociales y cosas por el estilo.
- Se debe distinguir entre la realidad jurídica y realidad que se da en la práctica.
 - ✓ Ejemplo reclamo supermercados: si voy a un supermercado y compro algo en el que ya pasó la fecha de vencimiento, uno no va directamente al SERNAC ni demanda, sino que reclama ante la empresa (a alta voz para que los demás escuchen el escándalo). Esto se termina arreglando en *servicio al cliente*.

○ **Art 3 bis: Dº de retracto**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 1º - LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSUMIDOR

Artículo 3 bis- *El consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato¹ en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo², en los siguientes casos:*

a) En la compra de bienes y contratación de servicios realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor³, en que el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión.⁴

(...)

b) En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario. Para ello podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato.⁵ En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12 A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien, materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor.

(...)

- Este art es bien curioso. *Yrarrázaval* no lo hubiese colocado nunca dentro de las disposiciones generales.
- ¹Habla del **dº de retracto** en 2 situaciones bien distintas.
- ²El consumidor puede poner unilateralmente al contrato en el plazo de **10 días** contados desde:
 - ✓ La recepción del producto.
 - ✓ La contratación del servicio y antes de la prestación del mismo.
 - Para **ciertos casos (a y b)**
- **Letra a)**
 - ✓ Es una situación relativamente reciente.
 - ✓ ³En la compra de bienes y contratación de servicios realizadas en **reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor**.
 - ❖ Esta es una estrategia de marketing, que según *Yrarrázaval* es casi cavernaria. A uno lo invitan a una reunión para darle a conocer un producto. La idea es que todo el entusiasmo que surja de la reunión influya en la compra del bien.
 - ❖ Generalmente se realiza esta estrategia para productos caros. Por ejemplo, en *departamentos por temporada*.
 - ❖ Se convida a un grupo de personas muy seleccionadas –deben ser clientes potenciales- y se les ofrece el producto. Antes de irse, se les insinúa que firmen unos documentos. En esos documentos, aparece el consentimiento de la persona. El comprador no tuvo ni el tiempo ni la oportunidad de analizar si le convenía o no. Es por esto, que se permite el **retracto**, que se refiere a “*echarse para atrás*”.
 - ✓ ⁴El consumidor debe expresar su **aceptación dentro del mismo día** de la

reunión.

❖ Si se da la reunión y acepta el mismo día, se puede retractar.

- ✓ El retracto en Chile y en otros países NO es permitido en la regla de formación del consentimiento. Pero aquí **excepcionalmente es permitido** porque hay poca oportunidad para que el consumidor analice objetivamente si le conviene o no.

▪ **Letra b)**

- ✓ Es una situación muy interesante, que, a juicio de *Yrarrázaval* debiese estar en otro art separado.
- ✓ Se incluye en la modificación del 2004.
- ✓ ⁵Se refiere a los **contratos celebrados por medios electrónicos** y aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de **comunicación a distancia**, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario.
- ✓ En estos casos, también se facilita el retracto.
- ✓ Este tema también se menciona posteriormente en la ley, pero aquí se indica en sus términos generales.

○ **Art 3 ter**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 1º - LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSUMIDOR

Artículo 3 ter- *En el caso de prestaciones de servicios educacionales de nivel superior, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, se faculta al alumno o a quién efectúe el pago en su representación para que, dentro del plazo de diez días contados desde aquél en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, deje sin efecto el contrato con la respectiva institución, sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados.¹*
(...)

- Es incorporado posteriormente.
- ¹Se refiere al **retracto en el caso de prestaciones de servicios educacionales**, es decir, con respecto a la matrícula de instituciones de formación técnica, institutos profesionales y universidades.
- Hay todo un sistema en el cual se da un plazo para retractarse del pago de una matrícula de educación por haberse inscrito en otro centro educacional.

○ **Art 4**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 1º - LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONSUMIDOR

Artículo 4- *Los derechos establecidos por la presente ley son irrenunciables¹ anticipadamente por los consumidores.²*

- Este art es fundamental.
- ¹Los **dº** establecidos por la presente ley son **irrenunciables**. Esto se debe al OPE.
- ²Lo que no se permite es la **renuncia anticipada** de dº por parte de los

consumidores.

- ✓ Pero, obviamente que una vez producida la infracción o la situación en materia de PC, el consumidor perfectamente puede decir que quiere renunciar a una parte de sus dº o algo por el estilo.
- ✓ Lo que quiere evitar la ley son las renunciaciones anticipadas al acto o contrato. Y esto lo hace con razón. La ley asume una cierta falta de diligencia por parte del consumidor, además de la asimetría que se da, y, por tanto, la ley quiere proteger al consumidor.
- En definitiva, todos los dº de los consumidores siguen vigentes, y, una vez producido el hecho o la práctica, el consumidor puede renunciar a sus dº, al igual que en cualquier acto o contrato.

PÁRRAFO 2º - DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

- Este capítulo se entiende con una simple lectura.
- Establece cómo se organizan los consumidores, qué pueden hacer y qué no, etc.
- Estas **organizaciones de consumidores** son muy importantes en algunos países, y, muy poco relevante en otros.
 - En Chile tienen una importancia mediana.
 - Lo que va a diferenciar la importancia de éstas organizaciones es **cuánto queda para el bolsillo** de estas organizaciones. Es el principal incentivo para la organización es cuánto percibe por la protección que brinda. Esto es especialmente relevante en los casos de **demandas colectivas** o de **interés difuso**.
 - ✓ Caso demanda colectiva al Banco Estado: 3 millones de clientes demandan al banco. En este caso, lo que quedó para el bolsillo de las organizaciones que estuvieron a cargo de esto fue mucha plata.
 - ✓ Indiscutiblemente, estas instituciones se tienen que financiar, pero depende de la ley correspondiente –reconociendo que siempre existe este dº- en la medida que se les permita quedarse con una parte importante de lo que se paga en demandas colectivas o difusas.
 - Todo este movimiento en favor del consumo empezó fundamentalmente en USA en la década del 60`-70`, y está vinculado especialmente a *Ralph Nader* (incluso se postula a la presidencia de USA). Este señor se preocupó exclusivamente a proteger los dº de los consumidores sobre la base de que esto era un gran negocio.
- No tienen mucha importancia, pero la empiezan a tener en los contratos y demandas colectivas (que viene más adelante en la ley). Ahí, estas organizaciones solas o junto con otros consumidores obtienen una indemnización de perjuicios bastante importante.

30 de abril

PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Hay una inmensa cantidad de normas con distintas relevancias.
- **Art 12: Respeto términos, condiciones y modalidades**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 12- *Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.*

- Esta disposición es relativamente obvia, es propia de cualquier contrato.

- **Art 12 A: Contratos celebrados por medios electrónicos**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 12 A- *En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquiera otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo¹ y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos.*

La sola visita del sitio de Internet en el cual se ofrece el acceso a determinados servicios, no impone al consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el proveedor.²
(...)

- **Inc 1:**

- Esta disposición se agrega después, por eso es 12 A.
- Habla sobre los contratos celebrados por medios electrónicos. Esto, aparece en la ley en muchos aspectos por el gran tema de la formación del consentimiento en los contratos electrónicos, formación del consentimiento en bienes comprados por medios electrónicos, publicidad por medio electrónico.
- Es toda una realidad nueva que se incorpora.
- Estas normas se incorporaron en el 2004, y hoy en día, algunas debiesen adecuarse más todavía a la nueva realidad.
- ¹El art 12 A indica que **no se entenderá formado el consentimiento** si el consumidor no ha tenido un **acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales** del mismo.
 - ✓ Acá se va no solamente a que en la oferta electrónica deben estar contenidos todos los elementos, sino que además, en la aceptación electrónica, el comprador tiene que tener claridad con respecto de qué es lo que está comprando.

- **Inc 2:**

- Se está normando respecto de situaciones cada vez más relevantes.
- Hoy en día, del orden del 25% de las compras se realiza por la vía electrónica. Este número seguirá aumentando (es exponencial).
- Esta nueva realidad trae una infinidad de complicaciones.

- ²La sola visita al sitio web no impone obligación alguna, salvo una aceptación inequívoca de la oferta del proveedor.

○ **Art 12 B: Proveedores de servicios de telecomunicaciones, prohibición oferta conjunta**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 12 B- Los proveedores de servicios de telecomunicaciones que realicen ofertas conjuntas deberán ofrecer individualmente cada uno de los servicios y planes que componen las mismas. De esta forma, no podrán atar, ligar o supeditar, bajo ningún modo o condición, la contratación de un servicio cualquiera a la contratación de otro.¹

- ¹Se refiere a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y, especialmente para **prohibir que se hagan ofertas conjuntas de varios servicios** (se relaciona con el concepto de *ventas atadas*). La expresión utilizada por la LPC es de **oferta conjunta**.
- Lo que se indica es que no se puede realizar la *oferta conjunta*, sino que se deben separar los distintos servicios, porque es la única forma de que el consumidor esté realmente pagando por lo que necesita.

○ **Art 13: Negativa de venta**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 13- Los proveedores no podrán negar injustificadamente¹ la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros² en las condiciones ofrecidas.

- Este art es muy importante, y ha estado presente en la LPC desde sus inicios (década del 80').
- Se refiere a la **negativa de venta**, que obviamente es una PR. Pero, esto es tan claro que ya hay muy pocos casos de negativa de venta desde el punto de vista del dº de la competencia.
- ¹**Negativa injustificada**
 - ✓ Es difícil poder determinar cuándo la negativa es justificada. Hay toda una casuística por detrás que está determinando cuándo es justificada y cuándo no.
 - ❖ Caso coreana: este fue un caso famoso en donde se le negó la entrada a una piscina a una coreana por el olor. Obviamente el fallo fue en contra de la piscina, porque claramente era injustificada.
 - ❖ Ejemplo discoteques: los guardias a veces sin razón justificada no dejan entrar a ciertas personas.
 - ❖ Por lo tanto, en la práctica se producen muchas negativas.
 - ✓ Para que se sancione, la negativa debe ser injustificada y estar dentro del giro de la empresa.
- ²**Giros de la empresa**
 - ✓ El *giro de la empresa* se refiere a lo que se dedica la empresa.
 - ✓ Por lo tanto, no se puede considerar como *negativa de venta* cuando un consumidor solicita algo a lo cual no se dedica la empresa (no pertenece a su

giro).

- ✓ El concepto del *giro de la empresa* es muy relevante dentro del dº comercial por el **objeto social** que tiene cualquier sociedad (en cualquier tipo).
- ✓ En los estatutos o reglas básicas que rige a cualquier sociedad, una de las menciones más importante es la del *objeto social*.
- ✓ El objeto social determina el giro. Y tanto es así, que cuando una empresa quiere iniciar otra actividad, debe cambiar o ampliar su giro.
- ✓ La gran mayoría de los giros de las empresas son muy amplios, por lo que es muy difícil que ese requerimiento del consumidor esté fuera del giro.
 - ❖ Esto se da por una práctica muy curiosa que se da en Chile, porque al final de una larga enumeración de los objetos a los que se puede dedicar la sociedad, se indica “y todos los demás que sean necesarios”. Entonces, el objeto termina siendo cualquier cosa.

○ **Art 14: Proveedor debe dar información sobre piezas usadas o refaccionadas**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 14- *Cuando con conocimiento del proveedor¹ se expendan productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas, se deberán informar de manera expresa las circunstancias antes mencionadas al consumidor, antes de que éste decida la operación de compra.² Será bastante constancia el usar en los propios artículos, en sus envoltorios, en avisos o carteles visibles en sus locales de atención al público las expresiones "segunda selección", "hecho con materiales usados" u otras equivalentes.*

El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior eximirá al proveedor de las obligaciones derivadas del derecho de opción que se establece en los artículos 19 y 20, sin perjuicio de aquellas que hubiera contraído el proveedor en virtud de la garantía otorgada al producto.

- ¹El art comienza *cuando con conocimiento del proveedor*, entonces éste debe saber cuáles de las piezas de los productos que ofrece son usadas/refaccionadas. El proveedor puede alegar no tener conocimiento de esto, y, es ahí donde empieza la prueba.
 - ✓ Es difícil que un proveedor de relativa importancia, no sepa que sus piezas son usadas/refaccionadas.
- ²El ofrecimiento de productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados (totalmente o con ciertas piezas/partes usadas) es una realidad presente cada vez más en productos tecnológicos, autos y maquinarias. Se da mucho más en los productos tecnológicos, y mucho menos en los autos.
- En cualquier producto tecnológico, hay partes refaccionadas y ya usadas. Esto se debe a que sale más barato producirlos.
- No es que se prohíba la incorporación de piezas usadas, sino que, de acuerdo con la ley, el **proveedor debe darlas a conocer al consumidor**.
- La realidad de vender cosas usadas/refaccionadas es cada vez más compleja. Es parecido a vender ropa de segundo uso.

○ **Art 15**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 15- Los sistemas de seguridad y vigilancia que, en conformidad a las leyes que los regulan, mantengan los establecimientos comerciales están especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas.¹

En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito² los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes.³

Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 24.⁴

- El art 15 ha dado muchos dolores de cabeza, especialmente a los supermercados.
- ¹Es una tendencia a nivel mundial, en definitiva, que la aprehensión del sospechoso se debe hacer con **dignidad y respetando sus dº**. Por lo tanto, lo que debe hacer el supermercado es aprehender a la persona por el menor tiempo posible para los efectos que llegue Carabineros y se lo lleve.
- ²Se refiere especialmente al **robo hormiga** que se hace en los supermercados de todas partes del mundo permanentemente. Algunos dicen que les roban del orden de un 5%.
- ³La autoridad competente se refiere generalmente a Carabineros.
- Los robos se concentran especialmente en ciertos productos ubicados en ciertos lugares. Por esto, por ejemplo, colocan los dulces y chocolates cerca de las cajas, en donde hay una mayor atención del personal y más cámaras.
- ²Si la contravención a lo dispuesto anteriormente no constituye delito, se sanciona por el art 24.

○ **Art 15 A: Estacionamientos ofrecidos al público general**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 15 A- Los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento de acceso al público general, cualquiera sea el medio de pago utilizado, se regirán por las siguientes reglas: (...)

- Se encuentra recién incorporado a la LPC -en la modificación del 2016-.
- Se refiere a los servicios de estacionamientos al público general, no incluye los estacionamientos privados.
- Tiene un largo desarrollo sobre cómo debe ser el cobro, cobro por minutos efectivos, cobro por tramos de tiempo, etc.

○ **Art 15 B: Estacionamientos ofrecidos por prestadores de salud**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Artículo 15 B- Los prestadores institucionales de salud, sean éstos de carácter público o privado, no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento cuando éstos sean utilizados con ocasión de servicios de urgencia o emergencia, y durante el tiempo que duren éstas, o por pacientes que presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento¹, circunstancia que deberá ser acreditada por el profesional a cargo del tratamiento o atención de salud.

- Estamos ante un detalle reglamentario importante.
- ¹Los prestadores de salud -de carácter público o privado- no pueden cobrar por los estacionamientos cuando sean utilizados por:
 - ✓ Urgencia o emergencia
 - ✓ Por pacientes que presenten alguna dificultad física -permanente o transitoria- para su desplazamiento.

○ **Art 15 C: Estacionamiento en la vía pública.**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 3º - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Artículo 15 C- A quien administre el servicio de estacionamiento en la vía pública sólo le será aplicable lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 del artículo 15 A.

- Se refiere a la obligación del proveedor que administre el servicio de estacionamiento en la vía pública.

PÁRRAFO 4º - NORMAS DE EQUIDAD EN LAS ESTIPULACIONES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

- El párrafo 4º se refiere a los **contratos de adhesión**.
- Se incluyen en la ley para regular las **asimetrías** que presentan.
- Las asimetrías existen y seguirán existiendo. Suponer que en tema contractual hay una simetría, es imposible. Siempre hay situaciones de asimetría en materia contractual, y, para que decir en materia laboral. También en materia de PC.
 - Por lo tanto, la asimetría justifica buena parte de las normas del trabajo.
- Ha habido una discusión importante. Algunos sostienen que éstas normas se aplican exclusivamente a los casos de PC. Pero, otros sostienen que se aplican a todo tipo de relación contractual.
 - La ley no dice nada con respecto de esto, entonces, los que sostienen que se aplica solamente a las normas de PC, se están basando en que debería estar en una ley general que en Chile no tenemos.
 - En la gran mayoría de los países esa ley general se denomina **Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC)**. En ella, se tratan todas estas situaciones que van surgiendo a raíz del consumo masivo.
 - ¿Por qué algunos sostienen que no se pueden aplicar las normas de la LPC en cuanto a contratos de adhesión a los contratos en general?² Sostienen que estas normas son solo para los contratos de consumo porque el origen de esta protección está en el CC. Entonces, estos son conceptos sustraídos del CC, y por eso es que la ley es bastante precisa, nunca habla de comprador y vendedor, sino que habla de *proveedor* y *consumidor*. Y, por lo tanto, especialmente los civilistas dicen que no se pueden aplicar estas normas a todos los contratos civiles existentes, eso sería absurdo, y que solo son normas para los miles de contratos de adhesión de relaciones de consumo celebradas todos los días.
 - Esta discusión no está zanjada ni siquiera por los tribunales, hay jurisprudencia totalmente contradictoria al respecto. En definitiva, no está zanjada ni por la ley,

² La ley no dice que es solo para los contratos de consumo.

- ni por la doctrina (hay poca al respecto), ni por la jurisprudencia.
- Los contratos de adhesión se van dando a partir del **consumo masivo** y la **contratación masiva**. Las empresas tienen el mismo contrato para miles y millones de clientes.
 - Algunos creen en la prohibición de los contratos de adhesión. *Yrarrázaval* no cree en la eliminación de éstos ya que sería volver a una situación de 40-60 años atrás. Dice que el tema contractual es cada vez más complejo, y la eliminación del contrato de adhesión sería un absurdo.
 - ¿Qué fue lo que cambió tan radicalmente en este periodo de tiempo que hace que nadie discuta que hay contratación masiva y que ésta lleva implícita el contrato de adhesión? Sería prácticamente imposible crear contratos específicos para cada cliente. Obviamente, la computación ha ayudado muchísimo a la contratación masiva, incluso en contratos sofisticados.
 - Ejemplo contratos de préstamos internacionales: estos contratos del orden de 150 páginas se crean apretando solo un botón. Por lo tanto, lo que se discute en ellos radica principalmente en las tasas de interés, quién es el acreedor y quién es el deudor, y, jurisdicción y legislación aplicada; todo lo demás está dado por muchos contratos celebrados anteriormente.
 - Los contratos de telecomunicaciones, de concesiones obras públicas y los de las ISAPRES claramente son de adhesión.
 - Las exigencias que pone la ley a los contratos de adhesión son bastante severas.
 - Diferencia Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y CC:
 - La LCGC le roba al dº civil conceptos en materia de contratos, pero se los adjudica en términos de condiciones generales de la contratación.
 - Esto lo hace para no ir modificando el CC permanentemente, porque hay nuevas situaciones dentro de la contratación que hacen razonable que haya una ley que señale y regule las condiciones generales de la contratación.
 - El CC lo dice de un modo general, pero se especifica en términos particulares en la LCGC, por ejemplo, en contratos electrónicos y otras situaciones que deben caer bajo esta ley especial.
 - Los contratos de adhesión surgen por la necesidad de cubrir contractualmente todas estas relaciones de forma **rápida y fácil**.

○ Art 16

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 4º - NORMAS DE EQUIDAD EN LAS ESTIPULACIONES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Artículo 16- *No producirán efecto alguno¹ en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:*

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución², salvo cuando ella se conceda al comprador³ en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

b) Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos⁴, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica;⁵

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;⁶

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;⁷

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;⁸

f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato,⁹ y

g) En contra de las exigencias de la buena fe¹⁰, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato.¹¹ Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen¹². Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.¹³

Si en estos contratos se designa árbitro, el consumidor podrá recusarlo sin necesidad de expresar causa y solicitar que se nombre otro por el juez letrado competente.¹⁴ Si se hubiese designado más de un árbitro, para actuar uno en subsidio de otro, podrá ejercer este derecho respecto de todos o parcialmente respecto de algunos. Todo ello de conformidad a las reglas del Código Orgánico de Tribunales.

(...)

○ Inc 1:

- ¹El art parte diciendo *no producirán efecto alguno*, esto se refiere a la **inexistencia**.
 - ✓ Hay una gran diferencia entre la *nulidad* y la *inexistencia* según sus efectos:
 - ❖ *Inexistencia*: si la cláusula es inexistente, no hay que solicitar nada ya que no nació nada para el dº.
 - ❖ *Nulidad*: se debe pedir ante tribunales. Puede que el tribunal no de la nulidad.
- Todas las cláusulas mencionadas en este art serán inexistentes. Todas ellas, tienen su razón de ser siempre que se interpreten adecuadamente según *Yrarrázaval*. Son todas bastante lógicas y ninguna es extrema, sino que, corresponden a la realidad de una relación asimétrica entre las partes (proveedor y consumidor).

▪ **Letra a): Modificaciones de contratos**

- ✓ ²Cuando una de las partes -**proveedor**- tiene la **facultad de dejar sin efecto un contrato, o de modificar a su solo arbitrio el contrato, o de suspender su ejecución.**

- ❖ Ejemplo aumento de los planes de las ISAPRES:

- Hay sobre 300.000 recursos contra las ISAPRES actualmente en tribunales.

- El contrato con las ISAPRES es un contrato de adhesión. Es una contratación masiva, y, si uno no está de acuerdo con alguna cláusula, deberá cambiarse a otra ISAPRE.

- Según el art 16 letra a), da la impresión de que las más de 300.000 demandas contra las ISAPRES tienen toda la razón. Pero, es la **ley** la que da una fórmula para el incremento del precio de los planes de las ISAPRE, que ciertamente modifica el contrato.

- A juicio de *Yrarrázaval*, la famosa fórmula está muy mal elaborada por el legislador. Y, permanentemente las ISAPRES se defienden diciendo que es culpa de la mala fórmula planteada por el legislador, y, que ellas solo aplican la fórmula establecida, que de hecho, es bien compleja.

- Los tribunales están fallando a favor de los afiliados, pero sin mucho fundamento jurídico. Simplemente dicen que como no se entiende la fórmula, se falla en favor de los afiliados. Hay abogados que se dedican a esto, porque cobran un % de lo obtenido, y esto es muy atractivo. Y, como los afiliados no saben si les irá bien-regular-mal, están dispuestos a reconocer que si no les aumentan el precio de los planes de ISAPRES, les darán un % a los abogados.

- Es pésimo para el sistema que no se haya enfrentado correctamente el tema. A juicio de *Yrarrázaval* es una irresponsabilidad que realmente no se haya enfrentado seriamente el tema. Y por eso se da el desprestigio actual de las ISAPRES.

- ✓ ³Luego, viene una **excepción** que es cuando se le concede al **consumidor**.

▪ **Letra b): Modificaciones de precios**

- ✓ ⁴Los incrementos del precio **no pueden ser unilaterales** en los contratos de adhesión.
- ✓ ⁵**Salvo que correspondan a prestaciones adicionales** y sobre la cuál hubo una **negociación** entre las partes.
- ✓ Tampoco soluciona el problema de las ISAPRES.

▪ **Letra c): Problemas del proveedor**

- ✓ ⁶¿Por qué no se acepta esta cláusula? Porque es un problema del proveedor y éste no lo puede traspasar al consumidor.
- ✓ Esto se produce bastante, porque muchas veces las empresas proveedoras se excusan de no cumplir por x motivo, y, eso no puede ser, ya que no puede traspasar sus problemas al consumidor.

- **Letra d): Invierta carga de la prueba**
 - ✓ Es bien relevante.
 - ✓ ⁷Se refiere a los casos en que se **invierta la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.**
 - ✓ La prueba es muy relevante.
 - ❖ De hecho, la ley establece cuáles son los medios de prueba. Y, cuando quiera que los medios de prueba sean muy amplios dice “*y todos los demás medios que existan*”, y ahí entonces opera la *sana crítica* por parte del juez.
 - ❖ La ley no solo los enumera, sino que le da una ponderación/importancia a cada medio de prueba. Por ejemplo, confesión de partes, declaración testimonial, documentos que se acompañen, inspección del tribunal, etc.
 - ✓ El consumidor si debe probar ciertas cosas, pero NO se puede invertir la carga de la prueba de cosas que debe probar el proveedor.
- **Letra e): Limitaciones absolutas en la responsabilidad del proveedor frente consumidor**
 - ✓ ⁸Contengan **limitaciones absolutas (totales) en la responsabilidad por parte del proveedor frente al consumidor.**
 - ✓ Esto es muy importante para el dº civil porque todo el sistema civil funciona sobre la base de quién asume la responsabilidad.
 - ✓ Lo que no permite la letra e) es que el consumidor asuma la responsabilidad por los casos que nombra.
 - ✓ Si se permiten las limitaciones relativas de responsabilidad, pero no se permiten las absolutas.
 - ✓ La ley lo establece así -y a juicio de *Yrarrázaval* está bien hecho- ya que fue el proveedor el que fabricó el bien o compró el bien (**distribuidor**) para venderlo posteriormente, así que no puede retraerse de la responsabilidad.
 - ✓ Caso autos: no se da tanto en Chile, sino que en otras partes del mundo. Cuando uno compra un auto, hay limitaciones con respecto a defectos de los autos que obligan a que el consumidor deba usar adecuadamente el auto.
 - ✓ Hay importantes casos sobre la *responsabilidad del fabricante*. En Chile, no existe una Ley de Responsabilidad del Fabricante, porque se ha ido incorporando a la legislación económica esta responsabilidad del fabricante ya sea para los casos en que venda al consumidor o al distribuidor.
 - ✓ Caso autos es tan severa esta normativa, que ha obligado a las empresas automotrices a que todos los consumidores de tal producto le lleven el bien para poder repararlos/cambiarlos, y así, evitar una responsabilidad posterior mayor.
 - ✓ Hay toda una normativa con respecto de la responsabilidad del fabricante. En Chile no existe, pero ésta tiene un desarrollo enorme en otros países sobre las obligaciones del fabricante -sea o no proveedor del consumidor-.

▪ **Letra f): Espacios en blanco**

- ✓ ⁹Se refiere a la inexistencia de los contratos de adhesión que contengan **espacios en blancos que no hayan sido rellenados**.
- ✓ Los espacios en blanco en dº son muy peligrosos, porque después viene el juicio correspondiente y en él habrá que demostrar que el blanco fue mal llenado.

▪ **Letra g): En contra de la buena fe**

- ✓ ¹⁰Aquí por 1º vez nos encontramos con un elemento menos objetivo. Obviamente, que hay que demostrar cuándo hay buena o mala fe en los contratos de adhesión.
- ✓ ¹¹La buena fe se atenderá por parametros objetivos en los que se esté causando un daño al consumidor producido por un desequilibrio importante entre los dº y obligaciones de las partes.
- ✓ En el dº no se habla de asimetría, sino que se refiere a desequilibrios.
- ✓ No era necesario mencionar el principio de la buena fe porque -en el caso chileno- uno de los principios generales del dº es la buena fe.
- ✓ ¿Por qué es tan importante el concepto de buena fe en el dº?³ Porque –según *Yrarrázaval*- es un principio inspirador del dº. La equidad se debe tratar de obtener a través de la buena fe, y no a través del engaño, fraude o artimaña.
 - ❖ Caso Colo-Colo: un presidente de Colo-Colo le da un préstamo al equipo para contratar jugadores con un interés bajo. Entonces, el club en vez de endeudarse con el sistema bancario o con lo que sea, se endeuda con el presidente con un préstamo con interés generosísimo.
- ✓ Habrá que analizar cada caso para ver si se hizo de buena o mala fe.
- ✓ ¹²La finalidad del contrato determina la buena o mala fe, además de las disposiciones especiales o generales que lo rigen.
- ✓ ¹³Si los contratos fueron revisados y autorizados por la autoridad competente (CMF u otras) se presume de buena fe. Pero esto no es una presunción de dº, sino una **presunción simplemente legal**. La diferencia entre una y otra es importantísima.
 - ❖ Cuando es simplemente legal, admite prueba en contra. Entonces, se presume la buena fe salvo que la otra parte pruebe la mala fe.
 - ❖ En las presunciones de dº no se admite prueba en contrario.
 - ❖ Pero, cuando la presunción no dice si es de dº o simplemente legal, se entiende que es simplemente legal. Ahí la jurisprudencia y la doctrina son concurrentes al respecto.

- Son 7 letras que cubren temas muy distintos, pero todos muy relevantes.

○ **Inc 2:**

- ¹⁴Si en estos contratos se designa árbitro, para resolver los conflictos el

³ Hay ciertos países en que ni siquiera se menciona la buena fe.

consumidor podrá recusarlo (rechazarlo) sin necesidad de expresar causa y solicitar que se nombre otro por el juez letrado competente.

- Muchos de los contratos masivos, tienen designación de árbitro. La designación se puede hacer con una cámara de arbitraje (que designará al árbitro) o con un árbitro con nombre y apellido.
- Como éstos arbitros -por lo general- están incluidos en el contrato de adhesión -no negociable-, se le permite al consumidor recusar al arbitro sin expresión de causa porque puede tener la desconfianza de que como fue designado por el proveedor, no será totalmente imparcial.
- Así, se le pide al juez letrado que designe al nuevo árbitro.
- Después, se incluyen ciertas normas para el arbitraje, pero no son relevantes.

○ Art 16 A: Nulidad

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 4º - NORMAS DE EQUIDAD EN LAS ESTIPULACIONES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Artículo 16 A- *Declarada la nulidad¹ de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato de adhesión², por aplicación de alguna de las normas del artículo 16³, éste subsistirá con las restantes cláusulas, a menos que por la naturaleza misma del contrato, o atendida la intención original de los contratantes, ello no fuere posible.⁴ En este último caso, el juez deberá declarar nulo, en su integridad, el acto o contrato sobre el que recae la declaración.*

- Se incorpora en el 2004.
- ¹Es bien interesante porque parte con *declarada la nulidad* y el art 16 parte con *no producirán efecto alguno*, entonces ¿es inexistencia o nulidad? Pareciera que es **nulidad** y no inexistencia. Esto no es muy claro, pero, *Yrarrázaval* se inclina más por la nulidad.
- ²Hubo una gran discusión de algunos que sostenían que si un contrato de adhesión contenía alguna de esas cláusulas, el contrato entero era ineficaz. *Yrarrázaval* no está de acuerdo con esa postura, y señala que la nulidad se tiene que pedir con respecto de aquellas cláusulas que no debieran ir contenidas en un contrato de adhesión, pero que las demás debieran seguir vigentes por justicia con el consumidor.
- ³Entonces, la sanción para los casos mencionados en el art 16 es la **nulidad de la o las cláusulas o estipulaciones** correspondientes.
- ⁴La nulidad se da con respecto de una o varias cláusulas o estipulaciones. **Subsiste el resto del contrato, a menos de que se elimine una cláusula de la esencia del contrato.** En ese caso, la declaración de nulidad debiera ser de todo el contrato.

○ Art 16 B: Procedimiento nulidad

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 4º - NORMAS DE EQUIDAD EN LAS ESTIPULACIONES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Artículo 16 B- *El procedimiento a que se sujeta la tramitación de las acciones tendientes a obtener la declaración de nulidad de cláusulas contenidas en contratos de adhesión, será el contemplado en el Título IV de la presente ley.¹*

- ¹El procedimiento para declarar la nulidad se contempla en el Título IV.

- **Art 17: Formato del contrato de adhesión**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 4º - NORMAS DE EQUIDAD EN LAS ESTIPULACIONES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Artículo 17- Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos¹ de modo claramente legible², con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros³ y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico⁴. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.⁵

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos impresos en formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen por sobre las del formulario cuando sean incompatibles entre sí.⁶
(...)

- **Inc 1:**

- ¹Los contratos de adhesión deben estar **escritos** con ciertos requisitos:
 - ✓ ²De un modo claramente **legible**.
 - ✓ ³**Tamaño de letra adecuado** (no inferior a 2,5 mm).
 - ✓ ⁴En **castellano** (salvo palabras en otros idiomas que el uso haya incorporado al léxico). En materia comercial, permanentemente se están agregando palabras en inglés, y que incluso la RAE ha ido aceptando algunos.
- ⁵Las cláusulas que no cumplan con los requisitos anteriores, no producirán efecto alguno para el consumidor. Esto se refiere a la **nulidad**.

- **Inc 2:**

- ⁶Entonces, si se agrega algo era porque la intención de las partes era que se modificara el texto anterior. Por lo tanto, si son incompatibles a las del formulario, prevalecen las **agregadas**.

- Desde el art 17C se refiere a los contratos de adhesión en los productos y servicios financieros.

2 de mayo

- En el año 2011, se le agrega al art 17 una profusa normativa con respecto de los contratos de servicios financieros. Va desde la 17 A hasta la 17 L. Toda esta normativa obedece a reemplazar al Superintendente de Bancos.
- Uno diría que a lo mejor fue bueno que la normativa de los contratos bancarios (constituyen buena parte de los servicios financieros) estén en la ley y no en circulares de la Superintendencia.⁴ El punto de fondo es ¿qué sistema es más adecuado? A juicio de *Yrarrázaval*, es mejor que estén en las circulares y no en la ley porque si se tuviera en la ley, por cada modificación se tendría que pasar por todo un nuevo trámite legislativo. Y, claramente, este es un tema que va a modificándose constantemente, y especialmente por las tecnologías.
- ¿Qué pasa cuando hay normas en la ley y en normativa regulatoria de circulares?

⁴ En la LGB hay muy pocas normas sobre los contratos, prácticamente ninguna.

Prima la ley por superioridad jerárquica. Entonces, prima la LPC frente al mismo tipo de normativa contenido en la LGB o en la Superintendencia de Bancos (SBIF).

- Del art 17 A en adelante, la normativa es totalmente reglamentaria.

PÁRRAFO 5º: RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

- Acá se habla sobre el incumplimiento, salvo para los contratos de adhesión que están mencionados anteriormente.
- Cuando se incumplen las normas legales con respecto a los contratos de adhesión, se pide la **nulidad** de alguna(s) de sus cláusula(s).
- En este título, todos hacen relación con las obligaciones del proveedor. Entonces, la ley primero conceptualiza cuáles son las obligaciones del proveedor y después dónde se producen los incumplimientos de dicho proveedor. Es una estructura curiosa. Aquí, se separa las obligaciones de las sanciones, y generalmente éstas van juntas.
- **Art 18: Precio**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 18- Constituye infracción a las normas de la presente ley el cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicitado.¹

- Aparece nuevamente el concepto **precio** que es muy relevante en los contratos de consumo, que generalmente son contratos de compraventa.
- ¹Será una infracción un **cobro de precio mayor** al exhibido -por el establecimiento comercial-, informado -a través de cualquier medio- o publicitado -a través de la publicidad-.

- **Art 19: Cosa**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 19- El consumidor tendrá derecho a la reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que haya pagado en exceso¹, cuando la cantidad o el contenido neto de un producto sea inferior al indicado en el envase o empaque.²

- ¹El consumidor tiene **dº a la reposición del producto** , y, si esto no es posible a optar por la **bonificación de su valor** en la compra de otro producto, o por la **devolución del precio que se haya pagado en exceso** .
- Reposición se hace en los casos en que el producto salió malo, y, se debe reponer por uno nuevo de similares características.
- ²Todo esto se hace en el caso de que la **cantidad o el contenido del producto** sea inferior al indicado en el envase/empaque.

○ Art 20

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 20- *En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados¹, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada:²*

a) Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio³ no cumplan las especificaciones correspondientes;⁴

b) Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado;⁵

c) Cuando cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad;⁶

d) Cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra;⁷

e) Cuando después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere la letra c).⁸ Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia distinta a la que fue objeto del servicio técnico, o volviere a presentarse la misma, dentro de los plazos a que se refiere el artículo siguiente;

f) Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine;⁹

g) Cuando la ley de los metales en los artículos de orfebrería, joyería y otros sea inferior a la que en ellos se indique.¹⁰

(...)

- ¹El consumidor puede optar a una serie de opciones **sin perjuicio** de la **indemnización** por los daños ocasionados.
- Se debe distinguir la sanción propiamente de la ley, que en general es una multa a beneficio fiscal de la indemnización por perjuicios otorgada a los consumidores. Lo que debe hacer el consumidor es demandar al mismo tiempo el incumplimiento de la ley y la indemnización de perjuicios. Y, si no demanda por indemnización de perjuicios, la pierde. Entonces, toda demanda -a juicio de Yrarrázaval- con respecto a la PC, debe llevar por un lado, toda la relación de cómo se produjo el incumplimiento por parte del proveedor, y, por el otro lado, cómo ese incumplimiento dañó al consumidor. Se hace **PARALELAMENTE** (no como en el caso de la LC).
- En la competencia, se puede demandar por indemnización de perjuicios **solo con sentencia ejecutoriada**. NO son paralelas. Hoy en día, el TDLC también tiene que resolver el tema de la indemnización, pero luego de la sentencia ejecutoriada del caso. Hasta el año 2016, se hacía la demanda por indemnización de perjuicios ante tribunales ordinarios.
- En este caso, una de las principales diferencias de la indemnización es que en este caso, se puede reclamar **desde el día 1** porque el consumidor tiene que tener el **incentivo** para denunciar, de lo contrario la aplicación de la LPC sería

muy baja.

- Esta indemnización es por los montos experimentados por el consumidor, y, no son gigantescos como en dº de la competencia. Los tribunales han sido bastante “mezquinos” con estos montos, ya que como es difícil medir, sancionan con un monto similar al de la multa.
- Además, hay **una gran audiencia** donde se resuelve todo. En ella, el consumidor tiene que jugársela con todo. En cambio, en dº de la competencia, las audiencias probatorias duran meses.
- ²La ley ofrece varias alternativas **antes** de ir a juicio. El consumidor puede optar por: la **reparación gratuita** del bien o, previa restitución, su **reposición o la devolución de la cantidad pagada**. Si se opta por alguna de ellas, se acaba el problema.
- Antes de la ley (década del 80'), los consumidores reclamaban en la forma más estruendosa posible directamente con las empresas.
- Luego, se señalan los casos en los que el consumidor puede optar por la reparación gratuita, reposición o devolución del dinero.
- **Letra a)**
 - ✓ ³Cuando los productos sujetos a **normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan** las especificaciones correspondientes.
 - ✓ ⁴La ley siempre está distinguiendo entre cumplimiento obligatorio de normas y cumplimiento voluntario de normas. Cuando quiere que haya un cumplimiento obligatorio lo dice expresamente.
- **Letra b)**
 - ✓ ⁵Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos **no correspondan a las especificaciones** que ostenten o a las menciones del **rotulado**.
 - ✓ La *rotulación* son las menciones que se exigen -tanto obligatoria como voluntariamente- a ciertos productos.
- **Letra c)**
 - ✓ ⁶Cuando cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, etc **no sea enteramente apto para el uso o consumo** al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad.
 - ✓ Aquí está metido a la LPC algo que a juicio de *Yrarrázaval* debería estar por separado. Se refiere a la **responsabilidad del fabricante**, porque ella no es la misma que la responsabilidad del proveedor.
 - ✓ Los países en los que hay legislación importante en materia de la responsabilidad del fabricante, esto pasa a ser una normativa mucho más importante que la de PC. Se debe a que los bienes que se fabrican son los más caros de todos, por ejemplo, autos, refrigeradores, lavadoras, etc.
- **Letra d)**
 - ✓ ⁷Cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas **especificaciones y esto no ocurre**.

- ✓ En muchos contratos el consumidor dice que quiere el producto con determinadas características. Esto sucede en muchas especificaciones, especialmente en maquinarias y productos tecnológicos.
- **Letra e)**
 - ✓ Se refiere al servicio técnico.
 - ✓ ⁸Cuando **después** de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el **servicio técnico** correspondiente, **subsistieren las deficiencias** que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere la letra c).
- **Letra f)**
 - ✓ ⁹Cuando la cosa objeto del contrato tenga **defectos o vicios ocultos** que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.
 - ✓ Esto en dº civil se llama **vicios redhibitorios**.
 - ✓ El CC contempla por un lado, la responsabilidad de que el vendedor sea dueño del bien (*evicción*), y, por otro lado, que la cosa tenga las cualidades y no tenga vicios ocultos, y, para eso está la acción redhibitoria.
- **Letra g)**
 - ✓ ¹⁰Cuando la ley de los **metales** en los artículos de orfebrería, joyería y otros sea **inferior a la que en ellos se indique**.
 - ✓ Se da típicamente en el caso del oro y la plata.
- Entonces, ya en el art 20 la ley empieza a entra en una infinidad de detalles importantes, pero con respecto de distintos tipos de bienes.

○ **Art 21**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 21- *El ejercicio de los derechos que contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto¹, siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor.² Si el producto se hubiere vendido con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si fuere mayor.³*
(...)

- ¹El ejercicio de los dº que contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los **3 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto**. Esta es la prescripción que contempla la LPC. Es cortísima en comparación a las de la LDLC, que depende de la gravedad del caso, pero es de 2, 3, 4, 5 y 10 años.
- ²Pero, después viene una **excepción** que es siempre que **éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor**. Esta excepción no deja de ser relevante, especialmente en los productos tecnológicos. Y, si uno lee los catálogos de los productos, probablemente no los esté usando adecuadamente.
- ³Si el producto se vende con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si éste fuese mayor.
- Después viene una larga normativa que distingue en los casos de devolución del producto, cambio por otro producto, etc.

○ **Art 22**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 22- Los productos que los proveedores, siendo éstos distribuidores o comerciantes, hubieren debido reponer a los consumidores y aquellos por los que devolvieron la cantidad recibida en pago, deberán serles restituidos, contra su entrega, por la persona de quien los adquirieron o por el fabricante o importador¹, siendo asimismo de cargo de estos últimos el resarcimiento, en su caso, de los costos de restitución o de devolución y de las indemnizaciones que se hayan debido pagar en virtud de sentencia condenatoria, siempre que el defecto que dio lugar a una u otra les fuere imputable.

- ¹Aquí se da una relación muy complicada entre **fabricante, proveedor y consumidor**.
- Cuando hay una Ley de Responsabilidad del Fabricante, esto no se produce. Se produce cuando no hay una ley.
- Entonces, ¿quién responde?. Este es un tema no menor. Uno se puede cuestionar quién agregó esa información engañosa, ¿el fabricante o proveedor? Por lo tanto, lo que hace la ley -en normas bastante complejas- es asignarle la **obligación al proveedor y él que se entienda con el fabricante**. Esta opción es la mejor ya que es la única forma seria de resolver el asunto. Puede ser que la responsabilidad no sea del proveedor, pero, con quien se entiende el consumidor es con él.
- Ejemplo supermercados: esto pasa constantemente, específicamente, con todos los productos con fecha de vencimiento y estado de pudrición. Ante reclamos, el proveedor usualmente recibe los productos -no forma una discusión con el consumidor- y luego se entiende con el fabricante del producto.

○ **Art 23: Multas**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 23- Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.¹

Serán sancionados con multa de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales, los organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto. Igual sanción se aplicará a la venta de sobrecupos en los servicios de transporte de pasajeros, con excepción del transporte aéreo.²

○ **Inc 1:**

- ¹Se comete infracción al estar vendiendo un bien/servicio con negligencia y que esto cause problemas al consumidor debido a fallas o deficiencias del producto.

○ **Inc 2:**

- ²Se sancionará con multas de hasta **2.250 UTM** a los organizadores de espectáculos públicos y transporte de pasajeros -salvo aéreo- que vendan sobrecupos.

- *Yrarrázaval* menciona que la venta de sobrecupos en las líneas aéreas debiese ser una de las más sancionadas. En el negocio aéreo siempre va a darse la situación de sobrecupos porque los aviones nunca vuelan llenos al 100%, entonces dejan siempre un sobrecupo para los efectos de tratar de llenar el avión completamente. Pero, indica que las empresas más serias resuelven estos temas de una forma razonable. Y, por tanto, cuando hay sobrecupo, le pagan a los consumidores y éstos lo pueden aceptar o rechazar. Hay otras aerolíneas que no hacen nada al respecto.
- *También, las aerolíneas indemnizan por el tema de las maletas, pero no tiene que ver con este art. Esto es un gran tema.
- Para los efectos de responsabilidad en materia de transporte aéreo está el Tratado de Varsovia.

○ **Art 24: Multas**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 24- Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales, si no tuvieran señalada una sanción diferente.¹

La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1000 unidades tributarias mensuales.² En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, hará incurrir al anunciante infractor en una multa de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales.³

(...)

- A juicio de *Yrarrázaval* se debió haber partido por este en vez del art 23.
- ¹Para las infracciones dispuestas en la ley, se impondrán **multas a beneficio fiscal de hasta 300 UTM** si no tuviesen señaladas una sanción diferente.
- Aunque son multas, no se comparan en lo absoluto con las multas existentes en el dº de la competencia. Eso explica que muchas situaciones de CD y de PC las partes traten de llevarlos al dº de la competencia por el tipo de sanciones que tiene.
- Luego, se mencionan algunas situaciones especiales. Algunas de estas son:
 - ✓ ²Cuando se trata de publicidad falsa o engañosa con hasta 1000 UTM.
 - ✓ ³Cuando se trata de servicios o productos que afecten a la salud, la seguridad de la población o el medio ambiente, hasta 2.250 UTM.

○ **Art 26: Prescripción**

TITULO II - DISPOSICIONES GENERALES - PÁRRAFO 5º - RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 26- Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de dos años, contado desde que haya cesado en la infracción respectiva.¹ Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales.

El plazo contemplado en el inciso precedente se suspenderá cuando, dentro de éste, el consumidor interponga un reclamo ante el servicio de atención al cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor, según sea el caso.² Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluida la tramitación del reclamo respectivo. Asimismo, dicho plazo se suspenderá por la intervención del Servicio, entendiendo por ésta la comunicación formal del acto a través del cual se efectúe el primer requerimiento referido a la infracción en cuestión, el que en todo caso deberá ser suscrito por el funcionario competente, por requerir el afectado la intervención del Servicio o por el inicio de oficio de un procedimiento administrativo sancionatorio.
(...)

○ **Inc 1:**

- ¹El plazo de prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad de las conductas que contravienen la ley, será de **2 años** desde que se cesa en la PR.
- El plazo para ejercer las acciones como consumidor es de **6 meses**.
- Muchas veces no es fácil distinguir entre los plazos de prescripción de 3 meses - para reclamar- y éste. Éste es para los casos en los cuales se cuenta desde la infracción. Y, los 3 meses son para reclamar por parte del consumidor.

○ **Inc 2:**

- ²El consumidor si interpone un reclamo ante el SERNAC, no tendrá ese plazo de prescripción, vale decir, se suspende el plazo de prescripción.

III. TÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECIALES

PÁRRAFO 1º - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

- Hay muchas disposiciones especiales. Muchas de ellas son reglamentarias y se entienden bajo una simple lectura.
- **Art 28**

TÍTULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES - PÁRRAFO 1º - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 28- Comete infracción a las disposiciones de esta ley el que, a sabiendas o debiendo saberlo¹ y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño² respecto de:³

- a) Los componentes del producto y el porcentaje en que concurren;⁴
- b) la idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante;⁵
- c) las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial;⁶
- d) El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad a las normas vigentes;⁷
- e) Las condiciones en que opera la garantía, y⁸
- f) Su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser reciclable o reutilizable.⁹

- ²Comete infracción el que -a sabiendas o debiendo saber- induce a error o engaño mediante la publicidad.
 - ¹Dice *a sabiendas o debiendo saber*, para que los proveedores no se excusen alegando que no tenían conocimiento. Entonces, el elemento intencional es muy importante. Este elemento es bastante discutido, porque la publicidad nunca proporciona la totalidad de la información, sino que, destaca algunas de las características más importantes del bien.
 - ³Luego, menciona 6 casos distintos, pero que están todos referidos a los bienes:
 - ✓ ⁴Componentes del producto
 - ✓ ⁵Idoneidad del bien
 - ✓ ⁶Características relevantes
 - ✓ ⁷Precio
 - ✓ ⁸Condiciones en las que opera la garantía.
 - ✓ ⁹Condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida, y de ser reciclable o reutilizable.
 - Caso McDonald's: existe una "biblia de McDonald's" acerca de cómo se hace cada uno de los productos. Entonces, si hay algo distinto, es porque el operador está interviniendo en la *biblia*, y eso es causal de término inmediato de la condición de operador (de la franquicia). Esto debe ocurrir en todas las franquicias nacionales o internacionales y respecto de distintos bienes o servicios (ropa, hoteles, etc).
- El art 28 A se refiere al **mensaje publicitario**.
 - El art 28 B se refiere a la **comunicación promocional**.

○ **Art 29**

TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES - PÁRRAFO 1º - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 29- *El que estando obligado a rotular los bienes o servicios que produzca, expendo o preste, no lo hiciere, o faltare a la verdad en la rotulación, la ocultare o alterar¹, será sancionado con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.*

- ¹Comete infracción el que estando obligado a rotular, no lo haga o falte a la verdad en ella.
- Caso Papayas La Serena: venden algunas como si se produjesen allá y no necesariamente tienen la misma calidad.
- La multa será de hasta **300 UTM**.

○ **Art 30**

TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES - PÁRRAFO 1º - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 30- *Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los precios de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.¹*
 (...)

- ¹Los proveedores deben **dar conocimiento al público de los precios** de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.
- Después, vienen todas las características con respecto al precio.

○ **Art 31**

TITULO III - DISPOSICIONES ESPECIALES - PÁRRAFO 1º - INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 31- *En las denuncias que se formulen por publicidad falsa, el tribunal competente, de oficio o previa solicitud del Servicio o del particular afectado, podrá disponer la suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten.¹ Podrá, asimismo, exigir al anunciante que, a su propia costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades,² dentro del plazo fatal de diez días hábiles.*
 (...)

- Es interesante porque contempla una sanción distinta a la multa.
- ¹En las denuncias que se formulen por **publicidad falsa**, es decir, la que no se compadece de la verdad, el tribunal competente, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la **suspensión de las emisiones publicitarias** cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten.
- ²También puede exigir al anunciante que, a su propia costa, **realice la publicidad correctiva** que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades.
- Esto se ha producido poco, pero no deja de ser una sanción bastante efectiva, porque cuando hay publicidad falsa, indiscutiblemente el impacto que eso tiene sobre otras empresas, es muy grande.

○ El art 32 refiere a la **información básica comercial**.

PÁRRAFO 2º - PROMOCIONES Y OFERTAS

PÁRRAFO 3º- DEL CRÉDITO AL CONSUMIDOR

- Aquí hay una largo articulado.
- Se refiere a los créditos al consumidor otorgado por los proveedores. Estos son importantísimos, por lo tanto, hay toda una normativa con respecto de los créditos de los proveedores.
- Son créditos de proveedores, NO de bancos.

PÁRRAFO 4º- NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÁRRAFO 5º-DISPOCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

→ Entonces, tenemos 5 párrafos sobre distintas materias que son muy reglamentarios.

IV. TÍTULO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE DA LUGAR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY

PÁRRAFO 1º - NORMAS GENERALES

- Las normas más importantes están al comienzo, luego, vienen unas normas procedimentales que son muy detalladas y de fácil lectura.
- Ciertas cosas fundamentales del procedimiento:
 - El juez competente son los **jueces de policía local (JPL) salvo en las demandas colectivas y de intereses difusos.**
 - En el caso de los contratos de adhesión uno se puede preguntar por qué las demandas colectivas y de intereses difusos está dentro de la LPC y no en una aparte.⁵ En Chile, esta materia está tratada en muy pocas leyes y la más importante es la LPC. Entonces, el legislador prefirió incorporar este tipo de contratos a la LPC y no tener una ley separada. *Yrarrázaval* tiene sus dudas sobre esto, pero dice que es mejor porque limita esta importante materia solamente a los casos de PC, y no por ejemplo a casos medioambientales o de responsabilidad del fabricante (tienen otros procedimientos).
 - Estas leyes de demandas colectivas o de intereses difusos tuvieron un gran desarrollo en el sistema anglosajón, pero mucho menor desarrollo en la Europa continental. En USA o Inglaterra, las grandes demandas son las colectivas o de intereses difusos, y, cada vez más. En cambio, en Europa continental hay muy pocas demandas de intereses colectivos o difusos.
 - ¿Por qué se llaman **demandas colectivas**? Porque se unen **muchas personas** que fueron **afectadas**.
 - ✓ Entonces, en definitiva es un gran sistema para **simplificar el procedimiento**.
 - ✓ El asunto es que estamos yendo de una demanda que generalmente es individual a otra que es colectiva y que puede tener una **repercusión enorme**.
 - ✓ En definitiva, es un reconocimiento de ciertas situaciones que comprometen a muchas personas afectadas por el mismo hecho.

⁵ En muchos países se encuentra en una ley distinta.

- ✓ Esto me cambia la visión de la **indemnización de perjuicios** que se puedan tener en forma muy relevante.
- ✓ ¿Cómo será la responsabilidad con respecto de accidentes medioambientales o con respecto de fallas en la producción de ciertos bienes?⁶ ¿Objetivas o subjetivas?
 - ❖ Andrés Bello siguiendo al dº continental estableció que la **responsabilidad siempre es subjetiva**, salvo que el legislador contemple responsabilidades objetivas para ciertos casos.
 - ❖ En cambio, en el dº anglosajón hay muchas **responsabilidades que son objetivas**. En ellas, no importa la razón del daño, solamente que se produjo un daño.
 - ❖ Caso Quinteros: uno cree que todo esto es muy teórico, pero, ¿qué pasó en Quinteros este año con esos miles de personas que terminaron en hospitales por la contaminación? Muy poco, justamente, se tuvo que modificar la ley para contemplar situaciones como esa. El problema de fondo de Quinteros es que todas las empresas establecidas se lavaron las manos, y, la autoridad tampoco pudo llegar a una conclusión clara porque esto era por gases en el aire que afectaban la salud de las personas, especialmente la de las guaguas y menores de edad. Eso en el medio anglosajón habría tenido una solución inmediata, por la responsabilidad objetiva, y por lo tanto responden todas las empresas que están contaminando, no importa cuánto contaminan.
 - Con este ejemplo se nota que el salto entre la responsabilidad objetiva y subjetiva es enorme, porque en la subjetiva se requiere que se pruebe la relación entre el actor del daño y el daño efectivamente causado, y en la objetiva no.
 - En el caso del Banco Estado y de otras situaciones que son pocas de demandas colectivas que han existido, al final, se ha llegado más a un acuerdo transaccional entre las partes, que a una resolución por la la CS.
- Las demandas de intereses difusos tiene complicaciones parecidas a la colectiva.
- Uno diría que ojalá que hubiese más responsabilidad objetiva en ciertos casos graves, pero es el legislador el que lo debe ir planteando.
- Pero ojo, que por el hecho de tener responsabilidad objetiva, no siempre se mejora mucho las cosas.
- ✓ Ejemplo sistema de salud USA: el sistema de salud es carísimo porque el cirujano tiene responsabilidad objetiva, entonces él toma un seguro para ese tipo de responsabilidad. Y, como éstos son altísimos porque el riesgo es altísimo (que la operación salga mala, incluso que la persona muera), entonces, lo que hacen las clínicas es traspasar este costo a los pacientes. Entonces, el sistema de salud es caro porque el sistema se distorsionó.

⁶ No están dentro del procedimiento de la LPC.

○ **Art 50: Demandas de interés individual, interés colectivo e interés difuso**

**TITULO IV – DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE DA LUGAR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY -
PÁRRAFO 1º - NORMAS GENERALES**

Artículo 50- *Las denuncias y acciones que derivan de esta ley se ejercerán frente a actos, omisiones o conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores.*

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ley dará lugar a las denuncias o acciones correspondientes, destinadas a sancionar al proveedor que incurra en infracción, a anular las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, a obtener la prestación de la obligación incumplida, a hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de los consumidores, o a obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda.

El ejercicio de las denuncias puede realizarse a título individual. El ejercicio de las acciones puede efectuarse tanto a título individual como en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores.¹

Se considerarán de interés individual a las denuncias o acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado.²

Se considerarán de interés colectivo a las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable³ de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual.⁴ Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.⁵

Para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan con motivo de denuncias y acciones será necesario acreditar el daño. Asimismo, en el caso de acciones de interés colectivo se deberá acreditar el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados.

- ¹Las demandas pueden hacerse a título individual, en beneficio del interés colectivo, o interés difuso de los consumidores.

1. Interés individual

- ✓ ²La ley las define como las denuncias o acciones que promueven exclusivamente la defensa de los dº del consumidor afectado.

2. Interés colectivo

- ✓ ⁴La ley las define como las acciones que se promueven en defensa de dº comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores.
- ✓ El asunto no es menor porque en materia de PC hay ciertas situaciones que afectan a muchas personas, entonces, pedir puras demandas individuales indiscutiblemente no corresponde.
- ✓ Este concepto de *demanda colectiva* es bastante nuevo dentro de nuestro ordenamiento jurídico a diferencia de lo que ha sido en el dº anglosajón, que ha estado ya por mucho tiempo.
- ✓ Por lo tanto, la novedad en su incorporación en nuestro sistema ya ha creado muchísimos problemas, porque no es nada fácil estas situaciones de demandas colectivas, ya que se puede prestar para muchos abusos.

- ✓ En los países anglosajones se está limitando las demandas colectivas -hay cada vez menos-, mientras que en los países continentales se produce una tendencia inversa. Esto se debe a los abusos que se han notado.
 - ❖ Ejemplo sistema de salud USA: en este sentido, algunos incluso sostienen que los problemas existentes en el sistema de salud norteamericano se deben a las demandas colectivas porque pasa a ser muy atractivo, especialmente para los abogados que se encargan de estas materias. Probablemente en el caso de nuestro país, se va a llegar a esto.
- ✓ A un consumidor afectado, le sale muy conveniente que vaya un abogado que no le va a cobrar nada en el caso que pierda el juicio. Como el juicio lo va a ganar más, o menos, obviamente que ir a las resultas de esos juicios pasa a ser toda una industria del pleito. Hay abogados que se dedican solamente a este tipo de juicios y les va excelentemente bien porque exactamente cómo hacerlo y la jurisprudencia que existe al respecto.
- ✓ ³La ley nos habla de consumidores **determinados o determinables**, porque muchas veces no se sabe a cuántas personas ha afectado una determinada infracción en materia de PC. **Entonces, perfectamente la demanda colectiva se puede presentar por "X" personas y después al comprobarse que los afectados fueron más, se agregan los restantes.**
- ✓ Caso ISAPRES: en el tema de las ISAPRES NO se hicieron demandas colectivas porque no está contemplada la posibilidad de hacerlas de esta manera.
- ✓ **NO son de aplicación general**, sino de aplicación a aquellas situaciones en las cuales el legislador las establece como permitidas.

3. Interés difuso

- ✓ Son más complicadas todavía.
 - ✓ ⁵**La ley las define como las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus dº.**
 - ✓ Estas demandas ya no requieren ni siquiera que sea determinable, sino que es indeterminado, y, va a depender de todas las pruebas que se presenten, el nº de personas que quepan en esa demanda.
 - ✓ La hace una persona y ésta plantea que por las características del caso abarca a más personas.
 - ✓ Aquí, es **en el juicio mismo donde se va a determinar a qué personas se afectó**. Incluso, en la sentencia misma puede decir que todas las personas afectadas que lo demuestren, tienen dº a la indemnización correspondiente, y, se indica el procedimiento por el cual se obtiene la indemnización.
- Existe un procedimiento para las demandas colectivas y otro para las de interés difuso, que, no son muy distintos. La diferencia radica en que en una el nº de afectados es **indeterminado** -difusas- y en la otra es **determinado o determinable** -colectivo-.

○ Art 50 A

**TITULO IV – DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE DA LUGAR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY -
PÁRRAFO 1º - NORMAS GENERALES**

Artículo 50 A- Las denuncias presentadas en defensa del interés individual podrán interponerse, a elección del consumidor, ante el juzgado de policía local correspondiente a su domicilio o al domicilio del proveedor.¹ Se prohíbe la prórroga de competencia por vía contractual.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a las acciones mencionadas en la letra b) del artículo 2 bis, emanadas de esta ley o de leyes especiales, incluidas las acciones de interés colectivo o difuso derivadas de los artículos 16, 16 A y 16 B de la presente ley, en que serán competentes los tribunales ordinarios de justicia, de acuerdo a las reglas generales.²

- ¹Los **jueces de policía local (JPL)** tienen jurisdicción solo para **demandas individuales**. Y, se puede interponer al JPL correspondiente al del domicilio del consumidor o proveedor.
- ²Los JPL local no tienen jurisdicción sobre las demandas de **interés colectivo o difuso**. Ahí, se les otorga la competencia a los **tribunales ordinarios de justicia**.
- Esto no es un tema menor, hay ventajas y desventajas con que sean los JPL.

✓ Ventajas

❖ La **cercanía** con los consumidores.

→ Estos jueces no necesariamente son abogados, pero, la inmensa mayoría lo son.

→ Resuelven infracciones de tránsito, patentes municipales - especialmente las de alcoholes-, problemas de convivencia vecinal, etc.

→ Además, a estos jueces no hay necesidad de ir con abogados. Esto expresa que es parte del sistema judicial pero conociendo temas menores, pero que para la gran mayoría de las personas son muy importantes.

→ Además, se contempla un procedimiento rápido, bastante sumario como se denomina procesalmente. Puede fallar perfectamente entre 1 mes a 3 meses a lo más. Mientras que un juez ordinario lo hace entre 1 año a 2 años. A esto se agrega que el juez ordinario tiene un carga de trabajo inmensa, por lo tanto, si tuviera jurisdicción sobre los casos de PC, no le daría prácticamente ninguna importancia, ya que tiene otras causas bastante más importantes en términos de montos y complejidades.

✓ Desventajas

❖ **No necesariamente son abogados**. Y, no es nada de fácil para una persona que no es abogada fallar una causa.

❖ Además, va surgiendo una **jurisprudencia bastante contradictoria**.

❖ Ojo que éstas sentencias se pueden apelar a la Corte de Apelaciones. Esto es un tema, porque nos pasamos de la menor categoría de tribunales a una categoría bastante alta. La otra posibilidad es que se pudiera apelar ante el juez ordinario, pero se prefirió llevar la apelación a las CA.

❖ Por lo tanto, la gran mayoría de las causas de PC terminan al nivel del JPL

ya que si se extiende a la CA se debe asumir todas las cargas y complicaciones que tiene una causa en ese nivel.

- Por lo tanto, el tema de la jurisdicción de la PC no es un tema fácil. En otros países, existen los denominados *jueces vecinales*, que es una categoría intermedia entre los JPL y los jueces ordinarios, y eran todos abogados. En Chile tuvimos una pequeña experiencia con ellos.

PÁRRAFO 2º - DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA

PÁRRAFO 3º - DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES

PÁRRAFO 4º - DEL PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES

V. TÍTULO V: DEL SELLO SERNAC, DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- Este título se incorporó en el año 2011.
- Esta materia se refiere solamente a los **contratos financieros en materia de PC**. Aquí, viene otra infinidad de normas incluyendo una figura importante en el dº que es la **mediación** entre el SERNAC -por un lado- y los proveedores implicados -por el otro-. De aquí surgen las famosas demandas colectivas. Las hemos tenido; no muchas, pero importantes.
 - Caso Banco Estado: 3 millones de demandantes en el caso. El SERNAC hizo todo un trabajo de mediación con el banco con un resultado razonable.
- La mediación es una institución en nuestro país todavía muy poco usada, porque la solución de conflictos o se hace en Chile en los tribunales ordinarios o por medio de un sistema de arbitraje.
- La gran diferencia entre la **mediación** y el **arbitraje** es que el arbitro **falla**, en cambio, el mediador no falla, sino que **recomienda**. Hay un abismo de diferencia entre uno y otro.
 - Por lo tanto, hoy en día, el sistema de arbitraje, en materia comercial especialmente es ampliamente usado; y, el sistema de mediación muy poco usado. En otros países se está usando cada vez más.
 - Pero, al no tener el mediador la facultad de fallar -sino solamente de recomendar- obviamente que las partes serán libres de seguir a un arbitraje o de aceptar o no la recomendación dada por el mediador.
 - ❖ Caso mediación Chile-Argentina: tuvimos de mediador al Papa y anteriormente a la Reina de Inglaterra.

LEY DE COMPETENCIA DESLEAL (CD) (LEY Nº 20.169)

- Esta es una ley bastante simple y bastante reciente.
- Es del año 2007 y tiene 2 modificaciones muy menores.
- Es una ley prácticamente copiada de la ley española con algo de la ley colombiana.
- *Yrarrázabal* considera que es una ley muy necesaria pero que se utiliza algunos conceptos de CD para el dº a la competencia -prácticas restrictivas- y otras veces para PC.
- Aquí, el bien jurídico protegido es la **RELACIÓN ENTRE EMPRESAS**⁷.

I. CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

○ **Art 1**

CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES

Artículo 1- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal.¹

- ¹Esta ley parte mal. Pretende definir la CD, no la define, y, mete a los consumidores entre medio. Esto genera que, haya muy poca jurisprudencia en materia de CD.

○ **Art 2**

CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES

Artículo 2- Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más de las siguientes acciones:¹

- a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, sobre libre competencia.²***
- b) Las reguladas en la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.³***
- c) Las reguladas en la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial.⁴***

- A juicio de *Yrarrázaval*, los 2 primeros art son igual de confusos.
- ¹En definitiva, este art 2 está diciendo que hay ciertas conductas que son de CD, pero además, menciona 3 casos:
- ²**Letra a): de Dº a la Competencia**
 - ✓ La relación que tiene con el dº de la competencia se da en una sola práctica: **competencia desleal.**
 - ✓ Especialmente después de esta ley, la jurisprudencia felizmente ha sido muy clara que para que haya una práctica de CD sancionable bajo el dº de la competencia se requiere que el **acto de CD signifique alcanzar, mantener o aumentar una posición dominante en el mercado.** Vale decir, NO es que la CD *per se* sea una PR de la competencia, sino que es aquella CD utilizada -por

⁷ El bien jurídico protegido en dº de competencia es la **competencia** y en la PC es la **relación entre consumidor y proveedor.**

una o más empresas- para los efectos de alcanzar, mantener o aumentar su posición dominante en el mercado.

- ✓ Y, a partir de esta exigencia de la jurisprudencia, han sido cada vez menos los casos de CD presentados como PR del dº de competencia.
- ✓ El problema generado en Chile -a juicio de *Yrarrázaval*- se da a raíz del art 3 inc 2 de la LDLC, que incluye a la CD como una PR. Esto fue mal copiado a los españoles. España es prácticamente el único país en el mundo que tiene la CD como una PR, y, lo ha mantenido.
- ✓ En Chile, se aclara a través de la jurisprudencia en materia de competencia, que la CD solamente podría llegar a ser una PR en la medida que alcance, mantenga o aumente su posición dominante. La jurisprudencia ha sido reiterativa en esto. Vale decir, una CD que no tenga ese objeto, no se considera como PR.
- ✓ Por lo tanto, si la empresa no tiene una posición dominante, y, realiza un acto de CD, no tendrá ningún efecto para la LDLC.
- ✓ Antes de esta ley, e incluso en algunos casos posteriores, obviamente hubo mucha confusión en la jurisprudencia. Pero, felizmente esto ya ha sido clarificado.
- **³Letra b): de PC**
 - ✓ Aquí es más dudoso todavía. ¿En qué casos de la LPC se puede dar una CD? En **ninguno**, porque la LPC exige una relación entre proveedor y consumidor NO relaciones entre 2 proveedores.
 - ❖ Por lo tanto, malamente puede existir una CD en un caso de PC.
 - ✓ Si analizamos el art 4 de la LCD que contiene las prácticas de CD, hay algunas que se acercan bastante a las prácticas del consumidor. Pero, el **objeto es distinto**, en una se está protegiendo al consumidor NO a alguna empresa.
- **⁴Letra c): Ley de Propiedad Industrial e Intelectual⁸**
 - ✓ Esta es aún más rara porque dice que puede coexistir la CD con la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial. No tienen nada que ver a juicio de *Yrarrázaval*; dice que son conceptos totalmente distintos.
 - ✓ ¿Podrá haber algún caso en que coexistan?
 - ❖ Caso Toyota VS Mercedes Benz: Toyota comparaba las características de una camioneta suya con una Mercedes Benz. Esta era una publicidad verdadera, demostrable y directa. Pero, este caso fue tratado por Ley de Propiedad Industrial e Intelectual porque estaba usando la marca de Mercedes sin su autorización -su propiedad industrial e intelectual-. La finalidad de Toyota era demostrar que eran igual de buenos que Mercedes, pero más baratos.
 - ❖ Caso Pepsi challenge: Se refiere a la comparación de *Pepsi* con *Coca-Cola* con la vista vendada. No tenían la autorización de *Coca-Cola*, por lo que después la hacen con una botella cualquiera, pero pierde toda la eficacia

⁸ Actualmente, son 2 leyes separadas, pero probablemente en un futuro serán 1 sola ley, como se da en la mayoría de los países.

de la publicidad, ya que lo que quería demostrar *Pepsi* es que todos los que preferíamos *Coca-Cola* sobre la *Pepsi* estábamos equivocados. Además, técnicamente estas comparaciones tienen su pillería. Por ejemplo, en la comparación con vinos, según los expertos a una tº determinada los expertos no puede determinar si es tinto o blanco. A lo mejor, en las bebidas sin alcohol se produce algo similar.

- ✓ La propiedad industrial-intelectual tiene un sistema de defensa desde la década del 30` en Chile, y además, tiene sanciones penales, por lo tanto, es mucho más eficaz que la de CD.
- ✓ Pero, la ley la menciona porque el dueño de una marca/patente no solo tiene dº a no se use su marca/patente sin autorización previa, sino que además a que su marca/patente no se asemeje a la otras inferiores. Por lo tanto, el dueño de la marca tiene dº a que no la imiten.
 - ❖ Ejemplo cafés: Las marcas N° 2,3,4, etc. tratan de asimilarse a la N°1 en los colores, logos, etc. Esto es para que los consumidores que compran rápidamente en el supermercado, se equivoquen de vez en cuando.
- ✓ El único caso que se podría dar eventualmente sería que una empresa aprovenchándose de las marcas y patentes que tiene, realice actos contrarios a la buena fe y a las buenas costumbres como lo dice el art 3 de la LCD. Pero, a *Yrarrázaval* no se le ocurre ningún caso, ya que la Ley de Protección a la Propiedad Industrial y la de Propiedad Intelectual protege al **dueño de la marca o patente**. Y, ¿cómo va a haber CD cuando el dueño se defiende de los dº que tiene? Sin embargo, hay casos en los cuales el tema de la propiedad industrial o intelectual han salido en materia de dº de la competencia. No son muchos, pero en todos ellos la jurisprudencia ha sido exactamente la misma: no es el dominio de la marca/patente lo que puede afectar el dº de la competencia, sino que un mal ejercicio de la competencia para afectar a otras empresas.
 - ❖ Caso fósforos chinos: los fósforos en Chile han sido producidos desde hace mucho tiempo por una sola empresa, y por eso hay un caso de LC entre la empresa chilena y una canadiense que quiso entrar al mercado. Pero, este caso fue peor porque la empresa chilena trató de evitar que entraran a Chile estos fósforos chinos. Lo hizo registrando la marca de estos fósforos chinos -que venían en camino- a su propio nombre. Esto no es un problema del dº de competencia, sino que de la Ley de Propiedad Industrial-Intelectual.⁹ Indiscutiblemente, se sancionó a la compañía chilena de fósforos porque esto era para evitar que entraran los fósforos chinos a Chile, ya que sabían que si entraban, iban a liquidar a la empresa chilena en buena medida.
- Entonces, es la misma ley la que parte bastante mal y lo arregla recién en el art 3. Pero, estas normas generales poco sirven para aclarar este tema.

⁹ Quién puede registrar una determinada marca o nombre.

II. CAPÍTULO II: DE LA COMPETENCIA DESLEAL

○ Art 3

CAPÍTULO II – DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 3- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe¹ o a las buenas costumbres² que, por medios ilegítimos³, persiga desviar clientela⁴ de un agente del mercado.⁵

- Este art trata de arreglar un poco el enredo del art 1 y 2.
- ⁵La *competencia desleal* se define como **toda conducta contraria a la buena fe o las buenas costumbres que por medios ilegítimos persiga desviar la clientela de un agente del mercado.**
- La *buena fe* y las *buenas costumbres* son 2 conceptos muy importantes en el dº, pero ambos **indeterminados**.
- El dº habla permanentemente de la buena fe, y, de las buenas costumbres habla mucho menos.
- ¹Esto se da porque el concepto de la *buena fe* **se mantiene** a través del tiempo.
- ²Las *buenas costumbres* **van cambiando** en el tiempo.
- ³Debe hacerse por **medio ilegítimos**. En definitiva, el **acto de CD debe hacerse en contra de la buena fe o buenas costumbres por medios contrarios a las leyes, y, que persiguen desviar clientela de una empresa para la otra.**
- El art 3 menciona que éstos actos se deben realizar por **medios ilegítimos**. En otras palabras, si la ley lo autoriza NO sería un acto de CD. Esto no deja de ser importante, porque hay muchas situaciones en que es la ley la que autoriza esa actuación, y, por lo tanto, no pueden ser calificadas como actos de CD.
- ✓ Ejemplo publicidad comparativa: esto aparece en evidencia en el caso de la publicidad comparativa. La ley en Chile afortunadamente -según *Yrarrázaval*- no prohíbe la publicidad comparativa, pero, se exige que ésta sea verdadera y comprobable para ser legítima.
- ⁴Dice **desviar clientela** y NO *aumentar su participación en el mercado*. Esas palabras no le gustan mucho a *Yrarrázaval*, ya que en definitiva el objetivo es para aumentar la participación en el mercado, y, disminuirla al otro.
- A juicio de *Yrarrázaval* no es posible tener una definición de estos conceptos ni a nivel legal ni a nivel constitucional, porque son **indefinibles** jurídicamente. Son conceptos que van evolucionando a través del tiempo, y, le corresponde a la jurisprudencia ir determinándolos en cada caso particular.
- ✓ Otros conceptos indeterminados son: orden público, seguridad nacional, etc.
- ✓ Ejemplo revistas pornográficas: no hace mucho tiempo hubo una larga discusión de si se podía exhibir revistas pornográficas en los quioscos. Y, se le impusieron una serie de requisitos para su venta. Hoy en día, ésta se encuentra en internet con un libre acceso para todos. Entonces, el concepto va cambiando.
- ✓ Ejemplo casas de masajes: algunas son en realidad casas de prostitución. En un momento determinado, se pretendió hacer una fiscalización de todas las casas de masajes para saber si además eran casas de prostitución. Esto era imposible.

- ✓ En definitiva, no es que sean relativos estos conceptos, pero van cambiando la gran mayoría de ellos.
- ❖ Uno de ellos que nos ha importado mucho es el OPE. El concepto que tenemos hoy en Chile del OPE es gracias al profesor José Luis Cea que dio en la década del 80`. Este no es un concepto que se utilizara anteriormente, ni conceptualmente ni en la ley.

○ **Art 4**

CAPÍTULO II – DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 4- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.²

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.³

c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.⁴

d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.⁵

e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable⁶, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.

f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.⁷

g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.⁸

h) La imposición por parte de una empresa a un proveedor, de condiciones de contratación para sí, basadas en aquellas ofrecidas por ese mismo proveedor a empresas competidoras de la primera, para efectos de obtener mejores condiciones que éstas⁹; o, la imposición a un proveedor de condiciones de contratación con empresas competidoras de la empresa en cuestión, basadas en aquellas ofrecidas a ésta. A modo de ejemplo, se incluirá bajo esta figura la presión verbal o escrita, que ejerza una empresa a un proveedor de menor tamaño cuyos ingresos dependen significativamente de las compras de aquélla, para obtener un descuento calculado a partir del precio pactado por ese mismo proveedor con algún competidor de la primera empresa.

i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.¹⁰

(...)

- Plantea -en un listado- todos los distintos casos de CD en particular, mientras que el art 3 lo hace en general.

- Algunos son más sencillos, y, otros más complejos, pero lo que tienen de común es que son **actos de unas empresas en contra de otras empresas**.
- Este art los enumera en forma NO taxativa, vale decir, a título ejemplar. Aun así, más de un 90% de los casos se refieren a uno de los ya mencionados. Se hace una enumeración no taxativa porque pueden ir surgiendo nuevos actos de CD que no estén la numeración. Es la misma razón del art 3 inc 2 de la LDLC.
- Pero, los ejemplos los da con bastante detalle. Da 9 ejemplos:
- **Letra a): Publicidad comparativa**
 - ✓ ²Se refiere a toda conducta que **aproveche indebidamente la reputación ajena** induciendo a **confundir los propios bienes con los de un 3º**.
 - ✓ Vale decir, se está refiriendo a los casos de **publicidad comparativa**, siempre que éstos no sean verdaderos, directos y comprobables.
 - ✓ Los que hacen la publicidad comparativa no es la empresa Nº1, sino la que están por debajo de ella.
 - ✓ Las Nº1 no hacen publicidad comparativa porque ya tienen el liderazgo, y por lo tanto, no tienen porque hacerla.
- **Letra b): Inducción a error con respecto de las cualidades de los productos**
 - ✓ ³Se refiere al **uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error** sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, etc sobre las ventajas presentadas por los bienes.
 - ✓ Caso Papayas La Serena: éstas tienen la fama de ser las mejores. Hoy en día, se están vendiendo papayas como si fueran de La Serena pero en realidad no lo son. Los hechos o aseveraciones tienen que ser **incorrectos o falsos**. Por lo tanto, si se uno pone "Papayas La Serena del valle "X"", ¿sería incorrecto o falso? Sobre esto, se puede dar una gran casuística.
- **Letra c): Menoscabo de reputación ajena.**
 - ✓ ⁴Se refiere a todas las **informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas** sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un 3º, que sean susceptibles de **menoscabar su reputación en el mercado**. Además de las expresiones dirigidas a **desacreditarlos o ridiculizarlos** sin referencia objetiva.
- **Letra d):**
 - ✓ ⁵Se refiere a las **manifestaciones agraviantes** que versan sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra **circunstancia personal del 3º afectado** y que no tengan relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.
 - ✓ Esto no es menor, especialmente por el CI que tenemos. Muchas veces aparecen ridiculizaciones o información falsa con respecto de bienes provenientes de determinados países.
 - ✓ Se aprovecha de ciertas fobias, o incluso, ciertas características de los competidores para los efectos de ganar participación en el mercado.
- **Letra e):**
 - ✓ ⁶Se refiere a toda **comparación** de los bienes, etc cuando se **funde en un**

antecedente que no sea veraz y demostrable.

- ✓ Entonces, aquí se está incorporando a la ley los criterios de que la publicidad comparativa debe ser veraz y demostrable.
- **Letra f):**
 - ✓ ⁷Se refiere a toda conducta que persiga a **inducir** a proveedores, clientes u otros contratantes **a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.**
 - ✓ A *Yrarrázaval* no le gusta para nada esta letra. Indica: *¿a qué se refiere conducta que induzca a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor?*
- **Letra g):**
 - ✓ ⁸Se refiere al **ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales** con la finalidad de **entorpecer la operación de un agente del mercado.**
 - ✓ Para evitar que un competidor entre al mercado, o, para evitar que el otro agente realmente compita con él, indiscutiblemente se pueden ejercer muchas acciones judiciales para postergar.
 - ✓ Ha habido muchos casos, y, probablemente van a seguir existiendo. Especialmente, en la industria farmacéutica, se ha dado mucho este caso.
 - ❖ Caso medicamentos: todos los medicamentos importados deben ser autorizados por el Instituto de Salud Pública, y, sin la autorización no puede entrar ese producto. El procedimiento ya es lento, y, se puede hacer más lento si se ejercen ciertas acciones judiciales.
- **Letra h):**
 - ✓ Se incorpora en el texto del 2010, al igual que la letra i).
 - ✓ ⁹Se refiere a **la imposición por parte de una empresa a un proveedor**, de condiciones de contratación para sí, **basadas en aquellas ofrecidas por ese mismo proveedor a otros.**
 - ✓ Vale decir, en definitiva, se está refiriendo a **condiciones discriminatorias** en los contratos.
 - ✓ *Yrarrázaval* tiene sus dudas sobre ésta, ya que las condiciones van cambiando de un contrato a otro.
- **Letra i):**
 - ✓ ¹⁰Se refiere al **establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, o incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.**
 - ✓ *Yrarrázaval* dice que no cree que ninguna de las 2 últimas letras sean grandes creaciones jurídicas.

8 de mayo

III. CAPÍTULO III: DE LAS ACCIONES, PROCEDIMIENTO, TRIBUNAL COMPETENTE Y SANCIONES

- Afortunadamente -a juicio de *Yrarrázaval*- no ha ocurrido lo que pasó con la LPC. Vale decir, son pocas normas, y, son bastante claras al respecto.
- Son pocas normas procesales porque el legislador se fue por una jurisdicción con un procedimiento ya totalmente conocido. Como lo dice el art 8, será el **juez de letras** en lo civil del domicilio del demandado o del actor a elección de este último. Aquí se prefirió entonces, la **justicia ordinaria civil**. Obviamente que como no es una materia penal, se elige la justicia ordinaria civil. Y, se aplica entonces, el procedimiento contemplado en el CPC para lo que se denomina -en dº procesal- un **juicio sumario**. Es una especie de juicio relativamente rápido en comparación de los que no son sumarios. **Por lo tanto, no hubo ninguna razón para que se establecieran reglas especiales de procedimiento.**

○ Art 5 - Acciones

CAPÍTULO II – DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 5- Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones:¹

a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica.²

b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.³

c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.⁴

d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto⁵, **sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.**

- ¹Establece qué **tipo de acciones** puede ejercer una empresa que está siendo afectada por un acto de CD. Menciona **4 tipos de acciones** que se pueden ejercer conjunta o separadamente (**NO son excluyentes**). Todas ellas van a ser resueltas por el **juez ordinario en lo civil en juicio sumario**.
- **Letra a): Cesación del acto o prohibición del mismo**
 - ✓ ²En la demanda en un juicio de CD, se le puede pedir al tribunal que decrete de inmediato la cesación del acto que está generando la CD, o, la prohibición de que continúen realizando ese acto.
 - ✓ La 2º opción es el máximo. Esto, no es imposible en otros procedimientos, pero es muy difícil. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo la ley es decirle al juez que una de las formas por la que él puede tratar de evitar que se produzca el daño por CD a esta empresa es que **suspenda** el acto, o, que se **prohiba**.
 - ✓ Esto NO es posterior al juicio, sino que se hace como medida cautelar.
- **Letra b): Acción declarativa del acto de CD**
 - ✓ ³Se exige la acción declarativa de acto de CD si la perturbación creada por el mismo subsiste.

- ✓ Esto se produce en algunos casos. Vale decir, lo que pide el demandante es que se **declare**, incluso, que se **publicite** que tal empresa efectivamente realizó un acto de CD, porque eso para algunas empresas puede ser muy relevante.
- **Letra c): Acción de remoción de los efectos a través de publicaciones**
 - ✓ ⁴Se exige la remoción de los efectos producidos por el acto mediante la **publicación** de la sentencia condenatoria o de una **rectificación** a costa del autor del ilícito.
- **Letra d): Acción de indemnización de perjuicios**
 - ✓ ⁵Se exige la indemnización de perjuicios.
 - ✓ Esta indemnización de perjuicios -como ya la vimos en el dº de la competencia y dº de PC- se rige por las **normas generales del CC**.
 - ✓ Para un juez ordinario determinar las indemnizaciones de perjuicios es algo recurrente y permanente. Pero, para un JPL es muy esporádico porque hay una infinidad de reglas, de situaciones, etc. Se debe determinar si cabe o no el *daño moral*, el *daño indirecto*, etc.
 - ✓ En el caso del dº a la competencia, la indemnización de perjuicios es bastante complicada -en las colusiones- porque las determina el mismo TDLC. Uno diría que esto es facilísimo porque llevan bastante tiempo analizando el caso, pero, esta es una facultad muy reciente del TDLC, antes se determinaba en tribunales ordinarios. Se incorporó esta facultad en 2016. Además, es muy difícil establecer los daños generados e identificar a quiénes dañó.
 - ❖ Caso papel tissue: como era difícil establecer los daños y los afectados, la papelería ofreció pagar 7.000 pesos a todos los consumidores que reunían determinados requisitos. Los requisitos eran tan exigentes, que muy pocos pudieron cobrar los 7.000, que de hecho, no tienen nada que ver con un daño producido prácticamente por 10 años.
 - ❖ Caso supermercados y venta de pollos: el daño en ese caso se da por no poder vender por debajo de un determinado precio acordado entre los supermercados. Es muy difícil determinar cuánto es ese daño y quiénes son los afectados que son miles y miles de consumidores que habrían comprado el pollo a un precio más caro y no habrían podido aprovechar liquidaciones.
 - ❖ Caso farmacias: a pesar de que demoró 6 meses, se afectó a las personas que compran productos farmacéuticos con receta retenida. Se seleccionó afectar el precio del orden de 200 remedios de un total de 10.000 remedios.
 - ✓ Este es un tema no menor, porque indiscutiblemente que si uno sabe que la gran sanción en **dº a la competencia** es la **multa a beneficio fiscal**, que la sanción que se procura en la **PC** es la **multa a beneficio fiscal**, y que aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿en qué quedan las empresas afectadas y los consumidores afectados?

○ **Art 7 – Prescripción acciones**

CAPÍTULO II – DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 7- Las acciones de competencia desleal previstas en las letras a) a c) del artículo 5º prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal, o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad.¹ La acción de indemnización de perjuicios prevista en la letra d) del artículo 5º prescribe en el plazo de cuatro años contado del mismo modo.² El ejercicio de alguna de las acciones previstas en las letras a) a c) del artículo 5º interrumpirá el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios.

- ¹Las **acciones** de CD previstas en las letras a) a c) del art 5 -NO la de indemnización- **prescriben** en el plazo de **1 año** contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de CD, o desde que fue conocido.
- ²La **acción de indemnización** prescribe en un plazo de **4 años** contados del mismo modo.

Dº REGULATORIO

- El dº regulatorio en un pasado se denominaba *régimen de comercio interno*.
- Los dos regímenes (comercio interno y externo) eran cientos y cientos de normas, y, a veces incluso contradictorias entre sí.
- Lo que tenemos hoy día son leyes que se han ido modificando y adecuado a través del tiempo. Y, toda o buena parte de esas normas que pertenecían a regímenes de comercio interno o externo han **desaparecido** o están a nivel de **circulares**. Por lo tanto, está la ley por un lado, y por el otro las circulares.
- Por primera vez en nuestro país se establece el **dº regulatorio a nivel constitucional**. Queda expresado en el art 19 Nº 21 de la CPR que se refiere al dº a realizar libremente cualquier actividad económica, pero se limita por las normas legales que la regulen – “*respetando las normas legales que la regulen*”- y por la moral, el orden público y la seguridad nacional.
- Esta incorporación a nivel constitucional fue muy importante -según *Yrarrázaval*- porque quedó muy claro aquí que hay una norma de **reserva legal**. Entonces, el dº regulatorio en sus aspectos básicos tiene que estar **contenido en la ley**, NO en decretos supremos, reglamentos, circulares, etc.
- Esto se hace con el efecto de **garantizar el libre ejercicio de las distintas actividades económicas**, porque cuando no existe claridad respecto de este concepto, las autoridades -en muchos países para restringir e incluso prohibir ciertas actividades económicas- lo hacen por medio de decretos supremos o reglamentos que no van a ningún congreso y no son analizadas por nadie más que el correspondiente ministerio dentro del poder ejecutivo.
- Esto es una cuestión de todos los días porque indiscutiblemente, las normas regulatorias van surgiendo prácticamente en todas las distintas áreas de actividades económicas. Pero, hay ciertas actividades que están *totalmente* reguladas -para estos efectos- y hay otras que están *parcialmente* reguladas.
- La **Ley General de Bancos (LGB)** es un ejemplo de actividad económica **totalmente regulada**. Es el máximo de regulaciones concebible para una actividad económica.
- Esta regulación la tenemos en Chile para la actividad bancaria desde el año 25`. Esto se le ocurrió a la **misión Kemmerer** que vino a hacer **recomendaciones** en Chile, y una de las más importantes fue que la **actividad bancaria tenía que estar regulada**.
- Antes del 25`, existía una **ley para cada banco que se creara**. Algunos pueden creer que esto era muy inorgánico, desordenado, las distintas leyes no recibieron un padrón común, etc. Pero, los economistas que han estudiado este periodo de la historia bancaria han llegado a la conclusión de que no se produjo **ningún problema** grave en el sistema bancario debido al **patrón oro**. Los bancos emitían dinero de acuerdo con la **cantidad de reservas en oro que tuviesen**, por lo tanto, si las personas que habían depositado en un banco en un determinado momento desconfiaban de ese banco, le debían entregar las monedas de oro equivalentes a su depósito. Y, esas monedas de oro las llevaban a otro banco y las guardaban ahí. Lo único que hacía la autoridad era establecer qué % de reserva de oro debía tener el banco en relación con los depósitos.
- Pero, en el año 25` ya se creía en la gran mayoría de los países que se debía cambiar el

sistema para que las economías se desarrollaran muchos más de lo que se habían desarrollado hasta ese entonces. Esto se haría a través del **papel moneda**. Se denomina así porque no tiene ningún respaldo, y, consecuentemente lo que hizo la *misión Kemmerer* -en Chile y otros países- fue recomendar la **creación del BC como ÚNICO EMISOR**, eliminando así los billetes de cada banco. Hoy en día, el BC tiene la exclusividad y monopolio de la emisión de dinero. Esto es así en prácticamente todos los países del mundo.

- Con eso, uno podría decir entonces que la LGB no era tan necesaria porque los bancos comerciales juegan un rol muy menor en relación con la emisión y respecto del monopolio exclusivo del dinero por parte del BC. (Los bancos comerciales pasan a ser intermediarios entre depositantes e inversionistas). Pero, esto no es así por la **masa monetaria**, que incluye el **dinero bancario o giral** que NO es dinero real, es decir, no existe un dinero real emitido por los bancos comerciales. Lo que sí existe es que en el total de los depósitos bancarios, los bancos comerciales deben retener un determinado %, y, eso es lo que se llama **encaje bancario**, que es determinado por el BC. Hoy en día, en la gran mayoría de los países, el encaje bancario no supera el 5%. La tendencia es que cada vez estamos hablando de encajes menores, porque se creyó que éste era para darle seguridad al sistema bancario. *Yrarrázaval* cree que NO se la da, y, hoy en día nadie lo cree debido a que % de retención es bajo, y además, está comprobado empíricamente que no le da seguridad jurídica. Entonces, puede ser que como medida transitoria se aumente en un momento determinando el encaje para enfrentar una situación crítica, pero, creer que otorga seguridad jurídica permanentemente no tiene ningún sentido.
- Lo que los bancos prestan o colocan es el remanente de los depósitos descontado el encaje, por lo tanto, hasta ahí no hay ninguna creación de dinero bancario o giral. Lo que pasa es que las personas que reciben los préstamos -normalmente- las depositan nuevamente al sistema bancario y llegan como depósitos. Y, al ser depósitos se les vuelve a aplicar el encaje, y, se vuelve a prestar, y así sucesivamente. Allí, se genera el **multiplicador bancario** porque es la misma plata la que está volviendo varias veces al sistema.
- Este dinero bancario o giral es una de las comprobaciones de que las relaciones entre el BC y los bancos comerciales es muy estrecha. Porque indiscutiblemente los bancos comerciales desean que la tasa de encaje sea la menor posible para poder prestar lo mayor posible. En cambio, la autoridad en ciertos momentos debe aumentarlo por problemas monetarios.
- *Kemmerer* quiere una **LGB, una Superintendencia de Bancos (SBIF) y un BC como único emisor de dinero de carácter estatal**.
- Esto, que hoy en día parece con toda claridad, en el año 25` no era tan claro. Se observa esto mediante la composición del directorio del BC. El BC tuvo directorio durante mucho tiempo, y, los directorios son propios de los bancos comerciales. Además, los directores del BC podían ser representantes de bancos comerciales nacionales o extranjeros, pero siempre el control lo tenía el Eº. Vale decir, la cantidad de directores estatales dentro del BC siempre fue mayoritaria, pero, entre el año 25` hasta la década del 60` se podía ser accionista del BC, que hoy en día se ve como rarísimo. Todo esto porque se le fue reconociendo al BC su carácter -correcto a juicio de *Yrarrázaval*- de órgano del Eº, y,

dedicado a las políticas monetarias, crediticias y cambiarias.

- La LGB -a juicio de *Yrarrázaval*- ha tenido un desarrollo muy positivo en el sistema bancario chileno, y, se ha ido modificando todas las veces que ha sido necesaria porque la actividad cambiaria ha ido cambiando.
 - Por ejemplo, en operaciones bancarias. En un comienzo, la ley era muy escueta sobre las operaciones propias de un banco comercial. Respecto de esto, decía fundamentalmente que los bancos eran solo para captar y colocar dinero. Pero, hoy en día, esa misma norma tiene del orden de treinta y tantas operaciones bancarias. Además, éstas se han ido haciendo más complejas porque se han ido agregando nuevas operaciones bancarias que antes no existían. Si surgen nuevas operaciones y la ley sigue siendo la misma, NO se pueden realizar aquellas no enumeradas en la ley. Lo que ocurre hoy en día, es que hay operaciones que están en la ley pero que no están con algunas cuestiones accidentales a esas operaciones, entonces, los bancos consultan a la SBIF, que se está cambiando a la CMF. Y, la SBIF ha sido muy activa en resolver ese tipo de consultas porque la realidad bancaria es totalmente dinámica al respecto.
- Esto demuestra que incluso respecto de las operaciones bancarias, hay **libertad** para realizar las operaciones que el banco quiere y no realizar las que el banco no quiere. Entonces, ¿dónde está el OPE en las operaciones bancarias? Está en el **marco regulador de las operaciones bancarias**, vale decir, **ningún banco puede realizar una operación que no está enumerada**. En otras palabras, los bancos solo pueden realizar aquellas operaciones que están enumeradas, y, si tienen dudas, las consultan.
- Si es tan cierto que las modificaciones de la LGB han sido tan **positivas**, ¿por qué se **produjo la crisis bancaria del 83`-85`**?¹⁰ Fue una crisis que se dio NO por un fallo de la ley, sino que por un fallo en los **préstamos** otorgados por el banco, porque si éstos no se pagan, el banco no tiene dinero para pagar los depósitos. Esto se debe a que los bancos tienen la misma cantidad de activos (préstamos) que de pasivos (depósitos), por lo tanto, si fallan los activos, el banco no puede pagar los depósitos. Esto es lo que ha ocurrido en muchos países donde se han producido crisis bancarias. **Por lo tanto, por lo general las crisis bancarias no surgen ni de la ley, ni del órgano regulador, sino que surgen de que en un momento determinado una cantidad importante de préstamos otorgados** -a la empresas en la mayoría de los casos- **no son pagados**. Y es ahí, donde debe ayudar el BC con sus **préstamos de urgencia**. Éstos tienen un plazo de **90 días**, y, pueden ser prorrogados excepcionalmente por otros 90 días. En definitiva, estos préstamos de urgencia no solucionan los problemas más serios de los bancos.
- El *riesgo bancario* se refiere a la preocupación de los ejecutivos bancarios de que las deudas (préstamos que el banco otorga) se paguen oportunamente.
- La figura del banco comercial tiene poco que ver con la figura del BC:

¹⁰ Se afectó una gran cantidad de bancos, y, eran muy importantes. De hecho, el Banco de Chile acaba de terminar de pagar la deuda subordinada al BC. *Se arrastró este problema del 85` al 2019. La deuda subordinada estaba en función de la cantidad de recursos que le dio el BC al Banco de Chile para que saliera de la situación de quiebra. *En realidad, no se producen quiebras en el sistema bancario, sino crisis. Otros bancos pagaron antes al BC, pero, esto dependía del monto de recursos que le pasó el BC a c/u de estos bancos. Algunos, volvieron a la normalidad en el año 85`-86`, pero seguían con la deuda con el BC.

- Ninguna de las 3 funciones que cumple el BC las cumple algún banco comercial.
- Ninguno de los criterios en las tomas de decisiones del BC existen para los bancos comerciales.
- La elección de los consejeros del BC tiene muchas exigencias, mientras que la elección del directorio de cualquier banco comercial no tiene muchas restricciones en su composición. No necesariamente se quiere elegir a las 5 mejores personas para que integren el directorio, depende de los accionistas de cada banco. La razón de ser de las exigencias para el consejo del BC se debe a la delicadez de las 3 funciones del BC que no las tiene ningún banco comercial. La función de un director de un banco comercial no tiene nada que ver con la función de un consejero del BC.
- Las operaciones que realizan son totalmente distintas, pero, es reciente esta diferenciación cada vez más clara.
- En el caso de los bancos comerciales, el nacimiento del banco depende de la SBIF que hoy en día se está pasando a la CMF. Si la CMF no quiere que se instale un banco, simplemente no pasará.¹¹ **El nº de bancos es determinado por la CMF** (hay del orden de veinte y algo bancos en Chile). Y, el nº de bancos no es un tema cualquiera porque para efectos de control es muy complejo controlar muchos bancos. Pero, entre menor cantidad de bancos, hay más regulación. Y, entre mayor cantidad de bancos, hay más competencia. Entonces, ¿qué prefiere la SBIF/CMF, más eficiencia o más competencia?

9 de mayo

LEY GENERAL DE BANCOS (DFL Nº3)

- Tiene una importante modificación el 12 de enero del 2019. Ésta tiene la gran virtud de revisar la redacción de muchas normas que habían quedado confusas, por lo tanto, se hizo un análisis bastante a fondo, y, hoy día tenemos un texto bastante claro en aquellos aspectos.
 - Esta ley tiene 2 o 3 cambios sustanciales.
 - Esta ley tiene del orden de 160 artículos. Nos vamos a concentrar en los más relevantes donde se expresa el OPE.
 - Hay muchas disposiciones e instituciones que están en la LGB, por ejemplo, las operaciones hipotecarias, esto no tiene mucho sentido, y deberían estar reguladas en otra parte. Pasa lo mismo con las comisiones de confianza que se le pueden otorgar a los bancos.
 - *Hubo una crisis bancaria importante en Chile en la primera mitad de la década 80`.
- I. **TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO**
- Este capítulo estuvo dedicado durante mucho tiempo a la SBIF, pero ella desaparece a mediados del año pasado. Ha sido algo progresivo en los últimos 2 años, en lo cual se ha ido incorporando la CMF, y, todas las otras normas que se referían a la SBIF

¹¹ Ejemplo Banco Chino. Se demoró 3 años en obtener la autorización de la SBIF (siendo el 2º banco más grande de China). Probablemente la SBIF tenía en consideración el nº de bancos existentes en el mercado chileno. Y pensó ¿es conveniente que entre al mercado chileno otro banco y de esa magnitud?

como institución quedaron derogadas.

- En este título quedan ciertas normas bancarias aplicables a la CMF, y, se derogan las que estaban relacionadas con la SBIF. Las que quedan se relacionan fundamentalmente a la publicidad de la información. Acá, se encuentra la obligación de la publicación trimestral de los bancos.
- Aparece aquí la clasificación de los bancos, publica que es lo que está pasando con cada uno de los bancos, especialmente, con la **morosidad en los activos** de los bancos.
 - Cuando hay morosidad alta, los bancos no logran responder a los depositantes, salvo que se pida un préstamo de urgencia.
 - El préstamo de urgencia en Chile se otorga por 90 días, y, se puede pedir una extensión del plazo por 90 días más.
 - El BC puede condicionar esos préstamos de formas muy exigentes, incluso por ejemplo, con cambios en los directorios.

○ Art 2

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 2- Corresponderá a la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión") la fiscalización del Banco del Estado de Chile¹ y de las demás empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza.²

Asimismo, la Comisión tendrá la fiscalización de las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago,³ siempre que éstos importen que el emisor u operador contraiga habitualmente⁴ obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos de él.

(...)

Con todo, la Comisión mantendrá las atribuciones conferidas por la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, respecto del conjunto de entidades fiscalizadas.⁵

Las personas que realicen tales actos en forma habitual y que eludieren la fiscalización de la Comisión serán penadas en la forma que contempla el artículo 39.⁶

○ Inc 1:

- ¹El Banco Estado fue creado en la década del 50' y siempre ha sido un banco comercial. En un inicio se le dio atribuciones especiales, pero hoy en día tiene igual trato que los demás. La normativa especial que tenía tampoco eran tan relevante.
- ²Desde ahí aparece el concepto de LGB, es una ley que está tratando a todos los bancos comerciales de la misma forma.
- Unos pocos que quedaron vigentes -por ejemplo, el banco hipotecario- fueron desapareciendo en un momento determinado, pero, no los hizo desaparecer la ley del 25'. Se encontraban dentro de la supervigilancia de la SBIF.

○ Inc 2:

- ³Se comenzó a hacer la distinción entre tarjetas de crédito bancarias y las comerciales, esto porque las bancarias siempre han estado sujetas al control, en

cambio, las comerciales se empiezan a regular hace muy poco tiempo, y, cada vez se les ha ido controlando más. Esto se debe a que es una operación total de captación y colocación de dinero, por eso hoy en día las **tarjetas no bancarias tienen un control muy parecido al de las tarjetas bancarias**.

- ⁴El concepto de la **habitualidad** desde el punto de vista bancario es crucial.
 - ✓ Ésta determina si ciertas empresas que están captando y colocando dinero lo están haciendo **dentro o fuera del giro**, eso lo determina la CMF.
 - ✓ Éste es un concepto claramente indeterminado, y, por lo tanto no es fácil discernirlo. ¿Por qué no definir la habitualidad? Es imposible, lo habitual va a depender de las circunstancias, queda a criterio de la CMF.
 - ✓ No hay ningún recurso especial para apelar la habitualidad.
 - ✓ **Que estén dentro o fuera del giro bancario es fundamental porque es lo que determina si se aplica o no la LGB.**
- **Inc 5:**
 - ⁵Se refiere a que la CMF mantiene las atribuciones de la ley N° 21.000 que crea la CMF.
- **Inc 6:**
 - ⁶Se refiere a que se aplicarán las sanciones del art 39 a las personas que realicen actos habituales -dentro del giro- y que evadan la fiscalización de la CMF.
 - Uno pensaría que las sanciones solo son para algunos, pero, las sanciones se pueden aplicar a una empresa que está fuera del sistema por considerar que está haciendo actividades que no corresponden.
- **Art 8**

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 8- Los recursos para el funcionamiento de la Comisión serán de cargo de las instituciones fiscalizadas.¹

La cuota que corresponda a cada institución será de un sexto de uno por mil semestral del término medio del activo de ellas en el semestre inmediatamente anterior, según aparezca de los balances y estados de situación que esos organismos presenten.²

Para los efectos del cálculo de la cuota que debe enterar cada institución no se considerarán como parte de su activo los bienes y partidas que deban excluirse en concepto de la Comisión.

La cuota deberá ser pagada dentro de los diez días siguientes al requerimiento.

- **Inc 1:**
 - ¹Este es un tema importante porque el **financiamiento de las superintendencias dependía del presupuesto del sector público**.
 - Antes, la única institución que no tenía esta regla eran los bancos, siempre han tenido un **financiamiento por parte de las entidades fiscalizadas**, y, esto se mantuvo como podemos ver.
 - Esto tiene un aspecto positivo y negativo.
 - ✓ Positivo: le da **estabilidad** de los recursos necesarios a la SBIF, y, en definitiva, no tiene que depender del presupuesto cada año donde les pueden llegar a

quitar dinero.

- ✓ Negativo: se ha planteado es que se supone que este tipo de financiamiento por parte de las empresas fiscalizadas **podrían hacer una captura de la superintendencia por parte de los entes fiscalizados** (si se portan mal se deja de financiar).
 - ❖ ²Pero, la ley contempla un % de los activos que tiene que aportar cada institución, por lo tanto, los bancos más grandes tienen que financiar más y los más chicos menos. Es un % igual para todos los bancos, y éste se encuentra formulado en el art 2 inc 2. El % es de un **sexto de uno por mil semestral del término medio del activo de ellas en el semestre inmediatamente anterior**. Es de los activos porque es lo que el banco TIENE y no debe.
 - ❖ Con este sistema no hay posibilidad de captura porque esto es automático.
 - ❖ El problema que se ha planteado ahora es que la CMF agrupa a los **bancos, a los valores, los seguros y las SA abiertas**, y las otras entidades que regula tienen financiamiento del presupuesto de la Nación y NO de las entidades fiscalizadas. Entonces, ¿cómo se mezclan ambos financiamientos? Se producen problemas por tratar de unir estos distintos tipos de recursos recibidos.
- **Del financiamiento depende la calidad regulatoria.** La calidad significa que todos los trabajadores estén muy bien calificados para sus funciones. Las cuestiones que tiene que controlar una superintendencia son bien sofisticadas. Por lo tanto, una persona que no sepa mucho de bancos ojalá que no trabaje allí, más aún cuando el control de los bancos se hace digitalmente, y, de esta manera, la SBIF/CMF tiene toda la información que quiere. Ella puede pedir en cualquier momento más información, pero quienes hagan ese control tienen que saber mucho de bancos, lo que nos lleva a las remuneraciones.
- Cuando se discutieron las **remuneraciones**, se llegó a una solución intermedia. Éstas deben ser **competitivas con las del sector privado**. Cuando se van reemplazando los comisionados (5), la nueva persona debe ser tan calificada como el anterior y eso pasa con todos quienes trabajan en la CMF.
- La calidad del análisis depende de que la fiscalización se haga “antes de” porque la idea es prevenir.
- Para asegurarse que la CMF tendrá un cierto nivel técnico se cambió de un sistema unipersonal -con la SBIF- a uno colegiado -con la CMF, porque da confianza de que entre 5 las cosas se van a estudiar mejor.

○ **Art 9**

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 9- *El Presidente de la Comisión recaudará los fondos con que las instituciones sometidas a su fiscalización e deben contribuir al mantenimiento de la Comisión y los depositará en el Banco del Estado.¹ De esa cuenta girará para efectuar los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión.²*

- ¹El pdte de la CMF estará encargado de recaudar los fondos otorgados de las instituciones fiscalizadas y debe depositarlos en el Banco del Estado.
- ²Los gastos que realice la CMF se deben hacer desde la cuenta del Banco del Estado.

○ **Art 11**

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 11- *La Comisión estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos.¹*

- Este es un tema importante.
- ¹Algunos han planteado que la CMF no debería tener la fiscalización de la Contraloría, pero, a juicio de *Yrarrázaval* es muy bueno que la tenga, ya que ésta sólo se preocupa de los **gastos** que tiene la CMF, y, NO se mete en las contoles que realiza la CMF a las instituciones.
- Es razonable que se meta en los gastos para controlar que efectivamente el gasto ha sido en lo que debe ser, es decir, que se haya hecho responsablemente y sin malversación de fondos.

○ Art 14

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 14- La Comisión dará a conocer al público, a lo menos cuatro veces al año, información sobre las colocaciones, inversiones y demás activos de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley,¹ así como su clasificación y evaluación conforme a su grado de recuperabilidad, debiendo la información comprender la de todas las entidades referidas.² Podrá, también, mediante norma de carácter general, imponer a dichas instituciones la obligación de entregar al público informaciones permanentes u ocasionales sobre las mismas materias.

Con el objeto exclusivo de permitir una evaluación habitual de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley por firmas especializadas que demuestren un interés legítimo, la Comisión deberá darles a conocer la nómina de los deudores de las entidades antes señaladas, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido.³ Lo anterior sólo procederá cuando la Comisión haya aprobado su inscripción en un registro especial que abrirá para los efectos contemplados en este inciso y en el inciso cuarto del artículo 154. La Comisión mantendrá también una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones fiscalizadas en virtud de la presente ley. Las personas que obtengan esta información no podrán revelar su contenido a terceros y, si así lo hicieren, incurrirán en la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.⁴ (...)

○ Inc 1:

- Esto estaba en la ley anterior y fue traspasada a la actual ley. Es muy importante.
- ¹La CMF deberá dar a conocer al público al menos 4 veces al año la información sobre colocaciones, inversiones y activos de las instituciones fiscalizadas.
 - ✓ Se mete **sólo con los activos** porque son lo que el banco TIENE.
 - ✓ Los pasivos son los que el banco DEBE.
 - ✓ Los activos y pasivos de un banco deben corresponderse. Así, el balance del banco estará equilibrado.
- ²Además, la CMF deberá dar a conocer al menos 4 veces al año información sobre su **clasificación y evaluación** conforme a su **grado de recuperabilidad**.
 - ✓ La CMF lo informa banco por banco.
 - ✓ La **recuperabilidad** se expresa en términos de la **morosidad de los activos**. En el informe, aparece expresada según el % de los activos del banco que son irrecuperables.
 - ✓ La SBIF/CMF determina la irrecuperabilidad. Y, esta indica la fortaleza o debilidad de cada banco.
 - ✓ En Chile, afortunadamente tenemos altas tasas de recuperabilidad, generalmente fluctúan las irrecuperabilidades entre el 2-3%. De aquí surge una clasificación de los bancos.
 - ✓ El caso chileno es muy positivo porque las diferencias de recuperabilidad entre los bancos son muy pequeñas, por lo tanto, casi todos los bancos se fluctúan dentro de más o menos un determinado porcentaje.
- La CMF al entregar esta información relevante, está ayudando al público en su elección sobre en cuál banco deben depositar su dinero.
- Los informes que hace la CMF sobre esta información están incluidos en

circulares.

○ **Inc 2:**

- ³Aquí se da una **excepción** o regulación especial muy relevante. En ésta, la CMF le pide a una **empresa de auditoría** que analice un banco y haga un informe. Para esto, se le puede pedir la **información concreta e individualizada de los deudores**.
 - ✓ Lo que se quiere saber es en qué situación están los 10 deudores más altos del banco.
 - ✓ Para eso, la auditoría tiene que ser especializada e individualizada.
- ⁴Después viene toda una normativa respecto del **secreto bancario** y la **reserva bancaria**.
 - ✓ Cuando hay normas especiales como ésta, quien hace la auditoría también tiene el deber de secreto y reserva respecto de esa información.
 - ✓ Esto no deja de ser relevante porque uno podría decir que alguien que trabaja en la CMF tiene acceso a información muy delicada, pero, todos ellos están sujetos a la misma obligación de reserva o secreto, y, si la llegar a dar a conocer pueden terminar en la cárcel.
 - ✓ Otra excepción es cuando los jueces o el Ministerio Público pide esta información. Aquí, ocurre lo mismo, porque es el caso de una demanda en particular en la que se requiere saber dónde están los bienes del demandado.

○ **Art 16**

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 16- *Las instituciones fiscalizadas en virtud de esta ley deberán publicar, en un periódico de circulación nacional, sus estados de situación referidos al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de cada año, o en cualquier otra fecha que lo exija, en casos especiales, la Comisión, en uso de sus facultades generales. La publicación se efectuará a más tardar el último día del mes siguiente a la fecha a que se refiere el estado.¹*
(...)

- ¹Las **instituciones fiscalizadas** deberán publicar sus **estados de situación**.
 - ✓ Los estados de situación se refieren al **balance trimestral de los bancos**, pero no incluyen todas las exigencias que tiene los balances anuales.
 - ✓ Los bancos son los que publican sus estado de situación en las fechas indicadas, pero luego se mencionan una serie de atribuciones que tiene la CMF para exigirle a los bancos publicaciones adicionales.

○ **Art 17**

TÍTULO I – FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL ÁMBITO BANCARIO

Artículo 17- *El gerente de una institución fiscalizada en virtud de esta ley o la persona que haga sus veces dará cuenta al directorio o al cuerpo directivo correspondiente en la próxima reunión que éste celebre de toda comunicación recibida de la Comisión y de ello se dejará testimonio en el acta de la sesión.¹*

(...)

- ¹El gerente de la institución debe dar cuenta al directorio en la próxima reunión que celebren la información recibida de la CMF y se debe dar constancia de ello.
- ✓ Esto nos incorpora a un tema muy relevante que es cómo se administra un banco, el que lo hace como sociedad anónima (SA).

14 de mayo

- Los bancos en Chile se puede constituir de distintas formas:

I. Banco como sociedad anónima (SA) constituida en Chile

- Un banco se administra como SA, denominada SA **especial**. Se denomina “especial” porque se rige por la ley de SA, y, por las normas respecto de sociedad que contenga la LGB (no son muchas).
- En un comienzo, las SA eran reguladas por la Superintendencia de SA, luego pasan a estar reguladas por la SVS, y, en la década del 80` por la CMF.¹²
- La SA puede ser **abierta o cerrada**. Hay 3 requisitos para que se considere la SA como abierta. Si se cumple 1 de ellos, es abierta:
 1. Más de 500 accionistas.
 2. 100 accionistas que controlen más del 10%.
 3. Hacen ofertas en público.
 - La gran mayoría de las abiertas cumple con ese requisito.
 - Se refiere a transar en público sus acciones en la bolsa (física o electrónica).
 - Esto es atractivo para las SA, ya que permite captar recursos de muchas personas.
 - Si no está en la bolsa, también se puede transar, pero, obviamente en mercado que no está regulado, con menor información y relativamente más chico.
 - Entonces, la gran mayoría de las SA relativamente grandes quieren transar en la bolsa, y, generalmente no transan todas en la bolsa, sino que un % (generalmente entre 25-50%)
- Aquí, comenzamos a entender por qué la misión *Kemmerer* recomendó crear una superintendencia de SA, aun cuando no eran las más importantes que existían en Chile en ese entonces. En el año 25` las sociedades que predominaban eran las de responsabilidades limitadas. Pero, en el s.XX cambia la situación, y, pasa a ser la SA la más importante. Este cambio se debe a 3 motivos:

¹² Los bancos han estado regulados por la Superintendencia de Bancos y luego por la CMF (cambio actual).

1. Regla de las Mayorías

- ❖ La regla de la mayoría explica el éxito de las SA en el s.XX.
- ❖ Se debe a que las SA tienen muchos accionistas, y pretenden aumentar su cantidad de accionistas. De hecho, hay SA que han tenido juntas de accionistas en estadios.
- ❖ Toda SA tiene junta de accionistas ordinarias y extraordinarias.
 - **Ordinaria:** se celebra 1 vez al año, y, generalmente es entre los meses de Marzo y Abril porque el objetivo fundamental de ésta es aprobar el balance de la SA que debe ser entregado a fines de Abril. Aprobar el balance es una facultad de la junta. Entonces, si no se hace la junta ordinaria en este período, indica que hay algo raro en la SA. Además, en ella se eligen a los directores, auditores externos, etc. Lo más importante es la operación del balance porque de acuerdo con este la sociedad debe pagar sus impuestos anuales a la renta.
 - **Extraordinarias:** son todas las que no son ordinarias. Se hacen para tratar cualquier otro tema societario, por ejemplo, para la modificación de los estatutos societarios, aprobar ciertas operaciones, etc.
- ❖ La regla de las mayorías implica que es la **decisión de la mayoría la que se impone en la juntas de accionistas** -ordinarias y extraordinarias- **y en el directorio ordinaria y extraordinaria**, y NO una decisión **unánime** como ocurre en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Vale decir, la SA se estructura sobre la base del accionista mayoritario. Si los accionistas minoritarios se juntan y deciden, puede que influyan, así opera la **cifra repartidora**.
- ❖ Esta regla es muy importante porque **evita conflictos permanentes en las sociedades**. En cambio, con la unanimidad hay muchísimos problemas.
- ❖ Hoy en día se puede tener la mayoría de acciones con un 10%, debido a la gran cantidad de accionistas minoritarios.
- ❖ Los accionistas minoritarios tienen ciertos dº en la SA. La ley les confiere ciertos dº, pero, son en situaciones extremas, por ejemplo, si desean retirarse de la SA tienen dº a vender sus acciones. Lo importante es que los dº de los accionistas minoritarios no pueden afectar la regla de las mayorías.
- ❖ El **directorio** en una SA es el órgano **administrativo de la sociedad**.
 - Los directores son elegidos por la junta de accionistas. Tienen una duración máxima de 3 años, pero, pueden ser reelegidos por varios períodos sucesivos.
 - El directorio asume -por ley- toda la responsabilidad fundamental de la sociedad, lo cual es muy delicado.
 - Un director se puede salvar de la responsabilidad si se dejó constancia de su oposición a la decisión en el acta de la junta.
 - El directorio también se rige por mayorías. En él hay directores mayoritarios y minoritarios.

→ La ley dice que los directores no deben responder a los accionistas que eligieron, sino que deben responder a la sociedad. El director debe proteger el interés social y no sólo el de los accionistas que lo eligieron.

2. Libre Transferibilidad de las Acciones

- ❖ Implica que cualquier accionista de un banco puede transferir a quien quiera y al precio que quiera sus acciones, y, nadie que se lo puede negar.
- ❖ Este concepto es fundamental en las SA, ya que el accionista es independiente de cualquier otro accionista o la SA como tal.
- ❖ También, el accionista las pueden donar.
- ❖ Debe haber un testigo en la transferencia, pero esto no es relevante.
- ❖ En todas las demás sociedades no existe la libre transferibilidad. En la de responsabilidad limitada, depende de lo que dicen las otras personas, ya que la decisión debe ser unánime.

3. Facilidad para el Aumento del Capital

- ❖ Va a aumentarse si la mayoría lo decide, y, no importa si a un accionista en particular está de acuerdo con esta decisión o no.
- ❖ Cuando no se es SA también hay problemas en esto, porque si no están todos de acuerdo, no se aumenta el capital.
- ❖ La responsabilidad de la SA es hasta el monto de los aportes que hayan hecho a la SA.
- ❖ En el caso de los bancos, es especialmente importante, ya que la cantidad de operaciones que puede hacer el banco depende de su capital.
- Es una buena decisión que el banco sea una SA. En otros países, se permiten que sean SA o de personas, es decir de responsabilidad limitada, que requieren la unanimidad en la toma de decisiones.
- En definitiva, el legislador quiere **evitar los conflictos societarios**.

II. Banco como agencia de un banco extranjero

- En Chile, la ley permite que hayan bancos como agencias de bancos extranjeros. Esto se refiere a **los bancos extranjeros que quieren operar en el país como banco comercial**. Y, para esto, requieren de **la autorización de la CMF**.
- Esta es una modalidad desarrollada especialmente en la LGB.
- ¿Por qué los bancos extranjeros operan a veces como agencias y otras veces operan comprando acciones de bancos chilenos que operan como SA¹³? Algunas diferencias son que el que opera como agencia **NO tiene junta de accionistas** que opere en Chile (se constituye en el extranjero), y, **tampoco tiene directorio** que opere en Chile, sino que tiene un **agente** (persona natural que tiene todas las facultades para la toma de decisiones de la agencia). Pero, esas son diferencias de forma, hay otras que son más de fondo como el uso de su **propio**

¹³ Para comprar acciones de un banco se requiere autorización si van a ser sobre el 10%. Pero, no hay ninguna restricción para que un extranjero compre acciones de SA.

nombre, porque el que funciona como agencia usa su propio nombre, y, esto tiene incidencia en el comercio exterior.¹⁴

- Desde el punto de vista societario, el banco como agencia NO constituye una SA, sino que tiene la misma forma que su banco en el extranjero.
- Si el banco tiene problemas, su responsabilidad depende del tipo de banco:
 - ✓ Si es una **SA**, responde hasta por los **montos de los aportes hecho a la SA**.
 - ✓ Un ejemplo de esto es el Banco de Chile, económicamente quebró, pero algunos accionistas no han querido reconocer que sus acciones no están y siguen participando como los otros accionistas que si valen mucho,
 - ✓ Si es una **agencia**, responde la **agencia matriz** si falla la agencia. Entonces, si el banco es una agencia asume **mucha más responsabilidad que la SA** constituida en nuestro país, pero quiere **utilizar su buen nombre** o reputación, por lo tanto, es una decisión que asume el banco extranjero. En otras palabras, es **mucho más seguro la constitución de un banco como agencia** para las personas que quieran realizar operaciones con ellos.
- El banco extranjero podría entrar como accionista de una SA, e ir comprando acciones hasta lograr un % en que se permita cambiar el nombre del banco al mismo del banco extranjero (si la junta está de acuerdo por regla de mayoría).¹⁵ Esto es una estrategia comercial. Se debe considerar la confianza que tendrán las personas en el banco nuevo (por el cambio de nombre). Por lo tanto, algunos prefieren esperar un tiempo y después de 5-10 le cambian el nombre.
- Liquidar una agencia es complicadísimo para la CMF, más aún que la liquidación de un banco constituido como SA (que ya es muy complicado).

III. Oficinas de representación

- Los bancos extranjeros requieren **autorización de la CMF** para operar como oficina de representación.
- Existen muchísimas en Chile.
- Actualmente, hay 27 bancos en Chile que operan como SA o como agencia. Entonces uno podría decir que existen muchos más bancos de los que dice la CMF, pero, este tipo de bancos **NO puede operar ni captaciones ni colocaciones** -este es el giro bancarrio por naturaleza-, pero están presentes en Chile para **contactos con el comercio exterior**.¹⁶ Así, capta clientes.
- La importancia del comercio exterior para Chile es inmensa.
- Hay un instrumento de comercio exterior que en materia bancaria es vital:

¹⁴ Ejemplo: el banco Chino prefirió constituirse en Chile como **agencia** porque es un banco que desea usar su nombre bien reconocido (2º banco más grande en China) para efectos del comercio exterior. Hoy en día, China es nuestro principal socio para el comercio exterior. Los chinos vieron la oportunidad de estar presentes en el país para una multiplicidad de operaciones de comercio exterior bancarias.

¹⁵ Scotiabank hizo esto en Chile. Compró un pequeño % al Banco Sudamericano, después fue aumentando ese %, y, terminó eliminando a ese banco.

¹⁶ El comercio exterior chileno al año es del orden de 80.000 millones de dólares de importaciones, y un valor parecido de exportaciones. Entonces, entre ambas, Chile tiene del orden de 160.000 millones de dólares en comercio exterior. Y, el producto está en el orden de 270.000-280.000 millones de dólares.

acreditivos bancarios.

- ✓ Lo que deben estar de acuerdo las partes es **cosa y precio**. Pero, ¿qué garantía tiene el vendedor de que el comprador le va a pagar si ni siquiera se conocen? Con los **acreditivos bancarios** se **garantizan los pagos del comercio exterior**.
- ✓ Hay **4 partes que intervienen** en el acreditativo: el comprador deposita en un banco de su país la cantidad determinada, y éste la transfiere al banco del país del vendedor para que la transfiera al vendedor.
- ✓ Existen acreditivos **simples** y **condicionados**. Se pueden incluir en el acreditativo ciertos requisitos que debe tener el bien, y si el bien no lo incluye, no se le paga al vendedor.
- ✓ Mientras **más condiciones** tiene, **más caro** es el acreditativo.
- ✓ Pueden haber plazos de garantía -por ejemplo, en maquinarias-, y deberán haber expertos que aseguren que funcione correctamente el bien.
- ✓ Por lo tanto, esto prueba que los bancos en materia de comercio exterior son vitales.
- ✓ Puede no haber acreditativo cuando el grado de confianza entre comprador y vendedor es muy alto.
- ✓ El precio que se paga por el acreditativo es el de la divisa tomada en el día y lugar que el comprador paga al banco de su país. Pero, esto se puede modificar.

II. TÍTULO II – CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

- Es un título muy relevante, ya que no solo incluye las normas de constitución de los bancos, sino que, además incluye muchas reglas que podrían estar en las disposiciones generales. Aquí se define qué es un banco comercial y cuáles son las operaciones bancarias.

○ **Art 27: Constitución de un banco como SA**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 27- Las empresas bancarias deben constituirse como sociedades anónimas en conformidad a la presente ley.¹

Para la creación de un nuevo banco, los accionistas fundadores deberán presentar un prospecto a la Comisión.² Este documento deberá ser acompañado de un plan de desarrollo de negocios para los primeros tres años de funcionamiento.³

Aceptado un prospecto, se entregará un certificado provisional de autorización a los accionistas fundadores que los habilitará para realizar los trámites conducentes a obtener la autorización de existencia de la sociedad y los actos administrativos que tengan por objeto preparar su constitución y funcionamiento.⁴ Para ello, se considerará que la sociedad tiene personalidad jurídica desde el otorgamiento del certificado. No podrá solicitarse la autorización de existencia de la sociedad transcurridos diez meses desde la fecha de otorgamiento del certificado provisional.

Los accionistas fundadores de una empresa bancaria deberán constituir una garantía igual al diez por ciento del capital de la sociedad proyectada, mediante un depósito a la orden del Presidente de la Comisión en alguna empresa bancaria fiscalizada por la Comisión.⁵

Dichos accionistas fundadores estarán obligados a depositar en alguna de las empresas bancarias fiscalizadas por la Comisión y a nombre de la institución en formación los fondos que reciban en pago de suscripción de acciones. Estos fondos sólo podrán girarse una vez que haya sido autorizada la existencia de la sociedad y que entre en funciones su Directorio. Los accionistas fundadores serán personal y solidariamente responsables de la devolución de dichos fondos y su responsabilidad podrá hacerse efectiva sobre la garantía a que se refiere el inciso anterior.

Los accionistas fundadores no podrán recibir, directa ni indirectamente, remuneración alguna por el trabajo que ejecuten en tal carácter.⁶

- ¹Desde el comienzo, la ley está indicando que una opción para la constitución del banco es mediante una **SA**.
- Esta SA es “*especial*” ya que requiere de una autorización previa de la SBIF/CMF. Se sale de la disyuntiva de sociedad abierta-cerrada, solo es SA especial. La ley contiene una infinidad de detalles sobre la constitución del banco.
- El que sea una SA especial trajo muchos problemas en nuestro país porque los bancos caían bajo el control de la SBIF y bajo la Superintendencia de SA en cuanto a materias de sociedades. Hoy en día, se acabó este tema porque está todo dentro de la CMF. La facultad normativa de la CMF la ejerce a través de la comisión como **órgano colegiado**. Tiene 5 miembros, y, no existe esa autoridad unipersonal que existió con la SBIF.
- Para crear un banco como SA se requieren de **3 etapas**. Se les pueden dar distintos nombres, pero lo importante es el fondo.
 - 1. Etapa de prospecto de un banco**
 - ❖ ²Se refiere a la **solicitud** que hace el banco ante la CMF para su creación.
 - ❖ ³Hoy en día, es cada vez más detallada, y exige un **plan de desarrollo** del banco por los 3 años siguientes.
 - ❖ Acá, la CMF puede aceptar o rechazar los prospectos.

- ❖ La CMF debe analizar si prefiere la **competencia** de los bancos o la **eficiencia** de éstos.
- ❖ La CMF debe considerar el nº de bancos, que es fundamental para el éxito o fracaso del control bancario. En Argentina hay más de 500 bancos, mientras que en Chile hay solo 27. La economía argentina es 3 veces a la chilena, pero se vuelve imposible controlar correctamente a 500 bancos, por lo que existe una superintendencia, pero ésta hace muy poco.
- ❖ Pero, el tema desde el punto de vista económico es más complicado todavía por las **economías de escala**.
 - En los bancos hay muchas tecnologías y éstas producen las economías de escala.
 - Por lo tanto, a los bancos más chicos les cuesta mucho sobrevivir.
 - En Chile, los 5 bancos más grandes captan y colocan del orden del 75% del total, y, el 25% restante se distribuye entre el resto de los bancos.
 - Entonces, los pequeños para sobrevivir se dedican a ciertas operaciones bancarias (ej: operaciones hipotecarias), a cierto público (ej: solo a empresas), etc.
 - En definitiva, cada banco da su propio perfil, y así, sobreviven a las economías de escala.
 - Esto es una tendencia a nivel mundial. Cada vez es menor la cantidad de bancos a nivel mundial, y, los bancos más pequeños se van quedando en niveles locales, provinciales/estatal, regionales, etc. Ej: en USA.
- ❖ Esta etapa es muy sencilla, pero bastante capciosa porque los bancos que presentan el prospecto **NO tienen ningún dº adquirido**.
- ❖ En términos vulgares, esta etapa es un “colador”.¹⁷

2. Etapa de autorización propiamente tal del banco

- ❖ ⁴En esta etapa, la ley y la CMF consecuentemente es muy exigente para los efectos de dar un **certificado de autorización provisional** de existencia. Se debe entregar una cantidad de dinero importante, y, se debe tener los estatutos del banco.
- ❖ El estatuto se refiere a ciertos elementos básicos de la composición interna del banco.
 - Se repiten ciertas normas contenidas en la ley para darle coherencia al estatuto.
 - Se refiere específicamente al nombre del banco, la cantidad de acciones que va a emitir, la administración del banco, duración del banco¹⁸, alguna condición especial que desee incluir en los estatutos.
 - Son las reglas **fundamentales**, no específicas.

¹⁷ Se demoraron 3 años en aceptar el prospecto del Banco Chino.

¹⁸ Según Yrarrázaval no es muy razonable que sea por un periodo determinado. La duración puede ser determinada o indefinida. De igual manera, se puede extender su duración mediante una aprobación de la mayoría en la junta de accionistas.

3. Etapa de funcionamiento

- ❖ La CMF debe autorizar el funcionamiento del banco, y para eso, se debe comprobar que el banco está listo para “abrir sus puertas al público”. Esto se hace mediante un firmado.
- ✓ La ley contempla todo tipo de mecanismo de control para que no se abuse de esto, por ejemplo:
 - ❖ ⁶Los accionistas fundadores no podrán recibir remuneración alguna por el trabajo que ejecuten en tal carácter.
→ Después de que se haya fundado, y, que la junta apruebe esas remuneraciones, si pueden obtener remuneración.
 - ❖ ⁵El depósito que tienen que hacer los fundadores para obtener el certificado de funcionamiento se debe hacer en ciertos bancos, con ciertas garantías, etc.

15 de mayo

○ Art 28: Condiciones que tienen que tener los fundadores o controladores

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 28- Los accionistas fundadores o controladores de un banco deberán cumplir los siguientes requisitos:¹

a) Contar individualmente o en conjunto con un patrimonio neto consolidado equivalente a la inversión proyectada² y, cuando se reduzca a una cifra inferior, informar oportunamente de este hecho.³

El requisito de solvencia deberá ser cumplido en forma permanente por los accionistas que sean considerados controladores del banco en los términos del artículo 97 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, y consistirá en contar, individualmente o en conjunto, con un patrimonio neto consolidado igual, en la proporción que les corresponda, al capital básico del banco.⁴

(...)

b) No haber incurrido en conductas graves o reiteradas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la entidad que se proponen constituir o controlar, ni la seguridad de sus depositantes.⁵

c) No haber tomado parte en actuaciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, contrarios a las leyes, normas o sanas prácticas financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero.⁶

d) No encontrarse en alguna de las situaciones siguientes⁷:
(...)

- Este art es interesante y complicado. Los requisitos son muy complicados.
- ¹Se refiere a los **requisitos** que deben cumplir los **accionistas fundadores o controladores de un banco**.
- Llama la atención el hecho de que estos requisitos no solamente son exigidos a los fundadores -es razonable-, sino que también a los controladores.
- Los controladores son accionistas de un banco que pueden ser personas naturales o jurídicas, y, ellos **deben velar por el control del banco**.
- Si un controlador no cumple con alguno de los requisitos, debe vender sus acciones y salirse de la SA.
- El concepto de controlador es de dº comercial y es muy complejo. El que controla

es el que **tiene efectivamente el poder de toma de decisiones dentro del banco**. Esta es una cuestión de hecho.

- La legislación comercial viene a dar una serie de reglas con respecto de cuándo se considera a una persona como controlador del banco. Esto no es nada de fácil, y más todavía tratándose de SA en las cuales muchas veces el % de acciones no está diciendo nada respecto de si tiene o no el control del banco.
- El control es una cuestión de hecho de que la toma de decisiones está en una sola persona.
- **Letra a): Requisito de solvencia**
 - ✓ ²Contar individualmente o en conjunto con un **patrimonio neto consolidado equivalente a la inversión proyectada**.
 - ❖ El patrimonio neto se refiere quitándole las deudas.
 - ✓ ³Y, si se **reduce** a una cifra inferior, se debe **informar** oportunamente este hecho a la CMF.
 - ✓ ⁴El **requisito de solvencia** deberá ser cumplido en forma permanente por los accionistas que sean considerados controladores y fundadores (aunque no los mencione en el inc), y consiste en contar con el patrimonio neto igual o superior al capital básico del banco.
- **Letra b)**
 - ✓ ⁵**No haber incurrido en conductas graves o reiteradas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la entidad que se proponen constituir o controlar, ni la seguridad de sus depositantes.**
 - ✓ Esto es amplísimo porque una de las razones por las que la CMF puede **liquidar** un banco es por la **inestabilidad** de éste.
 - Por lo tanto, el no cumplimiento de este requisito genera su liquidación.
 - La inestabilidad es determinada por la CMF, pero éste es un concepto vago. Por lo tanto, la liquidación de un banco por inestabilidad es reclamable ante los Tribunales Superiores de Justicia.
 - Esto ha ocurrido en Chile, pero afortunadamente en pocas situaciones. Un caso fue el del Banco Nacional en la década del 80`. La SBIF decretó la liquidación del Banco Nacional, y, el dueño dijo que esto era persecución política. Pero, la SBIF comprobó que se habían producido 2 operaciones el día 28 de diciembre que le cambiaban el balance totalmente al banco a uno bastante bueno (sospechoso). Finalmente, no acudió ante los tribunales de justicia porque otro banco le compró la cartera -con buenos, regulares y malos créditos-. Hasta el día de hoy hay arbitrajes con respecto a la compra de la cartera del Banco Nacional, ya que cuando se compra la cartera, se compra algo que no se sabe exactamente si esas empresas están en mejores o peores condiciones.
 - ✓ Es muy difícil que un banco gane un reclamo sobre la liquidación por inestabilidad porque su contraparte es la CMF. La CMF debe expresar cuáles fueron las razones por la que liquidó el banco con lujo de detalle, y, el banco

debe demostrar que no se cumplieron las causales de liquidación, que no se causó inestabilidad o inseguridad a los clientes, etc.

- ✓ Es bien difícil, pero es la única forma de proceder, es decir, con causales amplias y reclamables.
- ✓ ¿Qué sucedería si tuviéramos causales menos amplias? Entre más concreto o más tipificado es mucho más difícil que la CMF pueda ejercer la función de liquidación. Cuando lo hizo -especialmente en los años 81` y 82`- es porque tenía muchas razones distintas en relación de cada banco liquidado.¹⁹ Esta etapa fue muy ácida y muy complicada, y, no se sabía si los responsables eran los bancos, la SBIF o las empresas que no le pagaban los préstamos a los bancos. A juicio de *Yrarrázaval* se debe más por el 3º motivo, vale decir, los bancos entraron en un grado de morosidad impresionante, y, por cierto, no tenían entonces cómo pagarle a sus depositantes.

▪ **Letra c)**

- ✓ **6No haber participado en actuaciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, contrarios a las leyes, normas o sanas prácticas financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero.**
- ✓ Llega a ser muchísimo más amplia que la letra b), que ya es amplia.
- ✓ Mediante la letra b) y c) la CMF se basa para argumentar su postergación para autorizar la creación del banco (prospecto).

▪ **Letra d)**

- ✓ **7Menciona varias situaciones en las cuales los bancos no se pueden encontrar.**
- ✓ Va enumerando distintas situaciones. Esto también es muy amplio.

○ **Art 29: Bancos extranjeros que desean realizar actividades en Chile**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 29- *La institución financiera constituida en el extranjero que solicite participar en forma significativa en la creación o adquisición de acciones de un banco chileno o establecer una sucursal en conformidad al artículo 32¹, sólo podrá ser autorizada si en el país en que funciona su casa matriz existe una supervisión que permita vigilar adecuadamente el riesgo de sus operaciones y, además de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo anterior, cuenta con la autorización previa del organismo fiscalizador del país en que esté constituida su casa matriz. Además, para otorgar la autorización deberá ser posible el intercambio recíproco de información relevante sobre estas entidades, entre los organismos de supervisión de ambos países.*
(...)

- ¹Antes, este art solo se refería a las **agencias de bancos extranjeros**. Pero, con la modificación de la ley, este art pasa a referirse también a los **bancos que**

¹⁹ Se liquidaron del orden de 20 bancos. La gran mayoría de ellos tenía nombres de regiones: B. de Talca, B. de Constitución, B. de Osorno y la Unión, etc.

comprende acciones de un banco constituido como SA.

- No se va a detallar el **procedimiento**, pero éste es parecido al del banco constituido como SA. La diferencia es que aquí se trata de un **banco ya constituido**, con estatutos ya existentes, por lo tanto, lo que hace la **CMF fundamentalmente es darle su aprobación o rechazo** para que el banco extranjero opere en el país ya sea como **agencia** o ya sea **adquiriendo acciones de un banco constituido como SA**.

○ Art 30

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 30- *La Comisión, dentro del plazo de 180 días, podrá rechazar el prospecto por resolución fundada en que los accionistas fundadores no cumplen los requisitos señalados en los artículos anteriores.¹ Si la Comisión no dictase una resolución denegatoria dentro del plazo señalado, se podrá requerir la aplicación del silencio administrativo² positivo en la forma señalada en el artículo 64 de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.*

No obstante, la Comisión en casos excepcionales y graves relativos a hechos relacionados con circunstancias que, por su naturaleza, sea inconveniente difundir públicamente, podrá suspender por una vez el pronunciamiento sobre el prospecto hasta por un plazo de 180 días adicionales al señalado en el inciso anterior.³ (...)

- Este art es nuevo.
- ¹Viene a **reglamentar la aprobación o rechazo del prospecto de un banco que se constituye como SA**.
- Le da a la CMF un plazo de **180 días** para rechazar el prospecto por **resolución fundada**. Debe ser fundada para que el afectado pueda **reclamar** de forma efectiva, sino, es muy difícil reclamar.
- ²Cuando la CMF **no se pronuncia** ocurre el **silencio administrativo**. Si la autoridad administrativa no se pronuncia, se entiende como aprobado. A juicio de *Yrarrázaval* esta institución es muy buena, pero no ha funcionado muy bien. La autoridad ha puesto todo tipo de pretextos para no cumplir con la norma relacionada al silencio administrativo. La excusa más recurrente es que no les han entregado todos los documentos necesarios, por lo que no ha entrado a correr el plazo.
- ³En casos excepcionales, se puede renovar el plazo de 180 días por otros 180 días. Entonces, a fin de cuentas, puede dejar en espera al banco por un año.

○ Fusiones de Bancos

- La LGB reglamenta todos los aspectos fundamentales en el caso de una fusión de bancos.
- Esto es muy complicado.
- Han existido fusiones y van a seguir existiendo cada vez más debido a las **economías de escala**. Además, por el hecho de la mucha tecnología utilizada en la actividad bancaria, indiscutiblemente que las economías de escala serán cada vez mayores.

- El TDLC ha sostenido que estas normas de fusión de los bancos no le afectan en nada. Vale decir, un proceso de concentración bancaria tiene que pasar por los mismos controles que cualquier otra empresa.
- La SBIF ha sostenido que los bancos deben pasar por su procedimiento.
- En definitiva, lo que ha ocurrido es que se han hecho ambos trámites: ante TDLC y SBIF (ahora CMF).
- Pasa también por el TDLC porque en la LDLC dice que las únicas instituciones que se preocupan de proteger la LC es el TDLC y la FNE. Por lo tanto, ningún ministerio ni superintendencia puede pronunciarse en materia de LC de acuerdo con ese art. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido mucho problema. Habría conflicto, por ejemplo, si la CMF rechazara la fusión y el TDLC la aprobara o al revés.
- Hasta el momento, todas las fusiones de bancos han sido aceptadas debido a las economías de escala, salvo que sean bancos muy de *nicho* (algo muy especializado). Pero, el interés para un determinado segmento es cada vez menor, incluso a nivel mundial.
- Se ha tratado siempre de separar las funciones del TDLC y FNE respecto de la consulta de concentraciones. El TDLC no se pronuncia respecto de las aprobaciones, sino solo respecto de rechazos o aprobaciones con mitigaciones que se consideren injustas o desproporcionales.

○ **Art 31: Procedimiento de bancos constituidos como SA**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 31- *Solicitada la autorización de existencia y acompañada copia autorizada de la escritura pública que contenga los estatutos, en la que deberá insertarse el certificado a que se refiere el artículo 27, la Comisión comprobará la efectividad del capital de la empresa. Demostrado lo anterior, dictará una resolución que autorice la existencia de la sociedad y apruebe sus estatutos.*
(...)

- Este art sirve para establecer el procedimiento para la aprobación del banco como **agencia o sucursal**.

○ **Art 32 y 33: Procedimiento de bancos extranjeros**

○ **Art 34: Igualdad de tratamiento para los bancos extranjeros**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 34- Los bancos extranjeros que operen en Chile gozarán de los mismos derechos que los bancos nacionales de igual categoría y estarán sujetos en general a las mismas leyes y reglamentos, salvo disposición legal en contrario.¹

El capital y reservas que asignen a su sucursal en el país deberá ser efectivamente internado y convertido a moneda nacional en conformidad a alguno de los sistemas autorizados por la ley o por el Banco Central de Chile.² Los aumentos de capital o reservas que no provengan de capitalización de otras reservas, tendrán el mismo tratamiento del capital y reservas iniciales.

Ningún banco extranjero podrá invocar derechos derivados de su nacionalidad respecto a las operaciones que efectúe su sucursal en Chile.³

Toda contienda que se suscite en relación con las operaciones de la sucursal en el país, cualquiera que fuere su naturaleza, será resuelta por los tribunales chilenos, en conformidad a las leyes de la República.⁴

Para los efectos de las operaciones entre una sucursal y su casa matriz en el exterior, ambas se considerarán como entidades independientes.

Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que tuviera el banco extranjero, de acuerdo a las reglas generales, por las obligaciones que contraiga la sucursal que haya establecido en Chile.⁵

(...)

- ¹Se refiere a la **igualdad de tratamiento entre los bancos extranjeros operando en el país y los bancos constituidos como SA en Chile.**
- A juicio de *Yrarrázaval* esta norma es fundamental, porque en los países que no contienen una norma como ésta, o, no hay bancos extranjeros -no saben cómo se los va a tratar-, o, hay pocos bancos nacionales -porque al extranjero se le puede dar un tratamiento más favorable-.
- Esta regla de igualdad de dº se ha mantenido en la LGB desde el comienzo.
- **Implica que las leyes, reglamentos y circulares se aplican de igual manera para los bancos extranjeros.**
- Lo que sí, el banco extranjero tiene algunas particularidades que no los tienen los bancos constituidos como SA:
 - ✓ ²El banco extranjero tiene su capital en el extranjero, pero, el **capital asignado** en el país se refiere al que **efectivamente** se interna en el país.
 - ❖ Esto significa que las obligaciones con respecto al capital son las mismas para bancos como SA y bancos extranjeros.
 - ❖ Por lo tanto, el capital mínimo es el mismo para ambos.
 - ❖ El capital en el país es el capital que está asignando el banco extranjero a las operaciones en el país, NO es el capital de la casa matriz. Sino, que el banco extranjero asigna y entrega en Chile tal cantidad, y luego, la irá aumentando con el efecto de poder realizar más operaciones.
 - ❖ A juicio de *Yrarrázaval*, el sistema bancario tiene una gracia muy especial. Lo único que hace la ley es establecer un capital mínimo, pero mientras **mayor sea el capital, más operaciones puede realizar el banco.** Esto

incentiva a que el banco no se quede con el capital mínimo. Esta es una regla que ya se ha hecho casi universal.

❖ Esta regla curiosamente proviene del **Comité de Basilea**.

→ Éste ni siquiera es un órgano permanente, sino que, se reúnen en Basilea, Suiza banqueros de todas partes del mundo, y, sugieren ciertas reglas bancarias fundamentales.

→ Los países pueden aceptar o rechazar esas reglas, no hay obligatoriedad ante ellas.

→ Pero, Basilea ha demostrado -especialmente desde la última crisis bancaria a nivel mundial importante- que tiene mucha razón de exigir cada vez más capital.

→ Y, nosotros hemos modificado la LGB para contener esos conceptos en nuestra ley. No porque estemos obligados, sino porque se considera como razonable.

→ Este comité está vinculando **capital** con la **morosidad de los activos del banco**.

- Si tiene más morosidad, se necesita más capital.

- Si tiene menos morosidad, se necesita menos capital.

→ El capital del banco es una cantidad ínfima con respecto de las operaciones que está realizando.

→ En Chile antes del comité de Basilea existía una relación de 1:20.

- El capital era 1 frente a 20 operaciones. Esto se refiere a que en base a un capital de 1 se realizan 20 operaciones, y, además ese capital ya está gastado. Entonces, para liquidar al banco, es lo más complicado que hay.

- Con esto, no hay ninguna crisis bancaria que aguante.

→ A juicio de *Yrarrázaval* el aporte de Basilea ha sido importantísimo.

→ Hay algunos países que no se han sumado a Basilea, pero, son países en donde la actividad bancaria está muy disminuida.

✓ ³**Ningún banco extranjero podrá invocar d^º derivados de su nacionalidad** respecto a las operaciones que efectúe su sucursal en Chile. Esto es una consecuencia de la igualdad de tratamiento entre bancos.

✓ ⁴Toda contienda que se suscite en relación con las operaciones de la sucursal en el país, cualquiera que fuere su naturaleza, será resuelta por los **tribunales chilenos, en conformidad a las leyes de la República**.

✓ ⁵Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que tuviera el banco extranjero, de acuerdo a las reglas generales, por las obligaciones que contraiga la sucursal que haya establecido en Chile. Entonces, si el capital asignado es insuficiente para esas operaciones, se puede ir siempre a la casa matriz.

▪ En los 80`, los bancos tenían muchos activos en dólares. Como había inflación, se fijó el precio del dólar y ciertos activos que no eran riesgosos, se calificaron como riesgosos. Al ser riesgosos requieren un mayor respaldo de capital.

○ **Art 36**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 36- *Por exigirlo el interés nacional, ninguna persona podrá adquirir directamente o a través de terceros, acciones de un banco que, por sí solas o sumadas a las que ya posea, representen más del 10% del capital de éste, sin que previamente haya obtenido autorización de la Comisión.¹*

Las acciones que se encuentren en la situación prevista en el inciso anterior y cuya adquisición no haya sido autorizada no tendrán derecho a voto.²

(...)

- Este art es muy importante.
- ¹Con la justificación del interés nacional, se requiere de la **autorización previa de la CMF** para que alguna persona adquiera **acciones** -individuales o en su conjunto- que representen **más del 10% del capital** del banco.
- Es una **limitación/restricción al dº de acceso a la propiedad**, que se encuentra en el **art 19 Nº23 CPR**, especialmente en el **inc 2**. En éste se dice que por exigirlo el interés nacional, se podrá limitar la propiedad.
- ²Algo muy curioso de la ley, es que inmediatamente pone la sanción. Indica que las acciones que se adquirieron sobre el 10% y que no fueron autorizadas por la CMF **no tienen dº a voto**. Esto es importante porque se tratan acciones de una SA. Los accionistas compran acciones para influir en las decisiones, pero si son sobre este 10% y no son autorizadas, no tienen dº a voto.

○ Art 37 y 38 son de carácter general.

○ **Art 37**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 37- *Las empresas bancarias son instituciones de funcionamiento obligatorio con sujeción al horario vigente.¹ Ninguna empresa bancaria podrá iniciar, suspender o poner término a sus operaciones sin previa autorización de la Comisión.*

Los bancos, antes de abrir cualquier oficina dentro del país, deberán informarlo a la Comisión.² Esta, mediante norma de carácter general, determinará los antecedentes que deberán acompañarse para acreditar los requisitos necesarios para la apertura de la oficina y su registro.

(...)

- ¹Las empresas bancarias tienen un funcionamiento **obligatorio**.
- Es de los pocos casos en que la ley indica un funcionamiento obligatorio.
- Esto está muy vinculado con las huelgas. La actividad bancaria es una actividad de todos los días, y aquí se han producido ciertos problemas cuando ha habido huelgas. La gente que debe pagar los depósitos que vencen ese día no pueden entrar al banco por una cuestión de hecho.
- Indiscutiblemente que, hoy día con los sistemas computacionales este asunto tiene menores efectos, pero siempre tiene algún tipo de efectos.
- El funcionamiento es obligatorio para que se puedan realizar todas las operaciones bancarias en todos los días hábiles bancarios.
- Los días hábiles bancarios son de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El horario está

establecido por la CMF. Pero, la SBIF/CMF ha ido autorizando que algunas operaciones se hagan después de las 14 hrs.

- ¿Por qué tan estricto el horario?²⁰ Porque después de esa hora se debe procesar toda la información que se haya adquirido entre las 9 y las 14 hrs para así poder entregárselo a la CMF.
- ✓ Hoy en día, digitalmente los bancos están entregando información **diaria** de las operaciones de captación y de colocación, y, se van clasificando de distintas formas.
- ✓ Esto es muy relevante para la **fiscalización de los bancos**.
- ✓ Hoy día, afortunadamente -a juicio de *Yrarrázaval*- no se utilizan fiscalizadores que vayan físicamente al banco. Eso es lo más inútil que se puede hacer. Ej: Brasil.
- ✓ En definitiva, hoy en día el **trabajo de un banco para cumplir con las exigencias de información es inmenso**, sobre todo si son operaciones **cambiarías** porque el BC requiere saber cuántas operaciones se hicieron, a qué valor, etc para poder determinar el valor del dólar observado.
- ²Los bancos, antes de abrir cualquier oficina dentro del país, deberán informarlo a la CMF. Y, para cerrarlas también.

○ Art 38

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 38- *Corresponderá a la Comisión fijar, mediante norma de carácter general, el horario mínimo para la atención del público en el Banco del Estado de Chile y en el resto de los bancos, el que deberá ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad.¹*
(...)

- ¹Corresponderá a la **CMF** fijar, mediante norma de carácter general, el **horario mínimo para la atención del público** en el Banco del Estado de Chile y en el resto de los bancos, el que deberá ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad.
- El BC regula la política monetaria a través de 4 mecanismos:
 1. Tasa de Política Monetaria
 2. Tasa de Encaje
 3. Limitaciones a las operaciones bancarias (art 69)
 4. Calificación de activos por riesgo (depende del riesgo el % que se debe guardar)
 - La crisis bancaria en la década del 80` se dio porque la SBIF liquidó muchos bancos bajo el argumento de que no tenían más futuro. El **13 de enero de 1983**, la SBIF ya NO liquida bancos, sino que entra a administrarlos, ya que eran demasiado grandes para entrar en liquidación. A juicio de *Yrarrázaval*, se designaron muy buenos **administradores** de éstos bancos, y, así se volvió a la normalidad desde el punto de vista bancario en el 86`.
 - El punto de fondo de la crisis es que se fijó el el precio del dólar en el año 82`, y así, se

²⁰ En otros países el horario es bastante más extenso.

devaluó la economía. Y, así, ciertos créditos que no eran riesgosos se convierten en peligrosos.

○ **Art 39: Giro Bancario**

TÍTULO II –CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS BANCARIAS

Artículo 39- *Ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por ley¹, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.²*

Ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada por ley, podrá dedicarse por cuenta propia o ajena a la correduría de dinero o de créditos representados por valores mobiliarios o efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito.³

Tampoco podrá poner en su local, oficina, sitio web, plataforma o medio tecnológico, cualquier tipo de aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que indiquen que se trata de una empresa bancaria⁴, ni podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel o documento que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedica dicha persona son de giro bancario o de intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales expresiones.

Se presume que una persona natural o jurídica ha infringido lo dispuesto en este artículo cuando haga uso de un local u oficina o utilice algún sitio web, plataforma o medio tecnológico en el que, de cualquier manera, se invite al público a entregar dinero a cualquier título o al cual se haga publicidad por cualquier medio con el mismo objeto.⁵

Las infracciones a este artículo serán castigadas con presidio menor en sus grados medio a máximo.⁶ La Comisión, en este caso, pondrá los antecedentes a disposición del Ministerio Público, a fin de que inicie la investigación que correspondiere.⁷
(...)

○ **Inc 1:**

- Es fundamental ya que habla del **giro bancario**.
- A juicio de *Yrarrázaval*, la LGB debería partir con esta norma.
- ²Este inc hay que saberselo de memoria porque cada palabra es importante.
- ¹Se refiere a la LGB.
- ¿Habrán en Chile otras instituciones que no son bancos comerciales, y realizan actividades habituales de captación y colocación de dinero, y, que están autorizadas por ley? Sí, se refiere a las tiendas que tienen tarjetas. Se complicó especialmente cuando se permitió retirar dinero por las tarjetas.
- En definitiva, el art 39 se refiere a que bajo la LGB o leyes especiales, que hagan que determinadas empresas capten o coloquen dinero en forma habitual, son las únicas que pueden dedicarse al **giro bancario**.
- El **giro bancario** se refiere a la **actividad propia del banco**, vale decir, la **captación y colocación habitual de dinero al público**.
- Ese es el giro bancario que la LGB quiere proteger. Tanto así, que después el mismo art 39 viene a sancionar a todos los que se dedican al giro bancario sin autorización.
- Efectivamente, por desgracia -según *Yrarrázaval*- en Chile y en todos los países

hay muchas empresas y personas que se dedican a captar y colocar dinero en forma habitual fuera del sistema. Esto se denomina **financieras ilegales**. Esta es una realidad que **afecta a las personas que no tienen un acceso real al sistema bancario**.

- ¿Por qué hay tantas personas que no tienen acceso al sistema bancario?
 - ✓ Uno pensaría que debieran tener acceso al sistema bancario la gran mayoría de las personas. Esto hablaría de un sistema bancario sólido, y, que permite financiamiento a muchas personas.
 - ✓ En la LGB especialmente con respecto a los préstamos o colocaciones, se necesitan **garantías**, y, éstas son las que las personas más vulnerables o de menores ingresos no tienen. No tienen la posibilidad de la hipoteca sobre la casa, de la prenda sobre determinados bienes, de un buen aval, etc.
 - ✓ Entonces, uno diría que se deben disminuir las exigencias, pero esto implicaría un sistema bancario lo más vulnerable del mundo. Esto se debe a que el **sistema de garantías es lo que le permite al banco cobrarse en los préstamos que no se le han pagado**.
 - ✓ Dentro del sistema de garantías hay unas muy buenas y otras no tanto para los bancos.
 - ❖ La mejor es el **aval** porque se compromete a pagar lo que el deudor no pague. El aval se compromete a pagar lo que no va a pagar la persona. Igual, depende de quién es el aval, pero, los bancos se preocupan de elegir muy bien de que el aval tenga bienes, tenga solvencia, tenga protección, etc. **NO hay ninguna excepción para el pago de un aval**.
 - ❖ Si nos imaginamos la garantía de una casa, el banco tiene que empezar el juicio, y, después de mucho tiempo obtendrá una sentencia afirmativa, luego se va al remate. Entonces, en menos de 3 años el banco no ve ni un peso con respecto a ese préstamo.
 - ❖ Entonces, el sistema de garantías es un tema muy delicado, y, por eso la ley y las circulares son muy desarrolladas con respecto a este tema.

16 de mayo

- ¿Quién define la habitualidad? La habitualidad del giro la define la CMF.
- La captación y colocación de dinero es o no es.
- El tema no es nada de fácil, ya que deja fuera del sistema a muchas empresas que se dedican a captar y colocar dinero.
- Muchas personas no pueden acceder al sistema bancario, y, esto se nota especialmente en el **sistema de garantías** para los préstamos. Este va a ser un tema que aparece posteriormente en la LGB con bastante cuidado. La LGB se queda con lo fundamental de los conceptos, y, le deja a la CMF la regulación mediante **circulares**.

○ **Inc 2: Prohibición**

- ³El inc 2 del art 39 dice que ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada por ley, podrá dedicarse por cuenta propia o ajena a la

operaciones de captación y colocación. Y si lo llegare a hacer, el inc 5 indica la sanción.

○ **Inc 3**

- ⁴Tampoco podrá poner en su local, oficina, sitio web, plataforma o medio tecnológico, expresiones que indiquen que se tratan de empresas bancarias porque puede inducir a muchas personas a transar con ellos siendo que no son empresas bancarias.

○ **Inc 4**

- ⁵Se presume que una persona natural o jurídica ha infringido lo dispuesto en este artículo cuando haga uso de un local u oficina o utilice algún sitio web, plataforma o medio tecnológico en el que, de cualquier manera, se invite al público a entregar dinero a cualquier título o al cual se haga publicidad por cualquier medio con el mismo objeto. Nuevamente, se está refiriendo a empresas que intentan hacerse pasar por bancos comerciales y en realidad no lo son.

○ **Inc 5: Sanción**

- ⁶El inc 5 indica que las infracciones serán calificadas con **presidio menor en su grado medio a máximo**.
- ⁷La CMF debe poner los antecedentes en el Ministerio Público.
- La CMF no es la que la sentencia desde el punto de vista penal -ya que es una sanción de presidio-, sino que es el Ministerio Público.
- La SBIF anteriormente, y, hoy en día CMF ha utilizado muy poco esta sanción sobre la infracción en el inc 2. No se puede hacer correctamente porque se encuentran **fuera del sistema bancario**. La autoridad bancaria no tiene mucho que hacer. La culpa del mal funcionamiento de éstas no debería ser de la SBIF/CMF porque éstas están fuera del sistema y la SBIF no tiene conocimiento de estas miles de empresas.
- Es lo mismo que ocurrió cuando teníamos controles cambiarios con un tipo de cambio artificial en Chile. Finalmente, se terminó transando en la calle ("mercado negro"). ²¹
- ✓ Los afectados en estos casos recurrieron ante la SBIF, luego al BC y por último, terminaron demandando por **estafa**. Y, eso es lo que corresponde, ya que son estafas bancarias.
- Las financieras ilegales captan con un 10-15% de interés, pero también cobran un % similar en los préstamos y la gente después no los puede pagar.
- No se ha planteado una sanción para personas que inviertan su dinero en financieras ilegales. Generalmente, las personas que recurren a éstas saben muy poco sobre el sistema bancario. Entonces, se sanciona a las empresas ilegales y no a las personas.
- En ciertas estafas han intervenido personas que debieran haber sabido a lo que se estaban exponiendo, pero, es muy difícil determinar si debían saber o no.

²¹ Se transaban muchos dólares en los cafés de la calle Ahumada.

III. TÍTULO III – REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN

○ Art 40: Definición de Banco Comercial

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 40- Banco es toda sociedad anónima especial¹ que, autorizada en la forma prescrita por esta Ley y con sujeción a la misma², se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público³, con el objeto de darlos en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar estos dineros y, en general, realizar toda otra operación que la ley le permita.⁴

- Este art define los bancos comerciales, por lo que debiese estar en el art 1.
- ¹Es una SA especial.
- ²Es autorizado por la LGB y se debe sujetar a ella.
- ³Se dedica a **captar** dinero en forma **habitual**.
- ⁴Capta dinero para realizar distintas operaciones que la ley permite hacia el público. Estas operaciones están enumeradas por la LGB debido al OPE, ya que los bancos no pueden realizar operaciones que no estén en el listado.
- El banco comercial capta y coloca dinero en forma habitual.

○ Art 41

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 41- Los bancos se rigen por la presente ley¹ y, en subsidio, por las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto puedan conciliarse o no se opongan a sus preceptos.²

No se aplicarán a los bancos las normas que la ley de sociedades anónimas contempla sobre las siguientes materias:³

a) Exigencia de acuerdo de junta de accionistas para prestar avales o fianzas simples y solidarias;⁴

b) Derecho de retiro anticipado de accionistas; y,⁵

c) Consolidación de balances.⁶

- ¹Los bancos se rigen por la **LGB**.
- ²En subsidio, se regirán por las disposiciones aplicables a las **SA abiertas** en cuanto puedan conciliarse o no se opongan a la LGB.
- ³No se aplicarán a los bancos las normas de SA sobre 3 materias. En ellas se aplica la LGB. Es decir, rige en subsidio las normas de SA abiertas salvo en estos 3 casos:
 - a) ⁴**Exigencia de acuerdo de junta de accionistas para prestar avales o fianzas simples y solidarias.**
 - ❖ En el caso de las SA, cuando la SA está prestando fianzas o garantías de distinto tipo, se trata en la junta de accionistas porque es un tema delicado. Puede ser muy grave para una SA que esté dando fianzas o garantías, por lo tanto, lo debe resolver la junta.
 - ❖ Esto **NO** rige para los bancos porque en los bancos se exige una dinámica superior. **No se puede estar esperando.** Por lo tanto, estas materias pueden ser resueltas por directores y no por la junta.

b) ⁵Derecho de retiro anticipado de accionistas.

- ❖ En toda SA, existe la posibilidad de que los accionistas se retiren en un determinado % si hay una situación muy grave. Por ejemplo, que se fusione con otra empresa. La ley enumera las situaciones graves en las que el accionista se puede retirar. La SA le compra las acciones a un precio predeterminado -un precio de mercado-.
- ❖ En el caso de los bancos NO se quiso reconocer el dº a retiro porque esto puede **LIQUIDAR al banco**.
- ❖ Es una medida de protección.
- ❖ Esta es la más importante.

c) ⁶Consolidación de balances.

- ❖ En las empresas los balances se consolidan (se juntan) cuando hay relaciones con otras empresas que son filiales, sucursales, etc.
- ❖ La ley de SA contempla que cuando hay varias empresas relacionadas entre sí, hay una consolidación del balance.
- ❖ **Los bancos SOLO se pueden dedicar a la actividad bancaria por lo que NO hay consolidación de balance.** Su único giro es el bancario.
- ❖ El proceso de consolidación de balance es sumamente complejo porque en definitiva le agrega a la información de la *empresa madre* muchas otras empresas con resultados totalmente distintos. Y, se debe analizar si las otras empresas afectan el resultado de la empresa madre o no.

22 de mayo

○ **Art 42: Estatutos del banco**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN

Artículo 42- Los estatutos de un banco deberán contener las siguientes disposiciones, además de las exigidas a las sociedades anónimas:¹

1) El nombre del banco², en el que podrá omitirse la indicación de que se trata de una sociedad anónima.³

2) La ciudad de la República en que se instalará su casa matriz u oficina principal⁴, y que constituirá su domicilio social, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en conformidad a la ley. En esa ciudad deberán celebrarse las sesiones ordinarias de directorio y funcionar la gerencia general de la empresa.

3) El número de los directores del banco y el nombre de los integrantes del directorio provisional que deban ser designados por los accionistas.⁵

4) El nombre y domicilio del gerente provisional y el subgerente que lo reemplazará en caso de ausencia o incapacidad.⁶

- Habla de los **estatutos del banco**. Son una parte muy importante para la autorización de funcionamiento de un banco como SA. Vale decir, el banco ni siquiera puede empezar a funcionar si no tiene sus estatutos con todo el contenido que deben tener -que se encuentra en la Ley de SA- y si éstos no son aprobados por la CMF.
- Los estatutos incluyen quiénes son los accionistas fundadores, cuál es el capital, cómo es la administración, el objeto, etc.
- ¹Son exigencias adicionales en los estatutos de un banco que a las de los estatutos de cualquier SA.

1) ²El **nombre** del banco.

³No se requiere la indicación de que se trata de una SA.

- ❖ Toda SA debe indicar de que se trata de una SA. Entonces, requiere el nombre y el S.A o sociedad anónima al final. Esto es para que todos los que contraten con esta sociedad sepan de qué tipo societario se trata.
- ❖ En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) -la SA es un tipo de sociedad de responsabilidad limitada para estos efectos- se es responsable **hasta el monto de los aportes hechos por los accionistas**. Esto es un concepto fundamental en dº societario, y, explica por qué muchas empresas se organizan como SA o SRL. De esta manera, se arriesgan hasta el monto de los aportes.
- ❖ La excepción -que no es verdaderamente una excepción a juicio de *Yrarrázaval*- es en el caso de que los accionistas hayan dado alguna garantía que vaya más allá del monto de los aportes.
- ❖ Pero, no es una excepción propiamente tal porque no surge del hecho de que sea una SA limitada a los aportes. Que los accionistas den voluntariamente garantías es una decisión personal.
- ❖ La peor garantía o la más peligrosa es la de los avales, ya que se puede cobrar contra el avalista y no el deudor. Esta es la garantía personal más complicada.²² Pero, a veces es requerida.
- ❖ En el caso de los bancos no es necesario mencionar SA porque todos entienden de que un banco es un banco.

2) ⁴La **ciudad** de la República en que se instalará su casa matriz u oficina principal.

- ❖ Esto es en razón del domicilio de los bancos.
- ❖ El domicilio de los bancos tiene una gran importancia especialmente en cuanto a los recursos procesales que se presentan contra de los bancos.
- ❖ El recurso se debe presentar en la región del domicilio del banco, sino se podría llegar a desestimar la demanda.
- ❖ Es muy importante el concepto de *falta de jurisdicción*.

3) ⁵El **número de directores** del banco y el nombre de los integrantes del directorio provisional que deban ser designados por los accionistas.

- ❖ El directorio provisional existe hasta que se designe el 1º directorio definitivo.
- ❖ Los directorios son nombrados por la junta de accionistas.
- ❖ Cuando se está organizando un banco, todos los directores van a ser provisionales hasta la 1ª junta de accionistas.

4) ⁶El **nombre y domicilio del gerente provisional** y el subgerente que lo reemplazará en caso de ausencia o incapacidad.

²² Ha generado grandes complicaciones en figuras del fútbol nacional.

○ **Art 43: Administración y dirección de un banco**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 43- La dirección y la administración de las empresas bancarias se ejercerán en conformidad a las disposiciones legales que rijan la materia, a los estatutos de cada banco y con sujeción a las normas impartidas por la Comisión.¹

- Se refiere a la **administración y dirección de un banco**.
- ¹La LGB indica que se aplican:
 1. Las **disposiciones legales**: se encuentran en la LGB, Ley de SA, etc.
 2. Los **estatutos de cada banco**: el estatuto no puede ir más allá de la ley.
 3. Las **normas impartidas por la CMF**: al igual que la SBIF en el pasado, la CMF puede y dicta normas con respecto de la administración de un banco. Para esto, debe ser muy prudente, ya que en definitiva, la administración la tiene el directorio.
- Un concepto fundamental de toda SA y todo banco es que la **administración la tiene el director**²³, y, él es el que **asume la responsabilidad** de la dirección y administración.
- La junta de accionistas NO tiene -afortunadamente según *Yrarrázaval* en Chile ni en la gran mayoría de los países- ni dirección ni administración, sino que toma las decisiones que le corresponden a los dueños de la empresa o del banco. Algunas de ellas son: aprobación del balance, aprobación de las utilidades que van a ser distribuidas, la designación de los directores, la designación de los auditores externos, etc.
- La junta NUNCA entra en temas de administración.
- Los accionistas no pueden reclamar por ejemplo del comportamiento de cierto director, para eso no es la junta.
- ¿Por qué el director asume tanta responsabilidad y no tanto los gerentes? Porque la ley debe ser **eficaz** en el sentido que no debe ir eximiendo gerente por gerente y subgerente por subgerente, esto sería eterno. Entonces, la ley determina que los directores son elegidos para tener la administración y dirección de la empresa, y, por tanto, deben asumir el máximo de responsabilidad.
- ✓ Se puede eximir de responsabilidad si consta en el acta de directorio que ese director se opuso. Si no lo hace, o, no consta en el acta no se exime de responsabilidad. Es por esto que las actas de directorio tienen tanta importancia.
- ✓ Además, se puede eximir de responsabilidad diciendo que esa materia nunca llegó al directorio.²⁴ Esta es una manera indirecta. Ahí, es más complicado porque se debe entrar a ver la responsabilidad del gerente de llevar esa

²³ Generalmente se reúnen sólo 2-3 horas al mes para conocer lo relevante que ocurrió en la empresa.

²⁴ Caso de los laboratorios. La FNE analizó todas las actas de las 3 empresas y no encontró ninguna referencia al 1-2-3 de aumento de precios en los remedios con receta retenida. Pero incluso en ese caso, los directores siguen siendo responsables por el concepto amplio de administración, vale decir, los directores deben transmitir a todos los ejecutivos y gerentes de la empresa de que esta es una materia importantísima, y que hay acciones que debe conocer el directorio, o sino, se deben retirar esos gerentes o ejecutivos.

materia a la reunión de directorio.

- Caso Energy en USA: una empresa Nº15 en el mundo tuvo un fraude que fue estructurado dentro de la gerencia de finanzas, y, los gerentes generales ni el directorio sabían sobre esto.
- Muchos casos de colusión han sido fraguados por gerentes o subgerentes, y, con desconocimiento del directorio.
- Caso farmacias: ni el directorio ni los dueños sabían sobre este aumento de precios, sino que fue a nivel de los subgerentes de marketing.
- Caso La Polar: fue fraguado entre el gerente general, gerente de finanzas y gerente administrativo. Cuando la SBIF empezó el juicio en contra de La Polar sostuvo que el directorio tuvo que haber tenido conocimiento de esa maniobra que generó un precio de acciones espectacular (se infló artificialmente el precio de las acciones). Los directores se defendieron y terminaron con una sentencia bastante baja porque la SBIF no pudo demostrar que esta materia había llegado a conocimiento del directorio.

○ **Art 44**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN

Artículo 44- *Toda elección de directores será publicada en un periódico del domicilio de la empresa bancaria correspondiente y deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión¹, a quien se enviará copia autorizada de la escritura pública a que debe reducirse el acta de la junta de accionistas o sesión de directorio en que los nombramientos se hubieren hecho. (...)*

- Hay una serie de exigencias societarias, pero en el caso de los bancos, además la LGB pone más exigencias.
- ¹**Publicar la elección de directores en un periódico** es una exigencia que solo se aplica para los bancos.
- Pero, es una exigencia general de toda SA abierta publicar la elección de directores ante la CMF.

○ **Art 45**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN

Artículo 45- *El directorio celebrará sesión ordinaria por lo menos una vez al mes¹ y todos los acuerdos que adopte se consignarán en el acta respectiva.²*

- ¹El directotio debe celebrar una **sesión ordinaria por lo menos una vez al mes**.
- ²**Todos los acuerdos deben estar incluidas en el acta**, por lo que éstas pueden ser muy largas.
- En la gran mayoría de los casos, las actas se están reduciendo a los acuerdos, y, respecto de los votos de mayoría y minoría de los acuerdos.
- Entonces, empiezan a tener 4-5 páginas y no 40 como tenían antes ya que no es todo lo que se dijo en la sesión de directorio.

○ **Art 46**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 46- El directorio deberá adoptar las medidas e impartir las instrucciones necesarias con el objeto de mantenerse cabal y oportunamente informado, con la correspondiente documentación, del manejo, conducción y situación de la entidad bancaria que administra.¹
(...)

- ¹Los directores de banco -y los de SA abiertas en menor grado- tienen que estar permanentemente solicitando información ya que esta es la única forma que pueden enfrentar su responsabilidad.

○ **Art 47**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 47- Las empresas bancarias extranjeras¹ no estarán obligadas a tener directorio para la administración de sus negocios dentro del territorio de la República², pero deberán tener un agente ampliamente autorizado para que las represente con todas las facultades legales.³
Las responsabilidades y sanciones que afecten al directorio o a los directores de las empresas bancarias corresponderán o podrán hacerse efectivas en el apoderado de las sucursales de los bancos extranjeros.
Las empresas bancarias extranjeras podrán efectuar sus operaciones en Chile, en conformidad con sus prácticas habituales, siempre que no sean contrarias a las disposiciones que rijan la materia y no afecten a la seguridad de los negocios.⁴
Las remesas de las utilidades líquidas que obtengan las empresas bancarias extranjeras se harán previa autorización de la Comisión y con sujeción a las disposiciones legales vigentes y a las normas que imparta el Banco Central de Chile.

- Es una norma especial para las **agencias o sucursales de bancos extranjeros**.
- La forma en que lo plantea la ley es bastante curiosa.
- ¹NO oficinas de representación, que por cierto no tienen directorio en Chile.
- ²**Las empresas bancarias extranjeras** -agencias o sucursales- **NO están obligadas a tener directorio para la administración de sus negocios en Chile.**
 - ✓ Si quieren lo pueden tener, pero éste será más nominal que real porque no están obligadas a tener directorio.
- ³Lo que si **deben tener es un AGENTE**.
 - ✓ Se obliga de forma imperativa.
 - ✓ El agente debe tener todas las facultades habidas y por haber.
 - ✓ Cuando se está instalando un banco extranjero en el país, la CMF deberá tener mucho cuidado al revisar que el poder del agente sea el más general posible para que no haya ninguna disculpa de que éste no tuvo poderes suficientes para tal efecto.
- ⁴Parte la ley muy amable indicando que los bancos extranjeros pueden realizar sus operaciones en Chile cuando sean conformes con sus prácticas habituales, y luego pone una regla. Éstas prácticas no pueden ser contrarias a las disposiciones de la materia y no pueden afectar la seguridad de los negocios.
- Ejemplo: algunos bancos extranjeros le pidieron a la SBIF que la información bancaria de sus operaciones en Chile sean manejadas por su casa matriz,

teniendo la contabilidad centralizada en el extranjero. Para el banco es una economía de costos espectacular y muy engorroso tener en cada país donde opere su propio sistema contable. Pero, la SBIF respondió que no porque les quita control.

- **Toda la información que se necesita, debe llegar todos los días a la CMF.**
- Tal vez en un futuro se permita semanalmente, pero *Yrarrázaval* no está muy a favor de esto ya que sobre la base de la información diaria se hace la fiscalización.

○ **Art 48**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN

Artículo 48- *La Comisión o el delegado que designe al efecto podrá resolver administrativamente cualquier cuestión que se suscite en una junta de accionistas¹, sea con relación a la calificación de poderes o a cualquier otra que pueda afectar la legitimidad de la asamblea, de los acuerdos que se adopten o de los directores que en ella se elijan, sin perjuicio del derecho de los interesados para ejercer las acciones que les correspondan ante la justicia ordinaria.*

Cualquiera que sea la resolución de la justicia, no podrá ella afectar la validez de los acuerdos adoptados con la concurrencia de los directores elegidos en esa junta, ni de los actos celebrados en virtud de tales acuerdos.

- ¹Pueden haber problemas en una junta de accionistas con respecto de la calificación de los poderes, o respecto de otras materias, y, por lo tanto, la CMF puede mandar abogados a la junta de accionistas para resolver los problemas administrativos.
- Por ejemplo: si el poder fue bien o mal otorgado. Los poderes deben otorgarse manualmente y no a computador.
- La Ley de SA y los reglamentos de SA dan ciertas formalidades, pero a veces es conveniente que el abogado de la CMF decida de una manera. Por ejemplo, si todos los poderes están escritos a computador, no se podría realizar la junta por esa materia, entonces el abogado puede decidir qué hacer.

○ Art 49

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN**Artículo 49- Los bancos estarán sujetos a las siguientes disposiciones:¹**

1) Los aportes de los accionistas sólo podrán consistir en dinero efectivo, esto es, en moneda legal de Chile.² No se aplicará esta regla en los casos de fusión de bancos ni en los de adquisición del activo y pasivo de un banco por otro.

(...)

2) No podrán emitir acciones de industria, acciones para remunerar servicios, ni acciones con privilegio o preferencia, salvo conforme a lo dispuesto en el artículo 55 bis en relación con el artículo 66 letra b). Podrán, en todo caso, emitir distintas series de acciones.³

3) No se establecerá límite alguno en el número de acciones por las que cada accionista podrá votar en las juntas, salvo los que impongan o autoricen las leyes.⁴

4) No podrán ser accionistas de un banco el Fisco, los servicios, instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, todos los servicios públicos creados por ley, como asimismo las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación.⁵

5) Un banco podrá adquirir acciones de otro banco con el único objeto de efectuar una fusión entre ambas instituciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:⁶

(...)

6) Los bancos no estarán obligados a efectuar nuevamente la publicación de sus balances y estados de pérdidas y ganancias debidamente auditados en el plazo que señala la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas si lo hubieren hecho con anterioridad; pero en este caso deberán dejar constancia en los avisos de citación a junta, del periódico en que se publicaron y de la fecha en que se efectuó la publicación.⁷

- ¹Se refiere a todas las normas con respecto a los bancos que no corresponden a las anteriores mencionadas.

1. ²Los aportes de los accionistas sólo podrán consistir en **dinero efectivo**, esto es, en **moneda legal de Chile**.

❖ El dinero efectivo consiste en la moneda legal de Chile.

❖ En el caso de las SA, los aportes pueden ser en dinero efectivo o en bienes muebles o inmuebles valorados.

→ Perfectamente un accionista puede aportar un sitio propio, y, ese debe ser valorizado porque ese accionista va a querer valorizarlo en una cantidad inmensa.

→ Lo mismo ocurre con respecto de bienes muebles.

❖ Pero, en el caso de los bancos la ley es más exigente, e indica que SOLO se pueden hacer aportes en **dinero efectivo**, es decir, en moneda de curso legal.

2. ³No podrán emitir acciones de industria, acciones para remunerar servicios, ni acciones con privilegio o preferencia, salvo conforme a lo dispuesto en el artículo 55 bis en relación con el artículo 66 letra b). Podrán, en todo caso, emitir distintas series de acciones.

❖ Hay múltiples tipos de acciones, incluso hay acciones para remunerar servicios. En una SA, esas acciones se valorizan.

- ❖ La ley dice que en el caso de los bancos **no puede ser ninguna otra acción que no sea en dinero efectivo**. La ley es mucho más cuidadosa que respecto de cualquier SA, y, esto se hace para evitar la sobrevaloración de ciertos aportes a un banco.
- 3. ⁴**No se establecerá límite alguno en el número de acciones** por las que cada accionista podrá votar en las juntas, salvo los que impongan o autoricen las leyes.
 - ❖ En el pasado existieron unos máximos de votación en las SA. *Yrarrázaval* no concuerda para nada con esta medida ya que eran muy arbitrarios. Para esto, se utilizaban los *palos blancos*. Esto no era un problema de la ley, sino que obviamente esos límites máximos eran sobrepasados.
 - ❖ Esto lo tuvimos en Chile en materia bancaria, y, las personas normales no podían comprar más de “x” número de acciones y las personas jurídicas más de “y” número de acciones.
- 4. ⁵**No podrán ser accionistas de un banco** el Fisco, los servicios, instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, todos los servicios públicos creados por ley, como asimismo las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación.
 - ❖ Esto se debe a que son **bancos privados**.
 - ❖ Esta norma **NO se aplica al Banco Estado** porque el Fisco es el único dueño.
 - ❖ ¿Qué garantía me da que el Estado sea el único dueño? ¿Es distinto un capital de igual monto en un banco “x” y en el Banco Estado?
 - La gente cree que lo diferencia la seguridad, pero en realidad, no es distinto, pero como la gente cree eso, el Banco Estado puede dar tasas de captación bajas y de colocación altas.
 - La verdad es que el banco Estado no es tan distinto jurídicamente de los otros bancos, la **única diferencia** es que en lugar de ser privados los **accionistas, es el fisco**. Entonces, el fisco designa al presidente del banco, los directores, etc.
 - La diferencia existió en el pasado cuando se creó el Banco Estado -en 1953-, y, en aquel entonces la ley le daba ciertas operaciones en forma exclusiva, pero esas leyes se derogaron posteriormente, y, hoy día la normativa que se aplica al Banco Estado es exactamente la misma que para todos los demás bancos comerciales.
- 5. ⁶**Un banco podrá adquirir acciones** de otro banco con el **único objeto de efectuar una fusión** entre ambas instituciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos.
 - ❖ Esta norma es bien compleja, pero importa lo elemental.
 - ❖ Viene toda una normativa sobre cómo se debe hacer.

- ❖ Un banco no puede adquirir acciones de otro banco salvo que sea resultado de una fusión o adquisición.

6. ⁷**Los bancos no estarán obligados a efectuar nuevamente la publicación de sus balances** y estados de pérdidas y ganancias si lo hubieren hecho con anterioridad.

- ❖ En el Título I se menciona que la CMF obliga a efectuar balances trimestrales, y, también puede obligar a que un banco realice un balance de ese banco, es decir, un balance adicional.
- ❖ Entonces, si ya lo ha hecho, no hay obligación de volverlo a hacer.
- ❖ Se debe actualizar el balance hasta el día que se va a emitir el balance, pero, no es necesario hacer todo el proceso del balance nuevamente, sino, que solo se hace respecto del periodo nuevo que no se incluyó en el balance anterior.

○ **Art 49 bis: Directorio del banco, Incompatibilidades e Inhabilidades**

TÍTULO III –REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS BANCOS Y A SU ADMINISTRACIÓN
Artículo 49 bis- Los directorios de los bancos estarán compuestos por un mínimo de cinco y un máximo de once directores titulares y, en todo caso, por un número impar de ellos.¹ Podrán, además, tener hasta dos directores suplentes.² Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos.³
 (...)

- ¹Los directorios pueden tener entre 5-11 directores titulares, pero el nº siempre debe ser impar, por lo tanto, el banco puede tener 5, 7, 9 u 11 directores titulares.
 - ✓ Esto se hace para que no haya dificultad en las votaciones.
 - ✓ Esto ha ocurrido en el TC -tienen 10 ministros-, y cuando las decisiones son 5-5, termina resolviendo el presidente del TC, y, esto no es muy recomendable.
- ²Los directorios pueden tener hasta 2 directores suplentes.
 - ✓ La ventaja de tener directores suplentes es que al reemplazarlo asume todas las responsabilidades de un director titular.
 - ✓ Los directores suplentes también son elegidos por las juntas de accionistas.
 - ✓ El suplente sirve para cualquier ausencia de un director titular. Ej: enfermedades, viajes, etc.
- ³Los directores duran 3 años en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente.
- Esta es una regla especial distinta a la de SA, por eso se encuentra en la LGB.
- Después, vienen todas las **incompatibilidades** que tienen los directores de bancos, y, que no son menores, además de las **inhabilidades** para votar en ciertas materias.
 - ✓ El director estará inhabilitado para votar cuando se esté tomando una decisión con respecto de su cónyuge, parientes, etc.
 - ✓ La **incompatibilidad** es para **asumir el cargo**.
 - ✓ Las **inhabilidades** son para **votar determinadas decisiones**.

IV. TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

- Desde el año 25` hasta como hace 15 años había una **regla de capital mínimo**. Pero, lo importante es que dependiendo del monto del capital por encima de este mínimo, el banco podía realizar más o menos operaciones bancarias.
- Por lo tanto, era un % el que se denominaba **la regla del 1:20** (1 de capital con 20 de operaciones).
- Si el banco se sobrepasaba de 20 recibía una multa inmensa -casi lapidaria- porque a la SBIF le importaba muchísimo que no se pasara ni un peso de 20 que era lo permitido por la ley.
- En el caso de las financieras -que existieron durante mucho tiempo en Chile- se exigía 1:15 porque se suponía que eran bancos más chicos.
- Con *Basilea* cambia todo esto. Justamente la gran importancia bancaria de *Basilea* es respecto de esto.
- En la actualidad tenemos *Basilea I, II y III*. Estos son los acuerdos provenientes de esta reunión de banqueros de todo el mundo para establecer ciertas **proposiciones** para darle la **mayor seguridad posible al sistema bancario**. NO son obligatorias.
- *Basilea I* fue bastante tímido, el II menos tímido y III nada de tímido. Con *Basilea III* se está actualmente obligando a todos los países que incluyeron esos acuerdo en su LGB. La recomendación pasa a ser obligatoria cuando se incorpora dentro del sistema legal del país.
- *Basilea III* se incorpora luego de la **última crisis bancaria mundial**.
 - La última crisis bancaria -en 2008- se produce por los **créditos hipotecarios** otorgados por **2 instituciones estatales norteamericanas**.
 - Luego, los **bancos compraban los créditos hipotecarios** de quienes los habían otorgado, que por cierto los habían otorgado malamente.
 - Se otorgaron de mala manera porque al ver que estaba prosperando la economía, comenzaron a relajar los requisitos de los créditos hipotecarios, especialmente con respecto de los solicitantes de estos créditos. Incluso, se le otorgaron créditos a personas que se encontraban desocupados.
 - Entonces, se ampliaron los créditos hipotecarios.
 - Los bancos en lugar de revisar el riesgo de esos activos, los compraron porque creían que valían mucho y en realidad valían muy poco. Por lo tanto, **aumentó la morosidad en los activos** (riesgosos). Y, los bancos también fueron irresponsables al no analizar bien el riesgo.
 - No solo los bancos norteamericanos compraron estos activos, sino que también los europeos y asiáticos.
 - Felizmente, en Chile ningún banco compró ninguno de estos activos, por eso que el impacto en Chile fue muy menor.
 - A raíz de esta situación quebraron muchos bancos en todo el mundo, entonces, ¿es bueno o no que el BC venga a respaldar estos bancos con problemas? En USA se dejó quebrar a algunos y se ayudó a otros.
 - De ahí entonces que *Basilea* coloca el énfasis en la relación de **capital** en relación con los **activos riesgosos** del banco. Entonces, ya no existe el 1:20 o 1:15, sino que existe otros % que van a empezar a aparecer en la ley. Lo que interesa saber

es cómo está la cartera de cada banco en cada momento. Como eso es bastante complicado porque los distintos activos tienen distintos orígenes, distintos riegos, etc, hoy el día las circulares de la CMF son muy gruesas porque analizan una infinidad de situaciones.

- Algunos criterios para determinar el riesgo son: si los abogados iniciaron o no las acciones judiciales, o, los plazos.
- Esto debimos haberlo sabido antes de las crisis bancarias, porque esto es el a-b-c (lo básico) de cada banco. Si un banco no conoce con lujo de detalle que ciertas personas -naturales o jurídicas- se atrasaron en el pago y por cuánto tiempo, es mejor que se dedique a otra cosa ya que no funcionará adecuadamente.
- Los depósitos son dinero otorgado al banco. El banco sabe que éstos pasivos vencen, y, con toda la tecnología existente, el banco tiene un listado de qué depósitos vencieron y están por vencer. Esto es lo que el banco DEBE a los depositantes.
- Pero, para poder pagarle a los depositantes, el banco debe recibir el pago de los créditos que otorgó a empresas y personas.
- Para notar la importancia de este tema, el BC la semana pasada dijo que estaba preocupado por el nº de créditos hipotecarios contratados por algunas personas.
 - ✓ Han aumentado los créditos hipotecarios porque la tasa de interés está baja. Entonces, es un gran atractivo para las personas que tienen los recursos para pedir estos créditos.
 - ✓ El BC se pronuncia respecto de esto porque sabe que si esta tendencia se mantiene, se puede producir lo mismo que en USA.

○ Art 50: Capital Mínimo

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 50- El monto del capital pagado¹ y reservas de un banco no podrá ser inferior al equivalente de 800.000 unidades de fomento.²

Si el capital pagado y reservas se redujeren de hecho a una cantidad inferior al mínimo, el banco estará obligado a completarlo dentro de un año³, plazo que la Comisión podrá ampliar por motivos calificados hasta por otro año.⁴ Si no lo completare, se le revocará la autorización para funcionar.⁵

- La norma sobre capital se ha mantenido a través del tiempo, pero se ha ido actualizando la cantidad de capital mínimo.
- Muchos creemos que el capital mínimo es importante para un banco, pero, en realidad el capital mínimo tiene mucha menor importancia de la que creemos.
- El **capital mínimo** es el **requerido por la autoridad para instalarse como banco.**
- **Los bancos que se quedan en este mínimo le irá pesimo pueden realizar muy pocas operaciones.**
- En realidad los bancos tienen un capital muchísimo mayor al mínimo. Vale decir, los **capitales efectivos** de cada banco son millones y millones de UF y NO son las 800.000 UF.
- ¹El **capital pagado** se refiere al **efectivamente enterado por los accionistas en**

dinero efectivo -como lo contempla la LGB-.

- ¿Por qué la CMF puede controlar este *capital pagado*?
 - ✓ En las SA distintas a los bancos, pueden tener un capital suscrito 10 veces mayores al efectivamente pagado. Y, la diferencia entre el capital suscrito y pagado no sirve para estos efectos. Acá, debe ser el **efectivamente enterado** en arcas sociales.
- ²**El capital mínimo es de 800.000 UF.**
- ³Si el capital pagado y reservas se redujeran de hecho a una cantidad inferior al mínimo, el banco estará obligado a completarlo dentro de un año.
- ⁴La CMF puede ampliar el plazo hasta por 1 año más por motivos calificados hasta por otro año.
- ⁵Si no lo completare, se le revocará la autorización para funcionar.
 - ✓ Esto no ha sucedido en Chile felizmente.
- El **capital mínimo pagado** es importante para tenerlo como **referencia** para la **autorización de funcionamiento del banco** y para los **bancos que entren en problemas y disminuyan su capital por debajo de las 800.000 UF.**

23 de mayo

- Luego de la norma del capital mínimo, este capítulo contempla normas sobre la oportunidad del capital, qué pasa cuando el banco esta bajo el mínimo, etc.
- Tanto los aumentos de capital como las disminuciones, deben ser aprobadas por la CMF (art 52 y 53).
- Debe ser el **capital pagado**. En otras palabras, la LGB NO considera ni el capital suscrito, ni capital autorizado, ni ninguna otra denominación para el capital. Vale decir, es lo **efectivamente pagado por los accionistas**.
- **Art 52: Aumento del capital**

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 52- Los acuerdos sobre aumento de capital de los bancos que se efectúen conforme a lo previsto en el artículo 127 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, deberán ser aprobados o rechazados por la Comisión¹ en el plazo de treinta días, prorrogable, por una sola vez, hasta por treinta días adicionales.

- ¹El aumento de capital debe ser autorizado por la CMF.

- **Art 53: Reducción del capital**

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 53- Sólo con autorización previa de la Comisión, un banco podrá acordar la reducción del capital.¹ En ningún caso se autorizará que el capital quede reducido a una cantidad inferior al mínimo legal.

- ¹La disminución de capital debe ser autorizado por la CMF.

○ **Art 54**

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 54- *Se prohíbe a los bancos anunciar en forma alguna su capital autorizado o suscrito sin indicar, al mismo tiempo, el monto de su capital pagado.¹ Se prohíbe, asimismo, a las sucursales de los bancos extranjeros anunciar en forma alguna la cuantía del capital y reservas de la institución bancaria matriz sin indicar, al mismo tiempo, la cuantía del capital y reservas asignados a la sucursal que funcione en Chile.²*

- Este art es de antigua data.
- ¹Se prohíbe a los bancos anunciar su capital autorizado o suscrito sin indicar al mismo tiempo su capital pagado. Esto se hace para **evitar confusiones**.
- ²Se prohíbe a los bancos extranjeros anunciar la cuantía de su capital y reservas de la matriz sin indicar al mismo tiempo la cuantía del capital y reservas asignadas a la agencia o sucursal en Chile. Es el mismo concepto, pero aplicado a los bancos extranjeros.

○ **Art 55**

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 55- *Los bancos podrán emitir bonos subordinados¹ que, en caso de liquidación de acuerdo al título XV de esta ley, se pagarán después de que sean cubiertos los créditos de los valistas, o serán capitalizados.*
(...)

- ¹Los bancos pueden emitir **bonos subordinados**.
- Los bonos son *instrumentos de deuda* en este caso emitidos por el banco, y subordinados al pago que debe hacer el banco.
- ¿Qué tiene que ver estos bonos en las normas sobre capital?
 - ✓ La LGB acepta una proporción de esos bonos que se computen como si fueran capital.

○ **Art 57**

TÍTULO IV – CAPITAL, RESERVAS Y DIVIDENDOS DE LOS BANCOS

Artículo 57- *Los bancos no podrán repartir dividendos provisorios.¹*

- En toda SA, los **dividendos** son las **utilidades que pueden ser repartidas por la SA a sus accionistas**.
- ¹Esta instrucción de no utilidades está sujeta a la **aprobación del balance** -cada 31 de diciembre-. Primero, se aprueba por el directorio primero, luego por la junta de accionistas, y, ahí se envía a la CMF.
- Ese es el procedimiento por el cual llegan las utilidades a los accionistas.
- Lo único que el directorio y la junta pueden acordar es que una parte de esos dividendos se distribuyan, y, otra parte se reinvierta en la empresa. Es una decisión que primero toma el directorio, pero en definitiva, es tomada por los dueños en la junta de accionistas.
- Los *dividendos provisorios* prohibidos en el art 57 se refieren a distribución de dividendos antes del balance, vale decir, durante el ejercicio.

- ✓ Esto está permitido en el resto de las SA con una gran limitación.
- ✓ Si la utilidad no llegare a producirse, los directores son responsables personalmente y con sus recursos de devolver a la empresa ese dividendo cuya utilidad no se produjo.
- ✓ Por lo tanto, en las SA, el directorio -quien es el que aprueba los dividendos provisorios- es bastante cuidadoso porque sabe que están asumiendo una responsabilidad muy grande si la utilidad que se iba a generar al final no se genera por distintas razones.
- ✓ En el caso de los bancos, la ley fue más allá y no permite los dividendos provisorios. Por lo tanto, solo pueden repartir **utilidades definitivas** (no provisorias). Éstas son definidas en el balance aprobado por el directorio y posteriormente por la junta.
- El legislador en la legislación de bancos siempre va un paso más allá de la Ley de SA. Entonces, muchas cosas que están permitidas en las SA abiertas están restringidas para los bancos.

V. TÍTULO V – CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA

- Este título hace referencia a recomendaciones de *Basilea*.
- Este capítulo clasifica los bancos según **gestión y solvencia**.
- Este tema es bien complejo.
- El art 60, 61 y 62 son claves, y provienen de *Basilea*.

○ Art 59

TÍTULO V – CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA

Artículo 59- La Comisión mantendrá permanentemente la clasificación de gestión y solvencia de los bancos, realizada conforme al procedimiento señalado en los artículos siguientes.¹

Esta clasificación deberá efectuarse periódicamente, y al menos una vez al año², por resolución fundada y se notificará a cada banco dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su realización,³ sin perjuicio de las actualizaciones que haga la Comisión cuando se acrediten cambios en las situaciones que motivaron las calificaciones anteriores.

- ¹Hay una clasificación -de gestión y solvencia- **permanente** de los bancos.
- ²Esta clasificación debe realizarse **periódicamente y al menos 1 vez al año**.
- ³Por resolución fundada de la CMF se notificará a cada banco dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su realización.
- **La idea es que siempre hay 1 clasificación al año, pero la CMF puede efectuar más clasificaciones si hay cambios importantes en el año bancario.**

○ **Art 60: Clasificación de bancos (categorías)**

TÍTULO V – CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA

Artículo 60- Los bancos se clasificarán en una de las siguientes categorías:¹

Categoría I: Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel A de solvencia y nivel A de gestión.²

Categoría II: Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel A de solvencia y en nivel B de gestión³, en nivel B de solvencia y en nivel A de gestión,⁴ o en nivel B de solvencia y en nivel B de gestión.⁵

Categoría III: Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel B de solvencia y por dos o más veces consecutivas en nivel B de gestión.⁶ Asimismo, estarán en esta categoría los bancos que se encuentren clasificados en el nivel A de solvencia y nivel C de gestión⁷, o en nivel B de solvencia y nivel C de gestión.⁸

Categoría IV: Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel A o B de solvencia y por dos o más veces consecutivas en nivel C de gestión.⁹

Categoría V: Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel C de solvencia cualquiera sea su nivel de gestión.¹⁰

- ¹Los bancos se clasifican en una de las siguientes categorías (I-V).
- Estas categorías son la mezcla de los 2 elementos tanto de gestión como de solvencia.
- Esta clasificación está intimamente vinculada con el capital mínimo que se requiere a partir de *Basilea*.
- 1. **Categoría I:**
 - ❖ ²A solvencia + A gestión
 - Es la categoría más alta porque incluye las categorías más altas de solvencia y gestión (A).
- 2. **Categoría II:**
 - ❖ ³A solvencia + B gestión
 - ❖ ⁴B solvencia + A gestión
 - ❖ ⁵B solvencia + B gestión
 - Se baja de A a B en solvencia, gestión o ambas.
- 3. **Categoría III:**
 - ❖ ⁶B solvencia + 2 o más veces consecutivas en B gestión²⁵
 - ❖ ⁷A solvencia + C gestión
 - ❖ ⁸B solvencia + C gestión
 - Ya baja a B repetidamente o C.
- 4. **Categoría IV:**
 - ❖ ⁹A/B solvencia + 2 o más veces consecutivas en C gestión
- 5. **Categoría V:**
 - ❖ ¹⁰C solvencia + A/B/C gestión
 - Por lo tanto, se le aplica una **importancia mayor a la solvencia que a la gestión**.
- La gran mayoría de los bancos chilenos se encuentran dentro de la categoría I,

²⁵ Las veces consecutivas deben ser anuales. NO se puede caer en una categoría más baja por estar 2 veces consecutivas en un mismo año.

por lo tanto, se considera que el sistema bancario chileno está en muy buenas condiciones.

- Si uno analiza otros países, hay muchos bancos bastante relevantes que se encuentran dentro de la II y III categoría.
- La categoría IV y V ya son bastante malas, incluso, algunos opinan que la CMF debiese liquidar a los bancos que estén en esas condiciones.

○ **Art 61: Criterios para clasificación de solvencia**

TÍTULO V – CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA

Artículo 61- Para los efectos de lo señalado en los artículos anteriores, los bancos se clasificarán según su solvencia en los siguientes niveles:¹

Nivel A: Instituciones que cumplen con las exigencias de capital básico y patrimonio efectivo a que se refiere el artículo 66², y que además satisfacen los requerimientos de capital adicional a que se refieren los artículos 66 bis y 66 ter.³

Nivel B: Instituciones que cumplen con las exigencias de capital básico y patrimonio efectivo a que se refiere el artículo 66, pero no con los requerimientos de capital adicional establecidos en los artículos 66 bis o 66 ter.³

Nivel C: Instituciones que no cumplen con las exigencias de capital básico ni con el patrimonio efectivo a que se refiere el artículo 66.⁴

- ¹Se clasifican en A-B-C según nivel de solvencia.
- La solvencia tiene parámetros otorgados por *Basilea*.
 1. **Nivel A:**
 - ❖ ²Cumplen con las exigencias de capital básico y patrimonio efectivo -del art 66- + cumplen requerimientos de capital adicional.
 2. **Nivel B:**
 - ❖ ³Cumplen con las exigencias de capital básico y patrimonio efectivo -del art 66- + NO cumplen requerimientos de capital adicional.
 3. **Nivel C:**
 - ❖ ⁴NO cumplen con las exigencias de capital básico y patrimonio efectivo -del art 66- + NO cumplen requerimientos de capital adicional.
- ²El art 66 entra la relación entre **patrimonio neto** -no de capital- y **activos riesgosos**.
- *Basilea* incluye el concepto de **capital adicional** a la fórmula que plantea.
- Los requerimientos de capital son proporcionales.
- Las circulares de la CMF determinan qué tan riesgoso es un activo. La LGB no podía estar colocando toda esa normativa reglamentaria.
- Pero, esas circulares son de los más complejo que existen porque se deben poner en una infinidad de situaciones que existen en la realidad.
- El nivel C hace que el banco sea automáticamente de categoría V.
- Resumen:

	Capital básico + patrimonio efectivo	Capital Adicional
Nivel A	✓	✓
Nivel B	✓	X
Nivel C	X	X

○ **Art 62: Criterios para clasificación de gestión**

TÍTULO V – CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA

Artículo 62- *Para los efectos de lo señalado en los artículos anteriores, los bancos se clasificarán según su gestión en los siguientes niveles:*¹

*Nivel A: Instituciones no clasificadas en los niveles B y C siguientes.*²

*Nivel B: Instituciones que reflejan ciertas debilidades en su gobierno corporativo, los controles internos, seguridad de sus redes, sistemas de información para la toma de decisiones, seguimiento oportuno de riesgos, clasificación privada de riesgo y capacidad para enfrentar escenarios de contingencia,*³ *las que serán corregidas por la propia institución durante el período que preceda al de la próxima calificación para evitar un deterioro paulatino en la solidez de la institución.*⁴ *También se considerarán las sanciones aplicadas a la empresa, salvo las que se encuentren con reclamación pendiente.*⁵

*Nivel C: Instituciones que presentan deficiencias significativas, en alguno de los factores señalados en el Nivel anterior, cuya corrección debe ser efectuada con la mayor prontitud para evitar un menoscabo relevante en su estabilidad.*⁶

*La Comisión, mediante norma de carácter general, establecerá las condiciones y modalidades necesarias para la implementación de esta clasificación.*⁷ *Tales normas deberán tratar en igual forma a los bancos que se encuentren en situaciones de características y naturaleza equivalentes.*⁸ *Del mismo modo, deberán considerar el cumplimiento de la normativa sobre infraestructura crítica de la información que, en materia de ciberseguridad, establezca la Comisión, con sujeción a la normativa legal vigente.*

- ¹Se clasifican en A-B-C según nivel de gestión.

1. Nivel A:

- ❖ ²Instituciones no clasificadas en los niveles B y C siguientes.
- ❖ Obvia la definición diciendo que todo lo que no es B y C, será A.

2. Nivel B:

- ❖ ³Instituciones que reflejan **ciertas debilidades** en su gobierno corporativo, los controles internos, seguridad de sus redes, sistemas de información para la toma de decisiones, seguimiento oportuno de riesgos, clasificación privada de riesgo y capacidad para enfrentar escenarios de contingencia.
- ❖ Vale decir, se da una serie de criterios de **debilidad en la gestión**.
- ❖ ⁴Estas debilidades deberán ser corregidas por la propia institución durante el período que preceda al de la próxima calificación para evitar un deterioro paulatino en la solidez de la institución.
- ❖ ⁵También se considerarán las sanciones aplicadas a la empresa, salvo las que se encuentren con reclamación pendiente.
- ❖ Por lo tanto, la ley aporta todos los criterios importantes, incluso, el sistema de redes que es importantísimo hoy en día en los bancos. Y, sobre esa base plantea un nivel B de gestión. Y, se le exige al banco en cuestión arreglar el problema antes de la próxima clasificación. Si no lo arregla, se produce una reiteración.
- ❖ Según *Yrarrázaval* el sistema está bastante bien construido, porque plantea ciertas observaciones que si los bancos arreglan antes de la

próxima clasificación, serán calificados como A, sino lo arregla, puede entrar en reiteración y ahí su clasificación puede venirse abajo.

- ❖ Esta información es pública, pero en sus aspectos fundamentales, NO en los detalles.

3. Nivel C:

- ❖ ⁶Instituciones que presentan **deficiencias significativas** en alguno de los factores señalados en el nivel anterior (B), cuya corrección debe ser efectuada con la mayor prontitud para evitar un menoscabo relevante en su estabilidad.

- ❖ Aquí cambia, porque en la letra B le dice que lo arregle, y, si lo tiene bien arreglado pasará a ser A. En cambio, en la letra C es mucho más lapidario, la corrección debe ser hecha con la mayor prontitud para evitar un menoscabo relevante en su estabilidad.

- ❖ Esto dice relación con las **medidas para regularizar situaciones complicadas de los bancos.**

→ La LGB incorporó hace 20 años aproximadamente un título nuevo que se llama “*medidas para regularizar a los bancos*” para que si se producen estas situaciones más extremas los bancos tengan posibilidad de arreglar la situación.

→ Hay 4 medidas para regularizar, pero a juicio de Yrarrázaval verdaderamente son 3 ya que la 4ta es la liquidación. Las 4 medidas son:

1. **Capitalización preventiva.** Es una de las medidas más importantes. Se le dice al banco que su problema está en el capital, entonces, debe llamar a un aumento efectivo de capital, y, si no lo llama o no se hace, ese banco va a entrar en liquidación.
2. **Capitalización por otros bancos.**
3. **Convenio de ese banco con los acreedores.** Pueden ser bancos extranjeros u otras instituciones.
4. **Liquidación.** No se está regularizando, sino que está liquidando.

- ❖ La letra C le dice al banco que “*tocó fondo*”, y la corrección de esa deficiencia se debe hacer con la mayor prontitud para evitar un menoscabo relevante en su estabilidad. Y, si se presenta este menoscabo relevante en su estabilidad, el banco está listo para ser liquidado.

- ⁷La **CMF**, mediante norma de carácter general, **establecerá las condiciones y modalidades necesarias para la implementación de esta clasificación.** Vale decir, aquí hay muchísima normativa que va surgiendo a partir de circulares de la CMF.
- ⁸Tales normas deberán **tratar en igual forma a los bancos que se encuentren en situaciones de características y naturaleza equivalentes.** Aquí se repite algo que está en la CPR que es un mandato para el BC, y, se refiere a que se deben tratar a todos los bancos por igual (art 109 CPR).

VI. TÍTULO VI – ENCAJE Y RESERVA TÉCNICA DE LOS BANCOS

- El encaje bancario (EB) sale del **dinero bancario o giral**.
- Este dinero giral como masa monetaria es espectacularmente grande porque se produce el **multiplicador bancario**.
- El EB se produce en relación con los **depósitos** por las captaciones.
- Entonces, todos los depósitos bancarios a nivel de todo el país están sujetos al EB.
- **El EJ está representado por un % establecido por el BC.** ¿Por qué no por la CMF? Porque es una **masa monetaria**, y por lo tanto, debe ser controlada por el BC.
- Tanto es así, que se considera que el EB es probablemente **el instrumento de política monetaria más rápido y eficaz**.
 - Algunos pueden decir que es el emitir más o menos dinero, dar más acceso a las tarjetas bancarias, etc.
 - Pero, en realidad es el EB porque éste surge **todos los días con respecto de todos los depósitos de todo el sistema bancario**.
 - Por lo tanto, el BC a través de un acuerdo del Consejo establece el % de EB de cada tipo de depósito.
 - Allí siempre se ha hecho la distinción entre depósitos a la vista y depósitos a plazo. El % de EB es distinto.
 - a) **Depósito a la vista:** <30 días. Los depositantes pueden retirar su dinero en cualquier momento, por lo tanto, deben tener % de EB mayores que los de a plazo.
 - b) **Depósito a plazo:** >30 días. Hoy en día, en la gran mayoría de los países, también se pueden retirar en cualquier momento, pero, con un castigo que consiste en que no se le pagan los intereses que iba a percibir. Esta sanción es bastante razonable para *Yrarrázaval*. Pero, esto no evita las corridas bancarias.
 - ✓ El período de 30 días es un plazo arbitrario utilizado en la mayoría de los países.
 - ✓ En resumen, el **% de EB del depósito a plazo < depósito a la vista**.
 - ✓ Pero, hoy en día las diferencias son tan mínimas que se hace difícil distinguir este criterio en la práctica. Por lo general, todos los depósitos oscilan en un rango de un 1%.
 - ✓ En Chile en este momento, el % está entre 3% y 4%.
- El EB tiene una connotación histórica, éste se creó en el sistema bancario para dar mayor seguridad al sistema, pero, hoy en día con los actuales % de EB, no le dan seguridad a ningún sistema bancario en el mundo. Hoy en día el EB se considera como un **instrumento de política monetaria**, con el cual libremente el BC toma la decisión del % de EB.
- Cuando ↑ tasa de EB ↓ masa monetaria giral.
- Cuando ↓ tasa de EB ↑ masa monetaria giral.
- El encaje viene de “*en caja*”. El concepto de *caja* está incierto en el art 63.

○ Art 63

TÍTULO VI – ENCAJE Y RESERVA TÉCNICA DE LOS BANCOS

Artículo 63- Las empresas bancarias y el Banco del Estado de Chile¹ deberán mantener, por sus depósitos a la vista y a plazo u obligaciones, los encajes que determine el Banco Central de Chile.²

- ¹No tiene por qué mencionar por separado al Banco de Estado porque tiene igual tratamiento que el resto de los bancos.
- ²Los bancos deben tener sus encajes en sus **propios bancos o depositados en el BC**. Hay varias opciones.
- Lo importante es que el banco **NO puede utilizar en forma alguna ese dinero para sus operaciones de colocaciones**.
- Tanto es así, que la LGB contempla **sanciones altísimas** para los bancos que se equivoquen en calcular su encaje aunque sea por pocos pesos.
- Los bancos extranjeros están sujetos a las mismas normas que lo demás bancos, por lo que se le aplica toda la normativa de la LGB salvo por ciertas excepciones mencionadas por la LGB, como por ejemplo no deben designar ni directorio ni junta, su capital es asignado a la agencia o sucursal, etc. Por lo tanto, no pueden guardar el dinero del encaje en su matriz.
- *Yrarrázaval* está de acuerdo con el criterio de igualdad de tratamiento de bancos existente en Chile. Dice que es un criterio muy sano porque en otros países con criterios distintos, se ha terminado con situaciones bastante complicadas.

- El art 64 y 65 son normas bastante más reglamentarias con respecto al EB.

VII. TÍTULO VII – RELACIÓN ENTRE ACTIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA

- ¿Por qué habla de *patrimonio* y no de *capital*?
- El patrimonio en su concepto general es lo que TIENE efectivamente una empresa o banco.
 - Pero, este concepto no le convence para nada a *Yrarrázaval* por que solo considera los activos, pero frente a éstos están los pasivos. Y, resulta que en los balances NO se mete al patrimonio en los activos.
 - Los activos se igualan con los pasivos, por lo que el patrimonio sería 0.
 - El concepto de ***patrimonio neto*** del que habla la LGB **es lo que se debe a los dueños, accionistas o socios del banco**. Y, esto está en los **PASIVOS** en un espacio separado, ya que eestán los pasivos que se deben a 3eros y los pasivos que se deben a dueños, accionistas o socios.
 - Estos pasivos están compuestos por 3 elementos relevantes:
 1. **Capital**. Lo que efectivamente se enteró.
 2. **Utilidades no repartidas**. Deben ser las que no se han distribuido entre los accionistas o socios. Si están repartidas ya no están dentro de la empresa.
 3. **Reservas bancarias**. Ejemplos:
 - ❖ *Incobrables*, es decir, los que tienen mucha morosidad. Este ejemplo de reserva bancaria es muy importante.

→ La LGB dice que si hay mucha morosidad, el banco tiene que realizar reservas que son incobrables hasta que se normalice la situación del banco, vale decir, en la medida de que pase la contingencia.

→ Esa reserva es parte del patrimonio.

→ Puede que esa reserva pase a ser utilidad -luego de la contingencia- como puede que no lo sea nunca.

❖ *Indemnización por años de servicios.*

→ Se debe ir calculando anualmente de acuerdo con el nº de trabajadores y la edad que tiene cada trabajador en esa empresa.

→ Esta reserva es bastante grande.

→ Si ninguno de los trabajadores puede acceder a la indemnización por años de servicios, pasa a ser utilidad de la empresa.

Las reservas se clasifican en:

a) **Reservas legales:** lo exige la ley.

b) **Reservas voluntarias:** lo hace la empresa por iniciativa propia.

→ ¿Por qué una empresa haría una reserva voluntaria, si en definitiva lo que quiere es la mayor distribución de utilidades posible conjuntamente con la reinversión? Porque quiere adelantarse a que si se produce alguna contingencia, existan los recursos suficientes para responder a sus obligaciones, y, no tenga que ir a pedir dinero prestado para responder.

○ **Art 66**

TÍTULO VII – RELACIÓN ENTRE ACTIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA

Artículo 66- *El patrimonio efectivo¹ de un banco no podrá ser inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo², netos de provisiones exigidas, o al mínimo que le sea exigible de acuerdo con los artículos 51, 66 quáter y 66 quinquies. El capital básico no podrá ser inferior al 4,5% de sus activos ponderados por riesgo, ni al 3% de los activos totales, ambos netos de provisiones exigidas.³*

*Se entiende por patrimonio efectivo de un banco la suma de los factores que se indican a continuación,⁴ con sus respectivas limitaciones:
(...)*

- ¹Patrimonio efectivo es lo mismo que *patrimonio neto*.
- ²El patrimonio efectivo de un banco no podrá ser inferior al 8% de sus activos ponderados por riesgo.
- La LGB está poniendo la relación entre **patrimonio efectivo** y **activos riesgosos**.
- ¿Por qué habla de una ponderación? Porque hay algunos activos que son mucho más riesgosos que otros.
- Las circulares de la CMF detallan todas las distintas situaciones.
- **Se pondera en función de lo que representa el riesgo en ese activo.**
- Puede que la ponderación sea muy alta, pero que la cantidad de activos que estén en esa condición sean muy pocos.
- ³En un 2º caso el **capital básico no podrá ser inferior al 4,5% de sus activos ponderados por riesgo, ni al 3% de los activos totales, ambos netos de provisiones exigidas.**

- *Basilea* está entregando 3 criterios distintos: 8%, 4,5% y 3%. **Todo depende del patrimonio neto o efectivo del banco en los respectivos % de los activos ponderados por riesgo.**
- ⁴El cálculo del patrimonio efectivo es muy complejo. Generalmente, ni los abogados bancarios lo entienden.

○ **Art 67**

TÍTULO VII – RELACIÓN ENTRE ACTIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA

Artículo 67- *Para efectos de determinar la ponderación por riesgo de los activos, la Comisión establecerá metodologías estandarizadas para cubrir los riesgos relevantes de la empresa bancaria¹, entre ellos, el riesgo de crédito, de mercado y operacional. Dichas metodologías se establecerán mediante norma de carácter general, previo acuerdo favorable del Consejo del Banco Central de Chile.*
(...)

- ¹Para efectos de determinar la ponderación por riesgo de los activos, la CMF establecerá metodologías estandarizadas -es decir, la misma para todos los bancos- para cubrir los riesgos relevantes de la empresa bancaria.

VIII. TÍTULO VIII – OPERACIONES DE LOS BANCOS

○ **Art 69**

TÍTULO VII – RELACIÓN ENTRE ACTIVOS Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA

Artículo 69- *Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones:¹*
(...)

- ¹Este art hace **una larguísima enumeración de las operaciones de los bancos.**
- En este momento son **27**, pero dentro de cada una a su vez hay varias operaciones, entonces, en realidad son mucho más.
- Este enumeración **NO es ejemplar.**
- Es muy curioso el art porque no dice que es una enumeración taxativa, sino que indica que los bancos *pueden* realizar ciertas operaciones, y, ciertamente es mejor que dijera “*solamente podrán*”.
- Esta enumeración se ha ido actualizando constantemente en el tiempo.
- Se le podría criticar a esta enumeración diciendo que no es muy buena porque constantemente van naciendo nuevas prácticas, por lo tanto, daría la impresión de que el legislador se está quedando atrás.
- Lo que hace el art 69 al decir “*podrán*” es decir que éstas son las **únicas operaciones que pueden realizar**, y, si realizan operaciones fuera de este art, serán **sancionados por la CMF.**
- Algunas operaciones prohibidas son:
 - ✓ Inversiones inmobiliarias. Está permitido en muchos países.
 - ✓ Ser dueños de AFP.
 - ✓ Etc.
- Así, se le está diciendo a los bancos que se dediquen a lo que siempre se ha considerado como operaciones bancarias. Pero, a nivel comparado esto se

empieza a complicar porque hay ciertos países que tienen un concepto amplio de operaciones bancarias, y otros países tienen un marco regulador como nuestro art 69.

- Si un banco realiza una operación fuera del listado, la CMF lo considera como fuera del giro bancario.
- Y, si el banco tuviera dudas de si esa operación calza o no con el giro, debe consultarla. Para eso existen las consultas. A lo largo de la historia, se han hecho muchas consultas respecto de las operaciones mencionadas en el art 69 porque la LGB no expresa claramente las operaciones a través de las palabras utilizadas.
- Y, si quiere que específicamente esa operación se mencione en el art 69, debe ir el Congreso y obtener una modificación de la LGB.
- El problema está con que hay varios países que no tienen un concepto tan acotado de las operaciones bancarias.
- Lo bueno del concepto acotado es que la seguridad del banco se podría ver afectada por una de estas operaciones nuevas no incluidas. Las nuevas operaciones son riesgosas, y, pueden debilitar al sistema bancario.
- Por lo tanto, la legislación chilena prefirió ser lo más conservadora en el sentido económico de la palabra. *Yrarázaval* considera que esta fue una buena solución para el sistema bancario.
- Fuera de la crisis del 80`, hemos tenido un sistema bancario muy estable, de hecho, ejemplarmente estable a nivel latinoamericano.
- El tema de la estabilidad es muy relevante porque el sistema afecta a miles y miles de personas -acreedores/depositantes-.
- A partir de esto, se creó la **garantía para los depósitos** (no existe garantía para los préstamos). El Eº es el que da esas garantías a personas naturales hasta un cierto monto y NO a personas jurídicas. Ojalá que el Eº no tenga que gastar recursos en esta garantía.
- El legislador debe elegir entre dar más **seguridad** o más **rentabilidad** al sistema bancario.
- *Saltamos la enumeración porque es de dº comercial.

28 de mayo

- A pesar de que es una materia comercial, tiene mucha importancia en el OPE porque afecta a miles y miles de personas, y por lo tanto, la SBIF/CMF debe regular la actividad.
- La enumeración aunque no lo dice el art, es taxativa.
- En otros países, no hay enumeración taxativa, sino que dice "*los bancos se dedican al giro bancario*".
- La CMF tiene que velar por qué desea más: SEGURIDAD VS EFICACIA.
- Como hay una enumeración taxativa en Chile, debe existir el mecanismo de la **CONSULTA**, que a juicio de *Yrarázaval* se ha utilizado en buena forma.
- Si hay operaciones que son reiteradamente consultadas por los bancos, induce a la CMF a que proponga esa operación a la próxima reforma de la ley.
- Entonces, el sistema no es tan dinámico como en otros países, pero, es muy seguro. Y, según *Yrarázaval* la seguridad en el sistema bancario chileno es algo

indudable y obedece al OPE.

- Las consultas se hacen interpretando las normas legales.
- Las consultas y sus respuestas son públicas.
- En Chile se ha dicho que cuando se absuelve favorablemente la consulta para el banco, se puede realizar la operación en los términos consultados.

IX. TÍTULO IX

PÁRRAFO 1º- SOCIEDADES FILIALES EN EL PAÍS

○ Art 70

TÍTULO IX – PÁRRAFO 1º- SOCIEDADES FILIALES EN EL PAÍS

Artículo 70- Los bancos pueden constituir en el país sociedades filiales destinadas a efectuar las siguientes operaciones o funciones:¹

a) Agentes de valores; corredores de bolsa; sociedades administradoras generales de fondos² a que se refiere la ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales; securitización de títulos y corredores de seguros regidos por el decreto con fuerza de ley N° 251 del Ministerio de Hacienda, de 1931, de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Las sociedades que realicen las operaciones a que se refiere esta letra serán regidas por las leyes aplicables a tales materias, serán fiscalizadas por la Comisión y deberán sujetarse a las condiciones que ésta establezca para el desarrollo de dichas actividades mediante normas de carácter general.
(...)

- ¹Los bancos pueden constituir **sociedades filiales con ciertos objetivos**.
- La sociedad filial se entiende como una **sociedad del banco pero que no es parte del banco, sino que es una sociedad que forma el banco**.
- La LGB dice que las sociedades filiales se pueden formar con ciertos objetivos. Y, aquí se da una ampliación del giro bancario porque son actividades que normalmente no se considerarían como parte del giro bancario, pero al permitirle al banco formar una sociedad filial para dedicarse a ciertas actividades, pasan a integrar el giro bancario.
- Aquí se da una **ampliación de las operaciones bancarias**, ya que al darle la posibilidad de crear esta sociedad, aumenta sus operaciones.
- Los casos de sociedades filiales son:
 - a) ²*Agentes de valores, corredores de bolsas, sociedades administradoras generales de fondos.*
- Estas sociedades son autorizadas por la CMF, por lo que si esta tiene alguna duda sobre su alcance o efectos sobre el banco, simplemente no la aprueba.
- Las operaciones que realiza la sociedad filial, son normadas por la CMF. Entonces, a pesar de no ser operaciones bancarias estrictamente hablando, este es un mecanismo bastante razonable a juicio de *Yrarrázaval* para ampliar las actividades bancarias a cosas que no son parte del giro bancario.
- Después, se consolida todo esto con el banco porque la responsabilidad del banco no es solo con el banco propiamente tal sino que también por estas filiales.
- Todas las sociedades están obligadas **hasta el monto de sus aportes**.
- Estrictamente, no es parte del giro bancario -porque no es captación o

colocación habitual de dinero-, pero, con esta modalidad que existe en Chile y otros países, se amplía el giro bancario a actividades que no son propiamente bancarias pero que si se permite que los bancos las realicen.

PÁRRAFO 2º- SOCIEDADES DE APOYO AL GIRO

○ **Art 74**

TÍTULO IX – PÁRRAFO 2º- SOCIEDADES DE APOYO AL GIRO

*Artículo 74- Los Bancos podrán, también, previa autorización de la Comisión, y cumpliendo los requisitos generales que para el objeto específico ella establezca mediante norma de carácter general, ser accionistas o tener participación en una sociedad cuyo único objeto sea uno de los siguientes:¹
(...)*

- ¹Las sociedades de apoyo al giro requieren autorización previa de la CMF y es 100% del banco.
- Estas sociedades de apoyo al giro pueden ser muchísimas. Por ejemplo, la entrega de tarjetas bancarias.
- Por lo tanto, ya sea una sociedad de apoyo al giro o una sociedad filial, tienen el mismo resultado. Éstas **amplían la actividad bancaria**, pero siempre con la normativa de la CMF y con la autorización de ésta.

X. TÍTULO X – OPERACIONES EN EL EXTERIOR

○ **Art 76**

TÍTULO X – OPERACIONES EN EL EXTERIOR

Artículo 76- Los bancos podrán abrir sucursales u oficinas de representación en el exterior, efectuar inversiones en acciones de bancos establecidos en el extranjero o en acciones de empresas allí constituidas que tengan alguno de los giros que autorizan los artículos 70 , 71, 72 y 74. Las aperturas de sucursales u oficinas de representación requerirán autorización de la Comisión. Las demás inversiones referidas necesitarán, adicionalmente, la autorización del Banco Central de Chile. Para estos efectos, una vez emitido su pronunciamiento, la Comisión remitirá los antecedentes al Banco Central de Chile.

- Se refiere a las operaciones de los bancos en el extranjero.
- **Es la actividad de los bancos constituidos en Chile en su actividad en el extranjero.**
- Tiene la misma concepción, vale decir, requiere de la **autorización de la CMF** y se rige bajo la **normativa de la CMF**.
- Los bancos chilenos constituidos en el extranjero pueden hacer lo mismo que los bancos extranjeros en Chile. En otras palabras, pueden:
 - a) **Adquirir acciones de bancos extranjeros**
 - ❖ El BCI recientemente en Miami compró un banco de Florida. Ese banco aún mantiene su nombre original. Lo mantienen porque tienen un buen nombre.

b) Crear agencias

- ❖ Ej: Banco de Chile en China. Esta instalado en China hace más de 5 años. Con respecto de esa agencia, operan los mismos criterios que para los bancos extranjeros instalados con agencia en Chile. Deben tener la autorización de las autoridades chinas en este caso, y, generalmente se lo va a tratar en la misma forma que a un banco chino.
- ❖ Como la casa matriz está en Chile, deben cumplir la normativa de la CMF al respecto. No porque estén en el extranjero no se ciñen a la legislación bancaria chilena.

c) Crear oficinas de representación.

- ❖ Pasa exactamente lo mismo.
 - ❖ Acá son bancos chilenos interesados en hacer operaciones de comercio exterior -especialmente los *acreditivos*-, y, por lo tanto, se instalan con la autorización de la autoridad respectiva en distintos países.
 - ❖ Los bancos chilenos tienen oficinas de representación en muchos países (Europa, USA, Asia, etc).
 - ❖ Éstos NO pueden captar ni colocar dinero.
 - ❖ Estas operaciones están vinculadas especialmente con las **inversiones**. Éstas se encuentran muy limitadas en Chile por una disposición de la ley que dice que el total de lo invertido en un banco no puede exceder el monto total de las operaciones bajo ciertos números.
 - ❖ ¿Por qué la legislación chilena es tan restrictiva en este aspecto no así como otros países? Por el RIESGO.
 - ❖ La CMF tiene amplias facultades al respecto. Le puede decir a un banco que le da la autorización para operar en tal país en la medida que realice en ese país solo las operaciones del art 69.
- ¿Las normas para un banco extranjero son iguales en todos los países o cada país va poniendo las suyas? No son iguales, pero se van asimilando cada vez más. Esto porque en definitiva en la legislación bancaria felizmente se ha llegado a ciertas estructuras, instituciones o normativas que deben existir en la legislación bancaria. Entonces, se van copiando de otros países.
 - Hay que recordar que nuestra legislación bancaria es del año 25`, e indiscutiblemente la actual es muchísimo mejor. Chile fue bastante pionero en incorporar una legislación bancaria con criterios totalmente distintos a los criterios anteriores aplicados en Chile y otros países, en donde los bancos se constituían por ley cada uno de ellos y por la normas que esa ley determinara.
 - Los bancos chilenos que desean constituirse en el extranjero, deben pedirle autorización a la CMF. Después, las operaciones están en la ley -las más importantes- o determinadas por la CMF.

LIMITACIONES DE CRÉDITOS

○ Art 84

LIMITACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 84- *Todo banco estará sujeto a las limitaciones siguientes:¹*

1) No podrá conceder créditos, directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo.² (...)

2) No podrá conceder créditos a personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente a la propiedad o gestión del banco en términos más favorables en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías que los concedidos a terceros en operaciones similares.³(...)

3) No podrá conceder, directa o indirectamente, crédito alguno con el objeto de habilitar a una persona para que pague al banco acciones de su propia emisión.⁴ (...)

4) En ningún caso una empresa bancaria podrá conceder, directa o indirectamente, créditos a un director, o a cualquiera persona que se desempeñe en ella como apoderado general.⁵(...)

5) No podrá adquirir sino los bienes que expresamente autoriza esta ley.⁶(...)

6) No podrá comprometer su responsabilidad por obligaciones de terceros, sino en los casos expresamente establecidos en esta ley o en las normas sobre intermediación de documentos.⁷(...)

- Este art es bien complejo. Lo que importa son los conceptos de los 6 n° del art. Cada uno se refiere a materias distintas, de hecho, podrían estar en art diferentes.

- ¹Todo banco estará sujeto a ciertas **limitaciones**:

1. ²No podrá conceder créditos, directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo.

❖ Es una prohibición total.

❖ Se refiere al patrimonio efectivo del banco.

❖ Esto es tanto en forma directa como indirecta.

→ Esto es un tema que se repite enormemente en dº comercial.

→ Para estos efectos, se considera no solamente la persona que solicitó el crédito -ya sea natural o jurídica- sino que todas sus familias, y, si se trata de una persona jurídica, incluye a cualquiera sociedad en la cual pueda tener algún control.

→ Por eso entonces, que cuando cualquier persona pide un crédito le hacen firmar un formulario donde está todo esto para efectos de este art.

→ Cualquiera falsedad en estas declaraciones tiene una fuertísima sanción porque entregaron información falsa para obtener un crédito que en caso contrario no lo habrían obtenido. Esta sanción recae en quienes le proporcionan información al banco que no es veraz (art 84).

❖ Luego, viene un largo desarrollo del número 1) porque se mete también en las **garantías** ofrecidas por las personas que piden préstamos y contiene un desarrollo inmenso respecto de esto.

→ Incluso, clasifica como garantías algo que en el dº civil no se considera como garantía, pero se considera como garantía para efectos bancarios.

→ Este número tiene un amplísimo desarrollo justamente por las garantías.

→ La garantía es vital para la **seguridad** del sistema bancario, por lo tanto, a mayor garantías se le permite al banco otorgar más préstamos a esa persona natural o jurídica. A menos garantías, menos préstamos. Y, a falta de garantías, generalmente 0 de préstamos.

→ Por lo tanto, este número está lleno de % y conceptos de garantías.

2. ***³No podrá conceder créditos a personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente a la propiedad o gestión del banco en términos más favorables en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías que los concedidos a terceros en operaciones similares.***

- ❖ Este número es aun más complicado que el N°1.
 - ❖ Este número se refiere a los **créditos relacionados**.
 - ❖ Es una normativa complicadísima porque se refiere a las relaciones entre el que pide préstamo con el banco.
 - ❖ Este tema se produce bastante porque los **dueños de las empresas también son accionistas de los bancos a los que le está pidiendo los préstamos**, incluye también a **familiares** de los accionistas del banco.
 - ❖ En términos bancarios, siempre se menciona “*directo e indirecto*”, por lo que siempre afecta a la persona y a sus familiares.
 - ❖ El concepto fundamental es que los créditos relacionados en Chile NO están prohibidos sino que están **REGLAMENTADOS**.
 - ❖ La gran condición de los créditos relacionados es de que **se pueden otorgar en la medida de que sean en las mismas condiciones que a cualquier otra empresa no relacionada**.
 - ❖ Entonces, lo que teme el legislador con toda razón es que cuando hay relaciones, se dan créditos en condiciones más favorables.
 - ❖ Aunque sean accionistas muy pequeños del banco, deben otorgarse los créditos en las mismas condiciones que a los demás.
 - ❖ Establece ciertos límites totales, pero el concepto de fondo es de que los créditos relacionados tengan las mismas condiciones que los demás.
- El N°1 y N°2 son los más complicados, y, son las que dieron inicio al juicio bancario más grande hasta el momento. Fue entre la **SBIF y Banco Corpbanca** (hoy en día Itaú).
 - Caso Corpbanca:
 - ✓ Todo esto está relacionado con las *sociedades cascadas de SQMCH*.
 - ✓ La SBIF aplicó la sanción más alta que se conoce en la historia por aplicación de una **circular**, porque la materia por la que estaba sancionando la SBIF, no estaba ni en el art 84 N°1 ni el 84 N°2. Por lo tanto, a través de una circular intenta aplicar esta sanción.
 - ✓ Efectivamente, la SBIF la aplicó porque tiene todas las facultades para hacerlo. La sanción era altísima (muchos millones de dólares).
 - ✓ *Corpbanca* fue primero a la Corte de Apelaciones, y, le ganó a la SBIF por el art 19 N° 21 de la CPR “*respetando las normas legales que la regulen*”. La CA lo que hizo fue aplicar el dº.
 - ✓ La SBIF tenía facultad para aplicar la sanción, pero, no podía hacerlo de un día

para otro. Es una sanción de carácter administrativo aplicado por la SBIF sin posibilidad de que el banco se defendiera, entonces, ¿dónde queda el debido proceso? El debido proceso debe aplicarse también a sanciones de carácter administrativo.

- Los números a continuación son de relativa menor importancia.

3. *4No podrá conceder, directa o indirectamente, crédito alguno con el objeto de habilitar a una persona para que pague al banco acciones de su propia emisión.*

- ❖ En otras palabras, se refiere a **los que están comprando bancos o participaciones en los bancos (acciones) no pueden hacerlo sobre la base de préstamos otorgados por otros bancos.**
- ❖ La razón de esto es histórica. La gran mayoría de los bancos que fueron liquidados en el 81'-82' (del orden de 15 bancos chicos) se habían financiado de esta forma.
- ❖ En aquel entonces no estaba prohibido como lo está actualmente.
- ❖ Los que formaban los bancos, se financiaban sobre la base de un préstamo obtenido de otro banco. Por lo tanto, estos bancos nacían débiles, continuaban siendo débiles, y, cuando se liquidaron, nadie tuvo ninguna opinión contraria ya que eran bancos que no habían podido adquirir una escala razonable para poder desarrollarse.
- ❖ Por lo tanto, la LGB incluye esta disposición para evitar que esto vuelva a ocurrir.

4. *5En ningún caso una empresa bancaria podrá conceder, directa o indirectamente, créditos a un director, o a cualquiera persona que se desempeñe en ella como apoderado general.*

- ❖ Lo que quiere evitar la ley es que el banco le de créditos a los directores o empleados apoderados del mismo banco. Lo pueden hacer de otros bancos, pero no del banco en el cual son directores o empleados apoderados.
- ❖ Se busca evitar que se otorguen préstamos más favorables para algunas personas.
- ❖ Se ve más evidente esto en los créditos relacionados.

5. *6No podrá adquirir sino los bienes que expresamente autoriza esta ley.*

- ❖ Se refiere al tema de las **inversiones**.
- ❖ Esto se da por el tema de **seguridad**.
- ❖ Entonces, en definitiva ahí está la norma que dice que en materia de inversiones no pueden exceder de tanto.
- ❖ Esto en la realidad es bajísimo afortunadamente -a juicio de Yrarrázaval- porque estamos dentro de un esquema de respeto al giro bancario y de respetar que las operaciones se realicen dentro del giro también a través de sociedades filiales y sociedades de apoyo al giro.
- ❖ Por lo tanto, los edificios que dicen "*Banco Security*" o "*Banco de Chile*" no son propiamente de ellos -es publicidad falsa-, sino que son financiamientos que ellos hacen. Esos bancos no son dueños ni de 1

metro cuadrado de ese proyecto inmobiliario. Por cierto que los bancos pueden financiar proyectos inmobiliarios, pero no se permite que el banco tenga inversiones propias fuera de los 4 números dentro del art 84 N°5 y con ese límite. Y, según los expertos bancarios esto les alcanza solamente para los edificios del banco, automóviles, computadores, etc.

- ❖ Pero, hay una **excepción** al N°5. En muchos casos los **bancos se adjudican bienes en remate** provenientes de deudas impagas.

→ Allí, efectivamente el banco pasa a ser dueño de esos bienes inmobiliarios que se adjudicaron, pero la LGB los obliga a venderlos dependiendo del tipo de bien dentro del plazo determinado.

6. ⁷No podrá comprometer su responsabilidad por obligaciones de terceros, sino en los casos expresamente establecidos en esta ley o en las normas sobre intermediación de documentos.

- ❖ Esto nos devuelve al tema de las garantías.
- ❖ El banco no puede dar garantías con respecto de terceros, sino que en muy pocos casos y contemplados en la LGB.
- A juicio de *Yrarrázaval* este art es el más difícil de la LGB porque contiene toda una normativa especialmente para el N°1 o N°2 que son muy difíciles, y, además circulares también muy difíciles.

COMISIONES DE CONFIANZA

○ Art 86

COMISIONES DE CONFIANZA

Artículo 86- Los bancos podrán desempeñar las siguientes comisiones de confianza¹: (...)

- Las comisiones de confianza es una de las tantas operaciones que pueden realizar los bancos.
- A juicio de *Yrarrázaval* es de bastante poca importancia en la actualidad.
- ¹Esta operación se refiere a que **una persona le puede entregar al banco la posibilidad de que le administre una parte de sus bienes o la totalidad de sus bienes sobre la base del pago de una comisión.**
- Esto es lo que en el dº anglosajón se denominan “*trust*”. Los *trust* son comisiones de confianza pero con otra envergadura totalmente distinta. El *trust* es una institución muy importante en el dº anglosajón, y, las comisiones de confianza son de muy poca importancia en el dº continental europeo.
- Esto se debe a que en el dº anglosajón se le permite al que administra esos bienes una amplitud no infinita, pero enorme de cómo sacarle la mayor rentabilidad a estos bienes. Eso es lo que quiere la persona que le entrega a otro la administración de los bienes. En cambio, en Chile las posibilidades que tiene el administrador -los bancos para estos efectos- están muy limitadas.
- ¿Por qué en el dº anglosajón han sido exitoso los *trust* y en el dº continental no mucho? (muy pocas personas lo entregan a comisiones de confianza).
→ En Chile existe la posibilidad de entregárselos a bancos de inversión de todo tipo, que obviamente tienen mayor conocimiento y expertis con respecto de

sacarle la mayor rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad que sacan los bancos comerciales con respecto a las comisiones de confianza son de las más bajas en el mercado financiero.

→ Esto se debe a que los mejores profesionales están en los bancos de inversiones y no en los bancos comerciales administrando las comisiones de confianza.

→ La gran diferencia con el sistema anglosajón es que la **responsabilidad en el sistema anglosajón es inmensa, y la responsabilidad en nuestro sistema es muy pequeña.**

→ Por lo tanto, en el sistema anglosajón se le da una gran posibilidad al administrador con respecto de todo tipo de operaciones financieras, pero con una gran responsabilidad. En cambio, en el sistema nuestro se le da muy poca amplitud y con poca responsabilidad.

- Esto está en la LGB por razones históricas, pero en realidad no debiese estar en la LGB sino que en una ley distinta que contemplara esto.
- Las comisiones de confianza y operaciones hipotecarias son los 2 casos de operaciones bancarias desarrolladas en la LGB.
- ¿Estas operaciones se limitan solo en el extranjero o para todo? *Yrarrázaval* no sabe la respuesta. Fuera de Chile, están dentro de una realidad totalmente distinta en cuanto a las operaciones.
- No sabe la respuesta sobre lo que pasa respecto de las operaciones fuera de Chile con respecto de las operaciones bancarias que exceden en mucho a lo que se remite en Chile.
- Aún así, La CMF siempre puede decir que no se realice una operación aunque ésta esté autorizada en el extranjero y prohibida en Chile.

OPERACIONES HIPOTECARIAS CON LETRAS DE CRÉDITO

○ Art 91

OPERACIONES HIPOTECARIAS CON LETRAS DE CRÉDITO

Artículo 91- El Banco del Estado y los demás bancos podrán conceder préstamos¹ (...)

- Se refiere al otorgamiento de préstamos para la obtención de bienes inmuebles.
- Se refiere a **proyectos inmobiliarios** con préstamos bancarios.
- Si hoy en día se analizan los préstamos a las personas, la gran mayoría van a préstamos inmobiliarios. Lo que no va a préstamos inmobiliarios va a préstamos de consumo, pero éstos representan un % muy inferior con respecto a los préstamos inmobiliarios.
- Ambos préstamos tienen características distintas.

INMOBILIARIO	DE CONSUMO
Son préstamos largos.	Son préstamos muy cortos.
Generalmente de 20-30 años. También se puede pedir un préstamo a 8 años pero es carísimo.	Generalmente a no más de 6 meses.

- Respecto de los créditos inmobiliarios:
 - ✓ Para los bancos esta operación es muy atractiva.
 - ✓ La **garantía es la propiedad adquirida**, por lo tanto, si el deudor hipotecario no llega a pagar el crédito -denominado *dividendo hipotecario* (no tiene nada de dividendo, sino que se refiere al *pago mensual que hace el deudor hipotecario al banco*)-, la propiedad entra en todo un proceso judicial con remate incluido.
 - ✓ Por lo tanto, la hipoteca sobre la propiedad es determinante para la otorgación del préstamo. Nunca se otorga por el 100% porque la casa se va devaluando. Lo que se valoriza es el sitio en el que está ubicada.
 - ✓ El procedimiento para ejecutar esta garantía es un poco lento -a juicio de *Yrarrázaval*- pero efectivo. En el sistema judicial hay muchos casos de estos, que en otros países se solucionan fuera del sistema judicial.
 - ✓ Estos créditos tienen bastante **riesgo** y han arruinado a ciertas personas que han contratado un préstamo hipotecario inadecuado. Es inadecuado en relación a los ingresos que tiene la familia. No se refiere a los ingresos actuales, sino a los que tendrán en un futuro, ya que éstos van disminuyendo.
 - ✓ Este es un tema difícil porque estos préstamos tienen una morosidad apreciable.
 - ✓ Todo este sistema se hace más complejo cuando el banco no se queda con el préstamo en definitiva, sino que lo vende a través de **letras hipotecarias**.
 - ❖ Lo que hace el banco es emitir letras que están basadas en la misma operación, pero en la cual se deshace del préstamo y emite una letra que puede ser comprada por cualquiera.
 - ❖ Es de los instrumentos financieros más codiciados en Chile.
 - ❖ Estas mismas letras bancarias generaron la última crisis mundial. Pero, en Chile estas letras se han pagado siempre, entonces no ha ocurrido lo que pasó en USA.
 - ❖ En Chile, el poseedor de esa letra hipotecaria tiene el dº de dirigirse en contra de quien no está pagando y tiene una buena rentabilidad por la hipoteca de toda la operación.
 - ❖ Se le debe notificar al deudor este cambio de acreedor. Tiene todo un procedimiento establecido.
 - ❖ La gran causa de la última crisis bancaria mundial se debe a estas compras de letras a nivel mundial. Los bancos compraban estas letras hipotecarias al precio que las clasificadoras de riesgo determinaban, y, resultó ser que

esta cartera hipotecaria de los bancos estaba podrida. Esta misma cartera después se transfería entre los bancos. Entonces, la cantidad de bancos contaminados con esta cartera podrida fue muy importante. Esto hace muy difícil toda la crisis.

XI. TÍTULO XIV – MEDIDAS PARA LA REGULARIZACIÓN TEMPRANA

- Anteriormente, este título se denominaba *medidas para la regularización bancaria*. Se modifica el nombre este año.
- Se refiere a **medidas de regularización**.
- Vienen 4 medidas -en definitiva 3- que son bien interesantes, pero totalmente distintas. Lo que pretenden es **regularizar una situación complicada de los bancos**.
- Las **medidas de regularización** mencionadas por la LGB son:
 1. **Capitalización preventiva**
 2. **Liquidación**
 3. **Insolvencia del banco**
 4. **Capitalización por otros bancos**
- La más importante de ellas es la 1ª que está en el art 112.

1. CAPITALIZACIÓN PREVENTIVA

○ Art 112

TÍTULO XI – MEDIDAS PARA LA REGULARIZACIÓN TEMPRANA

Artículo 112- Las empresas bancarias deberán informar a la Comisión en forma inmediata, a través de los medios que ésta instruya mediante norma de carácter general, si ocurriere cualquiera de las circunstancias siguientes:¹

(...)

ñ) Se haya detectado cualquier otro hecho indiciario de inestabilidad financiera o administración deficiente.²

- Se refiere a la **capitalización preventiva**.
- ¹Parte de una forma muy curiosa. Vale decir, parte de la notificación inmediata que debe hacer el banco que está con problemas a la CMF.
- Hay un largo listado de causales por el cual el banco debe informarle a la CMF de su situación. Tiene hasta la letra ñ).
- ²La letra ñ) dice que se debe informar cuando se haya detectado cualquier otro hecho indiciario de inestabilidad financiera o de administración deficiente.
- Lo que hace la LGB entre la letra a) – n), es decir, que en cualquier de esos casos hay **administración deficiente o inestabilidad financiera**.
- Es el mismo banco que debe asumir el problema e informar de inmediato a la CMF que se produjo uno de esos problemas establecidos en el art 112. Y, por si se le hubiera olvidado algún caso al legislador, lo fija en la letra ñ) diciendo cualquier otro hecho de inestabilidad financiera o administración deficiente.
- **Estos 2 conceptos son los que permiten a la CMF liquidar un banco**. Es por eso que lo incluyen dentro del ñ) para abarcar todos los casos.

- ¿No serán demasiado amplias las causales para liquidar un banco? ¿Será razonable que la CMF entre en un banco que tiene inestabilidad sin haberla informado?
 - ✓ La calificación genérica sólo le corresponde a la CMF, y, será el banco -en caso de liquidación- el que tendrá probar ante la CA que no es así.
 - ✓ El sistema funciona bien así.
 - ✓ La otra opción es establecer causales de liquidación, así, los bancos saben cuándo están mal. Pero, pasaría que serían muchos los bancos funcionando mal y que no serían liquidados.
 - ✓ La LGB lo que hace es entregárselo a la responsabilidad de los bancos.
 - ✓ Ahora, si no lo informa, lo que va a ocurrir es la liquidación del banco u otras sanciones que mencionaremos.
- Caso *Banco Nacional*:
 - ✓ Este es el caso más reciente.
 - ✓ El Banco Nacional hizo 2 operaciones el 28 de diciembre. Ambas operaciones se referían a la importación de naves desde Suecia.
 - ✓ Eran operaciones con acreditivos, y, en opinión de la SBIF era sospechoso de que a través de esas 2 operaciones el banco mejorara su balance al 31 de diciembre de forma considerable, pasando del rojo al azul.
 - ✓ Cuando se plantió esto, obviamente los dueños del banco cuestionaron a la SBIF diciendo que esto era totalmente arbitrario.
 - ✓ Este asunto no llegó a tribunales gracias a que otro banco le compró la cartera al Banco Nacional.
 - ✓ Esta cartera era tan compleja que hasta el día de hoy hay varios arbitrajes respecto a esto. Se debe a que en la compraventa de la cartera se contempló que podía ser revisado el valor de cada uno de los grandes préstamos de la cartera por un tribunal arbitrario.
 - ✓ *Yrarrázaval* cree que se resolvió en buena forma la situación.
 - ✓ Si no hubiera comprado la cartera otro banco, la CA hubiera fallado a favor de la SBIF porque eran 2 operaciones muy raras en las que no había intervenido el banco antes, que no intervienen generalmente los bancos, y, por los montos que se establecieron.
 - ✓ En cambio, en el caso del *Corpbanca* -a juicio de *Yrarrázaval* - la decisión de la CA fue muy acertada porque era un tema estrictamente jurídico.

29 de mayo

- En resumen, la 1ª medida para la regularización es la **capitalización preventiva**:
 - ✓ Trata de prevenir que un banco por escasez de capital entre en problemas mayores.
 - ✓ Por eso entonces, que es el propio el banco el que debe informar a la CMF de cualquier caso identificado en el art 112 hasta la letra ñ).
 - ✓ La ley en forma razonable -a juicio de *Yrarrázaval*- le entrega la responsabilidad a los bancos.

- ✓ Si no lo informa, se sanciona. La sanción más relevante es la liquidación del banco, pero, también existen otras sanciones.
- ✓ Luego, aparece como una pieza fundamental para la capitalización preventiva el **plan de regularización**.
 - ❖ A la SBIF/CMF se le debe presentar un plan de regularización, y, viene una infinidad de detalles respecto de este plan en la LGB.
 - ❖ Pero, como es una capitalización se requiere el **acuerdo de la junta de accionistas** del banco en cuestión.
 - ❖ Allí, se pueden presentar diversas situaciones, por ejemplo que los accionistas no estén de acuerdo en entrar en un plan de regularización, o, que los accionistas estiman que el pequeño aumento de capital es suficiente.
 - ❖ En todos estos aspectos, lo que prima es la **opinión de la CMF**, que tiene siempre pendiente la liquidación del banco.

2. LIQUIDACIÓN

XII. TÍTULO XV – LIQUIDACIÓN FORZOSA

PÁRRAFO 1º - DE LA LIQUIDACIÓN

○ Art 120

TÍTULO XV - LIQUIDACIÓN FORZOSA – PÁRRAFO 1º - DE LA LIQUIDACIÓN

Artículo 120- Los bancos sólo podrán ser sometidos a un procedimiento de reorganización o liquidación concursal regulado por la ley N° 20.720, que sustituye el Régimen Concursal vigente por una ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del Ramo, cuando se encuentren en liquidación voluntaria.¹ En todos los demás casos serán aplicables las normas del presente título, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 N° 11, 117 inciso sexto, y 136 de la presente ley.

- A partir del art 120 aparece la figura de **liquidación** propiamente tal del banco. A juicio de Yrrarázabal debiese ir al final de las medidas ya que no es una medida para regularizar, sino que simplemente liquida al banco.
- Esta disposición es muy importante y ha estado en la LGB por mucho tiempo.
- **¹Los bancos sólo podrán ser sometidos a un procedimiento de reorganización o liquidación concursal en los casos de liquidación voluntaria.**
- Lo que está diciendo la LGB es que **no procede la quiebra** -es decir, la reorganización o liquidación concursal- **cuando no es voluntaria** la liquidación.
- Pero, sería muy raro un caso de liquidación voluntaria en la cual se incurriera en esta situación. Entonces, no es que la ley diga que el banco no puede entrar en un proceso de reorganización o administración empresarial, pero está mencionando un caso que hasta el momento no se ha producido, y, se refiere a la liquidación voluntaria.
- En la liquidación voluntaria, los propios accionistas deciden que no van a continuar con el banco por distintas razones.
- Este es un tema mayor en materia bancaria porque hay algunos que argumentan que los bancos deben quebrar, y, hay otros que argumentan que los bancos no

deben quebrar. Esta es una discusión eterna, y, no solamente en Chile, sino que también se da en otros países.

✓ A favor de la quiebra: dicen que debe quebrar igual que cualquier otra SA o empresa en general. De esta manera, le asignan **igualdad de tratamiento** a los bancos que al resto de las SA, así, los riesgos los deben correr los dueños del banco. Argumentan relacionándolo con el **impacto** de la quiebra de un banco.

❖ En Chile, las demostraciones del impacto fueron menores, pero en otros países fueron grandes.

❖ El 13 de enero del 83` el Banco de Chile quebró pero a las autoridades se les ocurrió una solución bastante genial a juicio de *Yrarrázaval*. De esta manera, le designaron un **administrador provisional** como lo contempla la LGB. Éste se demoró 3 años para sacar al Banco de Chile de su situación de quiebra. Ahora, perdieron los accionistas del banco de Chile, pero, perdieron *sus aportes*. Por lo tanto, estos accionistas pierden su dº a voto en la junta, pero el banco sigue funcionando.

❖ En México, el sistema bancario quebró íntegramente hace 20 años porque los bancos estaban interrelacionados.

❖ Este también fue el penúltimo problema del sistema bancario en USA.

❖ Por lo tanto, si un banco mediano quebraba, terminaba arrastrando a casi todo el sistema bancario. Porque éste estaba endeudado con los bancos más grandes.

✓ En contra de la quiebra: los bancos son instituciones muy especiales dentro del OPE por lo que no se debiera dar el mismo tratamiento que al resto de las SA.

→ Indiscutiblemente aunque hay buenos argumentos para las 2 tesis, todo depende de lo que uno cree.

▪ ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la **quiebra y liquidación** de un banco? Es inmensa.

1. El liquidador es la SBIF y no el síndico de quiebra.

2. Los plazos de los síndicos son más acotados que los liquidadores (3 años con renovaciones sucesivas de 1 año).

3. Cualquiera liquidación de bancos es muy compleja porque hay una infinidad de acreedores enormes que tienen distintas preferencias.

4. Respecto del impacto para los acreedores, depende de dónde se ubique en las preferencias que tiene el acreedor. En los bancos, como son tantos los acreedores, si el acreedor no tiene ninguna preferencia, va a recibir 0. En cambio, en el caso de las demás SA, hay más posibilidades de obtener algo.

→ En Chile, generalmente en las quiebras por reorganizaciones lo que se obtiene es como el 20% de la credencia, y, eso va a depender especialmente de los 2 primeros acreedores, que son preferentes tanto en los casos de los bancos como en el resto de las SA ya que esta es una norma general. Estos 2 primeros acreedores son:

1º el **Fisco**, por tributos pendientes y cualquier otra multa o pendiente con el Fisco.

2º los **trabajadores**, por remuneraciones debidas, imposiciones debidas, etc.²⁶

- Pasamos de la *Ley de Quiebras* -que la tuvimos por muchos años- a la *Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas*. Esto es materia de dº comercial.
 - En Chile, incorporamos a nuestro sistema de quiebra conceptos del dº anglosajón. Algunos han funcionado muy bien, y, otros no tanto.
 - En el *sistema anglosajón*, se procura es que las empresas que llegan a esa situación de quiebra puedan seguir operando a través de un **administrador** designado por el sistema sobre un plan para recuperar esas empresas.
 - En cambio, en el *sistema continental* se tiene la idea de que la **quiebra es total**. La empresa que no sigue operando, muere. Pero, en quiebra o en liquidación sigue tratando de obtener el pago de cantidades que puedan aumentar la masa de bienes para pagar a los acreedores.
 - El cambio fue bueno según -Yrarrázaval- pero éste se hace entre 2 sistemas bastantes distintos, por lo tanto según Yrarrázaval hay algunos aspectos positivos y otros no tanto.
 - **Esto explica porque hoy en día NO se habla de la quiebra sino que se habla de la reorganización o liquidación.**
 - La **reorganización** se refiere a la implementación del administrador. Solamente se da a partir de una quiebra voluntaria del banco.
 - La **liquidación** es cuando está en una situación tan mala que se debe vender los activos que hay para poder pagárselos a los acreedores.

3. INSOLVENCIA DEL BANCO

○ Art 121

TÍTULO XV - LIQUIDACIÓN FORZOSA – PÁRRAFO 1º - DE LA LIQUIDACIÓN

Artículo 121- Si un banco cesa en el pago de una obligación, el gerente dará aviso inmediato a la Comisión, la que deberá determinar si la solvencia de la institución subsiste y, en caso contrario, adoptará las medidas que corresponda aplicar de acuerdo con la ley.¹ Lo anterior es sin perjuicio del derecho del acreedor afectado para recurrir a la Comisión con este objeto.

- ¹Este art habla sobre la 3º medida de regularizar a los bancos. Se refiere a la **insolvencia del banco**.
- La insolvencia desde el punto de vista jurídico, NO existe, sino que es una situación de hecho, económica.
- La insolvencia se refiere a la **imposibilidad de pagar obligaciones**.
- Esa imposibilidad puede ser muy temporal -de un día por ejemplo- o, puede ser con respecto de una deuda ínfima -por ejemplo de la cuenta de la luz-. Por lo

²⁶ Esto explica la situación del Club de la U y del Colo-Colo. Antes de que se constituyeran como SA, estaban totalmente quebrados, y, el 1º acreedor que tenían era el Fisco. Entonces, los pdtes de los clubes visitaban al pdte de la República para que el Fisco no le cobrara ya que si les cobraba, iban a tener que cerrar.

tanto, lo que hace la LGB con respecto de la insolvencia es **regularla** para que se reúnan todos los acreedores, y, esto será exitoso o un fracaso en la medida que algunos de ellos o todos ellos le den mayores plazos, mejores condiciones o incluso, renuncien a sus créditos. Por lo tanto, estas **juntas de acreedores** en el caso de la insolvencia son tremendamente complicadas porque para sacar a la empresa de la situación en la cual está, se debe renunciar a algo o dar mayores plazo de pago. Porque la empresa se encuentra en insolvencia y no está en condiciones de efectuar pagos importantes. Allí, empieza una pelea entre los distintos acreedores porque todos tienen distintas acreencias por distintos conceptos, con distintos plazos, con distintos intereses, etc. Por lo tanto, al final es la mayoría en la junta de acreedores los que tienen que aceptar los nuevos términos de estos créditos que tienen en relación con la empresa en cuestión. Y, si no se obtiene esa mayoría, fracasa este intento de resolver la situación.

- Esta situación está tratada en normas generales, en la Ley de Reorganización, y en el caso de los bancos se trata con normas todavía más exigentes que la Ley de Reorganización.

4. **CAPITALIZACIÓN POR OTROS BANCOS**

- Esta es muy complicada porque esta capitalización por otros bancos es la que puede producir un **efecto en cadena**.
- Por tanto, se contempla la posibilidad de capitalizar por otros bancos, pero está llena de limitaciones.
- Dentro de esta normativa, hay ciertas medidas que puede tomar la SBIF/CMF con respecto de todos los bancos. Son 3:
 - a) **Prohibición de realizar determinadas operaciones bancarias**
 - ❖ La ley enumera todas estas medidas, la regla general es que se puedan aplicar por 6 meses, renovable por otros 6 meses.
 - ❖ Pero, es una medida muy extrema. Tan extrema, que si está mal planteado con respecto a la situación de ese banco, puede ser que hunda más al banco.
 - ❖ Felizmente, la autoridad en Chile no las ha aplicado porque a juicio de *Yrarrázaval* es muy complicada su aplicación, y, además estas prohibiciones van a ser conocidas en el mercado bancario.
 - b) **Administración del banco por parte de la SBIF**
 - ❖ Esta medida se implementa en la **reorganización** del banco cuando el banco se declara voluntariamente en quiebra.
 - ❖ Estas fueron precisamente las medidas que se aplicaron el 13 de enero de 1983 en *el Banco de Chile*.
 - ❖ Esto significa que la administración del banco recae en manos de la SBIF y el superintendente designa quiénes van a ser las personas naturales que van a tomar la administración del banco.
 - ❖ Esta medida NO afecta a los accionistas, ellos no están perdiendo. Pero, la SBIF está tomando el control de la administración del banco.

- ❖ Cuando se tomaron estas medidas hubo una discusión entre algunos que lo consideraron una medida muy inapropiada y otros que la calificaban de muy apropiada. Va a depender de lo que pase desde el momento en que se tome la medida hasta que se devuelva la administración.
- ❖ En el caso chileno felizmente a juicio de *Yrarrázaval* esto fue muy exitoso. La SBIF designó a personas que sabían mucho de bancos, muy criteriosas y que después de un gran esfuerzo pudieron sacar al *Banco de Chile* de la situación en la que estaba.
- ❖ La SBIF es la que designa al administrador, e incluso puede designar a personas de la propia SBIF. La única forma de sacar al banco de esa situación, es que el administrador sea una persona muy calificada.
- ❖ La SBIF determina la remuneración del administrador. *Yrarrázaval* considera que en el año 83` se asignó una remuneración buena pero nada exagerada.
- ❖ El tema es aún más delicado porque los directores dejan su cargo y el administrador está tomando decisiones solo (con toda la asesoría que el quiera) pero no es nada de fácil.
- ❖ Obviamente que si los administradores no son bien designados es un desastre. Esta situación es muy delicada, por lo que la calidad de los administradores es fundamental.
- ❖ *Banco de Chile*: salió de la situación debido al **capitalismo popular**, vale decir, gracias a una capitalización por parte de cualquiera que estuviera interesado en comprar acciones en muy buenos términos. Eso se produjo en el año 85`-86`. Pero, toda la labor de limpieza del banco la hicieron los administradores entre el 83`-85`.

c) Inspector delegado

- ❖ *Yrarrázaval* no cree en ella porque implica que la SBIF envía fiscalizadores al banco en cuestión para que supervisen la toma de decisiones.
- ❖ Hace 50-100 años atrás se habría podido haber hecho, pero, hoy en día es imposible. Para *Yrarrázaval* es una irrealidad para el s.XXI y parte del s.XX ya que esta toda la información en formato digital y la SBIF la puede analizar. Pero, suponer que 1 o más personas por su presencia física en el banco le van a entender las miles de operaciones que se están realizando, es imposible. Incluso, para el administrador es difícil, y a éste lo toma tiempo enterarse cabalmente de los problemas serios que tiene el banco.
- ❖ En algunos países, estos inspectores de la SBIF han sido el germen más importante de corrupción en los bancos.
 - Por ejemplo, en Brasil llegan los inspectores, se sientan en la oficina del gerente general y se quedan ahí hasta que les paguen para que se vayan.
- ❖ Por más de que estén físicamente presentes, no van a poder tomar decisiones.

- ❖ La diferencia entre el *administrador* y el *inspector* es que el 1º reemplaza al gerente, mientras que el inspector no reemplaza a nadie, y, lo único que puede hacer es suspender alguna decisión a nivel del directorio o de la gerencia.

PÁRRAFO 2º- DE LOS DELITOS CONCURSALES BANCARIOS

- Se regula en los art 141-143.
- Después vienen los *delitos bancarios* (NO son iguales a los *delitos concursales bancarios*).
- Aquí se establecen una cantidad de delitos que son muy parecidos a los delitos de *reorganización y liquidación*.
- Ejemplo *delito bancario*: si los directores o gerentes reconocen deudas inexistentes.
- Ejemplo *delito concursal bancario*: si los directores o gerentes simulan enajenaciones.
- Son una serie de delitos que tienen una sanción muy fuerte porque es la que genera parte o buena parte del problema en el banco. Son puros actos en donde se está afectando el patrimonio del banco.

PÁRRAFO 3º - GARANTÍA DEL ESTADO

- **Art 144**

TÍTULO XV - LIQUIDACIÓN FORZOSA – PÁRRAFO 3º - GARANTÍA DEL ESTADO

Artículo 144- *Otórgase la garantía del Estado a las obligaciones provenientes de depósitos y captaciones a plazo, mediante cuentas de ahorro o documentos nominativos o a la orden, de propia emisión de bancos.¹ Dicha garantía favorecerá solamente a las personas naturales.²*

El conjunto de depósitos y captaciones amparados por esta garantía que un acreedor tenga en un banco, se considerará como una sola obligación para los efectos previstos en este párrafo.³

- Se refiere a la **garantía del Estado**.
- ¹La garantía del Eº está solamente referida a las **captaciones** y NO a las colocaciones. Las mencionadas en el art son distintos tipos de captaciones.
- ²Solo se otorgará a **personas naturales** porque se quiso **limitar la garantía del Eº** pues esta puede ser en un momento determinado **muy cara** para el Fisco.
 - ✓ Caso México: la garantía del Eº le costó carísimo al fisco porque no estaba limitada.
- ³Luego, la norma dice que todos los depósitos que puede tener una persona natural, se **contabilizan como una sola**, con el fin de limitar la garantía.

- **Art 145**

TÍTULO XV - LIQUIDACIÓN FORZOSA – PÁRRAFO 3º - GARANTÍA DEL ESTADO

Artículo 145- *Ninguna persona podrá ser beneficiaria de esta garantía en una misma empresa bancaria por obligaciones superiores a 200 unidades de fomento en cada año calendario.¹*
(...)

- ¹Se limita la garantía a **200 UF** en cada año calendario. Son 5.500.000 aprox.

- Es por eso que a partir de la crisis que tuvimos en la primera mitad de la década del 80` viene la exigencia de la SBIF que dice “*infórmese de la garantía estatal*”.
- Las garantías estatales en materia bancaria son caras por el riesgo, y por lo tanto, prácticamente todos los países tienen limitaciones a estas garantías.
- Ahora, hay otras posibilidades con respecto de garantías bancarias. Otra posibilidad sería que el mismo banco la ofreciera. Podría ser atractivo para alguien que está depositando que tenga una garantía además de la estatal. Pero, esto también es carísimo.
- La 3ª posibilidad es que el mismo ahorrante o depositante tome una garantía, pero eso obviamente también es caro y hace poco atractivo depositar en un banco.

XIII. TÍTULO XVI – SECRETO BANCARIO Y OTRAS NORMAS

- Luego, viene una norma importantísima sobre el **secreto bancario**.
- La norma chilena es tan difícil como la gran mayoría de las normas en otros países.
- Hay ciertos países en que el secreto bancario es absoluto. Ej: en Suiza era absoluto y hoy en día es mucho menos.
- Han estado disminuyendo cada vez más los países que tienen secreto bancario absoluto o casi absoluto por presión de lo demás países. Porque a pesar de ser muy razonable el secreto bancario -a juicio de *Yrarrázaval*- se puede prestar para lavado de dinero, para tráfico de armas y para otras cosas por el estilo.
- Por lo tanto, a nivel mundial si hay algunos países que tienen secreto y otros que no lo tienen, los perjudicados son los países que no lo tienen.
- La economía suiza sin el secreto bancario, sería una economía totalmente distinta (mucho menor a la actual).
- **Art 154**

TÍTULO XVI – SECRETO BANCARIO Y OTRAS NORMAS

Artículo 154- *Las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos en virtud de la presente ley estarán sujetas a secreto bancario¹ y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente.² El que infringiere la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.³*

Las demás operaciones quedarán sujetas a reserva⁴ y los bancos en virtud de la presente ley solamente podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo⁵ y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda ocasionar un daño patrimonial al cliente.⁶

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los casos en que la Comisión, en virtud de lo establecido en el numeral 35 del artículo 5 de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, deba remitir antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero, pudiendo en dichos casos enviarle la información bancaria sujeta a reserva que le fuere necesaria a dicha Unidad para evaluar el inicio de uno o más procedimientos administrativos en los términos señalados en el Título II de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero.⁷

Asimismo, con el objeto de evaluar la situación del banco y sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del presente artículo, éste podrá dar acceso a firmas especializadas del detalle de las operaciones que allí se señalan y sus antecedentes. Dichas entidades quedarán sometidas a la reserva establecida en el precitado inciso y deberán estar aprobadas por la Comisión e inscritas en el registro de carácter público que la Comisión abrirá para estos efectos.⁸

La justicia ordinaria y la militar, en las causas que estuvieren conociendo, podrán ordenar la remisión de aquellos antecedentes relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso, sobre los depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza que hayan efectuado quienes tengan carácter de parte o imputado en esas causas u ordenar su examen, si fuere necesario.⁹

(...)

La omisión total o parcial en la entrega de dichos antecedentes podrá ser sancionada por la Comisión de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.¹⁰

	Secreto bancario	Reserva Bancaria
Ubicación	¹ Inc 1	⁴ Inc 2
Tipo de operaciones	¹ Rige solamente para las operaciones de depósitos y captaciones (depósitos y captaciones se refieren a lo mismo). Las colocaciones NO tienen secreto bancario.	⁴ Rige para las demás operaciones, es decir, para las colocaciones .
Consecuencias jurídicas	² NO se puede proporcionar antecedentes relativos de esas operaciones sino al titular y su representante legal .	⁵ El banco solo podrá darlo de conocer a quien demuestre un interés legítimo . ⁶ Y, siempre que no sea previsible en la reserva que el conocimiento de los antecedentes pueda causar un daño patrimonial al cliente.
Sanción	³ Quien lo infrinja será sancionado con penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Se refiere a la infracción de la obligación que tienen los bancos comerciales sobre los depósitos.	¹⁰ También tiene sanción.

- Lo importante a juicio de *Yrarrázaval* son las **consecuencias jurídicas** del secreto y de la reserva.
- ¿En qué caso puede ser muy importante para un 3º obtener información de las colocaciones en un determinado banco?
 - Por ejemplo, en **disputas familiares**.
 - El caso judicial (de investigación policial) tiene excepciones, vale decir, no tiene igualdad de tratamiento.
 - La persona le debe demostrar al banco su interés legítimo.
 - Los abogados de los bancos deben hacer 2 análisis complejos para observar si se cumplen los 2 requisitos que permiten obtener la información que tiene reserva bancaria:
 1. Discernir si hay un interés legítimo o no.
 2. Discernir si el conocimiento de esos antecedentes puede generar un daño patrimonial al cliente o no.
 - Luego, vienen las **excepciones** que son en sentido estricto, vale decir, no se pueden ampliar porque son excepciones dentro del OPE que contemplan secreto y reserva bancaria. Parten en el inc 3 del art 154. Las excepciones son:
 1. **⁷Unidad de análisis financiero.**
 - ❖ Esta unidad existe en Chile más o menos hace 10 años.
 - ❖ Se creó fundamentalmente para lavado de dinero, tráfico de armas y cosas por el estilo.
 - ❖ Lo que se hace la unidad de análisis financiero es *investigar el uso de los dineros y ver si a través de ese uso se puede estar financiando lavado de dineros, corrupciones, tráfico de armas, etc.*
 - ❖ Entonces, no es que la unidad de análisis financiero esté por encima de la CMF, sino que está realizando su papel en áreas específicas en la cual necesita de la información particular de los préstamos de determinadas personas.
 2. **⁸Análisis hecho por firmas especializadas a los bancos.**
 - ❖ Estas son firmas de auditoría que están inscritos con la CMF por las que un banco en particular o la CMF le puede pedir un análisis de casos particulares.
 - ❖ Por lo tanto, estas firmas que están analizando situaciones particulares pueden dar a conocer la información, pero, con una gran calificación que es que la información que obtienen es para la auditoría específica que están haciendo, vale decir, se les traspasa a ellos la reserva desde el punto de vista bancario. Y, la firma de auditoría no puede dar a conocer a 3º que no sean el banco ni la CMF la información que obtienen.
 3. **⁹Justicia en las causas que estuvieren conociendo.**
 - ❖ Esta es la excepción más recurrente.
 - ❖ Se refiere a la justicia solo en las causas que estuvieren conociendo, vale decir, alguien no puede ir a la justicia a decir que necesita la información con respecto de X persona. Debe ser respecto de una causas específica que está conociendo.

- ❖ Sirve para que se remitan antecedentes relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso.
- ❖ El caso más recurrente es el del juicio de alimentos, porque es esa información la que le va a permitir al juez conceder un monto mayor o menor.

XIV. TÍTULO XVII – SANCIONES PENALES

- Aquí de partida, uno se pregunta si estarán bien ubicados estos delitos. Uno pensaría que debieran estar en el Código Penal porque aunque son delitos bancarios, los resuelve la justicia penal NO la CMF.
- Hay algunos países que tienen en su Código Penal todo un capítulo dedicado a delitos económicos. Sería más ordenado. Pero, *Yrarrázaval* no está de acuerdo con esa técnica porque los delitos hay que entenderlos en el tenor de la ley sustantiva.
 - Por ejemplo, el delito de colusión no se entiende sino que dentro de la Ley de LC.
 - ✓ Desde el s.XIX estaba en el Código Penal como *cualquiera manipulación artificial de precios*. Esto produce muchísimos problemas porque puede afectar la delación compensada.
 - ✓ La vez que el Ministerio Público lleva a los ejecutivos de farmacias por este tipo penal a los Tribunales Penales le fue pésimo porque no tenían buenas pruebas para la sanción penal.
 - ✓ La probanza en materia penal es la más exigente de todas ya que está de por medio la libertad de las personas.
- Estos delitos penales deben ser conducidos por el **Ministerio Público**.
- **Art 157**

TÍTULO XVII – SANCIONES PENALES

Artículo 157- Los directores y gerentes de una institución fiscalizada por la Comisión¹, en virtud de esta ley que, a sabiendas, hubieren hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la empresa, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su situación,² especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados, serán castigados con reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales.

- Todos los señores que han hechos estafas no están dentro de este caso porque se encuentran fuera del sistema (no están fiscalizados por la CMF).
- ¹Se aplica a **directores y gerentes**.
- Lo que le importa al legislador es la veracidad de una infinidad de declaraciones que están haciendo los directores y gerentes todos los días.
- 2 elementos fundamentales:
 1. ²Debe ser **a sabiendas**, esto NO es por ignorancia o porque le pasaron el papel para que firmara sin tener conocimiento de lo que estaba firmando.
 - ❖ La 1ª defensa del afectado en estos casos va a ser que no es sabiendas.
 - ❖ Caso Banco de Chile: la SBIF demandó a los ejecutivos más altos del *Banco de Chile* -a raíz del 13 de enero de 1983- por distintas operaciones que según ella eran sospechosas. La defensa de los ejecutivos fue

espectacular -a juicio de *Yrarrázaval*- sobre la base de que le mostraba el balance del *Banco de Chile* en donde esas operaciones eran informadas año tras año. La SBIF alegó que objetivamente se había incurrido en una infracción. Algunos ejecutivos terminaron en la cárcel por poco tiempo. Y, fue muy poca la sanción con respecto a la pedida por la SBIF.

2. En las declaraciones de directores y gerentes recae toda la **eficacia** de todo el sistema de operaciones bancarias.
- Todos los temas sobre la cual no puede haber declaración falsa son importantes: el capital del banco, un balance adulterado o falso, etc. Son situaciones objetivamente muy relevantes para el buen funcionamiento de un banco.

○ Art 158

TÍTULO XVII – SANCIONES PENALES

Artículo 158- *Los accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de una institución sometida a la fiscalización de la Comisión¹, en virtud de esta ley que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercer a la Comisión de acuerdo con la ley,² se les aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.*
(...)

- ¹Es una sanción aplicable para los **directores y gerentes** (al igual que el art 157), pero, lo amplía a **empleador o auditores externos**.
- ²Se sanciona a los que **alteren o desfiguren datos con la finalidad de desviar o eludir la fiscalización que corresponde por parte de la CMF**.

○ Art 160

TÍTULO XVII – SANCIONES PENALES

Artículo 160- *El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución,¹ sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.*

- ¹Se refiere a los que **piden créditos/préstamos a las instituciones bancarias**.
- ²Se sanciona a los que **suministren o proporcionen datos falsos o maliciosamente incompletos**.
- ¿Por qué existe esta figura para la solicitud de préstamos? Porque es la única forma que tiene la ley para darle mayor seguridad al sistema.
- Se ha aplicado relativamente poco, pero, se aplica cuando hay algunas personas que mienten descaradamente para recibir un préstamo.

LEY DE MERCADO DE VALORES (LMV) (LEY 18.045)²⁷

- Esto es materia de dº comercial, pero, tiene expresiones del OPE que son bien importantes por lo que es necesario estudiarla.
- Esta es una ley bien compleja.
- En el art 182 aparece que las normas de la ley de seguros priman sobre los estatutos y sobre los contratos que tengan cláusulas distintas, entonces claramente es de OP, en donde obviamente la ley y la autoridad (CMF) dan flexibilidades, vale decir, una serie de aspectos en cada una de las instituciones que están en la LMV para que las empresas se muevan libremente. Entonces, es lo mismo que vimos con la LGB pero bastante más reducido.
- Nos vamos a enfocar en determinados aspectos en donde el OPE está presente.
- Respecto a la historia de la ley:
 - La LMV es del año 81`, pero se ha ido modificando permanentemente. Se modifica generalmente por nuevas instituciones que se van agregando a la ley.
 - La ley durante mucho tiempo tuvo del orden de 70 artículos. Hoy en día, tiene 249 artículos. Esto demuestra que el mercado de valores (MV) se ha ido sofisticando cada vez mas, y, por lo tanto, ha obligado al legislador a incorporar nuevas instituciones, y, a juicio de *Yrarrázaval* lo ha hecho relativamente bien.
 - Antes del 81`, ocurría muy poco, vale decir, habían pocas normas referidas a valores, y éstas estaban dispersas en distintas leyes.
 - Entonces, la LMV las reordenó dentro de lo que es la primera mitad de la LMV, y, después se fueron agregando nuevas instituciones.
 - La regulación de valores NO comenzó el 81` sino que partió con la *misión Kemmerer*, pero como un apéndice de la Superintendencia de SA y de la Ley de SA. Esta ley contenía los primeros esbozos con respecto de valores.
 - Esto se debe a que en aquel entonces el MV era infinitamente chico, y, por lo tanto, la Superintendencia de SA controlaba a las agencias de SA extranjeras, a las bolsas de valores y a los valores.
 - Por esto se explica que la Superintendencia de SA fuese sustituida en el 81` por la SVS, y, actualmente por la CMF.
 - El MV tuvo su mayor desarrollo a partir de la década del 80`, por lo tanto, lo que vino a ser la LMV en el año 81` fue adelantarse en cierta medida a un mercado que era cada vez más relevante.
 - **¿Qué pasó con las SA?** En la Ley de SA se introdujo un tema de valores muy relevante que se refiere a la distinción entre SA abiertas y SA cerradas. El tema societario queda mucho más vinculado a las SA cerradas. Las abiertas, en su gran mayoría, caen dentro del tema de valores de la LMV porque emiten instrumentos al público.²⁸ La gran mayoría de las SA abiertas emiten valores, y, por lo tanto, la gran mayoría de

²⁷ La ley 18.046 es la Ley de SA.

²⁸ Requisitos para ser SA abiertas (con cualquiera de ellos, NO son copulativos):

1. Más de 500 accionistas
2. 100 accionistas controlan más de un 10%
3. Emitir instrumentos al público

éstas caen dentro del control regulatorio por el lado de valores.

I. TÍTULO I – OBJETIVO DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

- En 5 artículos intenta resolver cuál es el **ámbito de aplicación** de la ley y da una serie de **definiciones** con respecto de valores que son fundamentales.

○ Art 1

TÍTULO I – OBJETIVOS DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1- A las disposiciones de la presente ley queda sometida la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios¹, los que comprenden las bolsas de valores², los corredores de bolsa y los agentes de valores; las sociedades anónimas abiertas; los emisores e instrumentos de oferta pública y los mercados secundarios³ de dichos valores dentro y fuera de las bolsas,⁴ aplicándose este cuerpo legal a todas aquellas transacciones de valores que tengan su origen en ofertas públicas de los mismos o que se efectúen con intermediación por parte de corredores o agentes de valores.

Las transacciones de valores que no sean de aquellas a que se refiere el inciso primero del presente artículo, tendrán el carácter de privadas y quedarán excluidas de las disposiciones de esta ley, excepto en los casos en que ésta se remita expresamente a ellas.⁵

- ¹Quedan sujetos a la ley:
 1. Oferta pública de Valores
 2. Mercados de Valores (MV)
 3. Intermediarios de Valores
- ²Las bolsas de valores están tratadas con lujo detalle en la LMV.
- ³Un **mercado secundario** (contrapuesto al concepto de **mercado primario**) en materia de valores se refiere al que **NO corresponde al emisor**.
- Cuando el emisor está emitiendo bonos, etc y los ofrece al público es el **mercado primario**, pero después todas las ventas que se hacen sucesivamente corresponden al *mercado secundario*.
- En materia de valores, la regla general es que todos los **valores son transables**. Esto es fundamental para el MV porque un valor que no es transable en los *mercados secundarios* indiscutiblemente no tiene el valor (relevancia).
- ⁴El resto del inc 1 (después del ¹) menciona todos los mercados que están sujetos a la LMV.
- El gran tema que nace de acá es ¿qué se entiende por oferta pública de valores VS oferta privada de valores? Esto se aclara en el art 4.²⁹
- ⁵Salvo que la LMV diga expresamente que hay una norma que se aplica a los valores privados, no se aplica la LMV. Y, son muy pocos los casos en donde la LMV aplica ese criterio en particular a los valores privados.

²⁹ P. 269

○ Art 2

TÍTULO I – OBJETIVOS DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 2- Corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros¹, en adelante la Superintendencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de acuerdo con las facultades que se le confieren en su ley orgánica y en el presente cuerpo legal.²

- ¹Hoy en día es la CMF NO SVS.
- ²La CMF debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de la LMV de acuerdo a las facultades conferidas por la ley para la CMF.
- La nueva ley de la CMF establece todas las atribuciones. Es un listado muy largo porque se fueron sumando las atribuciones de todas las superintendencias que ahora comprenden (bancos, valores y seguros) más las facultades que tenía por la Ley de Valores y Seguros (LVS).

○ Art 3

TÍTULO I – OBJETIVOS DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 3- Para los efectos de esta ley, se entenderá por valores cualesquiera títulos transferibles incluyendo acciones¹, opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión.²

Las disposiciones de la presente ley no se aplican a los valores emitidos o garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por el Banco Central de Chile.

- ²Este art entra a definir qué se entiende por **valores**: cualquier título transferible, incluyendo acciones, opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión.
- ¹Ojo, las acciones que muchas personas no la consideran como un valor, SI son un valor para la LMV.
- Acá surge la gran clasificación de los valores en acciones por un lado, y, títulos de deuda por el otro lado. Entonces, algunos hablan de títulos de capital (acciones) y títulos de deuda (todo el resto). Esto se refleja en las transacciones que se hacen en la bolsa.
- En Chile, ¿qué se transa en la bolsa? **acciones y títulos de deuda.**
- En el lenguaje de la bolsa, se habla de *instrumentos de renta fija* (título de deuda) e *instrumento de renta variable* (acciones).
- Curiosamente, si uno ve en cualquier día la bolsa, las transacciones en ambos grupos (renta fija y variable) son relativamente parecidas en cantidades, son pequeñas diferencias.
- Esto me lleva al tema de ¿por qué la existencia y la operación de las bolsas es tan importante desde el punto de vista de valores?, de hecho, siempre las bolsas han estado bajo el control regulatorio. ¿Qué es lo que se transa en bolsa o fuera de bolsa? ¿Cuál es el sentido de transar en bolsa o fuera de bolsa?
 - ✓ La gran mayoría de los emisores tienen esa posibilidad (hacerlo dentro o fuera de la bolsa).

- ✓ Si tomamos cualquier SA abierta importante, ésta ¿transará un 100% de sus acciones en bolsa? NO. No tiene para qué. Por lo tanto, transa un % de ellas en la bolsa. Ese % es determinado por el **directorío** o la **junta de accionistas** en algunos casos.
- ✓ La bolsa existe para que un **mayor número de personas adquiera esos títulos** -ya sea de capital o de deuda-, pero perfectamente se puede transar fuera de bolsa.
- ✓ El inconveniente económico de transar fuera de bolsa es que se **reduce a un mercado mucho más pequeño**.
- ✓ Los valores transados fuera de la bolsa se transan directamente, vale decir, la persona va a un banco de inversión o empresa y los compra.
- ✓ Por eso entonces, que la bolsa con respecto a los instrumentos de renta fija (títulos de deuda) y a los de renta variable (acciones) es una institución fundamental.
- ✓ Los dueños que se preocupan de mantener el control de la empresa a través de un determinado %, por lo tanto, permiten transar x% porque los dueños saben que no van a perder el control si se transa ese %.
- ✓ Transar en bolsa es mucho más fácil, es más rápido y tiene mejores precios.
- A través de la historia, las bolsas han tenido problemas. El mayor problema fue el **jueves negro en octubre de 1929**.
 - ✓ Lo que ocurrió fue que se vino abajo la *Bolsa de Nueva York*, que en aquel entonces era la bolsa más importante del mundo. Sigue siendo la más importante, pero tiene mucha competencia.
 - ✓ Algunos sostienen que se vino abajo por falta de regulación.
 - ✓ En realidad se debe a que los precios de las acciones suben y bajan permanentemente de acuerdo con muchos factores, pero, en aquel entonces bajó radical y drásticamente en cosa de horas porque miles de personas fueron a vender sus acciones antes de que siguieran bajando. Esto se debe a que la bolsa en materia de acciones está a las expectativas y a una infinidad de factores que no son fáciles de determinar. Pero, aquí el tema era bastante universal.
 - ✓ Esto mismo ha vuelto a ocurrir en menor grado varias veces después del 29`. Pero, ahora existe un **mecanismo de límite** en la gran mayoría de las bolsas que es cuando una acción en bolsa baja más del 10% se suspende la transacción hasta el día siguiente, y también la puede suspender la autoridad por más del día siguiente. Entonces, hay un mecanismo dentro de la bolsa que se hace que no se vuelva a repetir aquel día negro, pero hasta un punto determinado (debe ser mayor al 10%).
 - ✓ Entonces, indiscutiblemente que aquí hay un elemento en el lado **accionario** NO en el lado de los instrumentos de deuda.
 - ✓ ¿En qué me puede afectar a los títulos de deuda un problema en la bolsa? En las **tasas de intereses flotantes** y también porque el título de deuda que compré en 100 puede estar en 50. Es un título de deuda que lo compré muy caro, y, ahora vale muy poco y el vendedor de las deudas también se ve

afectado.

- Por lo tanto, el tema de las bolsas no es menor en el caso de los valores. Las bolsas se han ido sofisticando, en el sentido de que hoy en día la gran mayoría de ellas son **digitales**.
 - ✓ Ya no hay lo que se denomina en bolsas **ruedas**.
 - ✓ En las **ruedas** asisten los corredores de bolsa para hacer transacciones en función de órdenes de compra y órdenes de venta de las acciones y de los instrumentos de deuda.
 - ✓ Los corredores de bolsa son **intermediarios** entre los compradores y vendedores dentro de la bolsa.
 - ✓ Pero, hoy en día se puede hacer lo mismo digitalmente sin necesidad de intermediarios para la compra y venta en el mercado bursátil. Vale decir, si tengo una orden de venta que calza digitalmente con una orden de compra, se cierra la transacción, y, no hay necesidad de hacer **rueda**.

○ Art 4

TÍTULO I – OBJETIVOS DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 4- *Se entiende por oferta pública de valores la dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste.¹*

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer que determinados tipos de ofertas de valores no constituyen ofertas públicas, en consideración al número y tipo de inversionistas a los cuales se dirigen, los medios a través de los cuales se comunican o materializan y el monto de los valores ofrecidos.

Asimismo, la Superintendencia podrá eximir ciertas ofertas públicas del cumplimiento de alguno de los requisitos de la presente ley, mediante normas de carácter general.

Los emisores que estén en liquidación no podrán hacer oferta pública de valores excepto si se tratare de sus propias acciones.

- En este art se aclara el concepto de **oferta pública de valores**.
- ¹En el inc 1 menciona que la **oferta pública de valores** es la “*dirigida al público en general o a ciertos sectores o grupos específicos de éste*”.
- Cuando habla de *ciertos sectores o grupos específicos* cabe la duda si éstos son o no ofertas privadas. Por lo tanto, aquí ha existido un **área gris** -parecida al tema de la habitualidad en materia bancaria-. ¿Dónde está la línea divisoria entre la oferta a un grupo o sectores -ya no de carácter al público en general- y dónde está la oferta privada? Es la CMF la que tiene que ir definiendo este tema.
- Es obligación la **consulta** cuando hay **dudas** al respecto, porque si se hace como oferta privada y después la CMF la considera oferta pública, vienen las sanciones más feroces -al igual que en el caso de los bancos-.
- Uno de las sanciones es por estar haciendo ofertas catalogadas de públicas por la CMF cuando se creyó que era privada. Es un tema que ha dado para mucho porque a veces se cree que era privada pero la CMF la considera pública.
- La consulta es fundamental.

○ **Art 4 bis**

TÍTULO I – OBJETIVOS DE LA LEY, FISCALIZACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 4 bis- En los mercados de valores se entenderá por:

a) **Mercado secundario formal:** *aquél en que los compradores y vendedores están simultánea y públicamente participando en forma directa o a través de un agente de valores o corredor de bolsa en la determinación de los precios de los títulos que se transan en él,¹ siempre que diariamente se publiquen el volumen y el precio de las transacciones efectuadas y cumpla con los requisitos relativos a número de participantes, reglamentación interna y aquellos tendientes a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúan en él, que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general;*
(...)

d) **Accionista minoritario:** *toda persona que por sí sola o en conjunto con otras con las que tenga acuerdo de actuación conjunta, posea menos del 10% de las acciones con derecho a voto de una sociedad, siempre que dicho porcentaje no le permita designar un director.²*
(...)

g) **Valores de presencia bursátil:** *aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos por la Superintendencia a través de una norma de carácter general, los que deberán responder a condiciones que, de acuerdo a la Superintendencia, sean indicativas de la liquidez de los valores o de la profundidad de los mercados en que se negocien los valores en cuestión, a efectos de propiciar una correcta formación de precios.³*
(...)

- En este art se dan una serie de **definiciones**.
- ¹**Mercado secundario formal:** *aquél en que los compradores y vendedores están simultánea y públicamente participando en forma directa o a través de un agente de valores o corredor de bolsa en la determinación de los precios de los títulos que se transan en él// aquél que no es un mercado primario, vale decir, un mercado de los emisores ya sea de acciones o de títulos de deuda.*
- ²**Accionistas minoritarios:** Esta definición se encuentra en la LMV (aunque es una definición debiese estar en la LSA) porque sirve para una infinidad de instituciones en donde se distingue accionistas minoritarios y mayoritarios. En la medida que el accionista minoritario siga siendo minoritario, indiscutiblemente que en algunas instituciones será menos importante el control. Pero, cuando el accionista minoritario a través de una operación de valores pasa a ser mayoritario, si tiene mucha importancia.
- ³**Valores de presencia bursátil:** la LMV no lo define, sino que dice *aquellos que la CMF determine como tales*. ¿Por qué? Porque hay ciertos valores que se transan todos los días *-de presencia bursátil-*, pero ¿qué pasa si hay un valor que se transa una vez a la semana? Entonces, viene una serie de distinguos con respecto de valores. Por lo tanto se hace una diferenciación.

II. TÍTULO II – DEL REGISTRO DE VALORES Y DE LA INFORMACIÓN

- El **registro de valores** es muy relevante ya que va a determinar quién puede emitir valores y quién no puede. Por lo tanto, bajo la LMV los únicos que pueden emitir valores *-de oferta pública-* son los que están **registrados**.
- La misma LMV en su art 5 señala a quiénes corresponde el registro.

○ Art 5

TÍTULO II – DEL REGISTRO DE VALORES Y DE LA INFORMACIÓN

Artículo 5- La Superintendencia llevará un Registro de Valores el cual estará a disposición del público.

En el Registro de Valores se deberán inscribir:¹

- a) Los emisores de valores de oferta pública;²*
 - b) Los valores que sean objeto de oferta pública;³*
 - c) Las acciones de las sociedades anónimas que tengan 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, y⁴*
 - d) Las acciones emitidas por sociedades anónimas que voluntariamente así lo soliciten o que por obligación legal deban registrarlas.⁵*
- (...)

- ¹Corresponde el registro a:
 - a) ²Los emisores de valores de oferta pública.
 - b) ³Los valores que sean objeto de oferta pública.
 - c) ⁴Las acciones de las SA que tengan 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho %.
 - d) ⁵Las acciones emitidas por SA que voluntariamente así lo soliciten o que por obligación legal deban registrarlas.
 - En la letra d) se dan 2 situaciones.
 - ⁱQue la SA no tenga la obligación de hacer oferta pública porque no cumple con los requisitos, pero está interesado en hacerlo. Por lo tanto, es una SA generalmente cerrada que se registra porque le interesa hacer oferta pública.
 - ⁱⁱHay ciertas leyes que obligan a ciertas sociedades a registrarse también por la importancia que tienen.
- Este registro ha jugado un papel muy importante dentro del sistema porque la **cantidad de información** que pide la CMF para registrarse es impresionante.
 - ✓ Esta información se tiene que mantener **actualizada** todo el tiempo.
 - ✓ Las exigencias o condiciones para registrarse son las que la misma CMF determine, y, deben ser de carácter general.
 - ✓ **Sólo podrá hacerse oferta pública de valores cuando éstos y su emisor hayan sido inscritos en el registro de valores.**
 - ✓ ¿Qué es lo que se inscribe? Los emisores de valores y los valores propiamente tal.
 - ❖ En el caso de los **emisores**, son requisitos generalmente más bien societarios, de capital, etc de quienes los van a emitir.
 - ❖ En el caso de los **valores**, los requisitos serán las características de cada valor al ser emitido. Esto es especialmente relevante en los **valores de deuda**.
 - ¿Por qué es tan exigente la LMV y la CMF en los *instrumentos de deuda* y no en las *acciones*?

- Parte siendo exigente desde el *prospecto*.
 - El *prospecto* contiene toda la información que se le va a entregar al público con respecto de ese valor.
 - Éste es muy acabado, y, contiene toda la información de cada instrumento de deuda que se está emitiendo.
 - Después con respecto del emisor hay cambios a través del tiempo, pero no tantos.
 - Pero, los valores van cambiando, van surgiendo nuevos tipos de valores, nuevas series, etc, por lo tanto, tienen que registrarse antes de su emisión.
- Uno de los **bienes jurídicos** involucrados en el MV es la **TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN** para dar la **mayor seguridad posible**. Esto no está dicho en ninguna parte de la LMV, pero se encuentra implícito.
- ✓ Ejemplo: una empresa emisora de valores que aparece como muy sólida, pero que tiene una contingencia espectacularmente grande. Esa contingencia está dada por una infinidad de factores que se encuentran en el *prospecto*. ¿Hasta qué punto da seguridad a los compradores esos valores, y, así que la empresa no se venga abajo el año siguiente o subsiguiente?
 - ✓ Esto es lo que ha pasado en pocos casos felizmente en Chile con respecto de ciertos instrumentos de deuda.
 - ✓ Caso EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Eº): sus bonos tenían una tasa de interés espectacular (el que no compraba era tonto) hasta que las contingencias le hicieron fallar. Ocurre lo mismo con *ENACAR (Empresa Nacional del Carbón)*.
 - ✓ Por lo tanto, esa seguridad de que hablábamos es bien distinta en las acciones a la de los instrumentos de deuda, porque la **seguridad de pago de los instrumentos de deuda es más frágil**.
 - ✓ **El riesgo es mucho mayor en los instrumentos de deuda.**
 - ✓ Por lo general, las **acciones son más seguras que los instrumentos de deuda**.
 - ✓ La emisión de *instrumentos de deuda* lo hacen casi todas las empresas. Es muy raro que una empresa no tenga instrumentos de deuda. Pero, depende de cuánta deuda tiene, de qué calidad, de qué condiciones consiste esa deuda, y lo más importante es hasta qué punto esa empresa va a estar en condiciones de pagar los intereses y el principal de ese instrumento de deuda.
 - ✓ Existen *instrumentos de deuda cortos* (de 1 año) y los factores que pueden ocurrir son menos. Pero, en 20-30-50 años, pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, que se fusione la empresa, que el mercado cambie radicalmente, etc.
 - ✓ ¿Cuáles son los **riesgos en las acciones**? El historial pasado de la empresa, el presente de la empresa, y, su política de dividendos hacia el futuro, dan bastante elementos de juicio para saber que el riesgo es bastante menor que en los instrumentos de deuda. Indiscutiblemente, pueden haber equivocaciones.

- ❖ Pero éstas también pueden ser a favor del *comprador* de las acciones, y, por eso se denomina *instrumentos de renta variable*. Y, puede ser que el precio de esa acción suba mucho.
- ✓ En todos los casos, en el MV la **transparencia** de la información pasa a ser **vital**.
 - ❖ Por eso que grandes escándalos financieros en el mundo en empresas se han producido por falta de transparencia, o, incluso en algunos casos ninguna transparencia, por ejemplo, lo que sucede con algunas *empresas venezolanas petroleras o mineras*.
 - ❖ Lo que tiene que procurar la CMF es siempre la mayor transparencia para los inversionistas, vale decir, los que están comprando esos títulos.
 - ❖ Hoy en día, muchas empresas controladas por la CMF, tiene que entregar información mensual, pero por lo menos es trimestral. Y, la información que entrega es del orden de 150-200 páginas además del balance. Y, esa información está disponible para cualquiera que la quiera usar.
 - ❖ Entonces, en definitiva felizmente -a juicio de *Yrarrázaval*- hemos llegado a una cantidad de información bastante razonable.
 - ❖ Obviamente para emplear esa información hay que ser especialista. Es información muy contable, financiera y de auditoría.
 - ❖ Por ejemplo, estas empresas llevan informes de auditorías externas, y, si uno lee el resumen de ese informe de auditoría no va a entender prácticamente nada porque tienen un lenguaje críptico/especializado - que es entendido casi exclusivamente por contadores y auditores- ,y, que además depende mucho de la empresa en cuestión.

→ Caso CRAV (empresa azúcar en Chile): era una empresa muy exitosa que le competía a IANSA en aquel entonces. Como los informes de auditoría son hasta diciembre, el informe era "*limipio*", es decir, sin observaciones. Pero, entre enero-abril cambió el precio del azúcar a nivel internacional en una forma drástica y esta empresa se vino para abajo y quebró. Y, después responsabilizaron a la empresa de auditoría y ésta se defendió de que hicieron la auditoría hasta diciembre, y, si no fue previsto por la empresa, menos va a ser previsto por la auditoría.

III. TÍTULO III – DE LA INFORMACIÓN CONTINUA Y RESERVADA

- Esto es algo que se repite en la LMV permanentemente.
- La **información continua** se refiere a la que no termina ni con el registro ni cosa por el estilo, sino que es información que está siempre, y, ahí es la CMF la que tiene que determinar la periodicidad de esa información y el tipo de información exigida.
- Pero, después viene un tema bien delicado que es la reserva de la información.
 - Hay una parte de la información entregada a la CMF que se puede entregar bajo la condición de que es **información reservada** para la CMF.
 - Por lo tanto, está prohibido que la CMF dé a conocer en cualquiera forma esta información reservada a competidores, a terceros, etc.

- Pero esta es una decisión bastante delicada porque se tiene que referir a materias que son estratégicas, y, que los competidores especialmente no deben conocer.³⁰
- Puede ser que en un momento determinado la CMF diga que no puede mantener la reserva porque justamente es en esa información donde se está produciendo el problema, y, por lo tanto tiene que tener la capacidad de sancionar a pesar de que se lo hayan entregado en forma reservada.
- Entonces, la reserva es con **respecto de 3º**, pero la CMF tiene que tener las facultades de sancionar si llega a la conclusión de que en esa información reservada estaba el problema.

IV. TÍTULO IV – DE LAS TRANSACCIONES SOBRE VALORES DE OFERTA PÚBLICA

V. TÍTULO V – DEL MERCADO SECUNDARIO

VI. TÍTULO VI – DE LOS CORREDORES DE BOLSA Y LOS AGENTES DE VALORES

VII. TÍTULO VII – DE LAS BOLSAS DE VALORES

VIII. TÍTULO VIII – DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

○ Art 52

TÍTULO VIII – DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Artículo 52- Es contrario a la presente ley efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.¹

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrán efectuarse actividades de estabilización de precios en valores de acuerdo a reglas de carácter general que imparta la Superintendencia y únicamente para llevar adelante una oferta pública de valores nuevos o de valores anteriormente emitidos y que no habían sido objeto de oferta pública.

- ¹Está **prohibido** utilizar las **transacciones en valores** con el objeto de **estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios**.
- Con esto se han producido en Chile y en todas partes del mundo problemas serios porque permanentemente van surgiendo ciertas situaciones en que las compras o las ventas de los valores son hechos o a precio artificial, o, con una finalidad de lo que justamente está prohibido, vale decir, estabilizando, fijando o variando artificialmente los precios.
- No es un tema fácil pero obviamente que la ley lo tiene que prohibir porque lo que se quiere es que los precios sean reales. Y, puede ser que debajo de algunos precios éstos no lo sean.

○ Art 53

TÍTULO VIII – DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

*Artículo 53- Es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor,¹ ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas.
(...)*

- ¹Este art refuerza el art 52, y menciona que *es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor*.

³⁰ En el caso de la LDLC también existe este tema.

IX. TÍTULO IX – DE LA INFORMACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE CONTROL

- Ahí termina lo que era originalmente la LMV. Pero, se le fueron incorporando distintos temas.

X. TÍTULO X – DE LA RESPONSABILIDAD

XI. TÍTULO XI – DE LAS SANCIONES

XII. TÍTULO XII – DEL RECURSO DE ILEGALIDAD

XIII. TÍTULO XIII – DISPOSICIONES GENERALES

XIV. TÍTULO XIV – DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO

- Este tema es importantísimo en materia de valores porque hay ciertas empresas especializadas en clasificar el riesgo de los títulos de deuda especialmente, y, a veces de las acciones (pero mucho más de los títulos de deuda).
- Se clasifica el riesgo de menos a más, vale decir las empresas que son clasificadas con riesgo A, AA, AAA son las de menos riesgo, y, en la medida que uno va bajando se va encontrando con más riesgo.
- Estas empresas son internacionales y también las hay en Chile, y, existen para que los inversionistas tengan más elementos de juicio.
- Con la gran **crisis del sistema bancario** a nivel mundial (2008-2009) todos dicen que fracasaron los clasificadores de riesgo.
 - ✓ Dicen que el problema estuvo en los clasificadores de riesgo porque estaban haciendo las clasificaciones para los bancos y para cualquier otra institución financiera que quisiera comprar estas carteras de créditos hipotecarios, y, los clasificaron en términos mucho más positivos que la realidad.
 - ✓ Pero, esa realidad cambió rápidamente, y, en cosa de semanas ya se había desatado la crisis, pero las clasificaciones se habían hecho antes.
 - ✓ Además, la clasificación se hacía en paquetes de títulos de deuda y en éstos paquetes habían títulos de deuda con riesgos muy distintos, entonces se hacía muy difícil la tarea de los clasificadores de riesgo.
 - ✓ *Yrarrázaval* considera que esos paquetes nunca debiesen haber existido. Al hacer paquetes, se ésta mejorando en la clasificación el alto riesgo de ciertos instrumentos con costa de otros instrumentos que tienen bajo riesgo. Incluso, lo encuentra poco profesional.
 - ✓ En virtud de que las clasificadoras de riesgo sostuvieron que estas acciones no tenían tanto riesgo, las terminaron comprando los bancos. Y, en la medida que pasaba el tiempo, el riesgo de la cartera bancaria iba aumentando cada vez más.

XV. TÍTULO XV – DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES, DE LOS CONTROLADORES Y DE LAS PERSONAS RELACIONADAS

- Estas normas también podrían estar en la LSA, pero están en la LMV aplicándose a las SA que transan valores en público.
- Se incluye aquí porque el concepto de ser accionista mayoritario, minoritario y de grupo empresarial implican limitaciones muy importantes, y, por lo tanto, la CMF define qué es un grupo empresarial desde el punto de vista económico.

- Cada cierto tiempo la CMF señala “*en Chile existen “x” grupos empresariales*”. Actualmente, son del orden de 100 grupos empresariales existentes según lo que ha señalado la CMF en virtud de estas normas. Estas normas son muy complejas.

XVI. TÍTULO XVI – DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

XVII. TÍTULO XVII – DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

XVIII. TÍTULO XVIII – DE LA SOCIEDADES SECURITIZADORAS Y DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA DE SECURITIZACIÓN

XIX. ~~TÍTULO XIX – DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN (DEROGADO)~~

XX. ~~TÍTULO XX – DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS FISCALIZADOS POR LA SUPRINTENDENCIA (DEROGADO)~~

XXI. TÍTULO XXI – DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

- Aquí es donde han habido casos en Chile bastante importantes. Uno de ellos involucró al actual Presidente de la República cuando estaba en actividades privadas en LAN.
- El tema es ¿qué se considera como información privilegiada?, ¿a quiénes afecta?
- La LMV establece una **infinidad de presunciones**, por ejemplo, se entiende que el/la cónyuge tiene la misma información que el/la cónyuge que es director de una empresa.
- Entonces, lo que hace la ley es señalar que el grupo que está afecto es lo más grande posible con el objetivo de que **ciertas personas no tengan o no usen la información que tienen antes que esta llegue al mercado**.
- Todo esto para efectos de la **igualdad de condiciones** entre los interesados en comprar o en vender.
- Este concepto de *información privilegiada* es relativamente nuevo en nuestro sistema jurídico, y, provino del dº anglosajón en donde se denomina *insider trading*.
- En el caso de los países anglosajones, los casos importantes de *insider trading* han sido escandalosos, y todos los que han intervenido han terminado en la cárcel.
- En el caso chileno, afortunadamente no han sido escandalosos, sino que son problemas de si se cumple en la realidad estas presunciones que establece la ley. Por ejemplo, una presunción es que los directores tienen toda la información disponible en todo momento. ¿Será realista esto?

- Hay varios títulos que no son relevantes para el estudio de este ramo.
- En la **parte sancionatoria**, se divide en:
 - parte sancionatoria administrativa: están las sanciones que pueda aplicar la CMF por infracción a la ley o nivel de circulares.
 - delitos de valores: sale la misma discusión que en los delitos en materia bancaria. ¿Será más razonable reunir todos los delitos económicos en un texto legal, en el Código Penal o si es mejor que estén en distintas leyes? *Yrarrázaval* prefiere que estén en las distintas leyes para que se analice de acuerdo con el tema que corresponda, en este caso con la LMV. El ejemplo más dramático de eso es el art 285 del Código Penal con respecto a la *manipulación de precios*.

LEY 21.000 - CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)

- Es del año 2007.
- La ley es larga y compleja. Se hizo más todavía más compleja con un área que no estaba prevista para el CMF. Esto se refiere al **área bancaria**. Ésta se incorpora con la última modificación de la LGB y se va incorporando progresivamente hasta el 1 de junio de 2019 en donde desaparece totalmente la SBIF y queda todo bajo la CMF.
- La CMF fue pensada como sucesora de la SVS, pero se transformó también en la sucesora de la SBIF.
- Algunos creen que esto es positivo y otros creen que no tanto debido a:
 1. El **trato económico** que se le da al **personal** es peor al que tenían hasta antes del 1 de junio. Incluso, había una ceremonia oficial de la CMF que se suspendió por esto (huelga).
 2. Al **mecanismo de financiamiento**. La SBIF era financiada por los propios bancos, pero la SVS es financiada por la Ley de Presupuesto.
 3. La **labor** que debe realizar la CMF a los bancos es muy **distinta** a la de VS.
 - La supervigilancia de los bancos es de carácter **preventivo** (ex ante) debido a que se debe cuidar la estabilidad del banco (es demasiado complicada una situación de *inestabilidad financiera* o de *administración deficiente* de un banco). Para hacer esta labor preventiva, la CMF necesita una cantidad de información impresionante.
 - En cambio, la supervigilancia de la CMF con respecto a VS es **después de** (ex post). Lo preventivo de la CMF con respecto a VS es muy poco. Todos los valores deben estar registrados, cualquiera modificación debe ser informada, etc para que la información sea veraz y oportuna (cierta calidad de la información proporcionada) para que los inversionistas sepan la mayor cantidad de información para comprar o no determinados títulos ya sean de deudas o accionarios.
- Por lo tanto, el desafío que tiene hoy en día la CMF es muchísimo mayor al que tenía con la ley original, y, esto ha generado bastante controversia. Se le dieron un poco más de recursos a la CMF al agregar la supervigilancia de los bancos, pero es insuficiente según *Yrarrázaval*.
- Otros cambios:
 1. Cambio de **superintendencia a comisiones**.
 - De las 4 superintendencias económicas, nos vamos quedando solo con 2.³¹
 - ¿Qué significa este cambio? Muchísimo. De ahora en adelante, las decisiones son **colegiadas** (por una comisión integrada por 5 miembros). 5 miembros remplazan en la toma de decisiones a 1 sola persona (superintendente). Esto tiene pros y contras:

³¹ Quedan la de Fondos de Pensiones (depende del Ministerio del Trabajo) y la de ISAPRES (depende del Ministerio de Salud). Éstas tienen una naturaleza distinta a las de carácter financiero (que se eliminaron). También quedan algunas superintendencias que tienen mucho menos poder con respecto de ciertas áreas, por ejemplo, la S. de Electricidad, de Gas, etc. (propiamente, éstas no son económicas).

✓ Ventaja:

❖ **Mejora la calidad en la toma de decisiones.** Es muy distinto tener a 5 personas discutiendo y analizando que a 1 persona que no discute con nadie. Esto depende de que efectivamente los miembros sean de la calidad esperada, y, felizmente a juicio de *Yrarrázaval* los 5 miembros son de mucha calidad, y, todos expertos en distintas áreas. Esta combinación se dio gracias a la aplicación de la ley. Primero, fueron designado los 4 miembros no presidentes, y luego el presidente. Hasta el momento, en prácticamente los 2 años que llevamos con la CMF han sido bastante certeros pero no les ha tocado enfrentar temas muy delicados o problemáticos.

✓ Desventajas:

❖ **Rapidez en la toma de decisiones.** Se contempla en la ley un mecanismo para hacerlo más rápido, por lo tanto, a pesar de ser un órgano colegiado, deben tener dedicación exclusiva. Además, le asigna al presidente de la comisión una facultad para poder tomar decisiones de forma más rápida (decisiones urgentes).

❖ **Remuneraciones.** Originalmente, se contempló una remuneración muy baja por lo que habían muy pocas personas interesadas. Esto se cambió, por lo que hay más personas interesadas.

I. TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

- Este título es muy relevante porque habla del **ámbito de aplicación** de la ley, vale decir, hasta dónde puede llegar la CMF y dónde no puede llegar la CMF.

○ Art 1 - Características CMF y funciones

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 1- Créase la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante también la "Comisión"), como un servicio público¹ descentralizado², de carácter técnico³, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio⁴, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda⁵ y se regirá por la presente ley y demás normativa que se dicte al efecto.⁶

Corresponderá a la Comisión, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública.⁷ Para ello deberá mantener una visión general y sistémica del mercado⁸, considerando los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, así como el resguardo del interés público.⁹

Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan¹⁰, desde que inicien su organización o su actividad, según corresponda, hasta el término de su liquidación¹¹; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones.¹²

Su domicilio será la ciudad de Santiago¹³, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer en otras ciudades del país.¹⁴

○ Inc 1

- ¹Pertenece al Eº.

- ²Es **descentralizado** en la toma de decisiones.
- ³Las personas que la componen están bien instruidas en esos temas.
- ⁴Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Nos recuerda al BC. Es casi idéntico al BC pero con una diferencia que es que esta norma no nos habla de la *autonomía*. Incluso, en ciertos momentos del proyecto de ley estaba la palabra *autónomo* pero fue eliminada.
- ⁵Se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda como fue siempre en la SBIF y en la SVS.
- ¿Cuánta autonomía tiene la el consejo? Pareciera que no tanta pues la palabra fue eliminada del proyecto original. No tiene autonomía presupuestaria, y, se rige como cualquier otro servicio público sin autonomía. Pero, tiene autonomía en la toma de decisiones en el sentido de que no hay intervención alguna del Ministerio de Hacienda en la toma de decisiones. Se reproduce algo muy parecido a lo que sucede en el BC, vale decir, los miembros no pueden ser destituidos, hay causales de incompatibilidad muy importantes, hay causales de inhabilidad muy importantes, hay dedicación exclusiva, hay causales de destitución muy especiales y con un procedimiento de destitución especial.³² Los consejeros/comisionados de la CMF una vez que son elegidos no dependen del Presidente de la República al igual que los consejeros del BC. Una cosa es que los haya elegido, y otra cosa bien distinta es que tengan algún grado de dependencia con el ejecutivo.
- ⁶La CMF se rige por esta ley y por cualquier otra ley que haga referencia a la CMF.

○ **Inc 2**

- ⁷La CMF debe velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la *fe pública*.
 - ✓ Parece muy razonable la primera parte del inc 2 ("*velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado*"), vale decir, que no ponga trabas que no sean razonables para que más agentes se incorporen a un determinado mercado.
 - ✓ La ***fe pública*** se relaciona específicamente con la materia de información. Vale decir, la gran mayoría de las decisiones del mercado dependen de la información que se ha entregado. Si esa información es errónea, incompleta o falsa, indiscutiblemente que afecta a la fe pública. La *fe pública* se refiere a la cantidad de información que tienen disponible los inversionistas, los depositantes, etc.
 - ❖ Esto no es menor porque el problema del INE es justamente esto, vale decir, no se sabe si son 2 o 3 meses donde hubo un error de una décima en el cálculo del aumento del costo de la vida hecha por el INE. Esto ha generado un tremendo problema, y, el jefe de precios está siendo investigado porque desde el punto de vista financiero para algunas instituciones puede ser miles de millones de pesos. Esto ha planteado un

³² La destitución no ha ocurrido ni el BC ni en la CMF.

tema de fondo acerca de la autonomía del INE (que se encuentra bajo el Ministerio de Economía).

- ✓ El tema de la **fe pública** no está definido en ninguna parte, pero indiscutiblemente que se refiere a la **fidelidad de la información sobre la base la cual los depositantes, asegurados e inversionistas toman sus decisiones.**
- ⁸Para los efectos del correcto funcionamiento del mercado y el cuidado de la fe pública, la CMF deberá mantener una **visión general y sistémica** del mercado.
 - ✓ El *análisis sistémico de un mercado* se refiere al análisis de los mercados de acuerdo con ciertas condiciones macroeconómicas que lo van impactando, por lo tanto, las políticas que van surgiendo en la CMF no pueden ser las mismas en un momento de recesión que las implementadas en un momento de inflación. Se refiere al análisis del sistema de todas las instituciones que están siendo fiscalizadas.
- ⁹Deben considerar los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados, y, el resguardo del interés público.
- **Inc 3**
 - ¹⁰La CMF tiene la importante función de **sancionar** el incumplimiento de leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones. Pero, además se tiene que preocupar de que las normas de la CMF (no con rango legal ya que dependen del legislador) sean razonables en un momento determinado, porque a lo mejor que el incumplimiento se genera porque simplemente la norma es mala o no es clara al respecto. Es por eso, que anteriormente bajo la SBIF, y ya se está notando bajo la CMF, la normativa más delicada que dicta la CMF es respecto de la **consulta a los agentes involucrados** con anticipación. La CMF no se obliga a ceñirse a ninguna de las respuestas dadas por los agentes, pero indiscutiblemente que en ese momento para temas complicados (como préstamos entre partes relacionadas en materia bancaria, información confidencial en materia de valores, etc) es conveniente la consulta previa para los efectos que vengan observaciones de distinta naturaleza por parte de los agentes. Y, una vez que se completa ese análisis de las observaciones, se dicta la normativa. Entonces, no hay una disminución de funciones por parte de la CMF, sino que simplemente algo de prudencia de consultar antes respecto de normativas complicadas.
 - ¹¹La fiscalización es desde el comienzo hasta la liquidación.
 - ¹²La CMF puede ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones. La CMF tiene que priorizar las materias de las que se ocupa, si no lo hace, realiza muy mal su función.³³ Hay una cantidad enorme de instituciones y empresas bajo el control de la CMF. Solo las que están enumeradas en la ley serán reguladas ya que son las leyes las que le dan a competencia a la CMF (quedan fuera la ANFP y los bomberos).
 - ✓ La *prioridad* NO se encuentra en la ley, pero según *Yrarrázaval* se encuentra implícito para que la CMF sea más o menos eficientes. Tienen que priorizar según lo que sea más importante en el momento.

³³La ANFP y el cuerpo de Bomberos están dentro de la CMF.

○ **Inc 4**

- ¹³Su domicilio será la ciudad de **Santiago**.
- ¹⁴Puede tener **oficinas regionales**. Hoy día, hay mecanismos muy directos para entenderse desde las regiones con Santiago.
 - ✓ No es lo mismo que existió por ejemplo con el BC, en donde el BC estaba presente prácticamente en todas las capitales de regiones. Con la información digital no tiene ningún sentido que se ubique en distintas regiones.

○ **Art 2 - Normativas de aplicación**

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 2- *La Comisión y su personal se regirán por lo establecido en la presente ley y, supletoriamente, por las normas contempladas en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; y en la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, en todo lo no regulado expresamente por la presente ley.¹*

Con todo, la Comisión estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos.²

- ¹La CMF y su personal se deben regir por esta ley, y, supletoriamente por las normas de la Ley de Bases Generales de la Administración del Eº, Ley de Bases de los Procedimientos Admnisitrativos y la Ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, en todo lo no regulado expresamente por la presente ley.
 - ✓ Aquí se incorporan en forma **supletoria** normas de la administración del Eº.
 - ✓ Respecto de la Ley de Bases Generales de la Administración del Eº, indiscutiblemente se ha incorporado a esta ley una parte procedimental muy larga y bastante engorrosa, pero muy necesaria. La ley contempla los conceptos fundamentales, pero no puede comntemplar todo el procedimiento con lujo detalle.
 - ✓ Esto se produjo porque la SVS le fue bastante mal en las sanciones más relevantes que aplicó, especialmente en relación con el tema “*Cascadas de soquimich*” y el tema de *información privilegiada*.
 - ❖ Le fue muy mal en los tribunales superiores por 2 razones fundamentales: **falta de debido proceso y sanciones no razonables**. Por lo tanto, lo que pretende esta ley es que la CMF no pierda esos casos por falta de debido proceso. Para esos efectos, están las reglas procesales que se incorporaron.
 - ❖ Pero, hay un tema que quedó pendiente, y, que después fue bien resuelto -a juicio de *Yrarrázaval*- en la ley, que se refiere a que los que investigaran no fueran los mismos que los que sentenciaran, porque eso es una falta al debido proceso. La razón de esto es que se creó una unidad en la ley de esta CMF de **investigación** a cargo de un fiscal que solamente investiga

y le entrega los resultados de su investigación al consejo de la CMF, y, es él que determina si se aplica o no la sanción.

- ❖ Se estableció un sistema de independencia de esa unidad (de información) dirigida por un fiscal en relación con el consejo de la CMF. Ambos pertenecen a la CMF, y, lo que hacen es muy parecido a lo que hacen las fiscalías en relación con los tribunales.
- ✓ Por lo tanto, se incorporan una cantidad de normas procedimentales que no estudiaremos porque son de una gran complejidad, pero daremos algunas ideas fundamenales respecto del fiscal y esta unidad de investigación.
- ²La CMF estará sometida a la fiscalización de la **Contraloría** General de la República **exclusivamente** en lo que concierne al examen de las cuentas de sus **gastos**. Esto es super importante porque la Contraloría no se debería meter en el análisis legal de las resoluciones, sino solo respecto de los gastos.
 - ✓ Se analizan los gastos ya que la CMF pertenece a la administración pública y le dan presupuesto en la administración pública.

○ Art 3 - Fiscalización

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 3- Corresponderá a la Comisión la fiscalización de:

- 1. Las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública.¹**
 - 2. Las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles.²**
 - 3. Las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores que estos realicen.³**
 - 4. Los fondos que la ley somete a su fiscalización y las sociedades que los administren.⁴**
 - 5. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones que la ley sujete a su vigilancia.⁵**
 - 6. Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza, y los negocios de éstas, así como de las personas que intermedien seguros.⁶**
 - 7. El Comité de Autorregulación Financiera a que se refiere el título VI.⁷**
 - 8. Las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, así como las empresas dedicadas a la emisión y operación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de cualquier otro sistema similar, siempre que importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos de él.⁸**
 - 9. Las cooperativas de ahorro y crédito sujetas a su fiscalización en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 5, de 25 de septiembre de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas.⁹**
 - 10. Cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que esta ley u otras leyes le encomienden.¹⁰**
- No quedan sujetas a la fiscalización de esta Comisión las administradoras de fondos de pensiones y otras entidades y personas naturales o jurídicas que la ley exceptúe expresamente.¹¹**
- (...)**

- La CMF debe **fiscalizar**:
 1. *Las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública.*
 2. *Las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones*

bursátiles.

3. *Las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores que estos realicen.*
4. *Los fondos que la ley somete a su fiscalización y las sociedades que los administren.* Por ejemplo, fondos mutuos, administradoras de fondos, etc.
5. *Las SA y en comandita por acciones (casi no se usa) que la ley sujete a su vigilancia.*³⁴
6. *Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, y los negocios de éstas, así como de las personas que intermedien seguros.* Todo el tema de seguros entra entonces en la CMF.
7. *El Comité de Autorregulación Financiera contemplado en la ley.* Hasta el momento ni siquiera se ha conformado este comité por dificultades que ha habido.
8. *Las **empresas bancarias**, cualquiera sea su naturaleza, así como las empresas dedicadas a la emisión y operación de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de cualquier otro sistema similar, siempre que importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos de él.* Esta NO estaba originalmente en la ley.
9. *Las cooperativas de ahorro y crédito sujetas a su fiscalización.*
10. *Cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que esta ley u otras leyes le encomienden.* Acá entra la ANFP, el cuerpo de bomberos y otros.
 - Todavía Chile no incorpora claramente la concepción de que la mejor fiscalización proviene cuando es un n° acotado de empresas. Se tiene la idea de que para darle seriedad a algunas cosas, la metemos dentro del sistema.
 - No necesariamente por el hecho de ser comisiones en vez de superintendencia se garantiza el buen funcionamiento o la eficiencia. Pero a juicio de *Yrarrázaval* tiene algunas características que le permiten realizar mejor la labor que si fuera una superintendencia.
 - ¹¹No quedan sujetas las AFP y otras entidades que la ley exceptúe expresamente. Aquí surgió el cuestionamiento de los bancos porque no estaba incluidos, pero la idea era que se fueran incorporando **gradualmente** a este sistema.

○ **Art 4 - Colaboración SII**

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 4- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la Comisión colaborará con el Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria.¹
(...)

- ¹Este art es muy raro a juicio de *Yrarrázaval*, y se refiere a que la CMF debe **colaborar al SII** porque la CMF tiene mucha información que es relevante desde

³⁴Vigila a las SA con +500 accionistas, que 100 accionistas controlen +10%, o, que hagan oferta pública, vale decir, SA abiertas.

el punto de vista tributario. Pero esto en términos normales, también puede ser solicitado por el SII a la CMF manteniéndose siempre los secretos y reservas que corresponden.

○ **Art 5 - Atribuciones de la CMF**

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 5- *La Comisión está investida de las siguientes atribuciones generales¹, las que deberán ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum de aprobación que determine esta ley:
(...)*

- Este art contiene las **36 atribuciones de la CMF**.³⁵

1. Dictar las normas para la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos y, en general, dictar cualquier otra normativa que de conformidad con la ley le corresponda para la regulación del mercado financiero.

- ❖ Esta es la facultad normativa que tenía la SBIF y que ahora tiene la CMF. Se ejerce a través de circulares, resoluciones, etc que se van dictando permanentemente.
- ❖ Estas circulares pueden llegar hasta lo contemplado en la ley, la CMF NO es legisladora. La CMF dicta normas obligatorias, y, la gran mayoría de ellas son de implementación. Lleva una buena cantidad en estos 2 años y ahora van a ser más todavía porque debe hacer normas para cada una de las áreas que regula la CMF -bancaria, valores, seguros, etc-.
- ❖ Esta facultad normativa -a juicio de *Yrarrázaval*- es imprescindible para cualquier superintendencia bien desarrollada porque es la única forma que tiene para ser efectivo en su fiscalización.

De igual modo, corresponderá a la CMF interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas, entidades o actividades fiscalizadas.

- ❖ Esto parece muy razonable, pero la interpretación no es solamente respecto de sus circulares, sino también respecto de la ley, y ahí tenemos problemas. Esta interpretación por definición le corresponde a los tribunales de justicia y NO a las comisiones, superintendencias u otras instituciones.
- ❖ Y, los 5 miembros del consejo de la CMF, solo 1 es abogado, el resto no lo son y están interpretando la ley. Las consecuencias son que la gran mayoría de los abogados van a encontrarla insuficiente, ¿se debe cumplir o no con la circular interpretativa? No se puede reclamar en contra de la interpretación, pero se puede reclamar en contra de la sanción por no ceñirse a esa norma interpretativa, y, serán los Tribunales Superiores de Justicia los que resolverán.

³⁵Vamos a ver solo algunas.

→ Caso Corpbanca: lo que la SBIF hacía en ese entonces era darle una interpretación a las 2 primeras restricciones de los bancos, N° 1 y 2 del art 86 con respecto de los créditos que se le pueden entregar a una misma empresa y de los créditos relacionados entre los dueños de la empresa y los bancos. Afortunadamente -a juicio de Yrarrázaval- la SBIF perdió en la CA y la CS. De esta manera, queda claro el tema de que las interpretaciones de normas obviamente que se producen, y, es necesario que se produzcan, pero si no son compatibles con las normas de la ley, pueden ser reclamadas, y, esto en virtud del art 19 N° 21 de la CPR “*respetando las normas legales que la regulen*”. El que regula en Chile es el legislador NO las superintendencias, comisiones, poder ejecutivo a través de decretos ni reglamentos, etc.

Estas potestades (normativas) no podrán extenderse en ningún caso a las facultades normativas e interpretativas que le corresponden al BC.

❖ Entonces, si hay alguna de estas facultades que además le correspondan al BC no se puede ver afectadas por estas circulares de la CMF, por la autonomía del BC.

2. Absolver las consultas y peticiones e investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas, asegurados, depositantes u otros legítimos interesados.

❖ Se refiere a **denuncias y consultas**.

→ Esto es muy relevante porque muchas de las causas más importantes de la CMF van a surgir sobre la base de denuncias de accionistas minoritarios, inversionistas, depositantes, etc. Y, van a reclamar en contra de la información que se le entregó, que no era fehaciente y veraz, etc.

→ Las consultas son necesarias porque indiscutiblemente ni la ley ni las circulares alcanzan a cubrir todas las situaciones imaginables que se vayan presentando, por lo tanto, si se quiere tener alguna **seguridad jurídica** por parte de la CMF, se consulta. Es lo mismo que se hace con SII y con muchas otras instituciones.

3. Evacuar los informes que le requieran los fiscales del Ministerio Público que estén dirigiendo investigaciones criminales.

❖ Estos son informes.

4. Examinar sin restricción alguna y por los medios que estime pertinentes todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas, entidades o actividades fiscalizadas, etc de los entes fiscalizados.

❖ Se refiere al tema de la **fiscalización**.

Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización o estadística, sin alterar el normal desenvolvimiento de las actividades del afectado.

❖ Puede exigir la entrega de cualquier cosa.

5. Autorizar al fiscal a que se refiere el artículo 22, para que, en el marco de investigaciones o procedimientos sancionatorios, con el voto favorable de al

menos 3 de sus comisionados y mediante resolución fundada, requiera información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva.

- ❖ Aparece la figura del **fiscal de la CMF**. NO confundir con el FNE, FN del Ministerio Público ni los fiscales en materia penal.
- ❖ La Ley para la CMF permiten al fiscal que le pida a los bancos las operaciones bancarias -tanto de captación y de colocación (distingue el *secreto* de la *reserva*)- pero deben concurrir el voto favorable de a los menos 3 de los 5 miembros del consejo.
- ❖ Después vienen una infinidad de condiciones para estos efectos.

6. Fijar las normas para la confección y presentación de las memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de las entidades fiscalizadas.

- ❖ La CMF -SBIF tenía la facultad anteriormente- puede obligar a los entes fiscalizados a realizar la memoria, los balances, los estados de situación y demás estados financieros de acuerdo con una modalidad especial.
- ❖ Se hacen sobre la base de los ***principios de contabilidad generalmente aceptados*** que son **internacionales**.
- ❖ A pesar de que el Colegio de Contadores Auditores debe aprobar estos criterios para que tengan vigencia dentro del país, generalmente lo van aprobando de forma relativamente rápida porque ya son criterios que se aplican en las memorias, balances, etc.
- ❖ Y, la CMF puede ir más allá, y puede decir que para los efectos de entender bien cómo están tratando determinadas proviciones, puede establecer que en el balance debe ir de tal y tal forma una situación.
- ❖ Esto es para la **eficacia del sistema de control**.
- ❖ Menciona algunos ejemplos, vale decir, pueden ser determinados aspectos que le preocupan mucho a una superintendencia.
- ❖ *Ejemplo compañías de seguros:* sobre la base de las reservas las compañías de seguros pueden pagar los *siniestros*. Las compañías reciben las *polizas de seguros*, y, al producirse el *siniestro* tienen que tener las reservas correspondientes para poder pagar ese *siniestro*. Esto es fundamental para que las compañías de seguros funcionen bien, porque lo que no puede suceder es que se produzca el siniestro y la compañía no tenga con qué pagar. La CMF se preocupa especialmente de ver cómo está el tema de los balances y estado de situación de sus reservas porque para la CMF es fundamental.

7. Inspeccionar, por medio de sus empleados o de empresas de auditoría externa, a las personas o entidades fiscalizadas. En las inspecciones que la CMF realice en el marco de la fiscalización, podrá integrar su propio personal con el de la empresa fiscalizada.

- ❖ Se refiere a las **inspecciones**. A Yrarrázaval no le gustan porque son **ineficientes** y se prestan para **corrupción**.

- ❖ Caso Brasileiro: los inspectores llegan, se sientan en la oficina del gerente gral y no hacen nada hasta que les paguen las coimas correspondientes para que se retiren.
- ❖ Hay una razón más de fondo, hoy en día, la información es fundamentalmente digital, y, no hay mucho que puedan estar inspeccionando físicamente.
- ❖ Las inspecciones pueden ser realizadas por los empleados de la CMF o por firmas de auditorías externas.
- ❖ Las firmas de auditoría externa deben registrarse con la CMF porque la CMF quiere que sean de 1º calidad.
- ❖ La CMF le puede encomendar a estas empresas de auditoría análisis particulares con respecto de ciertas empresas que pueden ser muy importantes en un momento determinado.

5 de junio

8. *Requerir a las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público, información veraz, suficiente y oportuna.*

- ❖ Íntimamente vinculado con el tema de **valores**.
- ❖ Esto es lo mismo que aparecía en la LVS como un principio fundamental en materia de valores aparece nuevamente aquí porque la CMF tiene la facultad de requerir e incluso sancionar cuando la información no es veraz, suficiente y oportuna.
- ❖ *Veraz* se refiere a que no sea falsa.
- ❖ *Suficiente* en términos de cantidad.
- ❖ *Oportuna* con respecto al tiempo.
- ❖ Caso La Polar: se conoció el caso cuando ya habían pasado varios años en la cual ciertos ejecutivos habían dado información que no era veraz, y, por lo tanto, cuando no es oportuna, el daño obviamente que es mucho mayor. En este caso, se dañaron AFP, bancos y a todas las personas que les habían comprado bonos. Lo que habían hecho estos ejecutivos era **subirle el precio a las acciones** de La Polar, y, sobre esta base se compraban acciones y se emitían bonos. Cuando se desinfló todo esto, La Polar pasó por un período muy malo y recién ahora se está recuperando. Está volviendo a la situación que se encontraba hace 10 años, pero con daños a muchas personas en el país.

9. *Citar a declarar a los socios, directores, administradores, representantes, empleados y personas que, a cualquier título, presten o hayan prestado servicios para las personas o entidades fiscalizadas y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquier naturaleza, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. Podrán ser citadas a declarar aquellas personas que, sin ser fiscalizadas o relacionadas a ellas, ejecuten o celebren actos o convenciones cuyo objeto sean instrumentos o valores emitidos por personas o entidades fiscalizadas.*

- ❖ Esto no es menor porque estas personas que se les requiere para que declaren es porque se ha descubierto algún aspecto en alguna de las empresas fiscalizadas, y, son esas personas las que pueden dar a conocer esos temas.
- ❖ Por lo tanto, a veces son personas que trabajan para la empresa y otras veces son abogados o ingenieros que prestaron un determinado servicio, y, por lo tanto, son llamadas a declarar. Si no declara, existe un sistema de **sanciones** para ello. ¿Estoy obligado a declarar? SI, y si no lo hace, se sanciona por las sanciones establecidas por la ley.

10. Dictar normas que aseguren la fidelidad de las actas, libros y documentos que determine y requiera la CMF.

- ❖ ¿Por qué las *actas de directorio* pasan a ser tan importantes?
Hay actas de muchos tipos y de distintas extensiones. Lo relevante desde el punto de vista jurídico es que la responsabilidad de los directores sale del acta. ¿Por qué? Porque si un director no ha manifestado su oposición a un acuerdo determinado, por mucho que no le guste, va a ser solidariamente responsable con todos los demás directores, por lo tanto, el momento que tiene un director para expresar su posición distinta o negativa para un determinado proyecto es en el directorio y dejando constancia en el acta de aquello.

11. Ordenar a las personas o entidades fiscalizadas que ella determine la designación de empresas de auditoría externa.

12. Vigilar las actuaciones de las empresas de auditoría externa.

13. Designar empresas de auditoría externa en las entidades o personas fiscalizadas.

- ❖ ¿Qué son las *empresas de auditoría externa*? ¿A qué se dedican?
 - En Chile hay algunas muy buenas, y, hay 3 muy grandes.
 - Son sociedades profesionales que se dedican al tema de la auditoría fundamentalmente.
 - ¿Qué es una auditoría a una SA abierta? Es un análisis profesional realizado a dichas sociedades de todos los balances al 31 de diciembre de cada año. También pueden haber auditorías mensuales o trimestrales, pero anualmente se requiere por lo menos de una gran auditoría.
 - Los auditores revisan los **principios de contabilidad** generalmente aceptados dentro de la empresa, especialmente para formular lo que son las *notas de auditorías*. Si vemos cualquier balance, después del balance de los activos y pasivos, y después de los estados y resultados de la empresa, se encuentran las notas de auditorías.
 - ¿Qué se hace en las *notas de auditoría*? Lo que se hace es **informar** a cualquiera que lea esas notas de cualquiera situación especial y/o controvertida.
 - Ejemplo: informan de todos los juicios que tiene la empresa especialmente en su contra con bastante detalle porque

dependiendo de los resultados del juicio, se va a ver afectada la empresa.

→ Lo que hacen los auditores es **ayudar a terceros de la empresa** a analizar efectos relevantes que pueden afectar posteriormente al 31 de diciembre los resultados de la empresa.

→ Hay notas de auditorías que son muy larguísimas, y, obviamente corresponden a las empresas que tienen más contingencia y más problemas que pueden afectar sus resultados.

→ En materia de lo que le interesa a la CMF, la función de las auditorías es muy relevante. Deben estar inscritas y pueden ser requeridas para cuestiones puntuales o para cuestiones más generales, para que emitan su pronunciamiento independiente.

→ Pero ¿qué tan independiente puede ser una auditoría que es pagada por la empresa? En nuestro país son totalmente independientes al margen de quién le paga los honorarios. En otras palabras, si las auditorías para tener buenas relaciones y seguir como auditoras de la empresa, mienten o no entregan toda la información incurre en sanciones gravísimas de acuerdo con la ley.

→ Ejemplo empresa USA: cerca del 2000, se produjeron varios problemas en empresas mundiales de importancia, y, aquí es donde salieron estos temas. La 1ª de ellas se trataba de una enorme empresa de energía en USA (Nº15 de USA) tuvo justamente sus problemas en el área de finanzas, y se debe a que los auditores no eran independientes realmente de esa empresa. A la empresa de auditoría se le pagaba un % de las utilidades de la empresa. Esto no puede ser posible, ya que se le hace correr con los resultados a la empresa de auditoría, y, obviamente que era para inflarlos y así favorecía a la empresa de auditoría. Esta empresa de auditoría fue sancionada y terminó desapareciendo.

→ Todo esto se dice para que tengamos una idea de lo importante que son dichas empresas en este tipo de situaciones.

24. Proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, las normas legales y reglamentarias necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del mercado financiero y el cumplimiento por parte de las personas o entidades fiscalizadas de la normativa que las rige.

❖ ¿Dónde tenemos una norma parecida a esta? En la LDLC. Una de las facultades que tiene el TDLC es justamente proponer al Presidente de la República a través de un mecanismo distinto al planteado aquí la modificación de normas legales y reglamentarias que puedan afectar la LC y el normal funcionamiento de los mercados. ¿Por qué? Porque en la práctica, la CMF y el TDLC van descubriendo normas que en vez de fomentar la competencia, hacen justamente lo contrario, y, esas son las famosas **trabas de dº** que existen en la competencia.

→ Caso Taxis: hasta no hace mucho tiempo solamente se podía utilizar un taxi en la medida que el conductor fuera miembro del sindicato de

taxistas. Por lo tanto, era el sindicato el que determinaba la cantidad de taxis que existían en Chile. Esto fue planteado por el TDLC y a juicio de *Yrarrázaval* se eliminó bien esa traba de dº que no tenía ningún sentido. Ahora, se plantea el mismo problema con *Uber*. Este no es un tema que ocurre solo en Chile, sino que ocurre en todas partes del mundo. Luego se va a plantear respecto de los *Airbnb* (hoteles se oponen).

- ❖ Por lo tanto, la **proposición** es muy razonable, pero no obliga a la autoridad. Por lo tanto, si la proposición tiene buenos argumentos, probablemente la autoridad se va a preocupar del tema, pero en caso contrario no lo va a hacer.
- ❖ Es muy interesante que la CMF y el TDLC se estén preocupando de muchos temas que van quedando a nivel reglamentario y a nivel legal como trabas de dº.

- Luego, a partir del N º24 viene una serie de atribuciones referidas al **fiscal**.
 - ✓ Es un fiscal de la CMF. El actual fue anteriormente fiscal del Ministerio Público, que renunció para ser fiscal de la CMF y fue elegido previo concurso público.
 - ✓ Es fundamental para que la CMF (antes SVS) no siga perdiendo los juicios por la falta del **debido proceso**. Antes, investigaba y resolvía con respecto de las infracciones de la ley era la SVS, y no había un debido proceso. Por lo tanto, se incorpora a la ley la institución de la fiscalía para la CMF con una infinidad de normas que corresponden a normas complejas que se van a ir decantando a través del tiempo.
 - ✓ El concepto de *debido proceso* se incorpora en la CPR del 80` y se refiere al dº de las personas a tener un debido proceso en cualquier tipo de juicio que implique una sanción.
 - ✓ Anteriormente, lo que hacía la SVS era analizar una determinada situación y sancionarla si correspondía.
 - ❖ Caso Corpbanca: la empresa no tuvo ninguna posibilidad de defenderse frente a la SVS.
 - ✓ Deben haber ciertos dº procesales y sustantivos mínimos para que una persona pueda defenderse.
 - ✓ **Si el que investiga es el mismo que sanciona, no se da el debido proceso.** Esto ocurría bajo el antiguo sistema procesal penal. Con el nuevo sistema, se separa, y por lo tanto, se incorpora el Ministerio Público.

36. Ejercer las demás facultades que otras leyes expresamente le confieran.

○ **Art 6 - Patrimonio CMF**

TÍTULO I – OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA CMF

Artículo 6- El patrimonio de la Comisión estará formado por:

- 1. El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.**
 - 2. Los recursos que se otorguen por leyes especiales.**
 - 3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.**
 - 4. Los frutos de sus bienes.**
 - 5. Los ingresos que perciba por los derechos que cobre y los servicios que preste.**
 - 6. Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional.**
- (...)**

- El patrimonio de la **CMF** se conforma por:

1. Aporte de la Ley de Presupuestos.

- ❖ Este aporte es fundamental.
- ❖ Fue un problema bien serio con respecto de la incorporación de la SBIF a la CMF porque la LGB contempla un sistema en el cual porcentualmente de acuerdo con sus activos se hacen los aportes de los bancos al financiamiento de la SBIF. Esto fue muy criticado por algunos, pero *Yrarrázaval* no lo encuentra tan malo porque es un %, entonces no hay ninguna arbitrariedad, y, gracias a eso el financiamiento de la SBIF nunca tuvo problemas desde el 25` en adelante. En cambio, otras superintendencias han tenido problemas de falta de presupuesto.
- ❖ El presupuesto -a juicio de *Yrarrázaval*- es fundamental para el éxito de la SBIF/CMF. Lo peor que puede ocurrir -a juicio de *Yrarrázaval*- es una SBIF/CMF con muchas facultades y con poco presupuesto, eso se puede convertir en el reino de las arbitrariedades. *Yrarrázaval* sostiene que el personal de la CMF debe ser muy bien pagados, y a pesar de que se ha hecho un esfuerzo en este sentido, parece que no lo es tanto porque el 1 de junio entraron en huelga los empleados de la SBIF y después los de la CMF. Entonces, la CMF parte ya con huelgas prácticamente por parte de todo su personal debido a las remuneraciones.
- ❖ Se había omitido el financiamiento privado que los bancos le daban a la SBIF para la CMF. Después una modificación a la LGB lo incorpora.
- ❖ Desde un comienzo también se excluyó a las AFP.

2. Los recursos que se otorguen por leyes especiales.

- ❖ Son muy pocos, casi nada.

3. Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales que se le transfieran o adquiera a cualquier título.

- ❖ Son muy pocos.

4. Los frutos de sus bienes.

- ❖ Son muy pocos.

5. Los ingresos que perciba por los dº que cobre y los servicios que preste.

- ❖ Esto es bien curioso, ya que la ley tiene un tarifado en la ley misma (en UF).

6. Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional.

❖ Prácticamente ninguno.

- La verdad es que la parte fundamentalísima del presupuesto es por la Ley de Presupuesto.

II. TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF

- Aquí, el esquema es exactamente el mismo que el del Consejo del BC. Tiene algunas diferencias que vamos a notar, pero el esquema es el mismo. Para *Yrarrázabal* es bueno que sea así, ya que el Consejo del BC ha funcionado muy bien y no ha tenido ningún problema serio interno, y por lo tanto, es deseable que el Consejo de la CMF funcione igualmente bien.
- Hay distintos planos:
 - De la comisión (organización).
 - Del consejo de la comisión (5 personas que la componen).
 - ✓ Cuando aparece el consejo, hay nuevamente un listado de atribuciones del consejo.
 - Del pdte del consejo.
 - ✓ Después, hay otro listado de atribuciones respecto de las del pdte del consejo.
 - En definitiva, las atribuciones están en 3 lugares distintos de la ley: de la CMF, del consejo, del pdte del consejo.
- **Art 8 - Consejo de la CMF**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF

Artículo 8- La dirección superior de la Comisión estará a cargo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, al cual le corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que ésta y otras leyes le encomienden a ésta.¹

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero establecerá una normativa interna de funcionamiento², (...)

- ¹La dirección superior de la CMF estará a cargo del **Consejo de la CMF**.
- ²El consejo tendrá una normativa interna de funcionamiento.
- Nuevamente aquí aparece implícito que este consejo es un **organo colegiado**, y, esto tiene muchas repercusiones:
 - ✓ Todas las decisiones se toman **en el consejo** y NO fuera del consejo. Lo opinen los consejeros fuera del consejo, tiene 0 valor jurídico.
 - ✓ La opinión del pdte no es más importante que las de los demás consejeros si se da fuera del consejo.
 - ✓ Dentro del consejo, el pdte es un consejero más, salvo cuando haya empate entre los otros 4 consejeros, y ahí es él quien debe dirimir. Por eso se discutió bastante el nº de consejeros que debe existir. *Yrarrázaval* está muy de acuerdo con 5 consejeros.
 - ✓ La gran mayoría de las decisiones del consejo del BC son unánimes, pero hay algunas con decisión dividida. Hay opiniones que emiten los consejeros que quedan en acta y que tienen mucha importancia, como por ejemplo, que

pueden haber consejeros que dicen que no van a votar en contra pero que se debe enfrentar como comisión en el futuro. Por ejemplo, en tema de aumento/disminución de la tasa de interés del BC, o, en *cyber seguridad* que ellos digan que no tienen recursos para enfrentarlos, pero que dejen constancia de que a futuro van a pedir presupuesto para hacerlo.

- ✓ Ahora, las decisiones deben quedar **en acta**, esto es propio de un órgano colegiado, y por eso es que las actas deben contener las materias tratadas y los acuerdos. Y, si algún consejero está en desacuerdo, esto también debe quedar en acta. No tienen la responsabilidad de los directores de las SA, pero si tienen la responsabilidad de pronunciarse cuando no comparten el criterio de mayoría.
- ✓ La gran mayoría de las materias son muy **técnicas**, pero indiscutiblemente que es fundamental esta forma de funcionamiento.
- ✓ Incluso, hay una **tábula de cada reunión** porque los consejeros deben saber qué van a discutir, y si el tema es importante, el consejero va a querer formar su opinión con al respecto al tema.
- ✓ Debe ser **físicamente presente**.
- Todos estos conceptos -que se desarrollan en las SA- han tenido una aplicación a juicio de *Yrarrázaval* muy positiva en el BC y que ojalá lo tenga en el consejo de la CMF.

PÁRRAFO 1º - DEL CONSEJO DE LA CMF

○ Art 9 -Designación de los consejeros

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF

Artículo 9- El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante también el "Consejo") estará integrado por cinco miembros, denominados comisionados¹, los que se nombrarán y estarán sujetos a las reglas siguientes:

1. Un comisionado designado por el Presidente de la República, de reconocido prestigio profesional o académico en materias relacionadas con el sistema financiero, que tendrá el carácter de presidente de la Comisión.(...)

2. Cuatro comisionados designados por el Presidente de la República, de entre personas de reconocido prestigio profesional o académico en materias relacionadas con el sistema financiero, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previa ratificación del Senado por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.²

Los comisionados designados de conformidad con lo dispuesto en este numeral durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un nuevo período consecutivo. Se renovarán en pares, cada tres años, según corresponda.³

El Presidente de la República deberá proponer al Senado los candidatos que correspondan antes de la expiración del plazo de duración de los comisionados salientes.⁴ (...)

- Se refiere a la **designación de los consejeros**.
- ¹Son 5 comisionados.
- ²Se produce un cambio muy importante en relación al BC y al TDLC: los **5 son de designación del Presidente de la República**. Esto está íntimamente vinculado con la falta de autonomía, y, esto puede influir en algunas decisiones en algunos

consejeros, pero no debería serlo porque al igual que los ministros del TDLC, no pueden ser destituidos sino que por causales gravísimas y después de un procedimiento también complicado. Por lo tanto, son designados por el Presidente de la República, pero **no son ni de la confianza ni de la dependencia de él.**

- En este periodo de transición de la CMF le toco a la presidenta *Bachelet* la designación de los 5, y a juicio de *Yrarrázaval* fue una designación muy correcta.
- La única condición que se pone es que pasen por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Esto es importante porque el sistema implica un análisis de cada uno de los candidatos con lujo de detalle y ayuda por cierto a la designación. El sistema de ADP comenzó hace como 10 años, y es un sistema muy técnico y adecuado para la selección de personas que van a ocupar altos cargos dentro de la administración pública.
- La única lástima a juicio de *Yrarrázaval* es que el tema de la remuneración se arregló tardíamente. Como iba inicialmente la ley, la remuneración era muy baja para las responsabilidades que se asumen. Porque los consejeros son de **dedicación exclusiva** en el concepto que lo conocemos hoy día. En otras palabras, el consejero no se puede dedicar a nada más que a su actividad en la CMF. Después, afortunadamente se arregló el tema de la remuneración cuando muchos que habían expresado algún interés en la CMF señalaron que con esa remuneración no podían vivir razonablemente.
- ³Los comisionados durarán 6 años, pudiendo ser reelegidos por 1 solo período sucesivo y se renuevan de a pares cada 3 años.
- ⁴Luego, viene todo el sistema de designación de los comisionados. El Pdte de la República debe proponer al Senado los candidatos. Y, probablemente por lo bien que fueron elegidas las personas, el Senado le dió su aprobación con una altísima mayoría (muy cercana a la unanimidad).

○ **Art 10 - Dedicación exclusiva**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF
Artículo 10 - El desempeño de las labores de comisionado exigirá dedicación exclusiva y será incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado.¹ No obstante lo anterior, el cargo de comisionado será compatible con cargos docentes en instituciones públicas o privadas reconocidas por el Estado hasta un máximo de doce horas semanales.²(...)

- ¹Acá de habla de la **dedicación exclusiva**, implica una incompatibilidad con toda remuneración del sector privado o público. En definitiva, los comisionados solamente se pueden dedicar a las actividades de la CMF.
- ²La única **excepción** es la **labor docente** siempre y cuando que no sean más de 12 horas semanales.

○ **Art 11 - No pueden ser comisionados**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF

Artículo 11- No podrá ser designada comisionado:

1. La persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, por delitos de prevaricación, cohecho y, en general, aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contemplados en la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, delitos contra la fe pública y, en general, por cualquier otro delito contemplado en las leyes sujetas a la fiscalización de la Comisión.

2. La persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas cuya venta no se encuentre autorizada por la ley, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

3. La persona que esté siendo objeto de un procedimiento sancionatorio o que haya sido sancionada, dentro de los últimos cinco años, por infracción a las normas que regulan los mercados sujetos a la fiscalización de la Comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos.

(...)

▪ No pueden ser comisionados:

1. Personas condenadas por delitos que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
2. Personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas.
3. Personas sujetas a un procedimiento sancionatorio o que han sido sancionadas dentro de los últimos 5 años por infracción a normas que regulan los mercados.

○ **Art 12 - Incompatibilidades**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF

Artículo 12- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, el cargo de comisionado será incompatible con:

1. El cargo de diputado, senador, ministro del Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, consejero del Banco Central, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

2. El cargo de ministro de Estado, subsecretario, intendente y gobernador; alcalde y concejal; consejero regional; miembro del escalafón primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscal del Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembro de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembro de los demás tribunales creados por ley; funcionario de la Administración del Estado, y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales.

(...)

3. El cargo de director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité en entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión, como también de sus matrices, filiales o coligadas.

(...)

▪ Es **incompatible** con el cargo de diputado, senador, ministro de estado, director,

administrador, gerente, trabajador, etc. Entonces, la incompatibilidad es **absoluta**.

- ¿Cómo se garantiza esa incompatibilidad? Con una **declaración**, al igual que como lo hacen los ministros del TDLC en donde deben declarar que efectivamente no tienen ninguna incompatibilidad, y, cualquier omisión o falsedad tienen sanciones espectacularmente altas. Esta declaración está contemplada en el art 13.

○ Art 14 - Causales de cesación

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF

Artículo 14- Serán causales de cesación en el cargo de comisionado las siguientes:

- 1. Expiración del plazo por el cual fue nombrado.**
 - 2. Renuncia aceptada por el Presidente de la República.**
 - 3. Incapacidad física o síquica para el desempeño del cargo.**
 - 4. Sobrevinencia de alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las contempladas en los artículos 10, 11 y 12.**
- Si el comisionado hubiere sido acusado de alguno de los delitos señalados en el número 1 del artículo 11 quedará suspendido de su cargo hasta que concluya el proceso por sentencia firme.***
- 5. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes.**
- (...)**

- Este art es casi idéntico al de la LDLC.
- Las causales de cesación del cargo son:
 1. Expiración del plazo.
 2. Renuncia aceptada por el pdte de la República.
 3. Incapacidad física o síquica.
 4. Sobrevinencia de alguna causal de inhabilidad.
 5. Incumplimiento grave de sus funciones y deberes.
- Luego, viene todo el procedimiento para el *incumplimiento grave* y para la *incapacidad*.

○ Art 15

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF

Artículo 15- El Consejo sólo podrá sesionar con la asistencia de a lo menos tres de sus miembros.¹ Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los comisionados presentes, salvo que la ley exija una mayoría diferente.² El presidente de la Comisión, o quien lo subrogue, tendrá voto dirimente en caso de empate.³

(...)

- ¹El Consejo sólo puede sesionar con la asistencia de a lo menos 3 de sus miembros.
- ²Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los comisionados presentes, salvo que la ley exija una mayoría diferente.
- ³El pdte de la Comisión, o quien lo subrogue, tendrá voto dirimente en caso de empate.

○ **Art 16 - Inhabilidades**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 1º – DEL CONSEJO DE LA CMF
Artículo 16- Los comisionados deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés. Además, deberán informar al Consejo el conflicto de intereses que les afecta.¹
 Se entenderá que el comisionado tiene interés, entre otras circunstancias, cuando:
 (...)

- ¹Se refiere a las **inhabilidades** de los comisionados.
- En dº, el distingo entre *inhabilidades* e *incompatibilidades* es fundamental.
- Las *incompatibilidades* son para **ejercer el cargo**, mientras que la *inhabilidad* es para **votar y ser parte del acuerdo**.
- Las *inhabilidades* estan referidas fundamentalmente a **relaciones familiares**, entonces, se da una larga enumeración.
- Dentro de todo esto se trata el tema de conflicto de intereses.

PÁRRAFO 2º - DEL PRESIDENTE DE LA CMF

- El pdte del consejo es el mismo que el de la CMF. Ocurre lo mismo que en el caso del BC.
- Aquí viene un listado de las atribuciones del pdte. No tiene mayor importancia.

PÁRRAFO 3º - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

- Es una de las incorporaciones fundamentales de esta ley.
- **Art 22 - Unidad de Investigación**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 3º – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Artículo 22- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 18, la Comisión deberá contar con una unidad de investigación responsable de la instrucción del procedimiento sancionatorio¹ que regula el título IV, la cual estará a cargo de un funcionario denominado **fiscal**²
 (...)

- ¹La CMF deberá contar con una **unidad de investigación** responsable de la instrucción del procedimiento sancionatorio.
- ²Esta unidad esta a cargo de un **fiscal**.
 - ✓ Este fiscal puede tener fiscales adjuntos.
 - ✓ Las exigencias para este fiscal son enormes en términos de dedicación, incompatibilidades, inhabilidades y atribuciones.

○ **Art 25 - Denuncias**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 3º – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Artículo 25- El fiscal deberá recibir las denuncias que se le formulen respecto de actos que puedan importar infracción a la normativa bajo fiscalización de la Comisión¹ (...)

- ¹El fiscal debe recibir las **dencuncias** que se le formulen con respecto de infracciones a la normativa.
- Las denuncias se presentan a la fiscalía.

- Más adelante en la ley, hay un título completo con respecto del procedimiento en la fiscalía, pero no lo vamos a ver.

PÁRRAFO 4º - DEL PERSONAL DE LA CMF

- Del art 26-32.
- Esta normativa no tiene mayor importancia -a juicio de *Yrarrázaval*- porque lo que está regulando es la situación del personal propio de la CMF, pero hay 2 aspectos que son bastante especiales: la **reserva** y el **secreto**.
- ¿Por qué se produce el secreto? porque se traspasa de los bancos o en algunos casos de las compañías. Hay una inmensidad de información, que si se originó de forma reservada tiene continuar reservada en la CMF. Y, en el caso que no lo sea, los empleados del caso van a tener sanciones muy fuertes ya que es muy importante la reserva y el secreto especialmente en materia bancaria, y por lo tanto, estos temas son tratados por la LGB con bastante precisión y cuidado.

PÁRRAFO 5º - DEL COBRO DE Dº

- Del art 33-34.
- Vienen 9 situaciones distintas de dº y cada una de ellas con respecto de cuánto vale inscribir, cuánto valen las anotaciones en los registros, cuánto valen los dº por la aprobaciones y la autorizaciones, etc.
- A juicio de *Yrarrázaval* no tiene por qué ir en la ley, pero se agrega de todos modos para que sea de conocimiento público de que es un solo valor el que se cobra, y que depende del trámite o lo que se está planteando.
- **Art 34 - Pago dº**

TÍTULO II – ORGANIZACIÓN DE LA CMF – PÁRRAFO 5º – DEL COBRO DE Dº

Artículo 34- Los derechos fijados en el artículo anterior serán pagados en las oficinas de la Comisión o por medios electrónicos habilitados al momento de obtener la correspondiente inscripción, depósito, aprobación o certificación, en su caso, según el valor que haya tenido la unidad de fomento al último día hábil del mes anterior a aquel en que se realiza el pago.¹

- ¹Los dº fijados en el art anterior serán pagados en la **oficina de la CMF** o por **medios electrónicos**, que es bastante razonable según *Yrarrázaval*.
- Surge la **duda de si éstos son o no tributos**:
 - ✓ Si son tributos es obviamente más razonable que estén en la ley para que cumplan por lo menos con el *principio de legalidad de los tributos*.
 - ✓ Todavía hay mucha discusión en cuanto a esto. Porque estos dº se dan en función de lo que se está pidiendo.
 - ✓ Ejemplo traducciones oficiales de los documentos que provienen del extranjero: se da un ejemplo parecido. Las traducciones se tienen que hacer en el ministerio de relaciones exteriores. Esas traducciones tienen distintos cobros dependiendo del idioma, de la extensión del documento, etc. Se pagan en el Ministerio de RREE. ¿Corresponden o no a tributos? *Yrarrázaval* considera que son **dº**.

- ✓ Ejemplo Registro Civil: cabe preguntarse si corresponde a un tributo el pago por sacar cédula de identidad o pasaporte. Pareciera estar relacionado con el servicio que *supuestamente* se presta (planteado en este sentido haciendo alusión a la huelga que hubo en el registro civil debido a que el personal nota el gran aumento en los cobros sin aumento en las remuneraciones, por lo que se tomó la central del registro civil en la calle huérfanos).

III. TÍTULO III – APREMIOS Y SANCIONES

- Se sigue un esquema que ya lo tenía la SVS.
- **Art 35 - Sanciones**

TÍTULO III – APREMIOS Y SANCIONES

Artículo 35- *En los casos en que se obstaculizare o impidiere el pleno ejercicio de las funciones otorgadas a la Comisión o al fiscal por los numerales 4 y 8 del artículo 5, la Comisión podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación del procedimiento de apremio contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, a fin de obtener el cabal cumplimiento y ejecución de tales atribuciones.¹*

(...)

- ¹En los casos que se obstaculize o impidiere el pleno ejercicio de las funciones de CMF, habrán sanciones.
- Después entre el **art 36** y el **37** viene verdaderamente el **listado de sanciones** posibles por parte de la CMF.
- La distinción entre el art 36 y 37 es muy tenue.
 - El art 36 habla sobre las sanciones para las SA y empresas bancarias sujetas a la fiscalización de la CMF. Las menciona con sus posibles sanciones.
 - El art 37 habla sobre las que no califican como SA ni empresas bancarias pero que están sujetas a la fiscalización de la CMF.
- Las sanciones son muy parecidas. Se sanciona por **incurrir en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que la rigen, o del incumplimiento en funciones y orden.**
- Las sanciones son 3:
 - 1. CENSURA**
 - ✓ Se da en el art 36 y 37.
 - ✓ Es de la menor de las sanciones.
 - ✓ Hay un listado largo de estos casos que se puede ver en la página web de la CMF.
 - ✓ Es importante por el tema de la **reincidencia**. Vale decir, si ya hubo una censura y se vuelve a cometer el mismo ilícito, indiscutiblemente que la pena subirá enormemente.
 - ✓ Además, la censura en Chile felizmente -a juicio de *Yrarrázaval*- es un problema también de *prestigio*. Vale decir, las empresas más prestigiosas generalmente no tienen censura. Esto se da al margen de temas estrictamente legales.

2. MULTA A BENEFICIO FISCAL

- ✓ Se da en el art 36 y 37.
- ✓ Acá se produce un problema serio porque esta multa puede ser calculada sobre la base de **3 criterios distintos**:
 - a) Suma de 15.000 UF**
 - ❖ Aparece el asunto de la reincidencia. En el caso de haber sido sancionado anteriormente, se podrá aplicar una multa de hasta 5 veces el monto máximo (hasta 75.000 UF).
 - b) El 30% del valor, emisión, registro u operación irregular.**
 - ❖ Ha generado bastantes problemas porque como es un % sobre la operación, puede ser una cantidad espectacularmente alta. Porque cuando se emite un valor se rige por la totalidad de la deuda, de manera que el 30% de esa totalidad será probablemente muy alto. Este ha sido el problema que han tenido que enfrentar las superintendencias y que tendrá que enfrentar la actual CMF de una forma difícil, porque si es tanta la sanción los Tribunales Superiores de Justicia plantean que es contrario a las normas constitucionales relativas al dº de propiedad.
 - ❖ Entonces, ha venido en cuestionamiento que nunca se había planteado hasta la incorporación de esta modalidad, porque si el monto del título que se emite no es por una cantidad alta, el 30% puede ser muy razonable, pero esto no tiene límite, de manera que podría ser totalmente inequitativo.
 - ❖ Caso SQMCH: se plantea inicialmente por el caso cascada de Soquimich. Se sancionó al ejecutivo más alto (*Julio Ponce*) y a otros con el 30% de la supuesta infracción, y esto llegó a los Tribunales Superiores de Justicia que señalaron que la sanción era desproporcionada e inequitativa. También por este motivo se incorporan las *unidades de investigación*.
 - c) El doble de los obtenidos producto de emisión registro u operación irregular.**
 - ❖ Esta pareciera estar más acotada, porque es hasta el doble del beneficio, y la otra es el 30% sobre el título u otro.
 - ❖ El problema está en determinar cuáles fueron los beneficios obtenidos por la infracción.
- Las sanciones señaladas -multa y censura- podrán ser aplicadas a la sociedad, directores, gerentes, empresas de auditoría, según lo determine la CMF porque a diferencia de las prácticas restrictivas (PR) de la competencia, en la cual la gran mayoría de las multas van exclusivamente a las empresas -persona jurídica-, en este caso son por ciertas actuaciones generalmente de ciertos directores, gerentes o personas, por lo tanto, es mucho más fácil aplicar sanciones personales.

3. REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE EXISTENCIA

- ✓ Es la sanción más violenta de todas.
- ✓ En el art 36 es la *revocación de la autorización de existencia de la sociedad*. En el caso de los bancos esta autorización de existencia es el 2º paso dentro

de la *constitución del banco*.

- ✓ El art 37, contempla el caso de las que no califican como SA ni empresa bancaria, pero que si son fiscalizadas, es decir, cuando se trate de personas naturales, y señala que se les puede suspender la actividad que está realizando o revocar la autorización si procediera.
- ✓ Ha habido situaciones en la cual la CMF (anterior SBIF) por infracción ha suspendido a determinadas empresas o personas en su autorización.

6 de junio

○ **Art 38 - Criterios para la aplicación de las multas**

TÍTULO III – APREMIOS Y SANCIONES

Artículo 38- *Para la determinación del rango y del monto específico de las multas a las que se refieren los artículos anteriores, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte óptima para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda¹, considerando al efecto las siguientes circunstancias:*

- 1. La gravedad de la conducta.*
 - 2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese.*
 - 3. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del mercado financiero, a la fe pública y a los intereses de los perjudicados con la infracción.*
 - 4. La participación de los infractores en la misma.*
 - 5. El haber sido sancionado previamente por infracciones a las normas sometidas a su fiscalización.*
 - 6. La capacidad económica del infractor.*
 - 7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas circunstancias.*
 - 8. La colaboración que éste haya prestado a la Comisión antes o durante la investigación que determinó la sanción.*
- (...)*

- ¹Para la **determinación** del **rango y monto** de las **multas** la CMF deberá procurar que su aplicación resulte óptima para el cumplimiento de sus fines.
- Esto se agrega justamente con el caso *SQMCH* y otros.
- El art 38 le da **8 criterios** a la CMF para fijar una multa adecuada: ¹gravedad de la conducta, ²el beneficio económico obtenido, ³el daño o riesgo, ⁴la participación de los infractores, ⁵reincidencia, ⁶capacidad económica, ⁷sanciones anteriores, ⁸colaboración a la CMF.
- Todo esto ya lo vimos claramente en la LDLC.
- *Yrarrázaval* espera que la CMF empiece a utilizar verdaderamente estos criterios no como la FNE que no distingue los casos más importantes, y por lo tanto, siempre parte pidiendo el máximo de la sanción. Y, por lo tanto, en vez de poder aplicar estos criterios -que son todos bastante razonables- genera que el TDLC baje la sanción, y, si llega a la CS lo rebaja aún más. Es muy malo como sistema.

IV. TÍTULO IV – PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

- Esto es enteramente nuevo.
- Anteriormente, la ley de la SVS incluía ciertas normas de procedimiento, pero muy pocas y que obviamente a la luz del análisis los Tribunales Superiores de Justicia no

cumplía con el *debido proceso*.

- Lo que hace ahora la ley es incorporar un procedimiento bastante detallado para no tener nuevamente el mismo problema.
- Por muy detallado que sea, indiscutiblemente no puede contener todas las reglas aplicables al procedimiento, y, por lo tanto en subsidio se siguen aplicando las reglas procesales del CPC al igual que en la LDLC.

PÁRRAFO 1º - NORMAS COMUNES

- La ley distingue 2 tipos de procedimientos, y, estas normas son aplicables a los 2 tipos de procedimientos.
- Hay un procedimiento *general* y hay otro *abreviado*, porque indiscutiblemente que hay ciertas materias que deben ser analizadas con mayor profundidad que las otras.

PÁRRAFO 4º - DE LA COLABORACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR

- Aquí se ve la incorporación por 1º vez a este tipo de leyes algo parecido a la *delación compensada* en materia de la LDLC, pero no puede ser idéntico porque hay ciertos aspectos un poco distintos.
- **Art 58**

TÍTULO IV – PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO – PÁRRAFO 4º – DE LA COLABORACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR

Artículo 58- El que incurra en una conducta sancionable por la Comisión podrá acceder a una reducción de hasta el 80% de la sanción pecuniaria aplicable¹, cuando se auto denuncie aportando a la Comisión antecedentes que conduzcan a la acreditación de los hechos constitutivos de infracción.²

En el caso de una infracción que involucrare a dos o más posibles responsables, el primero en auto denunciarse y aportar antecedentes a la Comisión podrá acceder a una reducción del 100% de la sanción pecuniaria aplicable.³ Los restantes involucrados, en tanto, sólo podrán acceder a una reducción de hasta el 30%, siempre que aporten antecedentes sustanciales y adicionales a los ya presentados por el primer denunciante.
(...)

- ¹El que incurra en una conducta sancionable por la CMF podrá acceder a una reducción de hasta el **80%** de la sanción pecuniaria aplicable. Este es un 80% en el caso de la multa NO como en el caso del 1º delator en la colusión que puede optar hasta un 100% de reducción de la multa.
- ²Este % se aplicará cuando se **auto denuncie** aportando a la CMF antecedentes que conduzcan a la acreditación de los hechos constitutivos de infracción.
- ³En el caso de una infracción que involucrare a **2 o más** posibles responsables, el 1º en auto denunciarse y aportar antecedentes a la CMF podrá acceder a una reducción del **100%** de la sanción pecuniaria aplicable. Acá se parece aún más a la *delación compensada*.
- Después, viene una infinidad de exigencias al igual que la LDLC con respecto de cómo debe ser ese tipo de información, qué pasa con esa institución, etc.
- Es una figura importante porque se ha visto que en la LDLC ha funcionado bastante bien a juicio de *Yrarrázaval*, y que aquí también podría hacerlo bastante bien.
- Después, hay ciertas disposiciones generales desde el punto de vista procesal.

V. TÍTULO V – DE LOS RECURSOS

- Este título es muy importante a juicio de *Yrarrázaval*.
- Felizmente está bastante mejor desarrollado que las normas que teníamos anteriormente.
- Aquí, se incorpora claramente algo que anteriormente no estaba tan claro en la ley que es el **recurso de ilegalidad**. En el BC también hay un recurso de ilegalidad, por lo tanto, conceptualmente ya había una noción. En el caso del BC ha funcionado muy bien.
- La *ilegalidad* se produce cuando las **normas de la CMF no se compadecen de las normas de la ley**.

○ Art 68

TÍTULO V – DE LOS RECURSOS

Artículo 68- *Las personas o entidades que estimen que los actos administrativos que emita la Comisión no se ajustan a la ley, reglamentos o normas que le compete aplicar podrán impugnarlos mediante los recursos que señala este título, sin perjuicio de los que sean procedentes de conformidad a las normas generales.*¹

- ¹Las personas o entidades pueden reclamar sobre los actos administrativos de la CMF que no se ajusten a la ley, reglamentos o normas que le compete aplicar.
- Por lo tanto, a juicio de *Yrarrázaval* queda claro que si yo no estoy de acuerdo con respecto de una circular NO puedo reclamar la ilegalidad, esa circular tendría que no estar de acuerdo con las normas de la ley. Esto parece lógico, porque en los casos en que se pudiere reclamar contra la racionalidad, buen sentido, etc nos encontraríamos con un sistema lleno de reclamos de esta naturaleza.

○ Art 69- Recurso de Reposición

TÍTULO V – DE LOS RECURSOS

Artículo 69- *Se podrá recurrir de reposición contra los actos administrativos y sanciones del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda. La petición se formulará por escrito y contendrá en forma clara y precisa los hechos y el derecho en que se fundamenta.*¹
(...)

- ¹*Yrarrázaval* le da poca importancia porque como se presenta ante la misma autoridad -en este caso ante la CMF- indiscutiblemente que es muy difícil ganar un recurso de reposición, salvo cuando hay errores evidentes. Esto también ocurre en los tribunales (cálculos mal hechos, en ciertas frases, etc) pero cabe solo para cosas menores que no afectan el fondo del asunto.

○ **Art 70 – Recurso de ilegalidad**

TÍTULO V – DE LOS RECURSOS

Artículo 70- Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.¹

(...)

Interpuesto el reclamo, la corte deberá pronunciarse previamente sobre la admisibilidad de éste, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto reclamado, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica.²

(...)

- Entra en el detalle del *reclamo de ilegalidad* y lo amplía bastante.
- ¹Se puede presentar el *recurso de ilegalidad* por ilegalidades o perjuicios de normas, instrucciones, comunicaciones, resoluciones o cualquier acto administrativo del **consejo, pdte de la CMF o del fiscal**.
- Esto se amplió en buena forma porque han habido casos, especialmente hubo uno en el BC en el cual el problema surgió de una carta del pdte. La empresa que recibió esa carta del pdte consideró que esa era la posición del BC. El conflicto escaló hasta llegar a la CS.
- Entonces, el *recurso de ilegalidad* se da a partir de la consideración de que hay ilegalidad en un acto administrativo emanado del consejo, del pdte de la CMF o del fiscal. Es muy amplio y es muy bueno que sea así -a juicio de Yrarrázaval- porque siempre se tiene a creer que es toda la CMF la que lo estima de tal manera.
- ²Luego, establece una infinidad de situaciones en las cuales también se puede reclamar de ilegalidad. Pero este *reclamo de ilegalidad* debe contener ciertos elementos claves que si no los tiene será declarado **inadmisible** (ocurre lo mismo en el BC):
 1. especificar claramente dónde está la ilegalidad.
 2. hay que demostrar cómo esa ilegalidad afecta al reclamante.
 3. tiene que demostrar las razones de por qué esa ilegalidad lo daña.

→ Sólo si cumple con ello se declara la **admisibilidad** y continúa el tema en la CA de Santiago y muchas veces posteriormente en la CS.

VI. TÍTULO VI – DEL COMITÉ DE AUTORREGULACIÓN FINANCIERA

- Este es un intento (1º vez que se hace en Chile) de tener para ciertas materias *Comité de Autorregulación*.
- Hay en Chile unos pocos comités de autorregulación formado por las mismas empresas, es el caso de los seguros, en la publicidad también.
- Aquí el tema es más curioso porque es la **ley** la que está creando este organismo, y, hasta el momento no se ha podido implementar este aspecto de la ley porque tiene una composición muy variada, y, ha faltado un cierto interés por conformar este comité de autorregulación.
- Lo importante a juicio de Yrarrázaval es que si existen estos comités o comisiones

de autorregulación hacen posible que cierta normativa, que no es necesario que esté en la ley, sea aplicable a las empresas que conforman esa comisión de autorregulación.

- Este comité es bastante engorroso por lo que no se ha podido implementar.

DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL

- Bajo el dº económico internacional jurídicamente se distinguen 4 temas fundamentales:
 1. **Comercio Internacional (CI)**
 2. **Préstamos Internacionales (PI)**
 3. **Inversión Extranjera (IE)**
 4. **Procesos de Integación Económica**
- Como es internacional, uno de los temas más delicados es ¿qué **normativa** debiera contener la legislación interna de cada país con respecto de estos temas?, ya que además está la normativa internacional. Por lo tanto, la normativa interna no puede repetir el contenido de la normativa internacional.
- La normativa internacional, gran parte surge de **tratados** internacionales. Pero además, existen otro tipo de acuerdos internacionales que juegan un papel muy importante y que no son tratados, por lo tanto, es totalmente voluntario para los países someterse a esas normas.
- Por lo tanto, hay que ir distinguiendo dónde están esas normas: nivel internos, nivel internacional en tratados, o, nivel internacional en otros acuerdos que no son tratados.
- En materia bancaria, ya nos encontramos con **Basilea**, pero Basilea NO es tratado. Los que lo integran NO son los países, sino que son los **banqueros**. Son ciertos banqueros elegidos por esta misma institución. Ha sido fundamental desde el punto de vista bancario porque ha ido a la raíz de la **estabilidad** del sistema bancario.
- Basilea I, II, III, IV son distintos acuerdos que se han referido especialmente al tema del **capital en la relación con las obligaciones que pueden contraer los bancos**, pero cada vez con mayor detalle y más precisiones. Especialmente, cuando Basilea se metió en los **activos riesgosos**, vale decir, que la relación con el capital tenía que hacerse con los activos riesgosos del banco, ahí estaba el tema más delicado desde el punto de vista bancario y NO como se creía en aquel entonces de la relación 1:20 o 1:15 (financieras). Eso se ha ido incorporando en las LGB de los países que así lo deseen. Esto, es igual que la *misión kemmerer*. Ésta sugirió a la autoridad, pero NO dictó ninguna ley.
- La normativa en estos 4 aspectos es muy distinta y tampoco vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero tenemos que distinguir la cantidad de normativa entre cada uno de ellos.
 1. Comercio Internacional (CI)→ ha tenido mucha normativa.
 2. Préstamos Internacionales (PI)→ cada vez tienen menos normativa.
 3. Inversión Extranjera (IE)→ tiene normativa en algunos países y no en otros.
 4. Procesos de Integación Económica→ tienen una normativa enorme cuando estos llegan a una etapa de una UE. Pero, en nuestro caso, no hay normativa al respecto porque todos los procesos de integración económica han fracasado a través del tiempo.

1. COMERCIO INTERNACIONAL (CI)

- En el caso chileno, tenemos varias leyes que impactan este comercio.
 - A) **Ley de aranceles aduaneros.**
 - B) **Ley de aduanas.**
 - C) **Ley sobre las importaciones** (en realidad no se llama así). Dentro de ella, la parte más relevante a juicio de *Yrarrázaval* es la que se refiere a subvenciones y dumping en el CI, que perfectamente podría estar en otra ley.
 - *Durante mucho tiempo también tuvimos las normas cambiarias referente a las importaciones.

A) LEY DE ARANCELES ADUANEROS

- Probablemente sea la legislación más importante respecto del CI en Chile. Es de las leyes más largas. En este momento son del orden de 50 páginas digitales del Diario Oficial porque determina el arancel para cada uno de los artículos que se puede comerciar internacionalmente. El listado es enorme, porque los productos hay que irlos clasificando con detalle de acuerdo a una nomenclatura internacional que existe para el CI. En el CI ya no se habla de los productos en sí, sino que se habla de un número específico, porque ese es el producto que se quiere importar o exportar. Por lo tanto, desde hace bastante tiempo, se incorporó en nuestra legislación y demás legislaciones a través de las partidas arancelarias una **clasificación de los productos** imaginables que se pueden comerciar internacionalmente. Entonces, si se modifica esa clasificación, se debe modificar la Ley de Aranceles, pero, esto se hace muy de vez en cuando y generalmente se refiere a nuevos productos que no estaban contemplados en la clasificación anterior. El resto del contenido es cuánto es el arancel en la importación de esos bienes.
- Al comienzo de la Ley de Aranceles hay algunas excepciones a las que no se le aplica el 6%, por ejemplo, diplomáticos. Pero a todo el resto se le aplica un **6% de arancel**.
- Hay un tema más de fondo en relación con los aranceles que **hasta la CPR de 1980 los aranceles se determinaban por DS del Ministerio de Economía** donde fijaba los aranceles distintos de acuerdo con los distintos productos, y, se podía modificar por medio de DS. Ésta era una de las principales funciones del Ministerio. Pero, en la CPR del 80` llegó a la conclusión de que esto no podía subsistir -al igual que en otros países ya que era una tendencia- porque los **aranceles son TRIBUTOS**. Antes de la CPR del 80` y todavía en otros países se sigue llamándolos *impuestos*. *Yrarrázaval* tiene sus dudas si los aranceles son *impuestos*, pero no tiene ninguna duda de que sean *tributos*. Por lo tanto, la CPR del 80` que por 1ª vez habla de *tributos* -concepto genérico- indiscutiblemente que incluye a los *aranceles*. Y, a partir de aquel entonces, el único que puede modificar, crear o derogar los *aranceles* es el **legislador**, allí se origina esta Ley de Aranceles.
- Los aranceles en la gran mayoría de los países, son **generales**, y, en nuestro caso es de un 6%. Pero, durante mucho tiempo tuvimos aranceles diferenciados, y bastante diferenciados en función de la **Sustitución de Importaciones** (ISI) que fue una política que tuvimos en Chile desde la década del 40` hasta fines de la década del 70`.

Industrialización por Sustitución de Importaciones

- La política ISI no dice que los aranceles tenían que estar diferenciados, pero, está implícito. ¿Quién me dice que si quiero tener aranceles altos deben ser diferenciados? Una lógica fundamental, que los bienes que se importan son bastante distintos en características, impacto, etc. Entonces, para estos efectos, se distinguieron 3 **clases de importaciones**³⁶:
 - i. **Bienes de capital:** utilizados para producir otros bienes. Arancel muy bajo.
 - ii. **Bienes intermedios:** son los que se incorporan en los procesos productivos para llegar al bien final o de consumo. Arancel intermedio.
 - iii. **Bienes de consumo:** listos para satisfacer necesidades. Arancel muy alto.
- La lógica del arancel diferenciado es que **entre la mayor cantidad de bienes de capital desde el extranjero y entre la menor cantidad de bienes de consumo.**
- La idea del modelo ISI es tratar de fabricar internamente la mayor cantidad de productos que se importan. Y, esto aplicado a través del tiempo significó que los bienes de capital prácticamente no se fabricaban en Chile porque tenían un arancel tan bajo que entraban sin problema, y, que los bienes de consumo se producían en su gran mayoría en Chile. Para los bienes de consumo se establecía la **exclusividad** con respecto de los bienes extranjeros. Entonces, el que fabricaba bienes de consumo dentro de Chile solamente competía con los fabricantes dentro de Chile. Por ejemplo, en Chile se fabricaba un whisky que era caro y malo. A veces protegían al chileno con un arancel de un 100% para el extranjero y otras veces con prohibiciones de importaciones para ese producto.
- Por lo tanto, el tema de los aranceles para las empresas establecidas en Chile era un tema vital porque algunas de ellas iban a tener mucha competencia y otras muy poca competencia.
- Se fue dando la tendencia a que los aranceles fueran generales ya que el sistema ISI y de aranceles diferenciados no funcionaban muy bien. Pero, el arancel diferenciado hacía que la función de aduanas fuera muy importante, porque yo podía introducir al país una importación más cara o más barata cara dependiendo de la partida arancelaria que yo convenciera a aduanas que correspondía para ese producto. No todos los aranceles eran diferenciados, e indiscutiblemente que ahí había un manejo muy importante. Hoy día, la función de aduanas es totalmente distinta a la de estar viendo si se le aplica o no tal arancel.
- Los aranceles se clasifican en *ad valorem* y *específicos*. Esto, no tiene nada que ver con los aranceles diferenciados, sino que tiene que ver con cómo calcula la aduana el arancel que ha de pagarse, y, hasta el momento se han descubierto 2 grandes opciones:
 - i. **Ad valorem:** de acuerdo con su valor o precio, y, por lo tanto, hoy en día la categoría de aranceles *ad valorem* es por lejos la **regla general**. La excepción son los aranceles específicos.
 - ii. **Específicos:** se calculan sobre cualquier otra medida, peso, etc que NO sea precio. Son la **excepción**.

³⁶ Esta clasificación es solo para los efectos de aranceles diferenciados en un mecanismo ISI.

→ Es criterio del legislador establecer cuáles serán *ad valorem* y cuáles serán *específicos*.

- El CI ha cambiado tanto en los últimos 40-50 años que la regla general hace 50 años era justamente la contraria, vale decir, la mayoría de los bienes tenía aranceles *específicos* y muy pocos aranceles *ad valorem*. Esta situación cambió radicalmente debido a la **diversificación de las exportaciones**, incluso en países como el nuestro en donde no estuvo diversificada durante muchos años. Pero, la diversificación se ha ido produciendo de una forma impresionante.
- ¿Por qué se ha ido produciendo la diversificación? Hasta la década del 70` no teníamos importaciones diversificadas, pero a partir de la década del 80`, más en el 90`, y aún más en el s.XXI cada vez los bienes son más diversificados. **Se bajaron los aranceles para abrirse al comercio exterior**. En el año 73`, el promedio arancelario en el país era de más del 100%. Como es el promedio, habían algunos bienes con un 200% de arancel (bienes de consumo) y otros con un 10-20% (bienes de capital).
- En definitiva, la baja de aranceles ¿por qué implica exportaciones diversificadas? Cuando hablamos de *rebaja de aranceles*, se refiere a las importaciones. Pero cuando hablamos de la *diversificación en el comercio exterior* se refiere a las exportaciones. Pero, están íntimamente ligadas las unas con las otras a través de la **tecnología**.
- Ejemplo fruta: en la década del 80` era muy poca la exportación de frutas que hacía Chile, y, hoy en día es inmensa y no solamente a 2 o 3 mercados, sino que prácticamente a todos los mercados. Y, los pocos mercados que estaban cerrados a la compra de fruta chilena se han tenido que ir abriendo, por ejemplo, Japón se demoró como 10 años pero se logró gracias a los TLC.
¿Qué hace la tecnología para que productos que anteriormente no se exportaban, se empiecen a exportar? En el caso de la fruta, es espectacular el ejemplo porque se le incorporaron elementos tecnológicos que permitían que la fruta llegara en buena calidad y buenas condiciones a los mercados en cualquier parte del mundo. Esto fue gracias a los sistemas de refrigeración con alta tecnología, los sistemas de transporte con alta tecnología, etc.
- Por lo tanto, lo que ocurrió en países como el nuestro es que no nos dimos cuenta de que el CI estaba cambiando y que era un cambio enorme. Entonces, la teoría de que ciertos países eran monoexportadores o exportaban 2 cosas empezó a eliminarse.
- Todo esto nos lleva a que los **aranceles específicos como regla general pasaran a ser la excepción**.
- Ejemplo TV: podría ser que se asignara el arancel por la pulgadas del TV, pero esto no tiene ningún sentido hoy en día en el sistema internacional ya que no importa el tamaño sino que la calidad y el precio del TV.
- Los aranceles ***ad valorem* son mucho más complicados** que los aranceles *específicos* porque hay que entrar a **determinar el valor o precio** del bien que se está internando al país. Esto lo hace **aduanas**, y, por eso la función de aduanas en las importaciones es muy relevante. ¿Cómo lo hacen? Porque todos los días están llegando bienes con distintos precios dependiendo de dónde vengan, su calidad, etc.

Pero, hoy en día los precios de todos los bienes son **conocidos**. Entonces, lo que hace aduanas es **confirmar** o no ese precio.

- ¿Quién declara que se está internando un determinado bien en el país? El **importador**³⁷, por lo tanto, es él quien tiene que hacer la *declaración de precios*, y, esa es revisada por aduanas. En el Departamento de Valoración de Aduanas están todos en computadores revisando que los precios informados por los importadores correspondan al precio internacional.
- ¿Qué pasa si el importador tiene relaciones especiales con el exportador en el extranjero y el exportador le ofrece un descuento (y de esta manera lo puede vender más barato en el país)? Para efectos de aplicar el arancel aduanero se paga sobre la **base del precio normal**. Muchos dirían que se está castigando las buenas relaciones comerciales, pero se aplica sobre el precio original porque aduanas está aplicando un *tributo* y en los tributos **NO se pueden establecer discriminaciones**. Uno de los temas más complicados para la valoración aduanera es este debido a que aduanas debe aceptar o rechazar ese valor. Este tema podría llegar a tribunales aduaneros o tributarios (es el mismo tribunal).
- La OMC prohíbe el *dumping*, pero no dice nada respecto al nivel arancelario que debe tener los productos.
- El *arancel máximo consolidado* es del **35%** y se calcula especialmente para los **dº compensatorios**. Entonces, si se demuestra que hay subvención en determinada importación o que hay *dumping* (peor), la *Comisión anti-distorsiones* (CAD) puede recomendar al Presidente de la República un dº compensatorio que llegue hasta un 35%.
- La OMC procura por el *libre comercio* y está muy enojada con USA porque éste se ha burlado del libre comercio en 2 casos concretos.
- Pero, la OMC no se pronuncia sobre los % aranceles, y, sobre si éstos debiesen ser *ad valorem* o *específicos*.
- La OMC se ha preocupado de ir limpiando el CI.

11 de junio

B) **LEY DE IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS AL PAÍS (LEY 18.525)**

- Es una ley distinta a la de aranceles, bastante interesante y relativamente corta.
- **Art 1**

Artículo 1- Todas las mercancías procedentes del extranjero al ser importadas al país, están afectas al pago de los derechos establecidos en el Arancel Aduanero o en otras disposiciones legales que los impongan.¹

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior, las exenciones totales o parciales que se establecen en el mismo Arancel, en leyes especiales o en tratados internacionales.²

- ¹Parte la ley señalando que los **aranceles** se aplican solo a las **importaciones**. Y, se aplican a todas las mercancías provenientes del extranjero.

³⁷Para efectos de la ley, somos *importadores todos los que compramos desde el extranjero* (aunque sea 1 unidad). Se supone que los importadores son los que *venden después lo que trajeron al país*, pero si yo no lo vendo, la ley me sigue considerando como importador porque hay que simplificar las cosas.

- El *Arancel Aduanero* determina el arancel que es de un 6%, salvo los casos de excepción.
- Para hacer una importación hay que cumplir algunos requisitos, y el más importante es que el bien pase por aduanas, porque si no pasa por aduanas es **contrabando**. Por eso es que la institución de la *aduanas* es tan importante en materia de importaciones.
- ¿Por qué no hay arancel a las exportaciones?
Salvo algunos países como Argentina que tiene arancel a las exportaciones. Eso tiene un impacto tributario importante en Argentina pero que hoy no tiene ningún sentido porque que deja a las exportaciones de ese país en **desventaja** frente a las exportaciones de otros países. Hoy día, todos los países estamos compitiendo en exportaciones. Si no tuviera ese arancel podría exportar muchísimo más. Argentina si exporta, pero de forma disminuida en comparación de lo que podría exportar sin ese arancel.
- ²Hay excepciones para diplomáticos y otros. Pero, son muy pocas y ojalá que no existan a juicio de Yrarrázaval.

○ **Art 2**

Artículo 2- Forman parte de esta ley los derechos de aduana establecidos para las distintas clases de mercancías en el texto oficial del Arancel aprobado por decreto de Hacienda N° 679, de 1981, publicado en el Diario Oficial de 14 de diciembre de 1981, y sus modificaciones posteriores, así como los derechos que den aplicación al Tratado de Montevideo de 1980, que estableció la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).¹

Asimismo, forman parte de esta ley las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria, las reglas generales complementarias, las reglas sobre las unidades y los envases, las reglas sobre procedimiento de aforo y las Notas de cada partida contenidas en el Arancel a que se refiere el inciso anterior.²

- ¹Forman parte de esta ley los dº de aduana establecidos para las distintas clases de mercancías de acuerdo con las *partidas arancelarias* a nivel mundial. Así, se entienden en el lenguaje internacional.
- ²Luego este art menciona los **TLC**, y, esto es un tema muy relevante porque los TLC se confeccionan sobre la base de **desgravación arancelaria**.
- Hoy día, Chile tiene TLC con el **85%** de su CI. Son 40 tratados distintos. Todos tiene la misma característica de desgravación arancelaria.
- La *desgravación arancelaria* significa que cuando se firma un TLC empieza a través del tiempo una **disminución del arancel** en razón con el arancel general, generalmente en un plazo de 10 años, lo hace **gradualmente**. Generalmente, cada año disminuye un 10% de ese 6%, pero también en estos TLC se liberan de aranceles desde el día 1 una cantidad muy impresionante de bienes. Se deja entonces en esta desgravación a través del tiempo a los bienes más sensibles hasta llegar a 0% de arancel.
- Esto ha cambiado el CI porque lo mismo que ha hecho Chile lo ha hecho la gran mayoría de los países.
- Estos son tratados **bilaterales** NO multilaterales. Pero, tenemos un tratado con la

- UE, pero es como un solo todo.
 - El que sean bilaterales genera un problema no menor ¿cómo identifico a un bien como chileno o como chino? La ley dice que si el 50% del producto se produce en Chile es chileno, para esos efectos los exportadores hacen declaraciones juradas y cosas por el estilo, con sanciones bastante fuertes.
- **Art 5 – Base imponible de los dº ad valorem**

Artículo 5- La base imponible de los derechos ad valorem estará constituida por el valor aduanero de las mercancías que ingresen al país. Dicho valor aduanero será determinado sobre la base del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (en adelante Acuerdo sobre Valoración Aduanera) y del artículo 7º de esta ley.¹
 (...)

- Los dº *ad valorem* hoy en día son la regla mayoritaria (muy mayoritaria), y las excepciones son los *específicos*.
- ¹La ley se va directamente al tema neurálgico de los dº *ad valorem*, ¿cómo se calcula el valor de los bienes que están entrando al país? Y se calculan **sobre la base del bien cuando llega a Chile**, por lo tanto hay que agregarle el flete, los seguros, etc. (muy relevantes en el CI).

INCOTERMS

- Esto tiene que ver con los **incoterms** (*International Commercial Terms*) **CIF** (*Cost, Insurance and Fee*) que se refiere al precio del bien sobre el costo, seguro y flete. Es lo mismo que referirse al precio hasta que llegue a la aduana en el caso chileno. Esto no incluye el pago de los dº de aduanas en Chile, ni el IVA, ni el bodegaje, ni el traslado dentro de Chile, sino que es el bien puesto en alguna de las tantas aduanas de Chile.
- Esto refleja una realidad, que la cámara de CI tiene 11 precios distintos para el CI. Esos precios van desde el menor para el comprador/importador hasta el mayor para el comprador/importador.
- El precio **menor** se denomina **ex fábrica** (puesto en fábrica) que es el precio que tiene el bien en la fábrica o dónde opere quien lo va a vender. El importador/comprador asume todos los gastos desde que se compra el bien hasta que se traslada dentro del país en que compró, el flete a Chile, seguro a Chile hasta que llegue a sus manos. Por lo tanto, el precio es el más bajo porque el exportador/vendedor solamente tiene el costo de fabricación.
- El precio **mayor** se denomina **DDP** (*Duty, Deliver, Pay*) y éste implica que el vendedor lo va a tener que dejar donde el comprador quiera. Por lo tanto, ese vendedor tendrá que asumir el flete, los seguros, los dº de aduanas, el IVA cuando llegue a Chile hasta que llegue ese bien donde el vendedor indicó. Este es el más caro de todos y es el que generalmente se hace en los *courrier*.
- Los **incoterms** establecen 11 posibilidades distintas de precios internacionales, y son el comprador y vendedor los que tendrán que elegir cuál les gusta más. Va a depender de la **experiencia** que tenga el importador. Los que no tienen experiencia van a utilizar el DDP porque es más práctico.

- Lo más curioso de estos *incoterms* es que son **recomendaciones** de la **Cámara de Comercio Internacional de París**. No están en ninguna ley. Pero, no se van cambiando ciertas partes en cada caso porque le iría pésimo en CI a esa empresa. El CI tiene un lenguaje, y, el lenguaje de los precios es éste, no el que se le ocurra un precio distinto.
 - También porque en el CI hay otra normativa a nivel de tratado que es muy importante que es la **Convención de Viena (CV) de Compraventa Internacional**. Esta fue firmada en el año 90` después de una larguísima discusión. Este tratado debe ser aprendido de memoria por cualquier importador o exportador porque porque la gran mayoría de las transacciones en el CI son compraventas. Lo que hizo la CV es combinar en un solo texto de compraventa internacional las normas de compraventa anglosajonas con las de dº continental. Por eso la negociación de la CV duró 10 años por los juristas más importantes existentes tratando de ver cómo se podían arreglar las diferencias de compraventas entre ambos sistemas jurídicos.
 - **Por lo tanto la CV + los incoterms me dan a nivel internacional para el comercio un lenguaje común que es muy importante.** Es tan común este lenguaje que los mismos contratos de compraventa internacional son sencillísimos, simplemente se dice que se compra un bien a tal precio -que ni siquiera debe ser por escrito (mail, teléfono, etc)- porque todo lo demás se rige por la CV + *incoterms*. Por eso que en esta materia, felizmente hay muy pocos conflictos, y, los que hay son generados por los que no saben de CI.
- La ley de Importaciones tiene otro aspecto un poco distinto a los aranceles, que se refiere a **3 situaciones negativas en el CI**:
 - 1. Salvaguardias**
 - 2. Dumping**
 - 3. Subvenciones a las exportaciones**
 - Lo que tienen en común es:
 - a) buscan enfrentar una situación anómala en el CI.
 - b) son analizadas por una comisión que en Chile se llama **anti-distorsiones de precios en el CI**, que generalmente se denomina como *comisión anti-distorsiones (CAD)*.
 - El origen de todo esto es la Organización Mundial del Comercio (OMC).

OMC y GATT

- La OMC es la sucesora del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). El GATT fue creado con la finalización de la 2GM para **garantizar la libertad en el CI**. Fue GATT hasta la década del 90`, y, desde ahí en adelante en *Marrakech* -donde se reúnen los 1º mandatarios- se llama OMC.
- Cuando se formó el GATT, los países fundadores fueron del orden de 35, y eran los países ganadores de la 2GM. Por lo tanto, estos países empezaron a liberalizar su CI en el sentido de rebajar aranceles, eliminar prohibiciones, eliminar cuotas, eliminar cupos, y distintas formas que se han creado para restringir el CI.

- Desde aquel entonces en adelante, han ido adhiriendo al GATT una multiplicidad de países. Hoy día, el último fue el Nº 186.
- El último país muy importante que adhirió fue China. China se mantuvo al margen del GATT y de la OMC hasta que tomó la decisión de adherir porque en ese momento China tenía que estar de acuerdo con el objetivo fundamental del GATT (libre CI) y de acuerdo con una cantidad de medidas que exige el GATT/OMC. Si a un país no le gustan esas reglas, se sale de la OMC. China había aumentado su comercio gracias a la **piratería de la propiedad industrial e intelectual**. China dice que las limitaciones que da el GATT tienen un límite y siguen pirateando. Luego de 10 años de negociación, China firmó un tratado que tiene un período transitorio de otros 10 años.
- Fue la OMC y el GATT anteriormente que dijo que los países se podían defender en contra de la salvaguarda, dumping y subvención a las exportaciones siempre que crearan una **comisión**. En Chile es la CAD.
- La comisión en Chile es de carácter administrativo.
- Chile adhirió al GATT en la década del 80`, por lo que esta CAD es de la década del 80`. Está presidida por el FNE, 2 representantes del BC, representantes de aduanas, representantes del Ministerio de Hacienda, Economía, RREE y Agricultura. Son 9 en total. Esto está indicado en el art 11.
- Lo que hace la CAD es **analizar las denuncias** que se le hagan, NO funciona de propio oficio, sino sobre la base de denuncias. Y, la labor de los denunciantes no es fácil porque tiene que probar 2 elementos:
 1. La existencia del dumping, la exportación subvencionada o una situación general para aplicar una salvaguarda.
 - ✓ Esta ha sido una de las grandes dificultades para la denuncia de productos brasileiros porque según los propios abogados brasileiros el sistema de subvenciones a las exportaciones en Brasil es inexplicable porque está dispersa entre toda su legislación.
 - ✓ El peso de la prueba aquí lo tiene el denunciante, la CAD no hace ninguna investigación. Si el denunciante no lo hace, la denuncia va a fallar.
 2. El grave perjuicio para la producción interna.
 - ✓ Esto también lo tiene que probar el denunciante.
 - ✓ A juicio de *Yrarrázaval* esto es más fácil que probar la existencia porque cualquier buen economista o ingeniero puede hacer este un análisis perfectamente.
- Lo que hace la CAD es **analizar las denuncias**, y, **recomienda** al Pdte de la República la aplicación de un **dº compensatorio**. La decisión de si se va a aplicar o no el dº compensatorio es **exclusiva** del Pdte de la República, y, así lo ha sido siempre. Esto porque él es el **encargado de conducir las RREE**.

Dº COMPENSATORIO

- El dº compensatorio es para un **cierto producto proveniente de un solo país**, NO afecta a todas las exportaciones de ese país. Ahí, se produce la paradoja de que los países afectados lo toman muy en serio.

- Entonces, cuando se hace la denuncia se publica en el Diario Oficial los elementos más fundamentales para efectos de publicitarlo, y, el embajador de ese país está al otro día en La Moneda hablando de ello. Esto porque afecta mucho al CI a pesar de que sea un solo producto de ese país. Lo que dice ese embajador es que si no se resuelve bien, se van a aplicar medidas reparatorias a los productos chilenos que llegan a ese país.
- El problema que tenemos es que nuestra economía es chica, entonces, por lo general los Pdtes de la República desde la década del 80` en adelante no han aplicado dº compensatorios. Los que aplican dº compensatorio son la UE, USA, China porque eso me afecta las relaciones económicas internacionales.
- En resumen, este mecanismo termina bajo una decisión presidencial.
- ¿Qué es el dº compensatorio propiamente tal?
Imaginemos que se le aplica un dº compensatorio del 10%. Una posibilidad es que se modifique el arancel, entonces en el arancel se le incorpora al 6% un 10% adicional. Esa NO es la forma porque las modificaciones de aranceles desde la CPR del 80` se hacen por ley porque es muy claro que es un *tributo*. Además, que no tiene sentido incluir en el arancel esto que pertenece a algo distinto. Entonces, el dº compensatorio se aplica **por encima del arancel**, entonces si el arancel es del 6%, es un 6% + 10%, si es del 0%, el arancel será de 10%.
- El dº compensatorio puede llegar a un **35%**.
 - Y, de este orden fue el que amenazó *Trump* a México si en 45 días no arreglaban los problemas migratorios.
- La aplicación de un dº compensatorio es casi como una *apuñalada en la espalda*.

SITUACIONES NEGATIVAS EN EL CI:

1. Salvaguardias

- ✓ Se refiere a toda una rama de la producción interna la que reclama en contra de una importación de otro país por estar pasando por un período muy exitoso.
- ✓ No se ha aplicado hasta ahora en Chile.

2. Dumping

- ✓ Es lo mismo que los *precios predatorios* en materia de LC pero aplicadas en el CI.
- ✓ Vale decir, una empresa en el extranjero que venda más barato al mercado chileno para apoderarse del mercado enteramente o parcialmente.
- ✓ En el CI, es una PR pero se le puso el nombre de *dumping*.
- ✓ Caso Codelco-Alemania: en Alemania se demandó a Codelco por infringir estándares medioambientales reconocidos a nivel internacional. Se demandó sobre la base de que Codelco estaba haciendo *dumping* porque como no cumplía con esos estándares, permitía que Codelco fuese más eficiente que otras productoras. Codelco ganó ese juicio con mucha dificultad.

3. Subvenciones a las exportaciones

- ✓ Son más difíciles porque son hechas con dineros fiscales, por exenciones o con subvenciones, pero lo que se exige de acuerdo con la regla es que esta

sea una subvención a las exportaciones, pero no a cualquiera, sino que a determinadas exportaciones.

- ✓ Pero los países son libres de tener las subvenciones que quieran, pero no pueden hacerlo con aquellas que van a afectar el mercado de otro país al que lleguen estos productos.
- ✓ Caso Brasileiro: estos productos llegaban a todas partes del mundo a precios insuperables.

EXPORTACIONES

- No tienen ley y no es necesaria una ley.
- La *Ordenanza de Aduanas* nos define qué es una exportación. Señala que es **todo envío legal de mercadería al extranjero para ser usado o consumido en el extranjero**. Vale decir, lo contrario a la importación.
- Se agrega la palabra *legal* porque tiene que salir por aduanas ya que si no pasa por allí es *contrabando*. El contrabando se puede producir tanto al nivel de importaciones como de exportaciones.
- Caso Loza Penco: es uno de los fraudes tributarios más grandes que han existido en el país. Lo que hacía esta fábrica es que exportaba casi el 100% de lo que producía y cuando las naves llegaban a la alta mar se botaban las piedras que se habían exportado, para conseguirse del fisco la devolución del IVA. Gracias a esto, Loza penco se financió casi todos los años. El Fisco lo estaba financiando gracias este fraude enorme. Esto porque desde hace mucho tiempo en Chile las **exportaciones no están afectas al IVA**, esto porque la gran mayoría de los países no la grava con IVA.
- Los costos incurridos por las empresas exportadoras en los productos que exportan, se les **devuelve el IVA** por el Fisco.
- El control de las exenciones de IVA son muy complicadas, por eso que a pesar de que la exportación misma no está afecta al IVA, las otras compras de bienes que se compran por parte de la empresa exportadora si están afectas por lo que se hace la devolución. La gran mayoría de los países han ido eliminando estas exenciones salvo en la venta final.
- Hay otro sistema de subvención a las importaciones -que existió en Chile y desapareció- que consistió en una **devolución del Fisco de un % de lo exportado**. Es lo que se llamaba **reintegro**. Se debía probar lo que se vendió y el Fisco le devuelve el 10% de lo que se obtuvo. Esto es lo que se conocía como **subsidio directo**. En Chile, lo tuvimos para las **exportaciones no tradicionales**. Esto es bien difícil porque depende de cuántos años lleva exportandose ese bien.
- Lo que sí afecto a las exportaciones como a las importaciones fueron los **controles cambiarios**.
 - Hoy en día ya NO existen los controles cambiarios, pero perfectamente pueden volver, como ocurrió en Argentina y otros países.
 - Con este sistema, toda exportación e importación tiene que ser **autorizada** por el **BC**. El BC no está obligado a aprobar ninguna importación ni exportación. Esto porque está vinculado con el control cambiario.

- Dentro de la balanza de pagos los ingresos y salidas más importantes en términos numéricos son de las importaciones y exportaciones. **75 mil millones de dólares** de exportaciones al año, lo mismo en las importaciones. Entonces, hablamos de una parte muy significativa desde el punto de vista cambiario.
- Cuando partió este control -año 32`-, todos los exportadores estaban **obligados a retornar las divisas** que obtuvieran en cualquier parte del mundo, y, a todos los importadores se les daba **acceso** al mercado cambiario para poder comprar en el extranjero. Esto porque tuvimos **escasez de divisas** -del 29` al 35`- en razón de la *gran recesión*.
- **Las divisas de los importadores dependen de las divisas que los exportadores traigan al país.**
- Este control por parte del BC que no dice ninguna relación con la importancia ni la visión que se tenga de la exportación e importación, sino que es un tema cambiario. Y, era muy exigente con respecto de los exportadores porque de partida debía devolver el 100% de lo que obtuviera (NO de las utilidades, sino de lo recibido por venta, seguros, fletes, etc), y, se le ponía un plazo para devolver, y, si no cumplía dentro del plazo incurría en **delito cambiario**. Y, una vez que esa divisa llegara al país, estaba obligado a vender al BC de Chile al precio que éste determinase.
- Tratamiento de exportadores se resume en: 100%, plazo, y venta final al BC.
- Este tratamiento de los exportadores era para que los importadores tuvieran las divisas necesarias para importar.
- Esto terminó en Chile parcialmente con la LOC del BC y totalmente en el año 2000. Vale decir, tuvimos 68 años de controles cambiarios.

2. PRÉSTAMOS INTERNACIONALES (PI)

- Tampoco hay normas para los PI ni dentro de Chile ni fuera de Chile.
- El PI tanto como la inversión extranjera (IE) son divisas que entran al país y luego salen.
- Diferenciación PI VS IE
 - ¿Cómo se incorporan a las empresas?
 - El **PI** se diferencia de la IE en que **entran a los pasivos con 3º** que tiene la empresa deudora que recibe el PI. Y, eso tiene un *contrato de préstamo* que tienen muchas páginas (aprox 100-150 páginas) porque vienen de países que tienen un sistema jurídico distinto al nuestro. Por lo tanto, el *contrato de préstamo* tiene que definir una serie de temas que están en el CC, en el Código de Comercio, y, que deben ser inteligibles para el acreedor de Japón, China, USA, Europa, etc. El PI se paga de acuerdo con el *contrato de préstamo* y se paga el interés sin importar si a la empresa que pide el préstamo le ha ido bien, regular o mal.
 - En cambio, la **IE** llega al **capital** de la empresa deudora, que también está en los pasivos, pero en los **pasivos respecto de los dueños**. Entonces, si a la empresa receptora le va regular o mal, el inversionista extranjero no puede remesar ninguna utilidad.
 - ¿Cuánto tiempo permanecen?
 - Por lo tanto, la **IE** -por regla general- **queda en el país por muchos años**. Por lo

- tanto, el tratamiento que generalmente se le ha dado a la IE ha sido más favorable que el que se le ha dado a los PI.
- Los **PI**, por el contrario, **entran y salen** dentro de los plazos contratados.
 - Lo que tienen en común ambos es que son **divisas** las que entran o salen.
 - Tipo de aportes
 - En el caso de la **IE**, además de divisas se pueden hacer **aportes distintos** de divisas.
 - En el caso de los **PI** son **solamente divisas**.
 - **No hay legislación respecto de los PI** porque son **relaciones entre particulares** (acreedores y deudores), y, por lo tanto, lo que les suceda son problemas de ellos. Nunca han tenido regulación, salvo desde el punto de vista cambiario.
 - Respecto del punto de vista cambiario, durante mucho tiempo se exigió que todos los PI fueran registrados en el BC y fueran autorizados por éste. Pero esto terminó hace bastante tiempo.
 - Cambia el asunto con respecto de la **deuda pública externa**, vale decir, esto es *financiamiento desde el extranjero a las empresas del Estado* (préstamos).
 - Ya no es una contratación entre partes, sino que el deudor es el Eº, sus empresas u órganos.
 - Esta **deuda pública** tiene muy pocas normas, y las normas están en la Ley de Administración Financiera del Estado.
 - Son normas de cuándo se puede emitir deuda pública.
 - El problema de la **deuda pública** es que puede generar un tema cambiario muy complicado porque no hay suficientes divisas para pagar la deuda pública externa.
 - Ese fue el drama que tuvimos que pasar en la década del 80`. No solo Chile tuvo problemas, sino que la gran mayoría de los países. Chile tuvo 8 años de negociación de la deuda pública externa. Fue muy complicado porque la contraparte del Eº chileno eran 500 bancos (de distinto tipo). Chile tuvo que negociar con todos ellos en su conjunto para poder pagar. Hay ciertos países que trataron de resolver este tema diciendo que no iban a pagar porque no tenían divisas -como el caso de Argentina- y, eso tuvo graves consecuencias desde el punto de vista político y económico.

12 de junio

3. INVERSIÓN EXTRANJERA (IE)

- Tenemos normativa en materia de IE desde la década del 40`.
- Curiosamente surgió esta normativa a raíz de la 2GM y la declaración de guerra que hizo Chile en el año 42` a Japón, Alemania e Italia. Se contempló la posibilidad que el Presidente de la República pudiera contratar con inversionistas extranjeros para que vinieran a Chile en condiciones que el Presidente de la República lo determinara. Este fue el origen del **Estatuto de Inversión Extranjera**.
- Desde aquel entonces en adelante hemos tenido alrededor de 7 u 8 *Estatutos de IE*. Este Estatuto siempre ha sido relativamente simple porque contempla solamente ciertos aspectos del tratamiento legal de la IE, lo que se denomina generalmente como *dº del inversionista extranjero*. Estos aspectos están referidos especialmente a materias **cambiarías, tributarias y de no discriminación** (igualdad ante la ley). Estos son los 3

grandes temas que han estado presentes en todos los *estatutos de IE*.

- La ley actual es la 20.848 del año 2015 que viene a reproducir los *dº del inversionista extranjero*.

LEY 20.848 – ESTABLECE MARCO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CHILE Y CREA LA INSTITUCIONALIDAD RESPECTIVA

- Empieza definiendo al *inversionista extranjero*.

I. TÍTULO I – DEFINICIONES Y RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA

PÁRRAFO 1º – DEFINICIONES

- **Art 3 – Definición inversionista extranjero**

TÍTULO I – DEFINICIONES Y RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA – PÁRRAFO 1º – DEFINICIONES

Artículo 3- Para efectos de esta ley se entenderá por inversionista extranjero a toda persona natural o jurídica constituida en el extranjero, no residente ni domiciliada en Chile, que transfiera capitales a Chile, en los términos del artículo anterior.

- ¿Qué es lo que hace que sea extranjero? Es la **residencia o domicilio fuera del país**. Por lo tanto, cualquier chileno o empresa chilena que se instale en el extranjero y desde ahí haga una inversión es considerado un inversionista extranjero para los efectos de la ley. Por el contrario, cualquier extranjero domiciliado o residente en Chile no es un inversionista extranjero, sino un *inversionista interno*.
- Esta clasificación de inversionista extranjero es la única forma posible, sino es demasiado complicado.
- Entonces, la residencia y domicilio es un criterio fundamental para esta materia.
- ¹La definición de *inversionista extranjero* para la ley es la siguiente: ***“toda persona natural o jurídica constituida en el extranjero, no residente ni domiciliada en Chile, que transfiera capitales a Chile”***. Tiene que ser una transferencia **real**.

A) MATERIAS CAMBIARIAS

- **Art 2 – Definición capitales**

TÍTULO I – DEFINICIONES Y RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA – PÁRRAFO 1º – DEFINICIONES

Artículo 2- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 2º de este Título, se entenderá por inversión extranjera directa, la transferencia al país de capitales extranjeros o activos de propiedad de un inversionista extranjero o controlado por éste, (...)

- Los capitales pueden ser de distintas formas. El más importante es el de *divisas* o monedas extranjeras. Por lo tanto, el inversionista extranjero no aporta pesos, sino que aporta moneda extranjera. Y, va a tener un *contrato de inversión extranjera* expresado en monedas extranjeras, o, un *certificado en moneda extranjera*.
- Esto es así porque al inversionista le importa el dº en moneda extranjera -no en pesos- y por eso, la garantía la da el Eº en moneda extranjera y no en pesos. Cuántos pesos resultan de esa liquidación da lo mismo para estos efectos, lo

- importa es que transfirió realmente al país x cantidad de moneda extranjera.
- Los aportes en moneda extranjera o en **divisas** son totalmente mayoritarios, vale decir, del orden del 90% de la IE se hace en divisas.
 - Pero, ¿en qué se hace el 10% adicional? En **bienes físicos en todas sus formas o estados**. Pero, ¿cómo se valoran esos bienes físicos? Esto se traduce es un **certificado o contrato expresado en moneda extranjera**. La ley chilena adoptó un criterio bastante práctico, por lo tanto, para estos efectos -para valorarlo- se le trata como si fuera una importación. Pero NO es una importación, sino una inversión.
 - ✓ Los aportes de bienes físicos se dan en proyectos de construcción de ingeniería importantes porque al inversionista extranjero le interesa trabajar con sus equipos o con los equipos que conoce. También en minería.
 - El aporte también se puede hacer en **tecnología**.
 - ✓ Éste aporte es más complicado aún.
 - ✓ Muchas de estas empresas extranjeras han desarrollados ellas mismas desarrollos tecnológicos muy relevantes. Por ejemplo, en materia bancaria.
 - ✓ El problema es que la tecnología debe de ser valorada, y esa valoración es sumamente compleja. Entonces, esto ha hecho de que a pesar de que podrían haber muchos mayores aportes en tecnología, terminan entrando como divisas y no como tecnología.
 - ✓ Ha habido pocos aportes en tecnología por la razón dada anteriormente.
 - En resumen, las distintas formas de hacer IE son:
 - i. divisas (90% aprox)
 - ii. bienes físicos (10% aprox)
 - iii. tecnología (muy poco)

→ Después, como aportes la ley contempla otros 2.

 - iv. Los aportes que se hicieron como **préstamos** y que se capitalizan como inversión en la empresa receptora.
 - Esto entra como préstamo y después se transforma en inversión.
 - Se transforma el préstamo a capital y para esto tiene que haber un acuerdo entre el que otorgó el PI y la empresa que lo pidió.
 - En definitiva, en un momento dado por distintas razones, la empresa quiso bajar la cº de préstamos con respecto a 3º incorporando así a la institución que dio el préstamo y que está dispuesta a entrar como *accionista* o *socio* de la empresa.
 - Esto se produce en pocas situaciones.
 - Se hace esto porque las cosas van cambiando dentro de las empresas.
 - v. El otro aporte es cuando las **utilidades** que pueden ser remesadas por el inversionista extranjero **se reinvierten dentro de Chile**.
 - Entonces, el inversionista extranjero renuncia a remesar para los efectos de reinvertir, y ahí, se le reconoce esa parte como un aporte.
 - **El prestamista está en un condición de menos riesgo que el inversionista.**
 - Los bancos chilenos solo pueden ser accionistas de empresas a título excepcional, vale decir, cuando hay remates públicos, cuando le conviene a ese banco quedarse

con esa empresa, etc, pero después en la LGB se obliga a vender dentro de 2 años generalmente.

- Lo mismo ocurre con los bancos extranjeros, que generalmente no están interesados en ser accionistas, pero algunos pueden estar interesados por una situación coyuntural, y de esta manera, que esta transformación de PI a IE salve a la empresa.

PÁRRAFO 2º – RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA

○ Art 5

TÍTULO I – DEFINICIONES Y RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA – PÁRRAFO 2º – RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA

Artículo 5- *El inversionista extranjero tendrá derecho a remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas que sus inversiones generen, una vez cumplidas todas las obligaciones tributarias que correspondan de acuerdo a la normativa nacional.¹*

- ¹Aquí hay 2 conceptos que son claves en materia de IE la **remesa de utilidades** y la **repatriación del capital**. La ley no es tan clara con respecto a cuándo corresponde a la utilización de uno y del otro.

i. Remesa de utilidades

- ❖ La remesa de utilidades es de las **utilidades generadas por la empresa receptora**.
- ❖ Toda IE tiene una **empresa receptora**, la cual puede ser una SA abierta, cerrada, limitada, SPA, etc. Es receptora de la IE.
- ❖ El % de IE que recibe da lo mismo, puede ser de un 1% o el 100%. La ley en Chile no hace distinción.
- ❖ Lo que sí, el único que tiene **dº a remesar es el inversionista extranjero** y a condición de 2 factores:
 - 1- que se generen las utilidades.
 - 2- que pague los impuestos que corresponden a esa remesa de utilidades.
 - Generalmente las remesas han estado afectas a un **35% de impuesto a la renta**.
 - Este impuesto se genera por la remesa, en otras palabras, si no se remesa, y, se **reinvierte** dentro del país **no se paga impuesto a la renta por este concepto**.
 - Por lo tanto, nuestro sistema tributario tiene un **incentivo** a la **reinversión** dentro del país.
 - Los accionistas de la empresa extranjera ya pagaron los impuestos de 1º categoría que grava a la empresa. Muchos creen que al reinvertir no se paga este impuesto de 1º categoría, pero se hace de todas formas.
 - ¿Cómo se garantiza que se pague este 35% de la remesa? Se le **cobra a la empresa receptora**. Este mecanismo existe en Chile y en otros países, e implica que cuando de alguna otra forma se puede evadir el impuesto, llega la ley y le dice a la empresa receptora que

debe retener la totalidad del impuesto, y, si no lo hace son **responsables**. Es lo mismo que ocurre con las *honorarios*.

- ❖ ¿Qué diferencia esta remesa con el pago de intereses de un préstamo? En ambos casos salen divisas del país, ambos están gravados, pero, el pago de los intereses tiene un régimen tributario totalmente distinto, y, se aplica solamente a los préstamos, NO hay pago de intereses en la IE.

○ **Art 6**

TÍTULO I – DEFINICIONES Y RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA – PÁRRAFO 2º – RÉGIMEN APLICABLE A LA IE DIRECTA

Artículo 6- El inversionista extranjero tendrá derecho a acceder al mercado cambiario formal para liquidar las divisas constitutivas de su inversión.¹
(...)

- ¹El art 6 cierra este tema señalando que el inversionista extranjero tendrá **dº a acceder al mercado cambiario formal (MCF)** para liquidar las divisas constitutivas de su inversión.
- Una cosa sería la mera declaración (art 5) pero el art 6 dice que tiene dº a acceder al MCF. Esto es para comprar todas las divisas necesarias para la remesa. Esta empresa receptora funciona en pesos NO en divisas.
- Hasta antes de la existencia del MCF, esto era una atribución del BC. El BC le daba acceso o no dependiendo de los criterios que tuviera.
- Ahora, en cambio se constituye el MCF con la Ley del BC del 89', y con esto se dice que el Eº garantiza a los que operen en Chile el dº a acceder a ese mercado. No garantiza ningún precio en particular, sino el dº a acceder.
- Esto se garantiza porque en el pasado no se hacía. Y, como la facultad era totalmente discrecional, habían ciertos importadores que al no tener acceso al MCF no podían importar.

ii. Repatriación del capital

- ❖ Se refiere a cuando el ***inversionista vende su inversión en el país, total o parcialmente.***
- ❖ Esta venta se hace en pesos por comprar una parte o la totalidad de la inversión que hizo en el país.
- ❖ Cuando se envían esas divisas al extranjero, se denomina *repatriación del capital*. Lo que se está devolviendo es el capital de la empresa, NO se están devolviendo utilidades.
- ❖ En definitiva, lo que se está enviando al extranjero es el capital (por el precio que se vendió, que puede ser mayor o menor al invertido).
- ❖ Tiene mucha importancia porque las repatriaciones de capitales **NO están afectas al impuesto a la renta** porque **NO son utilidades**. Es capital, no utilidad.
- ❖ Ahora se han creado una serie de subterfugios para gravarlo de todas formas, pero ese es otro asunto. Conceptualmente, la devolución de capital no está afectada a este impuesto.
- ❖ La repatriación de capital tiene el mismo **dº de acceso al MCF**.

B) MATERIAS TRIBUTARIAS

- Con el transcurso del tiempo, se ha contemplado tanto en IVA como en renta ciertos dº tributarios para el inversionista extranjero.
- El de renta prácticamente no ha funcionado y el de IVA ha funcionado muy poco.
- Estos dº se refieren a la **invariabilidad tributaria**, vale decir, el inversionista extranjero tiene dº a solicitar cuando entra al país un régimen de invariabilidad en el impuesto a la renta, entonces, si entró a un país con un sistema en el cual todos los impuestos a la renta (4 tipos) ascienden por ejemplo a un 45%, con este dº puede exigir que éstos se mantengan en un 45%.
- En Chile, esa invariabilidad no ha sido atractiva para los inversionistas extranjeros ya que por lo general está por encima del régimen tributario general.
- El sentido que tiene es que el inversionista extranjero tema que en el futuro la carga tributaria del impuesto a la renta aumente y ahí se pueda empezar a beneficiar de la invariabilidad.
- Si empiezan a disminuir los tributos, pueden renunciar a este dº de invariabilidad. Pero, los inversionistas extranjeros pueden renunciar 1 sola vez al régimen de invariabilidad. Entonces, si lo piden y ven que no les conviene, pueden renunciar pasándose al régimen general.
- La idea es que en el momento que entran al país tomen la decisión de adoptar o no el régimen de invariabilidad.
- En el impuesto del IVA el asunto se prestó para problemas regulatorios bastante importantes. Eran tantos los requisitos que se ponían para acceder a una exención de IVA en la importación de determinados bienes, que se ha empleado muy pocas veces.

C) NO DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DEL INVERSIONISTA EXTRANJERO (IGUALDAD ANTE LA LEY)

- Este tema ha estado en nuestra Ley de IE desde la década del 70` en adelante. Incluso antes que el 19 N° 22 de la CPR (sobre la no discriminación arbitraria en materia económica).
- El temor es que se favorezca a los inversionistas internos o a determinados inversionistas extranjeros.
 - El 2º caso (favorecimiento inversionistas extranjeros) se produce especialmente en las licitaciones.
 - ✓ Hay una cantidad enorme de problemas que se generan en las licitaciones en materia de LC.
 - ✓ Caso Odebrecht: la empresa brasilera se ganaba las licitaciones en todo LA con **coimas**, y por eso que el presidente *Lula* está en la cárcel.
 - ✓ El tema de que la licitación sea *abierta y transparente*, no solo depende de la normativa jurídica, sino que tampoco hayan coimas.
 - ✓ Los europeos también hacían coimas en la década del 70` y 80`, especialmente empresas españolas e italianas (a un partido político que desapareció).

- ✓ Esto complica a las empresas extranjeras honestas porque saben que no van a poder competir con estas otras.
- En el caso de nuestra ley, existió antes de la norma constitucional una modalidad bastante curiosa de reclamo por toda discriminación. Se hacía un requerimiento al Comité de Inversión Extranjera, y, si éste rechazaba la petición, se iba a los Tribunales Superiores de Justicia. Esto ocurrió en 1 o 2 casos.
- Caso inversionistas malayos: querían hacer una inversión en Pirque. Cuando llegan, de las 1ª cosas que hacen es visitar al Pdte de la República, y éste les dijo bienvenidos. Entonces, los inversionistas creyeron que no tenían por qué ceñirse a la legislación interna porque ya habían recibido todas las autorizaciones al caso. Y, cuando empezaron a pedir permisos para comenzar el proyecto inmobiliario en Pirque, se los rechazaban. Entonces, los inversionistas se fueron del país y demandaron al Estado de Chile ante el CIADI.
- En materia de IE hay 2 tipos de tratados bien importantes.
 - i. **Tratados de Protección de las Inversiones**
 - ❖ Chile tiene como 40 de estos tratados. Curiosamente tiene como 40 TLC, pero no necesariamente corresponden los países.
 - ❖ Son tratados **bilaterales** y en los que **Chile se compromete a tratar a los inversionistas extranjeras de forma no discriminatoria**.
 - ❖ Por ejemplo, uno de los 1º tratados que tuvimos fue con Alemania, y, esto garantizaba que las empresas alemanas que hicieran inversión en Chile tenían un trato de no discriminación muy especificado, y, que a la vez las empresas chilenas en Alemania tendrían el mismo trato en Alemania.
 - ii. **Tratados de Solución de Conflictos en materia de IE**
 - ❖ El tema se complica con este 2º tipo de tratados.
 - ❖ Se han ido juntando con los 1º, pero no necesariamente van juntos.
 - ❖ Se creó a nivel del Banco Mundial un sistema para la solución de conflictos entre los Eº y los inversionistas extranjeros.
 - Este tribunal se conoce como **CIADI** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) / **ICSID** (International Centre for Settlement of Investment Disputes), y, tiene su sede en Washington.
 - Caso Clarín: el gran caso chileno es el del diario clarín que fue expropiado en el año 74'. Por esta expropiación, fue demandado el Eº chileno por 500 millones de dólares ante este tribunal. Y, por la buena defensa, se terminaron pagando solo 5 millones de dólares. Porque de partida, no era muy claro que el demandante fuese un inversionista extranjero, ya que era un ciudadano con doble nacionalidad (chilena y española), y todo esto era por un caso anterior a que Chile adhiriera a este sistema de resolución de conflictos.
 - Argentina ha tenido muchísimos casos en el CIADI por el **corralito**. Entre el año 2001-2003 (el corralito) los inversionistas extranjeros no podían ni remesar utilidades ni repatriar el capital. Por lo tanto, los

inversionistas perjudicados demandaron al Eº argentino, y el Eº argentino perdió todos los casos en el CIADI. Por eso entonces que ni siquiera el avión presidencial argentino puede salir de Argentina ya que sería embargado. Además, el buque escuela argentino fue embargado en un puerto africano y estuvo durante prácticamente 1 año, ya que si en materia internacional no se pagan ni se reconocen las sentencias, ocurre eso.

- Los países son libres de adherir a este sistema o no, y, los países lo hacen porque pareciera que es un buen sistema de resolución de conflictos.
- Hay otro aspecto que tenía el Estatuto de Inversión Extranjera que dejó de tenerlo en su última modificación que se refiere a los *contratos de IE*.

- **LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA (IE)**

- Desde el año 45` en adelante los inversionistas extranjeros celebraban un contrato con el Eº de Chile. Este contrato tenía una característica muy peculiar, que era un **contrato-ley**.
 - Esto era una institución jurídica que a veces ni siquiera tiene reconocimiento constitucional ni legal, pero es la consecuencia de que una ley (de inversión extranjera) se incorpora en el contrato.
 - Entonces, el contratante (inversionista extranjero) **celebra un contrato con el Eº de Chile pero con una ley que lo protege en estos aspectos**.
 - Ahora, para algunos profesores de dº administrativo estos contratos-leyes eran una aberración, y, a juicio de *Yrarrázaval* no lo son. Ellos consideraban que no podía existir un contrato que no pudiera ser modificado unilateralmente por el Eº. Si la ley me garantiza en el contrato los dº, la otra parte no puede modificar el contrato. Eso no es efectivo a juicio de *Yrarrázaval*, y tanto es así que, el *estatuto de inversión extranjera* fue modificado muchas veces pero en forma no retroactiva, sino que hacia adelante.
 - Por lo tanto, los inversionistas extranjeros se regían bajo distintos contratos-leyes dependiendo de cuándo se internaron en el país.
 - Esto no impide que el legislador modifique esa ley, tampoco impediría que la modificara retroactivamente, pero si la modifica retroactivamente se puede plantear el problema del 19 Nº 24 CPR (dº de propiedad) ya que esos dº se incorporaron patrimonialmente al inversionista extranjero, entonces, si se modifica retroactivamente se debe **indemnizar**.
 - En Chile, además de la inversión extranjera, hay varios otros contratos-leyes.
 - ✓ Por ejemplo, las *viviendas DFL2*.
 - ❖ Estos contratos-leyes (DFL2) son para incentivar la construcción de viviendas de x tamaño.
 - ❖ A quien compra o construya una vivienda DFL2, se le garantizan los dº tributarios que en ese momento existían para la vivienda.

- ✓ En *tierra del fuego* igual hay un contrato-ley para los inversionistas de esta zona.
 - ❖ Es para los inversionistas al sur del Estrecho de Magallanes y NO al norte.
 - ❖ Hay un régimen tributario muy distinto para los inversionistas al norte y al sur del Estrecho de Magallanes.
 - ❖ Los tribunales no han considerado esto como discriminatorios porque las discriminaciones no se establecen en relación con la región sino que con las características específicas de un área geográfica.
 - ❖ De todas formas, ha habido muy pocas empresas que se instalado ahí porque es dificilísimo por el transporte, comunicación, etc.
- Los contratos-leyes en Chile han existido y van a seguir existiendo, y la jurisprudencia de los tribunales les ha dado reconocimiento total de que hacia adelante todas las modificaciones legales son permitidas, y, hacia atrás también son permitidas pero al afectar el dº de propiedad hay que indemnizar por esas cantidades.
- Los *contratos de concesión* NO pueden ser modificados unilateralmente por una de las partes. Se acerca al contrato-ley. Se ha dado una discusión bastante importante, ya que esto se da en términos normales, pero si hay una anomalía dada por ciertas situaciones internas se puede modificar. *Yrarrázaval* no conoce ningún caso en donde se haya cuestionado esto, sería interesante que se hiciese porque se lleva a cabo una negociación entre las partes. Eso es lo que está tratando de hacer la autoridad con respecto de los peajes.
 - ✓ Está tratando que no suban en la misma forma que está contemplado en el *contrato de concesión*, pero esto debe ser negociado.
- En cambio, en el *contrato-ley* NO hay ninguna negociación, es o no es. Esto porque se celebró un contrato en el cual la garantía de la ley se le incorpora al contrato.

4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

4.1 EUROPA

- Veremos qué pasó en Europa en el año 57` en adelante con la famosa **CEE** (*Comunidad Económica Europea*) que se transformó hace 20 años aproximadamente en la **UE** (*Unión Europea*). Pero, se refiere a lo mismo, vale decir, al *proceso de integración europeo que tiene un impacto en el dº económico impresionante*.
- La CEE/UE tuvo una evolución impresionante porque partió muy fácil y se fue a complejizando llegando al *Brexit*.
 - Los ingleses habrán votado por el *Brexit* porque la mayoría de ellos no les convenía la UE. Ahora, *Yrarrázaval* tiene sus dudas de cuánto saben sobre la UE, pero simplemente no les convenía.
- La CEE partió por 6 países: **Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo** en 1957 con el ***Tratado de Roma***, y la eficacia comienza en 1959.
- Estos 6 países fundadores, en aquel entonces, tenían **características económicas bastantes parecidas**. Pero en forma muy inteligente 3 de ellos no lo tenían con respecto de los otros 3. Por lo tanto, Bélgica, Holanda y Luxemburgo formaron un país entre ellos para estos efectos, el denominado **BENELUX**.

- La suma de las economías de estos 3 países era similar a la de Alemania, Italia o Francia.

13 de junio

- Establecen 3 libertades estructurales para el proceso de integración europeo. Esto se logró eliminando todo tipo de barreras entre los países miembros. Son las famosas libertades de **Jean Monnet**. Estas son:

1. Libertad de movimiento de los bienes.

- El tráfico de bienes *entre los países miembros* sean totalmente libre. Vale decir, 0 arancel, ninguna prohibición, ninguna cuota, ningún contingente, nada.
- Entonces, en definitiva, cualquier bien que iba de Alemania a Francia era considerado para efectos aduaneros como si fuera un bien interno, y, efectivamente ya con esto, el mercado europeo integrado aumentó. Ya no era la economía alemana o francesa, sino era una más las otras.
- Esta libertad de movimiento de bienes fue muy exitosa, y en el plazo de 2 años se eliminaron todo tipo de trabas, y esto se ve hasta el día de hoy. En otras palabras, no hay aduanas para el movimiento de los bienes de los países miembros.
- Pero, ¿cómo se tratan a los 3º países que no son parte de este proceso? De igual forma en el sentido que los 6 países tratan a Chile de la misma forma, pero no tienen que tratar a Chile de la misma forma que a USA, por ejemplo.
- A Inglaterra se le condicionó su ingreso a la CEE sobre la base que eliminaran todos los tratados, que en realidad eran mucho más que un tratado, era la **Commonwealth**. Inglaterra desde el s.XIX estuvo estructurando un comercio libre dentro de la *commonwealth*, y cuando Inglaterra planteó su ingreso en la década del 70` a la CEE, lo aceptaron siempre y cuando elimináse la *Commonwealth* porque sino, distorsiona el resto de las relaciones.
- Esto con respecto de 3º países se denomina **arancel externo común**, pero no incluye solo aranceles. Vale decir, el **arancel externo común** es la denominación que se les da al arancel que hacen los miembros de la UE a los 3º países.

2. Libertad de movimiento de los capitales.

- Se refiere a que los capitales van a ir de un país a otro sin ninguna traba de ningún tipo.
- Se refiere a los capitales tanto de **inversión** como los **financieros**.
- Ésta ya fue más compleja.
- Respecto a los **capitales de inversión** en el sentido de que cualquier empresa de cualquier país miembro puede hacer una inversión en cualquiera de los otros países miembros sin ninguna restricción de ningún tipo. Distinto es el tratamiento que se le da a la IE propiamente tal, vale decir, la que proviene de 3º países. Nuevamente, se distingue entre lo *externo* e *interno*. Y, por lo tanto, hoy en día, no hay ninguna restricción ni regulación de ningún tipo sobre la inversión que va de un país miembro a otro país miembro.
- Respecto de los **capitales financieros**, el asunto comenzó a ser cada vez más complejo ya que siempre habían existido diferencias en tasas de intereses especialmente entre los países miembros, y tanto es así, de que se configuraban

los denominados **capitales nocturnos**. Éste era el que *se trasladaba de un país a otro para aprovechar una mejor tasa de interés y que después que esa tasa de interés bajaba, volvía al país de origen*. Por lo tanto, nuevamente el tema planteó de que de alguna forma se tenía que ir homologando la tasa de interés entre los países miembros.

3. Libertad de movimiento de las personas.

- Algunos pensaban que sería la mas fácil, pero pasó a ser la más complicada de todas. Algunos creyeron que esto es un tema del pasaporte europeo.
 - Pero, la real noción se refiere a los **trabajadores**, y, esto trae problemas inmensos.
 - Esta fue y sigue siendo la libertad más compleja a juicio de *Yrarrázaval*.
 - El tema del pasaporte europeo no causó mayores problemas. Los problemas se produjeron por las **migraciones de millones de trabajadores de un país a otro**. Si se trataba de países miembros, el trabajador de un país miembro debía recibir el mismo tratamiento laboral y de seguridad social que los trabajadores que no estaban migrando. Eso no tuvo mayores problemas a pesar de que eran migraciones importantes. Los problemas mayores se produjeron cuando **llegaron trabajadores de países no miembros a países miembros** porque éstos no tenían por qué tener el mismo tratamiento que los trabajadores de los países miembros. Se plantearon grandes cuestiones, y, se siguen planteando.
 - Alemania: entre el año ante-pasado y pasado le deben haber llegado más de 1 millón de trabajadores sirios que están fuera de la UE, y, no tienen por qué darles el mismo trato. Pero, indiscutiblemente que esto creó un problema bastante agudo.
- Curiosamente, las 3 libertades son de naturaleza económica.
 - Se debe distinguir el *tratamiento interno* (entre los países miembros) y el *tratamiento con los 3º países*. Afortunadamente a juicio de *Yrarrázaval* fue bastante rápido este proceso de eliminación de trabas internas, pero bastante difícil con respecto de 3º países ya que éstos deben de ponerse de acuerdo entre ellos de cómo van a tratar a los 3º países en términos de aranceles, cuotas, contingentes, etc.
 - Una de las grandes pesadillas actuales de la UE se da por las distintas tasas de impuestos, porque en la medida que la tributación de las empresas sea distinta, indiscutiblemente que las empresas se trasladarán de un país a otro no por razones estrictamente económicas sino que por aprovechar un tratamiento tributario mejor. Entonces, ha habido todo un proceso de *armonización* en materia tributaria, pero que todavía no se ha logrado totalmente.
 - Sea como sea, las libertades se fueron dando, algunas con mayor dificultad y algunas con menor dificultad.
 - Se empiezan a incorporar a la CEE otros países.
 - La 1º incorporación difícil fue la de **Inglaterra** por la existencia de la *Commonwealth*, vale decir, por el hecho de toda esta situación de libre comercio entre los países miembros de la *Commonwealth*. Por lo tanto, Francia dijo “*sí a Inglaterra pero sin la Commonwealth*”. Y esto explica una parte del *Brexit*.

- Se incorporaron otros países que no tenían ni la fortaleza, ni el desarrollo de los países fundadores (en donde los 3 más chicos se unieron en el BENELUX).
 - El caso de España y de Portugal fueron especialmente complicados. Pero, allí se produjeron los denominados **períodos de transición**, y esto habla muy bien de la CEE de aquel entonces. Estos *períodos de transición* NO eran impuestos por la CEE, sino, que eran planteados por los países que querían ser miembros.
 - Tanto España como Portugal escogieron plazos de 10 años de transición. Este es un plazo bastante prudente porque tiene que hacer todos los cambios microeconómicos que se producen en estas economías, donde el mercado ya no es el propio de cada país, sino que el mercado es el común europeo.
 - A juicio de *Yrarrázaval*, España lo hizo bastante bien (pero lo podría haber hecho incluso mejor) y Portugal muy mal.
 - Esto significa **cambios internos** importantísimos en las **estructuras de las empresas**. Aquí entra el concepto importantísimo de **economías de escala**. Con un mercado que se va agrandando en la forma que estamos explicando, cada vez se generan más *economías de escala*. En otras palabras, cada vez las empresas se tienen que agrandar. Y, quedan menos empresas, hay más fusiones, y, más adquisiciones.
 - El tema es ¿cuál es el futuro de empresas medianas y chicas dentro de este mercado más grande? El futuro está en ser **proveedoras de las empresas grandes**. Estos son cambios bastante fundamentales.
- De la Europa de los 6, pasamos a la Europa de los 12 , y, luego de los 15 países. Pero, donde se produce un cambio fundamental para nuestro análisis es en **Maastricht**, Alemania. *Maastricht* fue la sede de la reunión en la cual la **CEE pasa a denominarse UE**. Lo más relevante es que se resuelven 3 cosas fundamentales:

1. Banco Central Europeo (BCE)

- Esto está muy vinculado con el *euro*, porque 1º se crea el BCE, y, todos los países contiúan con sus respectivas monedas, y, después de que el BCE estaba funcionando adecuadamente, se plantea el asunto de la moneda común: euro.
- Con la existencia del BCE y con el euro, las **políticas monetarias son determinadas en el BCE**. A juicio de *Yrarrázaval* los BC de cada país se podrían cerrar y no pasaría absolutamente nada, porque hoy en día, estos BC están para fines estadísticos, de estudios, y ese tipo de cosas.
- Fue muy inteligente según *Yrarrázaval* en el sistema del euro porque fue por medio de distintas **categorías de aprobaciones**, porque ese era el temor que tenía Inglaterra de que realmente le iban a imponer un euro que iba liquidar la libra esterlina.
- Por lo tanto, dentro del BCE en el sistema del euro se dijo que algunas materias requerían **unanimidad** de los países miembros del euro, otras de mayorías especiales, y, otras materias menores de mayoría simple.
- Los representantes de los países en el BCE son los presidentes de los BC de cada país. En definitiva, la toma de decisiones, hoy en día, está en **Frankfurt** (donde funciona el BCE).
- Por eso, la **crisis griega** fue muy complicada para el sistema, porque no había respaldo entre la **economía real** y **economía monetaria**. La economía griega tiene

características totalmente distintas al resto de las economías. Vale decir, estrictamente hablando Grecia nunca debió haber sido miembro de la UE, y, mucho menos haber sido un país del euro. Y tanto es así, que a pesar de toda la ayuda que recibió del BCE y de lo alemanes, Grecia lleva 8 años tratando de salir a flote.

- *España* estuvo a punto de entrar en problemas e *Italia* también. ¿Por qué? Porque en definitiva, con una moneda única, las cosas que ocurren en un país miembro, repercuten en los demás países miembros.
- ¿Cómo estalló la **crisis griega**? Por la **deuda externa** en Grecia. Los **bonos** emitidos por la deuda externa empezaron a **caer** drásticamente. Hubo un detonante específico que fue muy importante, y, es que Grecia **falseó sus cuentas nacionales** y lo descubrieron, entonces indiscutiblemente se gatilló más este tema.
- Los países que no adoptan el euro están dentro del BCE pero fuera del euro. Y, por lo tanto, no están afectos a las políticas monetarias sobre el euro. Hay otros aspectos del BCE que no dicen directa relación con el euro que si los afecta. Pero, en definitiva, los afecta muy poco.

2. Moneda común (euro)

- El euro NO existió de un día para otro, sino que hubo 10 años en donde el euro era una moneda fiduciaria (moneda en el papel), y, luego hubieron 4 años de transición en la cual las monedas de cada uno de los países competían con el euro.
- Al cabo del 4º año, los BC de los países en cuestión no pueden seguir emitiendo sus propias monedas. Entonces, son reemplazadas las monedas locales por el euro.
- Este fue un cambio muy importante, y, fue **VOLUNTARIO**. Ningún país estaba obligado a ser parte del sistema monetario del euro, y tanto es así que, *Inglaterra* se quedó fuera de esta moneda.
- Esta decisión no era nada fácil para los países porque equiparaba a todos los mercados de todos los países. “*Es el test de la blancura*”. Se llegaba y se decía x marcos alemanes corresponden a x euros, x pecetas a x euros, x francos a x euros, etc.
- Y, por lo tanto, una vez desaparecida las monedas locales la situación en cada uno de los distintos países cambió en forma muy relevante, y, especialmente en los países con las monedas más débiles.
- Cuando desaparecen las monedas locales, los países se empiezan a comparar directamente con los otros.

3. Políticas fiscales y monetarias comunes

- ¿Con qué nos encontramos desde el punto de vista del dº? Con un cambio fundamental especialmente en el **dº económico**. Indiscutiblemente que el BCE no tiene nada que ver con los BC que existían anteriormente. Tiene otra dinámica, otro sistema, etc.

1. Constitución Europea.

- Incluso, se planteó dentro de la UE una **Constitución Europea** dentro del cual los conceptos económicos estaban presentes, y, el OPE está presente en numerosas disposiciones.
- Esta Constitución recogía el **mínimo común denominador** de los países miembros de la UE.
- Fue un trabajo fantástico hecho por los mejores juristas europeos.
- Ésta fue desechada 1º por los franceses, luego, le siguieron los holandeses, etc.
- Esto está relacionado con el *Brexit* por la racionalidad de la votación en el *brexit* o la racionalidad de la votación de los franceses. Solo un 1% de los franceses leyó la Constitución, el resto votó simplemente por si estaban a favor o en contra de la UE.
- Estos procesos tienen costos y beneficios, ventajas y desventajas. Entonces, como ha sucedido permanentemente en Europa, se piensa que el gran responsable de todos los males en todos los países es la UE, al final la gran mayoría de los europeos sostienen de que realmente prefieren estar fuera de la UE por la misma razón que plantearon los ingleses para hacer el *brexit*, y, después se dan cuenta de la brutalidad que habían hecho. Porque cuando la UE les pasó la cuenta se dieron cuenta de que el asunto NO era gratis, y, les iba a salir muy caro.

2. Cambios fundamental en la Ley de la LC.

- El *Tratado de Roma* -que es el que inicia el proceso- tenía el sistema de LC incorporado en el tratado. 2 artículos específicos eran el equivalente a nuestro art 3 de la LDLC.
- El tema de la LC empezó a adquirir cada vez más importancia porque dentro del mercado único, las PR de la competencia es dentro de todo el mercado.
- Los países continuaron con sus leyes de la LC. Pero, la **Ley de la LC Europea se aplica a cualquiera práctica que se desarrolle en más de un país.**
- Por lo tanto, la **ley de la LC de cada país analizan solamente las PR dentro del país.**
- Hoy en día, los casos europeos de LC han pasado a ser incluso más importantes que los norteamericanos (que empezaron con el asunto en el s. XIX) porque son miles y miles de casos.
- **Características de la Ley de LC Europea:**
 - i. Las prácticas están planteadas en **términos muy amplios** (igual que en el sistema nuestro).
 - Estos 2 art del *Tratado de Roma* contienen todo tipo de PR imaginable.
 - ii. Se da la misma relación ente una **unidad investigadora** y otra **sancionadora**, pero con características un poco distintas.
 - **La unidad investigadora además es sancionadora en 1º instancia.**
 - Ésta es la famosa *Comisión de la Competencia Europea* con sede en *Brucelas*. Ésta investiga y sanciona, con todos los inconvenientes que tiene eso, pero también con ciertas ventajas.

- La 2ª instancia es una instancia judicial.
- iii. En el sistema europeo, **NO hay delito de la LC.**
 - Todas las **sanciones son de carácter económico o pecuniario.**
 - En USA si hay delito económico.
 - Esto no le ha significado menor eficacia al sistema europeo.

3. Protección al Consumidor.

- Esta se desarrolló poco en la UE por lo que vimos en la LPC, vale decir, en definitiva, la LPC también se aplica a los productos que vengan de otros países, pero no se ha organizado en la forma en que se ha organizado la LC. Y tiene un desarrollo bastante menor. Lo mismo ocurre con la Ley de CD.
- Por lo tanto, la Ley de la LC como la más relevante porque está directamente relacionada con los pilares fundamentales de la UE.
- En definitiva, la LC ha ayudado a que se produzcan las 3 libertades planteadas por la UE.

4.2 AMÉRICA LATINA (AL)

- En AL ha sido un desastre a juicio de *Yrarrázaval*.

4.2.1 ALALC

- Esto parte en el década del 70` cuando ya en existía la CEE, hicimos en américa la **ALALC** (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) en la cuál se incorporaron prácticamente todos los países latinoamericanos.
- La ALALC fue un desastre, y, después de 10 años se le dio sepultura. Por 2 factores:
 1. Se refería a la 1ª libertad (de bienes), pero, en AL fuimos incapaces de llegar a un LC interno porque las **economías en AL eran muy distintas.**
 - Las economías de *Brasil, Argentina y México* son muy distintas al resto.
 - Y, por lo tanto, el resto de los países consideró que solo se beneficiarían los países más grandes y perjudicarían el resto, porque iba a permitir que los productos de estos países con economías más grandes entraran al resto de los países con 0 aranceles, sin ninguna traba, ni cosa por el estilo.
 - Y dentro del resto, además hay una mezcla. Hay países como *Colombia, Perú y Chile* que tienen un desarrollo mediano de las economías. Y, hay otros con economías tan chicas que indiscutiblemente que un TLC los haría desaparecer. Por ejemplo, *Uruguay o Paraguay*.
 2. Fuera de ese factor, los **aranceles vigentes eran totalmente distintos.**
 - Por ejemplo, *Chile* tenía un arancel promedio del 100%. Otros tenían menos, otros tenían mucho más, y, poner de acuerdo a países con aranceles muy distintos es muy complejo.
- ¿Cómo se puede hacer TLC entre economías tan distintas en tamaño (sin que desaparezca la pequeña)? Depende de lo **complementario** o no que sea.
 - Por ejemplo, *Canadá y USA* han tenido TLC hace muchísimo tiempo (de los 1º), pero son economías totalmente complementarias, vale decir, se topan en un 2-3% del total de lo que producen.
 - En cambio, en AL las economías de *Argentina y Brasil* son muy competitivas entre

ellas, y, por eso en el famoso Mercosur son puras peleas entre estos 2 países.

- El tema más de fondo está en las **ventajas competitivas**. Este es el ABC del CI.

4.2.2 Pacto Andino

- Después del fracaso de la ALALC, y ya casi cerca de su sepultura (en el 69` en *Cartagena de Indias*) a 5 países LA se les ocurrió el **Pacto Andino: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile**.
 - Lo que querían estos 5 países era copiar el BENELUX, y, era muy parecido.
 - Pero, el BENELUX fue un éxito y el *Pacto Andino* fue un fracaso porque lo **montaron sobre un proceso que estaba en liquidación**, en cambio, el BENELUX se montó sobre un proceso exitoso.
 - Si sumabamos las 3 economías del BENELUX, llegaban a competir con las otras economías (de los países grandes) y eso permitió que la integración sea exitosa.
 - Luego, vinieron los problemas entre los países miembros porque algunos querían rebajar sus aranceles antes y otros después, y cosas por el estilo.
 - El *Pacto Andino* muere. Sigue teniendo su sede en *Lima*, pero está totalmente muerto.
 - *Chile* se sale del *Pacto Andino* en el 75`.

4.2.3 MERCOSUR

- Luego, se les ocurre el **MERCOSUR**, otro desastre. Es entre **Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay**. Es entre 2 economías muy grandes -competitivas entre ellas- y 2 economías enanas al lado de estas otras.

4.2.4 NAFTA

- El proceso es muy curioso porque partió con el TLC entre *Canadá* y *USA*. Esta fue la base del NAFTA.
- Este fue muy exitoso a través del tiempo, entonces, se creyó de que se podía incorporar a un 3º país importante como *México*, el que se incorpora en la década del 90`.
- Éste ha funcionado muy bien en ciertos aspectos y muy mal en otros.
- Si vemos el tratado es relativamente corto, y, los anexos del tratado son larguísimos porque ellos contemplan las reglas con respecto de 2 temas muy sensibles que siguen hasta el día de hoy.

1. Tema *laboral*.

- Hay una cº enorme de mexicanos en USA. Hay del orden de 10 millones legales y 10 millones ilegales en USA. Vale decir, en total son 20 millones de mexicanos en USA.
- El tema ha sido siempre el mismo que planteó *Trump* a México recientemente. USA le ha dado un plazo para que solucione el tema migratorio, y, si no van a tener aranceles.

2. Tema *medioambiental*.

- En el tema medioambiental, México tampoco ha cumplido.
- ¿Por qué este tema saltó como un tema tan delicado en un tratado de la década del 90`?

Porque cumplir con las medidas medioambientales hace que los productos sean más caros porque implican costos. Entonces, si es que no está cumpliendo las medidas medioambientales, tiene una producción mucho más barata.

- Por lo tanto, a raíz del NAFTA, muchas empresas norteamericanas se fueron a instalar a México porque tienen una normativa medioambiental mucho más laxa que la estadounidense y canadiense.
- Estos 2 temas han estado pendientes, pero el resto del NAFTA ha funcionado bastante bien a juicio de *Yrarrázaval*.
- ¿Quiénes fueron los principales opositores al NAFTA?
Los **trabajadores estadounidenses** (las grandes centrales sindicales norteamericanas) por el temor de perder sus puestos.
 - Las empresas que se trasladaron a México contrataron trabajadores mexicanos.
 - Esta crítica -que fue muy dura-, después, no ha tenido mucha base porque empíricamente se demostró que estaban totalmente equivocados porque obligó a las empresas norteamericanas a adecuarse a los desarrollos tecnológicos (el desarrollo de *Silicon Valley* está muy vinculado con esto). Y, por lo tanto, indiscutiblemente que algunos trabajadores norteamericanos se quedaron sin trabajo, pero otros si lo tuvieron, y, por lo tanto, los los índices de desempleo en USA no aumentaron en la forma que se imaginaban que iban a aumentar centrales sindicales. Esto me dice que en muchas de estas decisiones es muy difícil prever lo que va a ocurrir porque no hay evidencia empírica.
- Indiscutiblemente que la economía norteamericana se fue transformando totalmente, y, se fue transformando en buena medida gracias al NAFTA.